발 간 등 록 번 호
11-1170000-100011-01



자치법규 의견제시 주제별 주요 사례 50선

법제처

일러두기

- ‘자치법규 의견제시’는 지방자치단체가 제정·개정하려는 조례안·규칙안이 상위법령에 위반되는지 등에 의문이 있거나 현행 조례·규칙을 집행할 때 해석상 이견이 있는 경우 법제처가 자문의견을 제시하는 제도로, 법제처는 2011년부터 2024년 12월까지 약 3,800건의 의견을 회신했습니다.
- 이 책자는 그간의 의견제시 사례 중에서 질의가 빈번한 주제별로 주요 사례 50건을 선정하여 수록하고 있습니다.
- 주제별 도입부에서는 그 주제에 관한 자치법규를 제정·개정할 때 유의할 점, 관련 판례 등을 서술하여 개별 사례를 이해하는 데 도움이 될 수 있도록 했습니다.
- 또한, 수록 사례의 내용이 법제처에서 발간한 『자치법규 입안 길라잡이(2022)』 등 자료집의 내용과 관련이 있는 경우에는 해당 자료집의 쪽 번호도 함께 표시하여 기존 자료와 연계하여 활용할 수 있도록 했으니 자치법규 입안 시 활용하시기 바랍니다.

CONTENTS
목 차

제1편 보 조

1. 보조금 교부대상에 해당하는지 2

사례1 보조금 교부대상에 해당한다고 본 사례 4
(「지방재정법」 제17조제1항제1호 해당)

사례2 보조금 교부대상에 해당한다고 본 사례 6
(상위법령에 위배되지 않는다고 본 사례)

사례3 보조금 교부대상인지 판단기준을 제시한 사례 9
(「지방재정법」 제17조제1항제4호 관련)

사례4 보조금 교부대상에 해당하는지 신중히 검토할 필요가 있다고 본 사례 11
(「지방재정법」 제17조제1항제4호 관련)

2. 운영비 지원에 관한 사항을 조례에 규정할 수 있는지 14

사례5 운영비를 지원하는 내용을 규정할 수 없다고 본 사례 16

사례6 보조금을 교부할 수 없는 운영비에 해당하지 않는다고 본 사례 18

3. 조건을 붙여서 보조금을 교부하도록 하는 내용을 조례에 규정할 수 있는지 20

사례7 보조금 교부조건을 규정할 수 있다고 본 사례 21

사례8 보조금 교부조건에 관한 판단기준을 제시한 사례 23

제2편 공유재산

1. 행정재산인 공공시설의 이용관계에서 사용료 감면 등을 조례에 규정할 수 있는지 30

사례9 사용료 감면 규정을 둘 수 있다고 본 사례 31

사례10 공공시설 이용료를 확정 금액이 아닌 최고액·최저액으로 규정할 수 있다고 본 사례 34

2. 행정재산의 관리위탁을 수의계약으로 할 수 있도록 하는 내용을 조례에 규정할 수 있는지 37

사례11 수의계약 대상에 해당하는 것으로 보기 어렵다고 본 사례 39

사례12 수의계약 대상에 해당하는 것으로 보기 어렵다고 본 사례 43
(「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제19조의5제1항제1호 관련)

사례13 수의계약 대상에 일부 해당한다고 본 사례 45
(「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제19조의5제1항제2호 관련)

제3편 재정·회계·기금

1. 특별회계 간 통합·운용 등에 관한 사항을 조례에 규정할 수 있는지 50

사례14 특별회계 간 통합·운용을 규정할 수 없다고 본 사례 51

사례15 특별회계 간 통합·운용을 규정할 수 없다고 본 사례 53

사례16 서로 다른 특별회계를 하나의 통합조례에 규정할 수 있다고 본 사례 55

2. 특별회계의 존속기한을 조례에 규정해야 하는지 57

사례17 존속기한을 규정해야 한다고 본 사례 58

사례18 존속기한을 규정하지 않아도 된다고 본 사례 61

3. 금고지정 기준 등에 관한 사항을 조례에 규정할 수 있는지 66

사례19 별도의 평가항목을 추가하고 감점 배점하는 형식으로 규정할 수 없다고 본 사례 68

사례20 금고로 지정할 수 있는 금융기관의 범위를 규정할 수 있다고 본 사례 70

사례21 금고지정 기준의 입법형식 선택에 관한 기준을 제시한 사례 72

CONTENS
목 차

4. 기금의 존속기한이 경과하면 기금 설치·운영을 위한 조례가 실효되는지 74

사례22 기금과 관련된 규정만 실효된다고 본 사례 76

사례23 조례 전체가 실효된다고 본 사례 78

5. 기금으로 융자를 지원받은 자에 대한 융자금 감면 등을 조례에 규정할 수 있는지 80

사례24 융자금이나 그 연체금 채권에 대한 감면 등을 규정할 수 없다고 본 사례 82

사례25 융자금의 이자 및 연체이자의 감면은 상위법령의 범위에서 가능하다고 본 사례 85

제4편 지방의회

1. 지방의회의원의 발의로 조례에 규정할 수 있는 내용인지 (지방자치단체의 장의 고유권한 침해 여부) 88

사례26 지방자치단체의 장의 예산편성권을 침해하지 않는다고 본 사례 90

사례27 지방자치단체의 장의 예산편성권을 침해할 소지가 있다고 본 사례 93

사례28 지방자치단체의 장의 집행권한을 침해하지 않는다고 본 사례 95

사례29 지방자치단체의 장의 집행권한을 침해할 소지가 있다고 본 사례 100

사례30 지방자치단체의 장의 인사권을 침해할 소지가 있다고 본 사례 103

사례31 지방자치단체의 장의 조직편성권을 침해할 소지가 있다고 본 사례 106

2. 지방의회의 동의 또는 지방의회에 대한 보고에 관한 사항을 조례에 규정할 수 있는지 108

사례32 업무협약 등의 체결에 관한 사전 또는 사후 보고를 규정할 수 있다고 본 사례 109

사례33 예산 전용 사유에 관한 사전 보고 및 동의를 규정할 수 없다고 본 사례 113
사례34 민간위탁 시 지방의회의 동의를 받아야 한다고 본 사례 116
사례35 지방공사의 정관 변경 시 지방의회의 동의를 받도록 규정할 수 없다고 본 사례 119

제5편 위원회

1. 조례로 설치·운영할 수 있는 위원회인지 122
사례36 기관위임사무에 관한 심의위원회 설치·운영 조례를 제정할 수 없다고 본 사례 124
사례37 자치사무에 관한 자문위원회의 설치 조례를 제정할 수 있다고 본 사례 129

2. 위원회의 심의·의결사항의 범위 및 효력 132
사례38 법령에 따라 설치된 자문위원회에서 법령에서 정하지 않은 사항을 심의할 수 있다고 본 사례 133
사례39 자문위원회의 심의·의결에 법적 구속력이 없다고 본 사례 136

3. 위원의 자격·구성 등에 관한 사항을 조례에 규정할 수 있는지 138
사례40 법령에서 정한 내용 외에 주민지원협의체의 구성원 등의 자격을 제한하는 내용을 규정할 수 없다고 본 사례 139
사례41 법령에 따라 설치된 심의회의 구성원 등에 관한 사항을 법령과 달리 정할 수 없다고 본 사례 143

CONTENTS
목 차

제6편 지방자치단체 출자·출연기관 등

1. 지방자치단체 출자·출연기관 등의 정관 기재사항 및 정관 제정·개정과 관련한 보고·동의를 조례에 규정할 수 있는지 148

사례42 지방연구원의 정관 기재사항을 규정하는 것은 바람직하지 않다고 본 사례 150

사례43 지방자치단체 출자·출연기관의 정관을 제정· 개정하려는 경우 지방의회의 사전동의를 받도록 규정할 수 없다고 본 사례 153

사례44 지방자치단체 출자·출연기관의 정관의 제정· 개정과 관련한 협의사항을 지방의회에 보고하도록 할 수 있다고 본 사례 158

2. 지방자치단체 출자·출연기관의 지도·감독에 관한 사항을 조례에 규정할 수 있는지 165

사례45 출자·출연기관의 사업계획과 예산안에 대한 군수의 사전 승인에 관한 사항을 규정할 수 없다고 본 사례 168

사례46 출자·출연기관의 결산서를 소관 상임위 등에 제출하도록 규정할 수 없다고 본 사례 171

제7편 위탁·대행

1. 지방자치단체의 사무 위탁 대상·범위에 해당하는지 178

사례47 공공단체에 대한 자치사무 위탁으로서 조례에 규정할 수 있다고 본 사례 179

사례48 법령상 수탁기관이 아닌 지방공단에 대한 사무 위탁을 규정할 수 없다고 본 사례 182

2. 지방자치단체 사무 대행의 근거 또는 의회 동의에 관한 사항을 조례에 규정할 수 있는지 185

사례49 법령의 근거 없이 사무 대행에 관한 사항을 규정할 수 없다고 본 사례 186

사례50 법령에 따라 사무를 대행하게 하는 경우 민간위탁조례에 따른 지방의회의 동의를 받지 않아도 된다고 본 사례 188











제 1 편

보조

1. 보조금 교부대상에 해당하는지[1)]

「지방재정법」 제17조제1항 각 호의 재정지출 인정사유 중 자치법규 입안 시 주로 문제가 되는 것은 제1호의 "법률에 규정이 있는 경우"와 제4호의 "보조금을 지출하지 아니하면 사업을 수행할 수 없는 경우로서 지방자치단체가 권장하는 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우"를 어느 범위까지 인정하느냐에 대한 것이다.

● 「지방재정법」 제17조제1항제1호에 따른 지원

「지방재정법」 제17조제1항제1호에서는 '해당 지방자치단체의 소관에 속하는 사무'이고, '법률에 규정이 있는 경우'에는 개인 또는 법인·단체에 대한 기부·보조, 그 밖의 공금 지출이 가능하도록 인정하고 있다. '법률에 규정이 있는 경우'와 관련하여 「지방자치법」 제13조에서 열거하고 있는 사항을 '법률에 규정'이 있는 경우로 볼 수 있는지, 「지방자치법」 제13조의 근거만으로는 부족하고 지방자치단체의 재정적 지원에 대해 규정한 다른 법률이 필요한지, 만약 다른 법률의 근거가 필요하다면 어느 정도까지 명시적으로 재정 지원에 관한 내용을 규정한 것이 필요한지 등이 문제되고 있다.

「지방자치법」 제13조에 규정된 자치사무의 범위가 매우 다양하고 포괄적이므로, 만약 「지방자치법」 제13조의 규정 사항을 「지방재정법」 제17조제1항제1호의 '법률에 규정이 있는 경우'로 본다면, 지방자치단체는 자치사무에 대해서는 조례 제정을 통해 사실상 제한 없이 재정적 지원을 할 수 있게 될 것이므로, '법률에 규정이 있는 경우'의 의미를 「지방자치법」 제13조에 따른 자치사무에 해당될 뿐만 아니라 더 나아가 다른 법률상 근거가 필요한 것으로 보는 것이 타당할 것이다.

● 「지방재정법」 제17조제1항제4호에 따른 지원

「지방재정법」 제17조제1항 각 호 외의 부분 단서 및 같은 항 제4호에 따르면 지방자치단체의 소관에 속하는 사무와 관련하여 "보조금을 지출하지 아니하면 사업을 수행할 수 없는 경우로서 지방자치단체가 권장하는 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우"로서 "해당 사업에의 지출근거가 조례에 직접 규정되어 있는 경우"에는 재정적 지원이 가능하다. 「지방재정법 시행령」 제29조제3항에서는 "지방자치단체가 권장하는 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우"란 "해당 지방자치단체의 소관에 속하는 사무의 수행과 관련하여 그 지방자치단체가 권장하는 사업으로서 보조금을 지출하지 아니하면 그 사업을 수행

1) 『자치법규 입안 길라잡이(2022)』 120~127쪽 참조

할 수 없는 경우를 말한다"고 하고 있다.

여기서 "보조금을 지출하지 아니하면 사업을 수행할 수 없는 경우"의 요건은 그 해당 여부 판단에 재량의 여지가 많을 것으로 보인다. 다만, 대법원 판결 및 법제처 의견제시 사례의 문언 및 취지에 비추어 보면, 반드시 사업수행이 절대적으로 불가능한 경우뿐만 아니라, 재정적 지원이 이루어지지 않으면 그 경제적 부담 등이 과중하여 사업의 원활한 수행을 기대하기 어려운 경우도 포함될 여지가 있을 것이다(대법원 2009. 12. 24. 선고 2008추87 판결 참조).

「지방재정법」

제17조(기부 또는 보조의 제한) ① 지방자치단체는 그 소관에 속하는 사무와 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우와 공공기관에 지출하는 경우에만 개인 또는 법인·단체에 기부·보조, 그 밖의 공금 지출을 할 수 있다. 다만, 제4호에 따른 지출은 해당 사업에의 지출근거가 조례에 직접 규정되어 있는 경우로 한정한다.

1. 법률에 규정이 있는 경우
2. 국고 보조 재원(財源)에 의한 것으로서 국가가 지정한 경우
3. 용도가 지정된 기부금의 경우
4. 보조금을 지출하지 아니하면 사업을 수행할 수 없는 경우로서 지방자치단체가 권장하는 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우

② 제1항 각 호 외의 부분 본문에서 "공공기관"이란 해당 지방자치단체의 소관에 속하는 사무와 관련하여 지방자치단체가 권장하는 사업을 하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관을 말한다.

1. 그 목적과 설립이 법령 또는 법령의 근거에 따라 그 지방자치단체의 조례에 정하여진 기관
2. 지방자치단체를 회원으로 하는 공익법인

「지방재정법 시행령」

제29조(기부·보조의 제한) ① 삭제

② 법 제17조제1항 각 호 외의 부분 본문에 따른 그 밖의 공금 지출은 법 제18조에 따른 출자 및 출연을 제외한 해당 지방자치단체의 보조 등 모든 재정지출로 한다.

③ 법 제17조제1항제4호에서 "지방자치단체가 권장하는 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우"라 함은 당해 지방자치단체의 소관에 속하는 사무의 수행과 관련하여 그 지방자치단체가 권장하는 사업으로서 보조금을 지출하지 아니하면 그 사업을 수행할 수 없는 경우를 말한다.

④·⑤ (생 략)

사례 1

보조금 교부대상에 해당한다고 본 사례

(「지방재정법」 제17조제1항제1호 해당)

2023. 8. 29. 의견제시 23-0255

질의요지

순창군수가 면 지역에 설치된 「의료법」 제3조제2항제1호에 따른 의원급 의료기관에 대하여 시설 리모델링 비용을 지원할 수 있도록 하는 내용을 조례로 규정할 수 있는지?

의 견

아래 이유를 참고하시기 바랍니다.

이 유

「지방재정법」 제17조제1항에서는 지방자치단체는 그 소관에 속하는 사무와 관련하여 법률에 규정이 있는 경우(제1호), 보조금을 지출하지 아니하면 사업을 수행할 수 없는 경우로서 지방자치단체가 권장하는 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우(제4호) 등에 한정하여 개인 또는 법인·단체에 기부·보조, 그 밖의 공금 지출을 할 수 있다고 규정하고 있습니다.

먼저, 순창군수가 면 지역에 설치된 「의료법」 제3조제2항제1호에 따른 의원급 의료기관(이하 "의원급 의료기관"이라 한다)의 시설 리모델링 비용을 지원하는 사무가 순창군의 소관 사무인지 살펴보면, 「보건의료기본법」 제4조제1항에서는 국가와 지방자치단체는 국민건강의 보호·증진을 위하여 필요한 법적·제도적 장치를 마련하고 이에 필요한 재원을 확보하도록 노력하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제4항에서는 국가와 지방자치단체는 민간이 행하는 보건의료에 대하여 보건의료 시책상 필요하다고 인정하면 행정적·재정적 지원을 할 수 있다고 규정하고 있으며, 「지방자치법」 제13조제2항제2호가목 및 바목에서 주민복지에 관한 사업, 감염병과 그 밖의 질병의 예방과 방역을 지방자치단체의 사무로 예시하고 있는 점 등을 종합하면 주민들에게 보다 쾌적한 진료환경을 제공하기 위해 순창군수가 의원급 의료기관의

시설 리모델링 비용을 지원하는 사무는 순창군의 자치사무의 범위에 포함될 수 있을 것으로 보입니다.

다음으로, 순창군수가 면 지역에 설치된 의원급 의료기관을 대상으로 시설 리모델링 비용을 지원하는 것이 「지방재정법」 제17조제1항제1호에 해당하는지를 살펴보면, 「지방재정법」 제17조제1항제1호의 "법률에 규정이 있는 경우"에 해당하기 위해서는 개별적인 법률상 근거가 필요한데(법제처 2022. 12. 8. 의견제시 22-0324 참조), 「보건의료기본법」 제3조제1호에서는 "보건의료"란 국민의 건강을 보호·증진하기 위하여 국가·지방자치단체·보건의료기관 또는 보건의료인 등이 행하는 모든 활동을 말한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2호에서는 "보건의료서비스"란 국민의 건강을 보호· 증진하기 위하여 보건의료인이 행하는 모든 활동을 말한다고 규정하고 있으며, 같은 조 제4호에서는 "보건의료기관"이란 보건의료인이 공중(公衆) 또는 특정 다수인을 위하여 보건의료 서비스를 행하는 보건기관, 의료기관, 약국, 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관을 말한다고 규정하고 있습니다. 그리고, 같은 법 제4조제4항에서는 국가와 지방자치단체는 민간이 행하는 보건의료에 대하여 보건의료 시책상 필요하다고 인정하면 행정적·재정적 지원을 할 수 있다고 규정하고 있는바, 민간이 행하는 보건의료에는 의원급 의료기관이 주민들에게 제공하는 보건의료서비스가 포함된다고 할 것이므로 면 지역에 설치된 의원급 의료기관의 시설 리모델링 비용을 지원하는 것은 「지방재정법」 제17조제1항제1호의 "법률에 규정이 있는 경우"에 해당하는 것으로 보입니다.

따라서, 순창군수가 면 지역에 설치된 의원급 의료기관에 대하여 시설 리모델링 비용을 지원하는 것이 보건의료 시책상 필요하다고 인정하면 조례에 별도의 지원 근거를 두지 않더라도 「보건의료기본법」 제4조제4항에 따라 해당 비용을 지원할 수 있을 것으로 보입니다.

사례 2

보조금 교부대상에 해당한다고 본 사례

(상위법령에 위배되지 않는다고 본 사례)

2024. 3. 29. 의견제시 24-0023

질의요지

장기요양급여 수급자의 가족인 요양보호사(「노인장기요양보험법 시행령」 제11조제1항제1호 가목 및 제2호에 따라 장기요양요원인 요양보호사를 말하며, 이하 같음)의 처우 개선을 위하여 가족인 요양보호사에게 보조금을 지급하는 내용을 조례에 규정할 수 있는지?

의 견

아래 이유를 참고하시기 바랍니다.

이 유

「지방자치법」 제28조제1항 본문에서는 지방자치단체는 법령의 범위에서 그 사무, 즉 자치사무와 단체위임사무에 관하여 조례를 제정할 수 있다고 규정하고 있는바(대법원 2014. 2. 27. 선고 2012추145 판결 참조), 「노인장기요양보험법」 제4조제5항에서는 장기요양요원["장기요양요원"이란 장기요양기관에 소속되어 노인등의 신체활동 또는 가사활동 지원 등의 업무를 수행하는 자를 말함(「노인장기요양보험법」 제2조제5호)]의 처우를 개선하고 복지를 증진하며 지위를 향상시키기 위하여 적극적으로 노력해야 하는 주체를 국가 및 지방자치단체로 규정하고 있고, 「지방자치법」 제13조제2항제2호에서는 주민복지에 관한 사업(가목)을 지방자치단체의 자치사무 중 하나로 예시하고 있는 점 등을 고려할 때, 요양보호사의 처우 개선을 위하여 보조금을 지급하는 사무는 자치사무에 해당하는 것으로 보입니다.

한편, 「지방자치법」 제28조제1항 본문에서 "법령의 범위"란 "법령에 위반되지 않는 범위"를 의미하는데(대법원 2003. 5. 27. 선고 2002두7135 판결 참조), 「노인장기요양보험법」과 같은 법 시행령 및 시행규칙에서 위임된 사항을 정하고 있는 「장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한

고시」(이하 "장기요양급여고시"라 한다) 제23조에 따르면, 장기요양급여 수급자의 가족[수급자의 배우자, 직계혈족 및 형제자매, 직계혈족의 배우자, 배우자의 직계혈족 및 배우자의 형제자매를 말함(「장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 고시」 제23조제1항)]인 요양보호사(이하 "가족요양보호사"라 한다)가 가족인 수급자에게 장기요양급여를 제공하는 경우의 급여비용 산정에 대하여, 가족요양보호사가 일정한 직업에 종사하면서 장기요양 급여를 제공하는 경우에는 급여비용을 산정하지 않으며(제3항), 동일한 시간의 장기요양급여를 제공하더라도 가족요양보호사에 대해서는 일정한 경우 가산규정을 적용하지 않는 등(제4항 및 제6항) 일반 요양보호사에 대한 급여비용 산정 기준을 하회하는 기준을 규정하고 있는바, 이 사안에서는 지방자치단체가 가족요양보호사에게 보조금을 지급하는 것이 가족요양보호사에 대한 장기요양급여비용의 산정기준을 정하고 있는 노인장기요양 보험법령에 위배되는지가 문제됩니다.

우선, 조례가 규율하는 특정사항에 관하여 그것을 규율하는 국가의 법령이 이미 존재하는 경우에도 조례가 법령과 별도의 목적에 기하여 규율함을 의도하는 것으로서 그 적용에 의하여 법령의 규정이 의도하는 목적과 효과를 저해하는 바가 없을 때, 또는 양자가 동일한 목적에서 출발한 것이라고 할지라도 국가의 법령이 반드시 그 규정에 의하여 전국에 걸쳐 일률적으로 동일한 내용을 규율하려는 취지가 아니고 각 지방자치단체가 그 지방의 실정에 맞게 별도로 규율하는 것을 용인하는 취지라고 해석되는 때에는 해당 조례를 정할 수 있을 것입니다(대법원 1997. 4. 25. 선고 96추244 판결 참조).

그런데, 「노인장기요양보험법」상 노인장기요양보험제도는 노인의 간병·장기요양 문제를 사회적 연대원리에 따라 정부와 사회가 공동으로 해결하기 위하여 도입된 것으로, 모든 국민을 적용대상으로 해서 장기요양보험료의 산정·징수(제8조 및 제9조), 장기요양급여의 종류 및 제공기준·절차·방법·범위(제23조), 장기요양기관의 장기요양비용 청구 및 지급(제38조), 장기요양급여비용의 산정(제39조) 등 노인장기요양보험제도 운영 전반에 관한 사항을 규율하고 있는 한편, 현행 「김해시 장기요양요원 처우개선 조례」는 김해시 장기요양기관의 장기요양요원의 노동조건 및 근무환경 개선, 지위 향상 등에 필요한 사항을 정하여 장기요양요원의 처우 개선을 통하여 돌봄서비스 질을 제고하려는 조례로서(제1조), 시장은 장기요양요원의 노동조건 및 근무환경 향상을 위한 사업, 인권 및 권리옹호 사업 등을 촉진할 수 있도록 규정하고 있는데(제5조), 이 사안의 경우 「김해시 장기요양요원 처우개선 조례」를 개정(이하 "김해시개정조례안"이라 한다)하여 가족요양보호사의 처우 개선을 위한 보조금 지급에 관한 사항을 추가하려는 것입니다.

살피건대, 이 사안의 김해시개정조례안은 노인장기요양보험제도의 일부로서 노인에게 장기요양급여

를 제공하는 장기요양요원의 업무범위 및 급여비용에 관한 사항을 정하고 있는 「노인장기요양보험법」과 달리, 가족요양보호사에게 반대급부 없이 금전을 교부함으로써 김해시 주민의 복지를 향상시키려는 것으로 노인장기요양보험법령과는 규율하려는 목적이 다른 것으로 보이고, 김해시개정조례안에 따라 지방자치단체가 보조금을 지급함으로써 가족요양보호사에 대하여 장기요양급여비용 외의 소득을 추가로 보전하는 결과가 되더라도 이는 지방자치단체의 정책적 필요와 재정 수준에 따른 복지 행정의 차이에 해당하는 것이지 김해시개정조례안에 의해 노인장기요양법령의 입법목적 및 효과를 저해하는 것으로 보이지 않습니다.

아울러, 일반적으로 주민들에게 혜택을 부여하는 조례는 주민의 권리를 제한하거나 새로운 의무를 부과하는 조례안과는 달리 조례입안자에게 보다 광범위한 입법형성의 자유가 인정되므로 조례입안자는 그 조례 제정의 목적, 수혜자의 상황, 예산 등 여러 사정을 고려하여 그에 합당하다고 스스로 판단하는 내용의 조례를 제정할 권한이 있고(대법원 2015. 6. 24. 선고 2014추545 판결 참조), 그렇게 제정된 조례의 내용이 현저하게 합리성이 결여되어 있는 것이 아닌 이상 상위법령을 위반하는지에 대해서는 보다 완화된 기준이 적용되어야 한다는 점도 이 사안을 판단할 때 고려할 수 있습니다.

따라서, 장기요양급여 수급자의 가족인 요양보호사의 처우 개선을 위하여 가족인 요양보호사에게 보조금을 지급하는 내용을 조례에 규정할 수 있는 것으로 보입니다.

사례 3

보조금 교부대상인지 판단기준을 제시한 사례

(「지방재정법」 제17조제1항제4호 관련)

2024. 2. 8. 의견제시 24-0022

질의요지

생애 처음으로 「주민등록법」 제24조제1항에 따라 주민등록증을 발급받는 주민에게 축하금을 지원할 수 있도록 하는 내용을 조례로 규정할 수 있는지?

의 견

아래 이유를 참고하시기 바랍니다.

이 유

「지방자치법」 제28조제1항 본문에서는 지방자치단체는 법령의 범위에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있다고 규정하고 있는바, 여기에서 "법령의 범위"란 법령에 위반되지 않는 범위를 의미하고, "그 사무"란 지방자치단체의 고유사무인 자치사무와 개별 법령에 의하여 지방자치단체에 위임된 단체위임사무를 의미하므로, 자치사무에 대해서는 상위 법령에 반하지 않는 범위에서 조례로 정할 수 있을 것입니다.

「고흥군 생애 첫 주민등록증 발급 축하금 지원 조례안」 제1조에서는 이 조례는 생애 처음으로 주민등록증을 발급받는 17세 이상 청소년에게 축하금 지원에 필요한 사항을 규정하여 지역사회 구성원으로서의 소속감과 자긍심을 고양하고자 함을 목적으로 한다고 규정하고 있고, 같은 조례 제2조제1호에서는 "주민등록증 발급 축하금"이란 생애 처음으로 주민등록증을 발급받는 17세 이상 청소년의 새로운 시작을 축하하고, 고흥군민으로서의 소속감과 자긍심을 고취하기 위하여 지급하는 금전을 말한다고 규정하고 있으며, 같은 조례 제4조제1항에서는 고흥군수는 주민등록증 신청일 기준으로 고흥군에 주민등록을 두고 생애 처음으로 주민등록증을 발급받는 17세 이상 청소년에게 축하금을 지원할 수 있다고 규정하고

있는바, 생애 처음으로 「주민등록법」 제24조제1항에 따라 주민등록증을 발급받는 주민에게 축하금을 지원하는 사무는 「지방자치법」 제13조제2항제2호에 따른 주민의 복지증진과 관련된 사무로서 고흥군의 자치사무에 해당하는 것으로 보입니다.

한편 「지방재정법」 제17조제1항에서는 지방자치단체는 그 소관에 속하는 사무와 관련하여 법률에 규정이 있는 경우(제1호), 보조금을 지출하지 아니하면 사업을 수행할 수 없는 경우로서 지방자치단체가 권장하는 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우(제4호) 등의 경우와 공공기관에 지출하는 경우에만 개인 또는 법인·단체에 기부·보조, 그 밖의 공금 지출을 할 수 있다고 규정하고 있으므로, 위와 같은 지원이 「지방재정법」 제17조제1항에 해당하는지를 살펴볼 필요가 있습니다.

살피건대, 「지방재정법」 제17조제1항제1호의 "법률의 규정이 있는 경우"에 해당하려면 개별적인 법률상 근거가 필요한 것으로 보이는데, 주민등록증을 발급받는 주민에게 축하금을 지원할 수 있는 개별적인 법률상의 근거는 없는 것으로 보이고, 위 사무가 「지방자치법」 제13조제2항제2호에 따른 자치사무에 해당하더라도 해당 규정만으로는 「지방재정법」 제17조제1항제1호의 법률에 규정이 있는 경우라고 보기는 어렵습니다.

다음으로, 주민등록증을 발급받는 주민에게 축하금을 지원하는 것이 「지방재정법」 제17조제1항제4호에 해당하는지를 살펴보면, 같은 법 시행령 제29조제3항에서는 「지방재정법」 제17조제1항제4호에서 "지방자치단체가 권장하는 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우"라 함은 당해 지방자치단체의 소관에 속하는 사무의 수행과 관련하여 그 지방자치단체가 권장하는 사업으로서 보조금을 지출하지 아니하면 그 사업을 수행할 수 없는 경우를 말한다고 규정하고 있습니다.

그런데, "지방자치단체가 권장하는 사업"에 해당하는지는 보조금 지출 대상의 성격, 실제 보조금이 지출될 사업의 내용, 해당 사업이 지방 재정에 미치는 영향, 해당 사업에 대해 지방자치단체 주민이 갖는 일반적 인식 등 객관적 요소를 종합적으로 고려하여 판단해야 할 것입니다.

따라서, 생애 처음으로 「주민등록법」 제24조제1항에 따라 주민등록증을 발급받는 주민에게 축하금을 지원할 수 있도록 하는 내용을 조례로 규정할 것인지는 「지방재정법」 및 같은 법 시행령의 규정 등을 참고하고, 고흥군의 재정적 상황 등을 종합적으로 고려하여 귀 군에서 결정할 사안으로 보입니다.

사례 4

보조금 교부대상에 해당하는지 신중히 검토할 필요가 있다고 본 사례

(「지방재정법」 제17조제1항제4호 관련)

2023. 5. 16. 의견제시 23-0089

질의요지

울주군은 대한노인회 울주군 지회 읍·면 분회장과 울주군 관할 내 경로당의 회장에게 매월 일정 금액의 활동비를 지원할 수 있도록 하는 내용을 조례로 규정할 수 있는지?

의 견

아래 이유를 참고하시기 바랍니다.

이 유

「지방자치법」 제28조제1항에 따르면 지방자치단체는 법령의 범위에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있는데, 여기서 법령의 범위란 법령에 위반되지 않는 범위를 의미하고, 그 사무란 지방자치단체의 고유사무인 자치사무와 개별 법령에 따라 지방자치단체에 위임된 단체위임사무를 의미하는바, 조례 제정을 위해서는 자치사무나 단체위임사무에 해당해야 하고, 법령에 위반되지 않아야 할 것입니다.

먼저 「노인복지법」 제4조제1항에서 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 한다고 규정하고 있고, 「대한노인회 지원에 관한 법률」(이하 "대한노인회법"이라 함) 제3조에서 지방자치단체는 대한노인회의 조직과 활동에 관하여 필요한 편의를 제공하고 협조·지원할 수 있다고 규정하고 있으며, 「지방자치법」 제13조제2항제2호라목에서 노인의 보호와 복지증진을 지방자치단체의 사무로 예시하고 있는바, 대한노인회 울주군 지회 및 울주군 관할 내 경로당의 활성화를 위하여 대한노인회 울주군 지회 읍·면 분회장과 울주군 관할 내 경로당의 회장(이하 "분회장등"

이라 함)에게 활동비를 지원하는 것은 울주군 소관 사무에 해당하는 것으로 볼 여지가 있습니다.

다음으로 「지방재정법」 제17조제1항에서는 법률에 규정이 있는 경우(제1호), 보조금을 지출하지 아니하면 사업을 수행할 수 없는 경우로서 지방자치단체가 권장하는 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우(제4호) 등에 한정하여 기부·보조, 그 밖의 공금 지출을 할 수 있다고 규정하고 있는바, 울주군이 분회장등에게 매월 일정 금액의 활동비를 지원할 수 있도록 하는 내용을 조례에 규정할 수 있는지를 판단하기 위해서는 해당 내용이 「지방재정법」 제17조제1항제1호 또는 제4호에 해당하는지를 살펴볼 필요가 있습니다.

살피건대 「지방재정법」 제17조제1항제1호의 "법률에 규정이 있는 경우"에 해당하기 위해서는 분회장 등에게 활동비를 지원할 수 있도록 하는 개별적인 법률상 근거가 필요하다고 할 것인데(대법원 2012. 5. 24. 선고 2011추117판결 참조), 대한노인회법 제5조제1항, 「노인복지법」 제47조 및 같은 법 시행령 제24조제1항제3호에서는 "대한노인회에 대하여 그 조직과 활동에 필요한 비용"이나 경로당을 포함한 "노인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용"에 대한 지원 근거 외에 분회장등의 '개인'에게 활동비라는 보조금을 지원할 수 있는 근거 규정은 두고 있지 않고, 「노인복지법」 제4조에서는 노인 보건 및 복지증진에 대한 지방자치단체의 일반적인 책무만을 규정하고 있을 뿐이며, 해당 사무가 「지방자치법」 제13조제2항제2호라목에 따른 자치사무에 해당한다고 하더라도 같은 법 규정만으로는 「지방재정법」 제17조제1항제1호의 "법률에 규정이 있는 경우"에 해당한다고 보기 어려우므로, 분회장등에게 활동비를 지원하는 것은 「지방재정법」 제17조제1항제1호의 "법률에 규정이 있는 경우"에 해당하지 않는 것으로 보입니다(법제처 2018. 12. 6. 의견제시 18-0258; 2020. 2. 3. 의견제시 20-0012 참조).

다음으로 「지방재정법」 제17조제1항제4호에 해당하는지를 살펴보면 같은 법 시행령 제29조제3항에서는 법 제17조제1항제4호에서 "지방자치단체가 권장하는 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우"라 함은 당해 지방자치단체의 소관에 속하는 사무의 수행과 관련하여 그 지방자치단체가 권장하는 사업으로서 보조금을 지출하지 아니하면 그 사업을 수행할 수 없는 경우를 말한다고 규정하고 있습니다.

그런데 "지방자치단체가 권장하는 사업"에 해당하는지는 보조금 지출 대상의 성격, 실제 보조금이 지출될 사업의 내용, 해당 사업이 지방 재정에 미치는 영향, 해당 사업에 대해 지방자치단체 주민이 갖는 일반적 인식 등 객관적 요소를 종합적으로 고려하여 판단해야 할 것(대법원 2013. 5. 23. 선고 2012추176 판결 참조)입니다.

이와 관련하여 지방자치단체가 해당 사업을 수행하지 않는다면 상당한 비용이 소요되어 그 비용을

민간에 부담시키게 된다면 경제적 부담으로 사업이 사실상 어렵게 된다거나(청주지법 2010. 2. 4. 선고 2009구합1285 판결 참조) 주민들이 일상생활을 영위하는 데 필수불가결한 시설의 설치 비용을 민간에 부담시키게 된다면 경제적 부담으로 해당 시설의 설치사업이 사실상 어렵게 되는 경우(대법원 2009. 12. 24. 선고 2008추87 판결 참조) 등을 위 「지방재정법」 제17조제1항제4호의 "보조금을 지출하지 아니하면 사업을 수행할 수 없는 경우로서 지방자치단체가 권장하는 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우"에 해당한다고 본 사례가 있습니다.

그런데 이 사안의 경우 앞서 검토한 바와 같이 대한노인회법 제5조제1항에서는 지방자치단체가 "대한노인회에 대하여 그 조직과 활동에 필요한 비용"을 보조할 수 있도록 규정하고 있고, 노인복지법령에서 노인복지시설로서 경로당의 "설치·운영에 필요한 비용"을 보조할 수 있도록 근거를 두는 한편, 분회장등의 개인에 대하여는 별도의 지원 근거를 두지 않은 점과 이와 같이 경로당 시설이나 대한노인회 단체에 대하여 울주군이 비용을 보조할 수 있음에도 불구하고 이와는 별도로 분회장등에게 매월 일정 금액의 활동비를 지원하는 것이 「지방재정법」 제17조제1항제4호의 "보조금을 지출하지 아니하면 사업을 수행할 수 없는 경우"에 해당한다고 하기 어려운 측면이 있는 점 등에 비추어 보면, 해당 내용을 조례에 규정함에 있어 신중을 기할 필요가 있을 것으로 보입니다(법제처 2018. 12. 6. 의견제시 18-0258, 2020. 2. 3. 의견제시 20-0012 참조).

2. 운영비 지원에 관한 사항을 조례에 규정할 수 있는지[2)]

지방재정의 건전성을 강화하기 위해 「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」 제6조제2항에서는 법령에 명시적 근거가 있는 경우 외에는 지방보조금을 운영비로 교부할 수 없도록 규정하고 있다.

"운영비"란 일반적으로 조직이나 기구, 사업체 따위를 경영하는 데 드는 돈을 의미하므로 어떤 단체나 법인의 기본적인 업무 수행에 필요한 인건비, 장비 구입비, 시설운영비 등이 해당된다고 할 것이다. 「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」 제6조제2항에서는 운영비로 사용할 수 있는 경비의 종목을 대통령령으로 정하도록 위임하고 있고, 「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률 시행령」 제3조에서는 운영비로 사용할 수 있는 경비의 종목에 대해 인건비, 사무관리비, 임차료. 그 밖에 지방자치단체의 장이 다른 지방자치단체, 법인·단체 또는 개인 등이 수행하는 사무 또는 사업 등의 기본적인 운영을 위해 특별히 필요하다고 인정하는 경비로 규정하고 있다. 구체적인 사안에서 운영비에 해당하는지 여부를 판단하기 위해서는 「지방자치단체 예산편성 운영기준」 등을 참고할 수 있다.

"법령에 명시적 근거가 있는 경우"와 관련해서는 「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」 제6조제2항은 지방재정의 건전성을 강화하기 위해 지방자치단체의 보조금의 관리체계를 강화하려는 취지의 규정이라는 점을 고려할 때, 법령에서 지방보조금을 운영비로 교부할 수 있도록 명시하고 있거나, 적어도 그에 상응하는 명문의 규정이 있어야 할 것이다.

「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」

제6조(지방보조금의 예산 편성 및 운영) ① 지방자치단체의 장은 해당 지방보조사업의 성격, 지방보조사업자의 비용부담능력 등을 고려하여 지방보조금을 편성하여야 한다.
② 지방자치단체의 장은 법령에 명시적 근거가 있는 경우 외에는 지방보조금을 운영비로 교부할 수 없다. 이 경우 운영비로 사용할 수 있는 경비의 종목은 대통령령으로 정한다.
③ (생 략)

2) 『자치법규 입안 길라잡이(2022)』 129·130쪽 참조

「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률 시행령」

제3조(운영비 사용 경비의 종목) 「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제6조 제2항 전단에 따라 법령에 근거하여 지방보조금을 운영비로 교부하는 경우 그 운영비로 사용할 수 있는 경비의 종목은 다음 각 호와 같다. 다만, 각 호의 경비가 지방보조사업을 수행하는 데 직접 드는 경비인 경우는 제외한다.

1. 인건비
2. 사무관리비
3. 임차료
4. 그 밖에 지방자치단체의 장이 다른 지방자치단체, 법인·단체 또는 개인 등이 수행하는 사무 또는 사업 등의 기본적인 운영을 위하여 특별히 필요하다고 인정하는 경비

사례 5

운영비를 지원하는 내용을 규정할 수 없다고 본 사례

2022. 5. 31. 의견제시 22-0148

질의요지

「서울특별시 성동구 전통시장 및 상점가 육성을 위한 조례」에 상인회의 사무실 임차료 등 운영비를 지원하는 내용을 규정할 수 있는지?

의 견

이 사안의 경우 질의요지와 같은 내용을 조례에 규정할 수 없을 것으로 보입니다.

이 유

「지방자치법」 제28조제1항에 따르면 지방자치단체는 법령의 범위 즉, 상위법령에 위반되지 않는 범위에서 자치사무와 개별 법령에 따라 지방자치단체에 위임된 단체위임사무에 관하여 조례를 제정할 수 있으므로 지방자치단체에는 자치사무를 수행하는데 필요한 사항을 상위 법령에 위반되지 않는 범위에서 규정할 수 있다고 할 것입니다.

먼저 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」(이하 "전통시장법"이라 한다) 제65조제1항에 따라 시장 등에서 사업을 직접 경영하는 상인이 자율적으로 설립하는 상인회는 사업내용(같은 법 제65조제4항)을 보면 시장 등의 지역상권 활성화를 위해 설립된 조직으로 볼 수 있고 상인회 등록, 정관 인가, 등록 취소의 권한이 시장·군수·구청장에 있으며(같은 법 제65조제3항 및 제8항), 정부와 지방자치단체는 상인회가 사업을 수행할 때 필요한 비용을 지원할 수 있는바(같은 법 제65조제7항), 상인회에 대한 사무는 자치사무에 해당하여 조례로 규정할 수 있는 것으로 보입니다.

한편 「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」(이하 "지방보조금법"이라 한다) 제6조제2항에서 지방

자치단체의 장은 법령에 명시적 근거가 있는 경우 외에는 지방보조금을 운영비로 교부할 수 없다고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제3조에서는 운영비로 사용할 수 있는 경비의 종목에 인건비, 사무관리비, 임차료 등을 규정하고 있습니다. 이에 따라 상인회에 운영비를 지원하거나 운영비 지원에 관한 사항을 조례에 규정하려면 법령에 명시적인 근거가 있어야 할 것입니다.

이와 관련하여 전통시장법 제65조제4항에서 상인회는 시설 및 경영의 현대화를 위한 사업(제1호), 상인의 매출 증대 및 영업활성화를 위한 공동사업(제2호), 상인 교육 및 지역주민과의 협력사업(제3호), 상거래 질서유지 및 고객 불만 처리에 관한 업무(제4호) 등 제7호까지 사업을 할 수 있다고 규정하면서 같은 조 제7항에서 정부와 지방자치단체는 이러한 사업을 수행할 때 필요한 비용을 예산의 범위에서 지원할 수 있다고 규정하고 있습니다.

그런데 이와 같은 규정들은 전통시장 및 상점가 육성으로 지역상권의 활성화를 위해 상인회가 할 수 있는 사업의 종류와 그 사업에 대해 정부나 지방자치단체의 예산지원 근거를 규정한 것으로 보이며, 상인회에 대하여 인건비, 사무관리비, 임차료 등 운영비를 지원할 수 있는 근거로 보기는 어렵다고 할 것입니다.

따라서, 「서울특별시 성동구 전통시장 및 상점가 육성을 위한 조례」에 상인회의 사무실 임차료 등 운영비를 지원하는 내용을 규정할 수는 없다고 할 것입니다.

사례 6 보조금을 교부할 수 없는 운영비에 해당하지 않는다고 본 사례

2022. 11. 16. 의견제시 22-0275

질의요지

「철원군 농촌체험관광 운영 활성화 및 지원 조례 전부개정조례안」 제3조제1항제3호, 제6조제2항제1호·제3호·제4호, 제7조제1항 각 호에서 규정하고 있는 각종 사업의 운영에 필요한 비용이 「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」 제6조제2항에 따라 지방보조금을 교부할 수 없는 운영비에 해당하는지?

의 견

이 사안의 경우 「철원군 농촌체험관광 운영 활성화 및 지원 조례 전부개정조례안」 제3조제1항제3호, 제6조제2항제1호·제3호·제4호, 제7조제1항 각 호에서 규정하고 있는 각종 사업의 운영에 필요한 비용은 「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」 제6조제2항에 따라 지방보조금을 교부할 수 없는 운영비에 해당하지 않는 것으로 보입니다.

이 유

「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」(이하 "지방보조금법"이라 한다) 제6조제2항 전단에서는 지방자치단체의 장은 법령에 명시적 근거가 있는 경우 외에는 지방보조금을 운영비로 교부할 수 없다고 규정하고 있고, 같은 항 후단에서는 이 경우 운영비로 사용할 수 있는 경비의 종목은 대통령령으로 정한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따른 같은 법 시행령 제3조에서는 운영비로 사용할 수 있는 경비의 종목을 인건비(제1호), 사무관리비(제2호), 임차료(제3호), 그 밖에 지방자치단체의 장이 다른 지방자치단체, 법인·단체 또는 개인 등이 수행하는 사무 또는 사업 등의 기본적인 운영을 위하여 특별히 필요하다고 인정하는 경비(제4호)로 규정하고 있습니다.

한편 『2022년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준』(행정안전부)에 따른 세출예산 성질별 분류를 참고하여 「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률 시행령」(이하 "지방보조금법 시행령"이라 한다) 제3조 각 호에서 규정하고 있는 운영비를 구체적으로 살펴보면, "운영비"란 업무 수행에 기본적으로 필요한 경상적·소모적 경비를 의미하는데, 일반적으로 "인건비"에는 보수·수당·정액 급식비 등이, "사무관리비"에는 사무용품 구입비, 소모성 물품구입비, 근로자의 피복비, 특근매식비 등이, "임차료"는 임대차계약에 의한 토지·건물·시설·장비 등의 사용·수익의 대가가 해당됩니다.

그런데 「철원군 농촌체험관광 운영 활성화 및 지원 조례 전부개정조례안」에서 규정하고 있는 농촌체험 관광 프로그램의 운영(제3조제1항제3호), 농촌관광택시 관련 인터넷 홈페이지 및 관광 상품 운영 등(제6조제2항제1호·제3호·제4호), 농촌체험관광 관련 기념품 및 농·축·수산물 판매시설 운영(제7조제1항 각 호)에 필요한 비용은, 철원군 농촌체험관광 운영 활성화를 위한 각종 사업을 수행하기 위한 비용으로 보이고, 지방보조금법 시행령 제3조 각 호에 따른 운영비에 해당하는 것으로 보이지는 않습니다.

따라서, 「철원군 농촌체험관광 운영 활성화 및 지원 조례 전부개정조례안」 제3조제1항제3호, 제6조제2항제1호·제3호·제4호, 제7조제1항 각 호에서 규정하고 있는 각종 사업의 운영에 필요한 비용은 지방보조금법 제6조제2항에 따라 지방보조금을 교부할 수 없는 운영비에 해당하지 않는다고 할 것입니다.

3. 조건을 붙여서 보조금을 교부하도록 하는 내용을 조례에 규정할 수 있는지

지방자치단체가 보조금 지급결정을 하면서 일정 기한 내에 보조금을 반환하도록 하는 교부조건을 부가한 사안에서 지방자치단체의 보조금관리조례 규정과 위 보조금 지급결정이 행정청 재량이 인정되는 수익적 행정행위의 성격을 지니고 있고 경제촉진을 위하여 다양한 형태의 보조금행정을 시행할 필요성도 있는 점 등을 종합하여 보면, 지방자치단체가 보조금 지급결정을 하면서 반드시 보조사업자에게 수익이 발생할 경우에 한하여 보조금을 반환하게 하는 조건을 붙일 수 있다고 볼 근거는 없고, 보조사업자의 보조금 신청 내용과 재정상태, 지방자치단체의 예산상태, 공익상·시책상 필요성, 보조금의 교부목적 등을 고려하여 금융이자의 부담 없이 보조금을 사용하도록 하되, 일정 기한 내에 보조금을 반환하도록 하는 조건의 재정상 원조를 하는 것도 허용될 수 있다고 해석된다[3].

3) 대법원 2011. 6. 9. 선고 2011다2951 판결 참조

사례 7

보조금 교부조건을 규정할 수 있다고 본 사례

2020. 7. 1. 의견제시 20-0135

질의요지

수원시로부터 보조금을 교부받는 지방보조사업자로 하여금 수원시의 보조금이 교부된 사업임을 표시하는 표지판을 지방보조사업자의 비용으로 제작하여 지방보조사업과 관련된 시설 등에 설치하도록 하는 내용을 조례로 규정할 수 있는지?

의 견

이 사안의 경우 질의요지와 같은 내용을 조례로 규정하는 것은 가능할 것으로 보입니다.

이 유

지방자치단체는 자치사무에 관하여 이른바 자치조례를 제정할 수 있고, 이러한 자치조례에 대해서는 「지방자치법」 제22조가 정하는 "법령의 범위 안"이라는 사항적 한계가 적용될 뿐 일반적인 위임입법의 한계가 적용될 여지가 없으며, 여기서 말하는 "법령의 범위 안"이라는 의미는 "법령에 위반되지 아니하는 범위 안"으로 풀이됩니다(대법원 2003. 5. 27. 선고 2002두7135 판결 참조).

「지방재정법」 제32조의2제6항에서는 지방보조금 예산의 편성 및 교부 신청과 교부 결정 등에 관하여 같은 조에서 정하지 않은 사항은 조례로 정하도록 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제29조제5항에서는 같은 법 제17조제1항에 따른 지방자치단체의 보조금 또는 그 밖의 공금 지출에 대한 교부신청, 교부결정 및 사용 등에 관하여 필요한 사항은 행정안전부장관이 정하는 기준에 따라 조례로 정한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따른 「지방보조금 관리기준」 Ⅳ. [3]에서는 보조금의 교부를 결정함에 있어 보조금액에 대한 상당률의 자체 부담과 법령 및 예산이 정하는 보조금의 교부 목적 달성에 필요하다고 인정되는 조건을 붙일 수 있다고 규정하여 보조금의 교부시 조건의 부가가 가능함을 명확히 하고 있습니다.

따라서 위와 같은 규정의 내용 및 취지, 그리고 지방자치단체는 법령에 특별한 근거규정이 없다고 하더라도 수익적 행정행위 중 재량행위에 해당하는 보조금 지급결정을 하면서 그에 대한 부관을 부가할 수 있는 점(대법원 2009. 2. 12. 선고 2005다65500 판결, 대법원 2011. 6. 9. 선고 2011다2951 판결 등 참조) 등을 종합적으로 고려하면, 지방자치단체에서 보조금을 교부받는 지방보조사업자에게 개별적인 보조금의 교부결정과 결부하여 일정한 조건을 부여할 수 있도록 하는 규정을 조례에 두는 것은 일응 가능하다고 할 것입니다(법제처 2012. 5. 30. 의견제시 12-0152 참조).

다만 행정행위에 부관을 부가함에 있어서는 관련 법령뿐만 아니라 부당결부금지원칙, 비례의 원칙 등 행정법의 일반원칙 또한 한계로 작용한다고 할 것이고(대법원 1998. 10. 23. 선고 97누164 판결, 대법원 1997. 3. 14. 선고 96누16698 판결 등 참조) 이러한 한계는 구체적인 부관을 부가하는 것을 내용으로 하는 조례에도 마찬가지로 적용된다고 할 것입니다.

이 사안의 경우 질의요지와 같은 내용을 조례에 규정하려는 목적이 주민들이 수원시 보조금이 지원되는 시설 등을 쉽게 알 수 있도록 하여 시설의 공공활용도를 높이고 보조금의 공정한 집행 및 공익에 입각한 시설의 운영·관리를 도모하는 것에 있는데(「수원시 보조금지원 표지판 설치에 관한 조례안」 제1조 참조), 수원시의 보조금 교부의 목적은 수원시의 행정목적 달성에 있는 점(「수원시 보조금지원 표지판 설치에 관한 조례안」 제2조제1호 참조), 「지방재정법」 제32조의4에서부터 제32조의9에서도 지방보조금의 용도 외 사용금지, 지방보조사업 수행상황의 점검, 지방보조사업의 실적 보고 및 정산, 법령 위반 등에 따른 교부결정의 취소, 재산 처분의 제한 등 지방보조사업의 공정하고 투명한 집행을 위한 지방보조사업자의 의무를 규정하고 있는 점 등에 비추어 볼 때, 특별한 사정이 없는 한 질의요지와 같은 내용을 조례에 규정하는 것이 수원시 보조금의 성격과 부당한 연관성을 지닌다고 보이지는 않습니다.

다만 구체적인 사안에서 교부되는 보조금의 규모와 표지판의 제작 및 설치 등에 소요되는 비용 사이에 적절한 비례관계가 유지될 수 있도록 하는 내용 등을 자치법규 등에 추가하는 방안도 고려할 수 있을 것인바, 이상의 내용을 참고하시기 바랍니다.

사례 8

보조금 교부조건에 관한 판단기준을 제시한 사례

2024. 4. 18. 의견제시 24-0126

질의요지

가. 부천시장이 지방보조금 교부를 결정할 때 지방보조금 교부를 신청한 자가 정치활동에 관여하였는지를 조사·검토하도록 하는 내용을 조례에 규정할 수 있는지?

나. 부천시장이 지방보조금 교부를 결정할 때 지방보조금 교부를 신청한 자로 하여금 정치적 중립을 유지하게 하는 조건을 붙일 수 있도록 하는 내용을 조례에 규정할 수 있는지?

의 견

가. 질의 가에 대하여

아래 이유를 참고하시기 바랍니다.

나. 질의 나에 대하여

아래 이유를 참고하시기 바랍니다.

이 유

가. 질의 가에 대하여

현행 「부천시 지방보조금 관리 조례」 제15조에서는 시장은 지방보조금의 교부신청서가 제출된 경우에는 "법령과 예산의 목적에 위배되는지 여부"(제1호) 등을 조사·검토하여 지방보조금의 교부를 결정한다고 규정하고 있는데, 「부천시 지방보조금 관리 조례 일부개정조례안」(이하 "부천시조례안"이라 한다)에서는 제15조에 지방보조금 교부결정 시 조사·검토 사항으로 "정치활동에 관여하는 행위 여부"를 추가하려는 것인바, 이 사안은 지방보조금 교부 신청자의 정치활동 관여 여부를 지방보조금의 교부결정 기준으

로 명시하는 규정을 조례에 둘 수 있는지에 관한 것으로 보입니다.

먼저, 「지방자치법」 제28조제1항 본문에 따르면 지방자치단체는 "법령의 범위"에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있는데, 여기서 "법령의 범위"란 법령에 위반되지 않는 범위를 의미하는바(대법원 2002. 5. 31. 선고 2001추88 판결 참조), 「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」(이하 "지방보조금법"이라 한다) 제8조제1항에서는 지방자치단체의 장은 지방보조금의 교부신청서가 제출된 경우 "법령, 조례 및 예산의 목적에의 적합 여부"(제1호) 등을 조사하여 지체 없이 지방보조금의 교부 여부를 결정하여야 한다고 규정하고 있고, 「지방재정법 시행령」 제29조제5항에서는 지방자치단체의 보조금 또는 그 밖의 공금 지출에 대한 교부신청, 교부결정 및 사용 등에 관하여 필요한 사항은 행정안전부장관이 정하는 기준에 따라 해당 지방자치단체의 조례로 정하도록 규정하면서, 그 위임에 따라 마련된 「지방보조금 관리기준」(2023. 12. 31. 행정안전부예규 제273호로 발령되어 2024. 1. 1. 시행된 것을 말하며, 이하 같음) 제3조제3항에서는 지방보조사업자 선정 시 고려사항으로 "법 제32조에 따라 지방보조사업의 수행대상에서 배제되거나 지방보조금의 교부를 제한받은 경우가 있는지 여부"(제1호) 등을 규정하고 있는바, 이 사안의 경우 부천시조례안에서 지방보조금법이나 「지방보조금 관리기준」에서 지방보조금 교부결정 기준으로 명시하고 있지 않은 사항을 추가로 규정하는 것이 지방보조금 관련 법령에 위배되는지가 문제됩니다.

살피건대, 보조금의 교부는 상대방에게 권리·이익을 부여하는 수익적 행정행위로서 보조금을 교부하는 자는 보조금 교부대상이나 교부결정의 기준을 정할 때 폭넓은 재량을 가진다고 할 것이고, 「지방재정법 시행령」 제29조제5항에서 조례로 위임하고 있는 보조금 교부결정에 관하여 필요한 사항에는 보조금 교부결정 시의 기준이나 고려사항이 포함된다 할 것이며(법제처 2011. 4. 1. 의견제시 11-0006 참조), 지방보조금법 제8조제1항이나 「지방보조금 관리기준」 제3조제3항은 지방자치단체의 장이 지방보조금 교부결정을 할 때 반드시 조사하거나 고려해야 하는 사항을 정한 것으로서, 그 밖의 사항을 조례에 추가로 정하는 것을 전면적으로 금지하고 있다고 단정해서 보기 어려운 점 등을 고려할 때, 이 사안의 경우 조례에 지방보조금 교부결정 기준을 추가로 규정하는 것은 가능하다고 할 것입니다.

다음으로, 질의요지와 같은 내용을 조례에 규정하는 것이 법령이나 헌법상의 일반원칙 등에 위배되는지를 살펴보면, 자치법규인 조례는 입법의 일반적인 원칙인 법규의 명확성을 확보함으로써 법규가 통일적이고 안정적으로 집행될 수 있도록 규정되어야 할 것이고, 법규범이 명확한지 여부는 그 법규범이 수범자에게 법규의 의미내용을 알 수 있도록 공정한 고지를 하여 예측가능성을 주고 있는지 여부 및 그 법규범이 법을 해석·집행하는 기관에게 충분한 의미내용을 규율하여 자의적인 법해석이나 법집행을

배제할 수 있는지 여부에 따라 판단할 수 있을 것인바(법제처 2024. 1. 22. 의견제시 23-0452 참조), 이 사안에서 부천시조례안 제15조제6호에 따른 "정치활동에 관여하는 행위"의 경우 그 행위의 내용이 어떤 것인지 구체적으로 밝히고 있지 않은바[「지방공무원법」과 「국가정보원법」은 '정치 운동'과 '정치 관여'를 금지하면서 각각 '특정 정당 또는 특정인을 지지 또는 반대하기 위한 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위'(「지방공무원법」 제57조제2항), '정치활동에 관여하는 행위란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위'(「국가정보원법」 제11조제2항)와 같이 그 대상을 개별화·유형화하고 있음], 지방자치단체의 장이 지방보조금 교부결정을 할 때 지방보조금 교부 신청자에 대해 어떤 형태의 행위를 조사·검토하는지 예상하기 어려워 수범자의 예측 가능성을 떨어뜨리고 자의적인 법집행 가능성을 배제하기 어렵다고 할 것이므로, 질의요지와 같은 내용을 조례에 규정하는 것은 법령의 명확성 원칙에 위반되는 것으로 보입니다.

또한, 부천시조례안의 내용을 수정하여 "정치활동에 관여하는 행위"의 의미를 구체화하더라도, 해당 규정은 지방보조금을 신청하기 전에 있었던 정치활동 관여 행위를 기준으로 지방보조금을 차별적으로 지원하게 하려는 취지로 보이는바, 이러한 내용을 조례에 규정하는 것이 평등의 원칙이나 부천시 조례안의 목적에 비추어 적절한지를 살펴보면, 「행정기본법」 제9조에서는 행정청은 합리적 이유 없이 국민을 차별하여서는 아니 된다고 하여 평등의 원칙을 규정하고 있고, 이러한 평등의 원칙은 법을 적용할 때뿐 아니라 입법을 할 때에도 불합리한 차별을 해서는 안 된다는 상대적·실질적 평등을 뜻하는 것인데(법제처 2014. 5. 14. 의견제시 14-0100, 헌법재판소 1994. 2. 24. 선고 93헌바10 결정 참조), 「부천시 지방보조금 관리 조례」는 지방보조금법에 따라 부천시의 예산을 재원으로 하는 지방보조금의 교부대상, 교부방법과 사용 및 보조사업 공개 등에 관하여 필요한 사항을 규정한 조례로서(제1조), 지방보조금의 관리에 관하여는 다른 법령이나 조례에 특별한 규정이 있는 것을 제외하고는 이 조례가 정하는 바에 따른다고 규정하고(제3조) 있는 점 등을 고려할 때, 이 조례는 부천시 소관 지방보조금의 관리에 관한 일반조례로서 부천시 예산을 재원으로 하는 모든 보조 사업에 적용된다고 할 것인바, 질의요지와 같은 내용을 조례에 규정하는 것은 부천시 예산을 재원으로 하는 각각의 보조사업별로 고유한 사업 목적이나 내용이 있음에도 불구하고 이와 무관하게 지방보조금 교부 신청자의 정치활동 이력에 따라 부천시 보조금 지원사업의 대상에서 일률적으로 배제하게 되는 불합리한 결과를 가져오고, 이러한 차별적인 취급을 허용하는 취지의 별도의 법적 근거도 없으므로, 그 내용이 불공정하고 합리성이 결여되어 있어 평등원칙에 위반될 여지가 있는 것으로 보입니다.

한편, 지방보조금 교부 신청자의 이전의 정치활동 관여 해당 여부를 조사·검토하기 위해서는 지방자치

단체의 장이 해당 정보를 수집하거나 처리할 수 있어야 할 것인데, 개인의 정당 가입·탈퇴나 정치적 견해 등의 정보는 「개인정보 보호법」 제23조제1항에 따라 민감정보에 해당하여 예외적으로 "법령에서 민감정보의 처리를 요구하거나 허용하는 경우"에만 처리가 허용된다고 할 것인데, 지방보조금법 등에서는 지방자치단체의 장이 민감정보인 개인의 정당 가입·탈퇴나 정치적 견해 등에 대한 민감정보를 처리할 수 있도록 허용하는 명시적 규정이 없는 점을 고려하면, 질의요지와 같은 내용을 조례에 규정하는 것은 「개인정보 보호법」을 위반할 소지도 있는 것으로 보입니다.

따라서, 귀 시에서 질의요지와 같은 내용을 조례에 규정하는 것은 법령이나 헌법상의 일반원칙에 위배될 소지가 있는 것으로 보이므로 입안에 신중하시기 바랍니다.

나. 질의 나에 대하여

현행 「부천시 지방보조금 관리 조례」 제16조제1항에서는 시장은 지방보조금의 교부를 결정함에 있어서 보조금액에 대한 상당율의 자체 부담과 법령 및 예산이 정하는 지방보조금의 교부 목적 달성에 필요하다고 인정되는 조건을 붙일 수 있다고 규정하고 있는데, 부천시조례안에서는 제4항을 신설하여 "정치적 중립을 유지"하는 조건을 붙일 수 있도록 규정하려는 것인바, 이 사안은 지방보조금 교부 신청자에게 정치적 중립을 유지하도록 하는 내용을 지방보조금 교부 조건으로 부과할 수 있도록 명시하는 규정을 조례에 둘 수 있는지에 관한 것으로 보입니다.

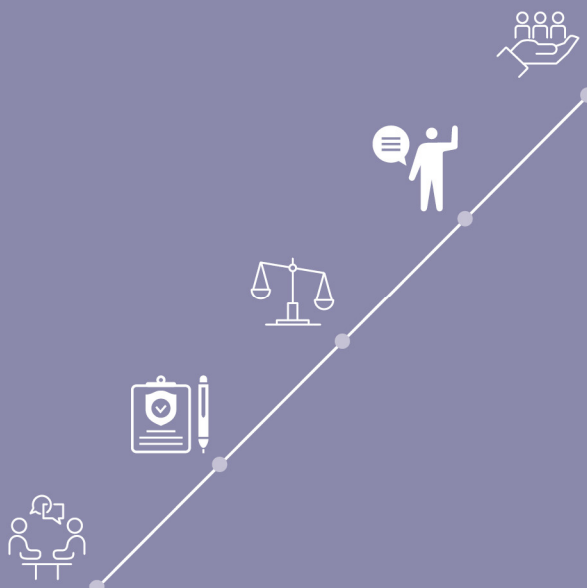
우선, 「행정기본법」 제17조에 따르면 행정청은 처분에 재량이 있는 경우(제1항)와 재량이 없는 경우라도 법률에 근거가 있는 경우(제2항)에는 조건, 기한, 부담, 철회권의 유보 등의 부관을 붙일 수 있고, 지방보조금법 제9조제1항에서는 지방자치단체의 장은 지방보조금의 교부를 결정할 때 법령, 조례와 예산에서 정하는 지방보조금의 교부 목적을 달성하는 데 필요한 조건을 붙일 수 있다고 규정하고 있으며, 「지방보조금 관리기준」 제8조에서는 지방자치단체의 장이 교부조건을 붙이는 경우에 명시하여야 할 사항 등을 규정하고 있는바, 부천시조례안 제16조에 따른 지방보조금 교부 결정 시 시장은 지방보조금법 제9조제1항에 따라 부관을 붙이는 것이 가능하다고 할 것이나, 부관을 붙일 수 있는 경우라 하더라도 관련 법령 및 행정법의 일반원칙에 위반되지 않아야 할 것입니다(법제처 2022. 2. 24. 의견제시 22-0015 참조).

그런데, 앞서 살펴본 바와 같이 자치법규인 조례는 입법의 일반적인 원칙인 법규의 명확성을 확보하여야 하는데, 이 사안에서 부천시조례안 제16조제4항의 경우 지방보조금 교부 조건인 "정치적 중립"의

내용이 어떤 것인지 구체적으로 밝히고 있지 않은바, 지방자치단체의 장이 지방보조금 교부결정을 할 때 지방보조금 교부 신청자에게 어떤 행위의 유무를 조건으로 부과할지 예상하기 어려워 수범자의 예측가능성을 떨어뜨리고 자의적인 법집행 가능성을 배제하기 어렵다고 할 것이므로, 질의요지와 같은 내용을 조례에 규정하는 것은 법령의 명확성 원칙에 위반되는 것으로 보입니다.

또한, 부천시조례안의 내용을 수정하여 "정치적 중립"의 의미를 구체화하더라도, 해당 규정은 같은 조례안이 적용되는 부천시 소관 지방보조금 사업 전부에 대해 정치적 중립을 유지하는 조건을 부과할 수 있도록 하려는 취지로 보이는바, 이러한 내용을 조례에 규정하는 것이 부당결부금지 원칙이나 부천시 조례안의 목적에 비추어 적절한지를 살펴보면, 「행정기본법」 제13조에서는 행정청은 행정작용을 할 때 상대방에게 해당 행정작용과 실질적인 관련이 없는 의무를 부과해서는 아니 된다고 하여 부당결부금지의 원칙을 규정하고 있는데, 앞서 살펴본 바와 같이 「부천시 지방보조금 관리 조례」는 부천시 소관 지방보조금의 관리에 관한 일반조례로서 부천시 예산을 재원으로 하는 모든 보조 사업에 적용되므로, 질의요지와 같은 내용을 조례에 규정하는 것은 부천시 예산을 재원으로 하는 각각의 보조사업별로 고유한 사업 목적이나 내용이 있음에도 불구하고 이와 무관하게 일률적으로 지방보조금 교부 신청자에게 정치적 중립 의무 조건을 부과할 수 있도록 허용하는 것으로서, 법령 및 조례와 예산이 정하는 지방보조금의 교부 목적 달성과 실질적인 관련이 없는 의무를 부과할 수 있도록 허용하는 결과를 가져오게 되는바, 그 내용이 부당결부금지의 원칙에 위반될 소지도 있는 것으로 보입니다.

따라서, 귀 시에서 질의요지와 같은 내용을 조례에 규정하는 것은 법령이나 헌법상의 일반원칙에 위배될 소지가 있는 것으로 보이므로 입안에 신중하시기 바랍니다.



제 2 편

공유재산

1. 행정재산인 공공시설의 이용관계에서 사용료 감면 등을 조례에 규정할 수 있는지

공공시설인 공공용재산(예: 지방자치단체가 설치한 수영장 등)에 대한 일반 주민의 이용 관계는 「공유재산 및 물품 관리법」 제20조의 사용허가에 따른 공유재산의 사용관계와 그 성격이 다르다.

「공유재산 및 물품 관리법」에서는 행정재산의 목적 외 사용허가에 대해 규정하고 있는바, 특정 공공시설의 사용관계가 행정재산의 목적 외 사용허가에 해당하는 경우에는 공유재산법령에 따른 사용허가에 관한 규정의 범위 내에서 조례로 정할 수 있다.

한편, 공공시설의 이용관계에 대해서는 「지방자치법」 제153조 및 제156조제1항에서 공공시설의 이용에 따른 사용료를 조례로 정할 수 있도록 하고 있는데, 이 경우의 사용료는 「공유재산 및 물품 관리법」 제22조의 사용허가에 따른 사용료와는 다른 것으로, 그 산정 방법이나 요금의 결정 방법은 조례로 정할 수 있다[4].

「지방자치법」

제153조(사용료) 지방자치단체는 공공시설의 이용 또는 재산의 사용에 대하여 사용료를 징수할 수 있다.

제156조(사용료의 징수조례 등) ① 사용료·수수료 또는 분담금의 징수에 관한 사항은 조례로 정한다. 다만, 국가가 지방자치단체나 그 기관에 위임한 사무와 자치사무의 수수료 중 전국적으로 통일할 필요가 있는 수수료는 다른 법령의 규정에도 불구하고 대통령령으로 정하는 표준금액으로 징수하되, 지방자치단체가 다른 금액으로 징수하려는 경우에는 표준금액의 50퍼센트 범위에서 조례로 가감 조정하여 징수할 수 있다.
②·③ (생 략)

4) 『자치법규 입안 길라잡이(2022)』 145쪽 참조

사례 9

사용료 감면 규정을 둘 수 있다고 본 사례

(질의 가)

2024. 8. 12. 의견제시 24-0261

질의요지

가. 화성시의 행정재산인 생활체육시설을 특정 생활체육시설 소재지의 주변지역 주민이 이용하는 경우 그 이용에 따른 사용료를 감면할 수 있도록 하는 내용을 조례에 규정할 수 있는지?

나. 화성시의 행정재산인 생활체육시설을 특정 생활체육시설 소재지의 주변지역 주민이 허가받아 사용하는 경우 그 사용허가에 따른 사용료를 감경할 수 있도록 하는 내용을 조례에 규정할 수 있는지?

의 견

가. 질의 가에 대하여

질의요지와 같은 내용을 조례에 규정할 수 있을 것으로 보입니다.

나. 질의 나에 대하여

질의요지와 같은 내용을 조례에 규정할 수 있을 것으로 보입니다.

이 유

가. 질의 가에 대하여

「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」(이하 "체육시설법"이라 한다) 제8조에서는 생활체육시설은 경기대회 개최나 시설의 유지·관리 등에 지장이 없는 범위에서 지역 주민이 이용할 수 있도록 개방하여야 하고(제1항), 그 체육시설의 개방 및 이용에 관하여 필요한 사항은 문화체육관광부령으로 정한다고(제3항) 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제5조에서는 체육시설법 제8조에 따라 국가나 지방자치단체 등이 체육시설을 지역 주민에게 개방하는 경우에는 개방시간과 이용방법 등을

잘 볼 수 있게 게시하여야 하고, 그 체육시설을 관리하는 데에 드는 경비의 범위에서 이용료를 그 이용자에게 부담시킬 수 있다고 규정하고 있습니다.

한편, 「지방자치법」 제153조에서는 지방자치단체는 공공시설의 이용 또는 재산의 사용에 대하여 사용료를 징수할 수 있다고 규정하고 있고, 제156조제1항 본문에서는 사용료의 징수에 관한 사항은 조례로 정한다고 규정하고 있는바, 이 사안의 생활체육시설은 화성시가 주민의 복지를 증진하기 위하여 설치한 공공시설(「지방자치법」 제161조)에 해당하고, 공공시설인 화성시 생활체육시설을 이용하는 자로부터 징수하는 요금은 「지방자치법」 제153조의 공공시설의 이용에 따른 사용료에 해당하는 것으로 보입니다(법제처 2018. 3. 6. 의견제시 18-0005, 2021. 6. 2. 의견제시 21-0147 참조).

살피건대, 「지방자치법」 제156조제1항에서는 사용료의 징수에 관하여 조례로 정하도록 포괄적으로 위임하고 있어 사용료의 산정방법이나 기준 등을 조례로 정할 수 있는 것으로 보이고, 이는 사용료의 감면에 대해서도 달리 볼 것은 아니므로, 지방자치단체가 합리적인 범위에서 정책적 목적에 따라 특정 생활체육시설 소재지의 주변지역 주민에 대한 사용료의 감면에 관한 사항을 조례에 규정하는 것은 법령에 위배되지 않는 것으로 보입니다(법제처 2016. 12. 28. 의견제시 16-0310, 2020. 8. 26. 의견제시 20-0189 참조).

따라서, 질의요지와 같은 내용을 조례에 규정할 수 있을 것으로 보입니다.

나. 질의 나에 대하여

체육시설법 제6조에서는 국가와 지방자치단체는 국민이 거주지와 가까운 곳에서 쉽게 이용할 수 있는 생활체육시설을 대통령령으로 정하는 바에 따라 설치·운영하여야 하고(제1항), 생활체육시설의 사용을 촉진하기 위하여 지방자치단체는 「공유재산 및 물품 관리법」, 그 밖의 다른 법률의 규정에도 불구하고 그 사용료의 전부나 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 감면할 수 있다(제3항)고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제4조의2에서는 생활체육시설이 국가나 다른 지방자치단체가 주최하거나 주관하는 행사(제1호) 등에 사용되는 경우에는 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 사용료를 감면할 수 있다고 규정하는 한편, 「공유재산 및 물품 관리법」(이하 "공유재산법"이라 한다) 제20조제1항에서는 지방자치단체의 장은 행정재산에 대하여 그 목적 또는 용도에 장애가 되지 아니하는 범위에서 사용허가를 할 수 있다고 규정하고 있고, 제22조제1항 본문에서는 지방자치단체의 장은 행정재산을 사용허가한 때에는 대통령령으로 정하는 요율(料率)과 계산방법에 따라 매년 사용료를

징수한다고 규정하고 있습니다.

일반적으로 공유재산의 관리·처분에 관해서는 공유재산법이 적용되나, 이에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있으면 그 개별 법률의 규정이 적용될 것인바(공유재산법 제2조의2), 이 사안의 생활체육시설 사용허가에 따른 사용료는 공유재산법 제20조에 따른 사용허가를 받은 자로부터 징수하는 요금인 제22조에 따른 사용료에 해당하는 것으로 보이는데, 그 사용료의 감경에 관하여는 공유재산법에 대한 특례를 규정하고 있는 체육시설법 제6조제3항 및 같은 법 시행령 제4조의2가 적용되어야 할 것입니다.

그렇다면, 질의요지와 같은 감경 대상이 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률 시행령」(이하 "체육시설법시행령"이라 한다) 제4조의2 각 호에 해당하는지가 문제되는데, 같은 조 제1호부터 제6호까지의 대상에는 해당하지 않는 것으로 보이므로, 제7호의 '그 밖에 사용료 감경이 필요하여 지방자치단체의 조례로 정하는 행사 또는 활동'에 해당하는지 살펴보면, 이 사안의 사용료 감경 대상인 '특정 생활체육시설 소재지의 주변지역에 거주하는 주민'이라는 지표는 문언상 '행사 또는 활동'에 해당하지 않는 것으로 볼 여지가 있으나, 입법연혁적으로 체육시설법시행령 제4조의2제7호 중 '조례로 정하는 행사 또는 활동'은 체육시설 사용료 감면 대상을 확대할 목적으로 2017년 12월 29일에 대통령령 제28521호로 개정되면서 종전에는 '조례로 정하는 행사'였던 부분에 '활동'이 추가된 것인 점, 같은 호는 사용료 감경의 필요성에 관하여 해당 지방자치단체가 판단하여 조례로 정하도록 포괄적으로 위임하는 입법형식을 취하고 있는 점 등을 고려할 때, 같은 호에 따라 조례로 정할 수 있는 사용료 감경의 대상을 넓게 해석하는 것이 입법체계 및 취지에 부합하는 것으로 보이므로, 지방자치단체가 합리적인 범위에서 정책적 목적에 따라 특정 생활체육시설 소재지의 주변지역 주민에 대한 사용료의 감경에 관한 사항을 조례에 규정하는 것은 법령의 위임 범위를 벗어나는 것으로 보이지 않습니다(법제처 2022. 7. 6. 의견제시 22-0155 참조).

따라서, 질의요지와 같은 내용을 조례에 규정할 수 있을 것으로 보입니다.

사례 10

공공시설 이용료를 확정 금액이 아닌 최고액 · 최저액으로 규정할 수 있다고 본 사례

(질의 가)

2018. 3. 6. 의견제시 18-0005

질의요지

가. 문경시는 문경시의 행정재산인 문경 에코랄라를 '직영'하는 경우 조례로 문경 에코랄라의 이용료를 확정 금액이 아닌 최고액과 최저액으로 규정할 수 있는지?

나. 문경시의 행정재산인 문경 에코랄라를 '관리위탁'하여 관리위탁을 받은 자가 이용료를 징수하는 경우 문경시가 조례로 문경 에코랄라의 이용료 감면에 관한 사항을 정하면 관리위탁을 받은 자는 이에 따라 이용료를 감면할 수 있는지?

의 견

아래 이유를 참고하시기 바랍니다.

이 유

가. 질의 가에 대하여

「문경 에코랄라 관리 및 운영 조례안」(이하 "문경시조례안"이라 함) 제3조제1호에서는 "문경 에코랄라"란 문경시 가은읍 왕능길 114 일원의 녹색문화체험관, 석탄박물관, 체험시설, 세트장, 야외 놀이시설, 부대시설로 이루어진 복합 생태 영상 테마파크를 말한다고 규정하고 있고, 같은 조 제3호에서는 "이용료"란 문경 에코랄라의 전시물 및 시설을 이용하기 위하여 입장하는 자로부터 징수하는 요금을 말한다고 규정하고 있으며, 같은 조례안 제14조제1항에서는 이용료는 이용대상에 따라 차등을 두며 5,000원에서 20,000원 이내로 정한다고 규정하고 있습니다.

이 사안에서는 문경시조례안에서 문경시의 행정재산인 문경 에코랄라의 이용료를 확정 금액이 아닌, 최고액과 최저액으로 규정할 수 있는지 문제되는 것으로 보입니다.

문경시의 행정재산인 문경 에코랄라는 「공유재산 및 물품관리법」(이하 "공유재산법"이라 함) 제5조제2항제2호에서 규정하고 있는 지방자치단체가 직접 공공용으로 사용하거나 사용하기로 결정한 재산과 사용을 목적으로 건설 중인 재산인 공공용재산이자, 문경시가 주민의 복지를 증진하기 위하여 설치한 공공시설(「지방자치법」 제144조)에 해당하는 것으로 보입니다. 또한, 공공시설인 문경 에코랄라의 이용료는 문경 에코랄라의 전시물 및 시설을 이용하기 위하여 입장하는 자로부터 징수하는 요금(문경시조례안 제3조제3호)으로서, 「지방자치법」 제136조에서 규정하고 있는 공공시설의 이용에 대하여 징수하는 사용료(이하 공유재산법 제22조에 따른 사용료와 구분하기 위하여 "이용료"라 함)에 해당하는 것으로 보입니다.

「지방자치법」 제136조 및 제139조제1항에서 지방자치단체는 공공시설의 이용에 대하여 이용료를 징수할 수 있도록 하고, 그 이용료 징수에 관한 사항을 조례로 정하도록 하고 있는데, 이는 공공시설에 대한 이용료 징수는 행정기관이 직접적으로 주민에게 부담을 주는 측면이 있고, 공물에 대한 사용 관계로서 공법적 관계가 적용된다고 할 것이므로 이에 관하여 직접 조례로 정하도록 하려는 것인바, 이용료 부과 금액 및 시기와 같이 이용료의 징수와 관계된 사항은 조례에서 직접 정하는 것이 가장 바람직합니다. 다만, 예외적인 경우 조례에서 이용료의 상한이나 부과의 기준 등과 같은 이용료 부과에 관한 기본적인 사항을 규정한 후에 지방자치단체의 규칙으로 세부사항을 정할 수 있도록 위임하였다면 지방자치단체의 규칙으로도 이용료 부과 금액 및 시기에 대하여 규정할 수 있다고 할 것입니다(법제처 2011. 6. 29. 의견제시 11-0110, 자치법규 입안 매뉴얼, 법제처 2013, 137쪽 참조).

따라서, 문경시에서 문경 에코랄라를 '직영'하는 경우에 문경시조례안에서 문경시 규칙으로 문경 에코랄라의 이용료에 관하여 세부적으로 정하도록 위임하여 그 위임한 세부사항을 문경시 규칙으로 정하도록 하는 경우에는 문경시는 문경 에코랄라의 이용료를 최고액과 최저액으로 규정할 수 있다고 할 것입니다.

나. 질의 나에 대하여

공유재산법 제2조의2에서는 공유재산 및 물품의 관리·처분에 관하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 이 법에서 정하는 바에 따른다고 규정하고 있고, 같은 법 제27조제1항에서는 지방자치단체의 장은 행정재산의 효율적인 관리를 위하여 필요하다고 인정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라

지방자치단체 외의 자에게 그 재산의 관리를 위탁할 수 있다고 규정하고 있습니다.

한편, 문경시조례안 제5조제1항에서는 문경 에코랄라의 효율적인 운영을 위하여 필요한 경우 기관, 단체, 법인, 개인에게 시설의 전부 또는 일부를 위탁하여 관리하게 할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조례안 제16조제1항에서는 시장이 정한 무료 관람일에 출입하는 사람(제7호) 등에 해당하는 경우에는 시장은 입장료를 면제할 수 있다고 규정하고 있으며, 같은 조 제2항에서는 시장이 정한 감면 관람일에 출입하는 사람(제4호) 등에 해당하는 경우에는 입장료 또는 체험료를 50퍼센트 이내에서 감면할 수 있다고 규정하고 있습니다.

이 사안에서는 문경시장이 문경 에코랄라를 관리위탁하여 관리위탁을 받은 자가 이용료를 징수하는 경우 문경시가 조례로 문경 에코랄라의 이용료 감면에 관한 사항을 정하면 관리위탁을 받은 자가 이에 따라 이용료를 감면할 수 있는지 문제되는 것으로 보입니다.

행정재산을 관리위탁하는 경우에 이용자로부터 징수하는 이용료에 관해서는 공유재산법 제27조제8항 제5호에서 관리위탁에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제21조제4항에서 관리위탁을 받은 자의 이용료 징수는 예상수익을 고려하여 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 결정한다고 규정하고 있습니다.

이와 같이 공유재산법 시행령 제21조제4항에서 행정재산의 관리위탁을 받은 자가 이를 이용하는 자로부터 받는 이용료는 지방자치단체의 조례로 결정하도록 명시적으로 규정하고 있는 점에 비추어 볼 때, 공유재산법 제27조제1항에 따라 문경시장이 문경 에코랄라를 관리위탁하는 경우 관리위탁을 받은 자가 문경 에코랄라를 이용하는 자로부터 받는 이용료는 조례로 정해야 할 것으로 보이며, 이용료 징수에 관한 사항은 해당 지방자치단체가 조례로 자율적으로 정할 수 있다고 할 것이므로, 공익상 필요가 있는 경우 해당 지방자치단체는 합리적인 범위에서 정책적 목적에 따라 조례로 이용료 부과 및 징수뿐만 아니라 행정재산의 이용료의 감면에 관한 사항도 정할 수 있다고 할 것입니다(법제처 2017. 3. 23. 회신 17-0068 해석례 참조).

따라서, 문경시가 행정재산인 문경 에코랄라를 관리위탁함에 따라 관리위탁을 받은 자가 이용료를 징수하는 경우 문경시가 조례로 문경 에코랄라의 이용료 감면에 관한 사항을 정하면 관리위탁을 받은 자는 이에 따라 이용료를 감면할 수 있을 것으로 보입니다.

2. 행정재산의 관리위탁을 수의계약으로 할 수 있도록 하는 내용을 조례에 규정할 수 있는지

지방자치단체의 장은 행정재산의 효율적인 관리를 위해 필요하면 지방자치단체 외의 자에게 그 재산의 관리를 위탁할 수 있는데(「공유재산 및 물품 관리법」 제27조), 이러한 "관리위탁"의 실질은 행정사무의 민간위탁이다. 즉 지방자치단체의 행정재산 관리사무 중 일부를 민간에 맡겨 그의 명의와 책임하에 행사하도록 하는 것이라는 점에서 「지방자치법」에 따른 민간위탁에 해당한다.

「공유재산 및 물품 관리법」 제27조제2항에서는 지방자치단체의 장은 행정재산을 관리위탁하는 경우에는 일반입찰로 하도록 하되, 계약의 목적·성질·규모 및 지역특수성 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 수의계약 등을 할 수 있도록 했다. 수의계약의 대상범위 등 이에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정하도록 위임하고 있으며, 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제19조의2부터 제19조의5까지에서는 입찰의 참가자격, 자격 제한에 의한 계약, 지명입찰에 의한 계약, 수의계약에 의할 수 있는 경우 등을 제한적으로 열거하고 있으므로 이러한 요건에 맞게 행정재산을 관리위탁해야 할 것이다[5].

「공유재산 및 물품 관리법」

제27조(행정재산의 관리위탁) ① 지방자치단체의 장은 행정재산의 효율적인 관리를 위하여 필요하다고 인정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 지방자치단체 외의 자에게 그 재산의 관리를 위탁(이하 "관리위탁"이라 한다)할 수 있다.

② 지방자치단체의 장은 제1항에 따라 행정재산을 관리위탁하는 경우에는 일반입찰로 하여야 한다. 다만, 계약의 목적·성질·규모 및 지역 특수성 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명하여 입찰에 부치거나 수의계약을 할 수 있다.

③ ~ ⑧ (생 략)

5) 『자치법규 입안 길라잡이(2022)』 152·155쪽 참조

「공유재산 및 물품 관리법 시행령」

제19조의5(수의계약에 의할 수 있는 경우) ① 법 제27조제2항 단서에 따라 수의계약으로 행정재산을 관리위탁할 수 있는 경우는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로 한다.

1. 다른 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체의 사무 또는 사업을 위탁 또는 대행할 수 있는 자에게 관리위탁을 하는 경우
2. 관리위탁의 업무 성질상 시설과 장비, 기술 보유 정도, 책임능력 등 특별한 기술과 능력이 필요하여 일반입찰에 부치기 곤란한 경우로서 행정안전부장관이 그 내용 및 범위를 정한 경우
3. 2회에 걸쳐 유효한 일반입찰이 성립되지 아니한 경우

② 지방자치단체의 장은 제1항에 따라 수의계약으로 관리위탁을 하려는 경우에는 수탁받으려는 자의 관리위탁 수행 능력, 사업수행계획 등을 행정안전부장관이 정하는 기준에 따라 평가하여야 한다.

사례 11 수의계약 대상에 해당하는 것으로 보기 어렵다고 본 사례

2020. 12. 2. 의견제시 20-0296

질의요지

가. 영덕군수의 권한에 속하는 지역문화에 관한 사무의 일부를 「지방자치법」 제104조제2항에 따라 영덕문화관광재단에 위탁하려는 경우 그에 관한 사항을 「영덕문화관광재단 설립 및 운영에 관한 조례」에 둘 수 있는지?

나. 영덕군수가 관리하는 특정 행정재산을 영덕문화재단에 관리위탁하는 내용을 「영덕문화관광재단 설립 및 운영에 관한 조례」에 규정할 수 있는지?

의 견

가. 질의 가에 대하여

아래 이유를 참고하시기 바랍니다.

나. 질의 나에 대하여

아래 이유를 참고하시기 바랍니다.

이 유

가. 질의 가에 대하여

「지방자치법」 제104조제2항에서는 지방자치단체의 장은 "조례나 규칙"으로 정하는 바에 따라 그 권한에 속하는 사무의 일부를 관할 공공단체 또는 그 기관에 위임하거나 위탁할 수 있다고 규정하고 있는 바, 「지방자치법」 제9조제5호라목에 따르면 지방문화·예술의 진흥에 관한 사무는 지방자치단체의 자치 사무의 하나로 예시되어 있고, 「영덕문화관광재단 설립 및 운영에 관한 조례」(이하 "영덕문화재단조례"라 한다)에 따르면 영덕문화재단은 「지역문화진흥법」 제19조 및 「지방자치단체 출자·출연 기관의

운영에 관한 법률」(이하 "지방출자출연법"이라 한다) 제4조에 따라 영덕군의 문화예술관광 진흥과 군민의 문화 복지 증진을 위하여 영덕군의 출연금을 기본재산으로 하여 설립된 재단법인인데, 「지방자치법」 제104조제2항에 따른 "공공단체"의 범위에는 법령이나 조례에 따라 설치된 단체, 지방자치단체가 출연·보조를 통하여 재정적으로 그 시설의 설치·운영에 대하여 관리·감독할 수 있는 단체 또는 그 밖에 지방자치단체가 그 조직이나 활동 등에 대하여 법률상 또는 사실상의 영향력을 행사할 수 있는 단체 등이 포함된다는 점(법제처 2010. 4. 16. 회신 10-0037 해석례 및 법제처 2018. 5. 4. 의견제시 18-0098 참조)에 비추어볼 때 「지방자치법」 제104조제2항에 따라 지방자치단체의 권한에 속하는 지역문화에 관한 사무 중 일부를 영덕문화재단에 위탁하는 것은 일응 가능하다고 할 것입니다.

그리고 「지방자치법」 제104조제2항에서 "조례나 규칙으로 정하는 바에 따라" 위임하거나 위탁할 수 있다고 규정한 취지는 행정권한의 위임이나 위탁으로 인한 행정주체의 변경은 주민의 권리와 의무에 중대한 영향을 미치는 사항임에도 불구하고 법률에서는 "위탁할 수 있다"고 위임의 근거규정만을 두고 있을 뿐 위탁 여부에 대하여 확정적으로 규정하고 있지 않으므로, 조례나 규칙에서 이를 확정적으로 규정하여 행정권한을 행사하는 행정기관의 권한과 책임을 일치시키고, 더 나아가 위탁관련 내용을 조례·규칙과 같이 대외적인 공포절차를 거치는 법규에 규정하도록 함으로써 주민이 쉽게 알 수 있도록 하여 행정의 투명성을 보장하기 위한 것입니다(법제처 2012. 4. 24. 의견제시 12-0122 참조).

그런데 「지방자치법」 제104조제2항에서 위임이나 위탁 시 "조례나 규정으로 정하도록"한 것은 사무의 위임·위탁을 규정하는 법령의 형식을 조례나 규칙으로 한다는 것이고 개별 조례 또는 개별 규칙에 위임·위탁 규정을 둔다고 하여 그 법적 효과에 차이가 있는 것은 아니므로 공공단체 등의 설립에 관한 조례에서 지방자치단체의 권한에 속하는 사무의 일부를 해당 공공단체 등의 업무 범위 내에서 해당 공공단체 등에 위탁하는 내용을 조례로 규정하는 것이 가능하다고 할 것입니다.

따라서 영덕문화재단에 위탁하려는 사무가 영덕군수의 권한에 속하는 지역문화에 관한 사무로서 「공유재산 및 물품관리법」(이하 "공유재산법"이라 한다) 제27조 등 사무의 위탁을 위해 준수하여야 할 별도의 규정이 없는 사무라면, 그 근거 규정을 영덕문화재단조례에 두는 것은 가능하다고 할 것입니다.

나. 질의 나에 대하여

「지방자치법」 제22조 본문에서는 "지방자치단체는 법령의 범위 안에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있다"고 규정하고 있고, 여기서 말하는 "법령의 범위 안에서"란 "법령에 위반되지 않는 범위

내에서"를 가리키므로 지방자치단체가 제정한 조례가 법령에 위반되는 경우에는 효력이 없습니다(대법원 2003. 9. 23. 선고 2003추13 판결 등 참조).

그런데 「지방자치법」 제104조제2항에서는 지방자치단체의 장은 조례나 규칙으로 정하는 바에 따라 그 권한에 속하는 사무의 일부를 공공단체 또는 그 기관에 위탁할 수 있도록 규정하면서 위탁 방법 등에 대해 별도로 규정하고 있지 않지만, 공유재산법 제27조에서는 행정재산의 효율적인 관리를 위하여 필요하다고 인정하면 지방자치단체 외의 자에게 그 재산의 관리를 위탁(이하 "관리위탁"이라 한다)할 수 있다고 하면서(제1항), 이 경우 일반 입찰을 원칙으로 하되, 계약의 목적·성질·규모 및 지역 특수성 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명하여 입찰에 부치거나 수의계약을 할 수 있다고 규정(제2항)하고 있습니다.

그리고 공유재산법 제2조의2에서는 공유재산 및 물품의 관리·처분에 관하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 이 법이 정하는 바에 따른다고 규정하고 있으나, 앞에서 살펴본 바와 같이 「지방자치법」에서는 공공단체 등과 그 외 민간에 소관 사무를 위탁할 수 있는 사무의 범위를 구분하여 공공단체 등과 그 외 민간기관에 소관 사무를 위탁할 수 있다는 일반적인 근거 규정을 두는 외에 위탁 방법 등에 대해 별도로 규정하고 있지 않고, 공유재산법에서는 '지방자치단체 외의 자에게 행정재산을 관리위탁 하는' 모든 경우를 적용 대상으로 하고 있으므로 「지방자치법」 제104조제2항을 공유재산법의 적용을 배제할 수 있는 '특별한 규정'에 해당한다고 보기는 어려울 것입니다[법제처 2018. 10. 10. 의견제시 18-0226 참조. 해당 안건은 지방자치단체장이 공공단체 등 외에 민간에 업무를 위탁할 수 있도록 규정하고 있는 「지방자치법」 제104조제3항과 공유재산법과의 관계에 대해 검토한 사항이나, 지방자치단체장의 사무 위탁 시 통제나 관리·감독의 범위를 공공위탁과 그 외 민간위탁을 반드시 구분하여야 하는 것은 아니라고 할 것이므로(법제처 2020. 11. 12. 의견제시 20-0228 참조) 공공단체 등에 지방자치단체장의 사무를 위탁하는 경우도 동일하게 볼 수 있을 것임].

따라서 영덕군수가 영덕문화재단에 소관 사무를 위탁하는 경우에도 공유재산법의 규정이 적용된다고 보아야 할 것인데, 영덕군수가 관리하는 특정 행정재산의 관리에 관한 사무를 영덕문화재단에 위탁하는 내용을 영덕문화재단조례에 규정하게 되면 해당 행정재산에 대한 관리위탁은 수의계약의 방법으로 이루어지게 될 것이므로 특정 행정재산의 관리위탁에 관한 사무를 영덕문화재단에 위탁하는 내용을 조례로 규정하기 위해서는 그 내용이 공유재산법 제27조제2항에 따른 수의계약 대상에 해당하여야 할 것입니다.

이와 관련하여 공유재산법 제27조제2항의 위임에 따른 「공유재산 및 물품관리법 시행령」(이하 "공유

재산법 시행령"이라 한다) 제19조의5에서는 수의계약으로 행정재산을 관리위탁할 수 있는 경우를 다른 법령에 따라 지방자치단체의 사무 또는 사업을 위탁 또는 대행할 수 있는 자에게 관리위탁을 하는 경우(제1호), 특별한 기술과 능력이 필요하여 일반입찰에 부치기 곤란한 경우로서 행정안전부장관이 그 내용 및 범위를 정한 경우(제2호), 2회에 걸쳐 유효한 일반입찰이 성립되지 아니한 경우(제3호)로 한정하여 규정하고 있습니다.

그런데 영덕문화재단의 설치 근거가 되는 「지역문화진흥법」을 살펴보면 지역문화재단에 국가나 지방자치단체의 사무 또는 사업을 위탁 또는 대행할 수 있도록 하는 내용에 대해 규정하고 있지 않는 바, 개별 법령에 따라 영덕문화재단에 관리위탁할 수 있는 대상에 해당하는지 여부나 그 밖에 공유재산법 시행령 제19조의5제1항제2호 및 제3호 대상에 해당하는지에 대한 판단 없이 영덕군수가 관리하는 특정 행정재산을 영덕문화재단에 관리위탁하도록 일률적으로 조례에 규정하는 것은 공유재산법 등 상위 법령에 위반되는 것으로 보이므로 이러한 의견을 자치법규 입안 시 참고하시기 바랍니다.

사례 12

수의계약 대상에 해당하는 것으로 보기 어렵다고 본 사례

(「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제19조의5제1항제1호 관련)

2024. 8. 19. 의견제시 24-0179

질의요지

「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제19조의5제1항제1호(이 사안이 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제19조의5제1항제2호 및 제3호에 해당하지 않는 것을 전제함)에 따라 구로구의 행정재산인 공공형 실내놀이터의 관리를 특정 법인·단체 또는 그 기관이나 개인에게 수의계약으로 위탁할 수 있도록 하는 내용을 조례에 규정할 수 있는지?

의 견

아래 이유를 참고하시기 바랍니다.

이 유

「공유재산 및 물품 관리법」(이하 "공유재산법"이라 한다) 제2조의2에서는 공유재산[공유재산이란 지방자치단체의 부담, 기부채납(寄附採納)이나 법령에 따라 지방자치단체 소유로 된 공유재산법 제4조제1항 각 호의 재산을 말하는데(공유재산법 제2조제1호), 크게 행정재산과 일반재산으로 구분됨(공유재산법 제5조)] 및 물품의 관리·처분에 관해서는 다른 법률에 특별한 규정이 없으면 이 법에서 정하는 바에 따른다고 규정하고 있고, 같은 법에서 행정재산 관리위탁의 계약방법 등에 대해 세부적인 사항을 규정하고 있는바, 이 사안의 공공형 실내놀이터 관리위탁에 관한 사항의 경우 다른 법률에 특별한 규정이 없다면 공유재산법에서 정하는 바에 따라야 할 것입니다(법제처 2017. 8. 2. 의견제시 17-0185 참조).

이와 관련하여, 공유재산법 제27조제2항 본문에서는 행정재산을 관리위탁하는 경우에는 일반입찰로 해야 한다고 규정하면서, 같은 항 단서에서는 예외적으로 대통령령으로 정하는 바에 따라 참가자의

자격을 제한하거나 참가자를 지명하여 입찰에 부치거나 수의계약으로 할 수 있다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」(이하 "공유재산법시행령"이라 한다) 제19조의5 제1항에서는 수의계약으로 행정재산을 관리위탁할 수 있는 사유를 '다른 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체의 사무 또는 사업을 위탁 또는 대행할 수 있는 자에게 관리위탁을 하는 경우'(제1호) 등으로 규정하고 있는바, 이 사안에서는 질의요지와 같은 내용이 공유재산법시행령 제19조의5제1항제1호의 수의계약 사유에 해당하는지가 문제됩니다.

그런데, 공유재산법 제27조제2항 단서는 행정재산에 관한 관리위탁 계약의 공정성을 확보하기 위하여 마련된 규정으로서(2014. 2. 19. 의안번호 1908036으로 제안된 공유재산 및 물품 관리법 일부개정법률안에 대한 국회 안전행정위원회 검토보고서 참조), 일반입찰 원칙에 대한 예외로서의 수의계약은 그 계약상대자 외의 자에 대해서 직업수행의 자유를 제한하는 것이므로(헌법재판소 2023. 10. 26. 선고 2019헌마871 전원재판부 결정례 참조), 수의계약 사유를 정하고 있는 공유재산법시행령 제19조의5제1항제1호에 따른 '다른 법령'의 범위도 엄격하게 한정적으로 해석되어야 합니다.

살피건대, 「지방자치법」 제161조에서는 지방자치단체가 주민의 복지를 증진하기 위하여 공공시설을 설치할 수 있고(제1항), 공공시설의 설치와 관리에 관하여 다른 법령에 규정이 없으면 조례로 정한다고 규정(제2항)하고 있으나, 이러한 규정을 공유재산법 제27조제2항 단서에 대한 특별한 규정으로서 수의계약에 의한 관리위탁의 근거 규정으로 보기는 어려운 점이 있고, 여타 법령에서도 공공형 실내 놀이터 관리위탁 등에 관한 사항을 달리 규율하고 있는 사례를 찾기 어렵다는 점과, 공유재산법시행령 제19조의5제1항제1호의 '법령'에는 지방자치단체가 '법령'의 범위에서 그 사무에 관하여 제정하고, 지방자치단체의 의회를 통해 의결하는 자치법규인 '조례'는 포함되지 않는 것으로 보이는 점(법제처 2024. 4. 4. 회신 24-0018 해석례 참조) 등을 종합적으로 고려할 때, 질의요지와 같은 내용을 조례에 규정한다 하더라도 공유재산법시행령 제19조의5제1항제1호의 수의계약 사유에 해당하는 것으로 보기는 어려울 것으로 보입니다(법제처 2022. 6. 28. 의견제시 22-0184, 2022. 10. 19. 의견제시 22-0264 참조).

따라서, 구로구의 행정재산인 공공형 실내놀이터의 관리를 특정 법인·단체 또는 그 기관이나 개인에게 수의계약으로 위탁할 수 있도록 하는 내용을 조례에 규정하는 것은 상위법령에 위배될 소지가 있으므로, 자치법규 입안 시 신중하시기 바랍니다.

사례 13

수의계약 대상에 일부 해당한다고 본 사례

(질의 나, 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제19조의5제1항제2호 관련)

2022. 6. 28. 의견제시 22-0143

질의요지

가. 행정재산의 관리를 위탁하려면 조례에 별도의 규정이 없더라도 「공유재산 및 물품 관리법」 제27조에 따라 가능한지 혹은 「지방자치법」 제117조제3항에 따라 조례에 별도의 규정이 있어야 하는지?

나. "도시재생활성화지역의 주민협의체, 해당지역 마을회, 그 밖에 군수가 시설물의 효율적인 관리운영을 위해 필요하다고 인정하는 법인·단체 또는 그 기관이나 개인 중 어느 하나에 해당하는 자"에게 주민공동이용시설인 행정재산의 관리를 수의계약으로 위탁할 수 있도록 조례에 규정할 수 있는지?

다. 주민공동이용시설인 행정재산의 관리를 위탁하는 경우 「산청군 사무의 민간위탁에 관한 조례」 제5조에 따라 의회의 동의를 받아야 하는지?

의 견

가. 질의 가에 대하여

아래 이유를 참고하시기 바랍니다.

나. 질의 나에 대하여

이 사안의 경우 질의요지와 같은 내용을 조례에 규정하는 것은 「공유재산 및 물품 관리법」 제27조제2항 및 같은 법 시행령 제19조의5제1항에 위반될 소지가 있다고 할 것입니다.

다. 질의 다에 대하여

이 사안의 경우 산청군수가 주민공동이용시설인 행정재산의 관리를 위탁하는 경우 「산청군 사무의 민간위탁에 관한 조례」 제5조제1항에 따라 산청군의회의 동의를 받아야 할 것으로 보입니다.

이 유

가. 질의 가에 대하여

「공유재산 및 물품 관리법」(이하 "공유재산법"이라 한다) 제27조제1항에서는 지방자치단체의 장은 행정재산의 효율적인 관리를 위하여 필요하다고 인정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 지방자치단체 외의 자에게 그 재산의 관리를 위탁할 수 있다고 규정하고 있고, 「지방자치법」 제117조제3항에서는 지방자치단체의 장은 조례나 규칙으로 정하는 바에 따라 그 권한에 속하는 사무 중 조사·검사·검정·관리업무 등 주민의 권리·의무와 직접 관련되지 아니하는 사무를 법인·단체 또는 그 기관이나 개인에게 위탁할 수 있다고 규정하고 있는바, 이 사안은 행정재산의 관리를 위탁하는 경우 공유재산법 제27조제1항과 「지방자치법」 제117조제3항 중 어느 규정을 적용해야 하는지에 대한 질의로 보입니다.

「지방자치법」 제13조제2항제1호자목에서는 공유재산 관리를 지방자치단체의 사무로 예시하고 있고, 공유재산법 제5조제1항에서는 공유재산은 그 용도에 따라 행정재산과 일반재산으로 구분한다고 규정하고 있으므로, 행정재산의 관리위탁은 그 성질상 지방자치단체 사무의 민간위탁에 해당한다고 볼 수 있습니다.

그런데 공유재산법은 구 「지방재정법」 및 구 「지방자치법」 등에서 분산 규정된 내용을 통합 규정함으로써 공유재산 및 물품의 체계적이고 효율적인 관리를 위해 제정된 법률로서 공유재산법령에 따른 행정재산의 관리위탁 제도는 행정재산의 효율적인 관리를 위해 별도로 규율된 제도이고, 「지방자치법」 제117조제3항은 지방자치단체 사무의 민간위탁에 관한 일반적인 사항을 규율하는 일반규정임을 고려하면, 행정재산의 관리위탁에 관해 공유재산법령에서 명시적으로 규정하고 있는 내용에 관해서는 원칙적으로 공유재산법령을 우선 적용해야 할 것입니다.

따라서 산청군에서는 공유재산법 제27조 및 그 위임에 따른 같은 법 시행령 제19조, 제19조의2에서 제19조의5까지, 제20조에서 제22조까지의 규정을 근거로 행정재산의 관리를 위탁할 수 있을 것이고, 관리위탁의 갱신, 수탁재산의 위탁료 등과 관련하여 같은 법 시행령에서 조례 등으로 정하도록 위임한 사항에 대해서는 조례 등으로 정하여 행정재산의 관리를 위탁하면 될 것입니다.

나. 질의 나에 대하여

공유재산법 제27조제2항 본문에서는 지방자치단체의 장은 행정재산을 관리위탁하는 경우에는 일반입

찰로 하여야 한다고 규정하면서, 같은 항 단서에서는 계약의 목적·성질·규모 및 지역 특수성 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명하여 입찰에 부치거나 수의계약을 할 수 있다고 규정하고 있고, 그 위임에 따른 같은 법 시행령 제19조의5제1항에서는 수의계약으로 행정재산을 관리위탁할 수 있는 경우를 각 호로 열거하고 있는바, 해당 규정은 행정재산을 관리위탁하는 경우 일반입찰 원칙에 대한 예외 사유에 해당하므로 문언에 충실하게 해석·적용해야 합니다.

이 사안과 관련하여 공유재산법 시행령 제19조의5제1항에서는 수의계약으로 행정재산을 관리위탁할 수 있는 경우 중 하나로 "관리위탁의 업무 성질상 시설과 장비, 기술 보유 정도, 책임능력 등 특별한 기술과 능력이 필요하여 일반입찰에 부치기 곤란한 경우로서 행정안전부장관이 그 내용 및 범위를 정한 경우"(제2호)를 규정하고 있고, 그 위임에 따른 「지방자치단체 공유재산 운영기준」 별표 4에서는 행정안전부장관이 정하도록 한 수의계약에 의할 수 있는 경우 중 하나로 "마을 공동이용시설 등의 관리·운영을 위해 해당지역 마을회 등 마을공동체에 위탁하고자 하는 경우"를 규정하고 있습니다.

살피건대, 귀 군에서 "도시재생활성화지역의 주민협의체"와 "해당지역 마을회"가 「지방자치단체 공유재산 운영기준」에 따른 "마을공동체"에 해당한다고 판단하였다면 해당 내용을 조례에 규정하는 것은 가능할 것으로 보입니다. 그러나 "그 밖에 군수가 시설물의 효율적인 관리운영을 위하여 필요하다고 인정하는 법인·단체 또는 그 기관이나 개인"은 수의계약의 상대방을 과도하게 넓히는 것으로서 이를 조례에 규정하는 것은 공유재산법 제27조제2항 및 같은 법 시행령 제19조의5제1항에 위반될 소지가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우 질의요지와 같은 내용을 조례에 규정하는 것은 공유재산법 제27조제2항 및 같은 법 시행령 제19조의5제1항에 위반될 소지가 있다고 할 것입니다.

다. 질의 다에 대하여

이 사안에서는 행정재산의 관리를 위탁하는 경우 공유재산법령에 규정되어 있지 않은 사항인 지방의회의 동의가 필요한지에 관하여 「지방자치법」 및 그 위임에 따른 조례의 규정이 적용되는지가 문제됩니다.

살피건대, 질의 가에서 살펴본 바와 같이 관리위탁 행정재산의 수탁 자격 및 기간, 입찰의 성립 및 참가자격, 수탁재산의 관리 등 공유재산법령에서 명시적으로 규정하고 있는 내용에 관해서는 공유재산법

령을 우선 적용해야 할 것이지만, 행정재산의 관리위탁도 지방자치단체 사무의 민간위탁의 성질을 가지므로, 공유재산법령에서 규정하고 있지 않은 내용에 관해서는 민간위탁에 관한 일반규정인 「지방자치법」 제117조제3항이 적용된다고 봄이 타당할 것입니다.

이 사안과 관련하여 「지방자치법」 제117조제3항의 위임에 따라 산청군수의 권한에 속하는 사무 중 일부를 민간위탁하는 경우에 필요한 사항을 정하고 있는 「산청군 사무의 민간위탁에 관한 조례」(이하 "산청군조례"라 한다) 제4조에서는 군수는 법령 또는 조례로 정하는 바에 따라 그 소관사무 중 조사·검사·검정·관리업무 등 주민의 권리·의무와 직접 관계되지 아니하는 다음 각 호의 사무를 민간위탁할 수 있다고 규정하고 있습니다. 그리고 같은 조례 제5조제1항에서는 군수는 제4조 각 호의 사무에 대해 민간위탁을 하고자 하는 경우에는 산청군의회의 동의를 받아야 하고, 다만 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 의회의 동의를 받은 것으로 본다고 규정하고 있습니다.

그러므로 산청군수가 행정재산의 관리를 위탁하는 경우에도 산청군조례 제5조제1항 각 호에서 규정하고 있는 사항을 제외하고는 산청군의회의 동의를 받아야 할 것이고, 이는 지방자치단체 사무의 민간위탁에 관하여 지방의회의 사전 동의를 받도록 한 취지가 지방자치단체장의 민간위탁에 대한 일방적인 독주를 제어하여 민간위탁의 남용을 방지하고 그 효율성과 공정성을 담보하기 위한 것임에 비추어 볼 때도 타당하다고 보입니다.

결론적으로 산청군에서 주민공동이용시설인 행정재산의 관리를 위탁하는 경우 산청군조례 제5조제1항에 따라 산청군의회의 동의를 받아야 할 것으로 보입니다.











제 3 편

재정·회계·기금

1. 특별회계 간 통합·운용 등에 관한 사항을 조례에 규정할 수 있는지

「국가재정법」 제15조에서는 특별회계 상호 간에 유사하거나 중복되게 설치된 경우 등 일정한 경우에는 특별회계를 다른 특별회계와 통합할 수 있다고 규정하고 있는 반면, 「지방재정법」에서는 특별회계를 다른 특별회계와 통합할 수 있도록 하는 규정을 두고 있지 않고, 다만 같은 법 제9조의2에서는 회계 및 기금의 목적 수행에 지장을 초래하지 아니하는 범위에서 회계 및 기금의 여유재원 등을 통합적으로 활용할 수 있도록 하는 근거 규정을 두면서 그 여유재원 등의 예탁 및 예수는 「지방자치단체 기금관리기본법」 제16조에 따른 통합재정안정화기금의 통합 계정으로 운용하여야 한다고 규정하고 있는바, 「지방재정법」이 특별회계 상호 간에 통합하여 운용하는 것을 일반적으로 허용하고 있다고 보기는 어렵다고 할 것이다[6].

「국가재정법」

제15조(특별회계 및 기금의 통합·폐지) 특별회계 및 기금이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이를 폐지하거나 다른 특별회계 또는 기금과 통합할 수 있다.

1. 설치목적을 달성한 경우
2. 설치목적의 달성이 불가능하다고 판단되는 경우
3. 특별회계와 기금 간 또는 특별회계 및 기금 상호 간에 유사하거나 중복되게 설치된 경우
4. 그 밖에 재정운용의 효율성 및 투명성을 높이기 위하여 일반회계에서 통합 운용하는 것이 바람직하다고 판단되는 경우

「지방재정법」

제9조의2(회계·기금 간 여유재원의 예수·예탁) ① 지방자치단체의 장은 재정의 효율적 운용을 위하여 필요한 경우에는 다른 법률 또는 조례에도 불구하고 회계 및 기금의 목적 수행에 지장을 초래하지 아니하는 범위에서 회계와 기금 간, 회계 상호 간 그리고 기금 상호 간에 여유재원 또는 기금 예치금을 예탁하거나 예수하여 통합적으로 활용할 수 있다. 이 경우 그 내용을 예산 또는 기금운용계획에 반영하여야 한다.

② 제1항에 따른 여유재원의 예탁 및 예수와 기금 예치금의 예탁 및 예수는 「지방자치단체 기금관리기본법」 제16조에 따른 통합재정안정화기금의 통합 계정으로 운용하여야 한다.

6) 법제처 2023. 4. 3. 의견제시 23-0077 참조

사례 14 특별회계 간 통합·운용을 규정할 수 없다고 본 사례

2023. 4. 3. 의견제시 23-0077

질의요지

순천시 지하수관리특별회계를 순천시 하수도사업특별회계와 통합하여 운용하도록 조례로 규정할 수 있는지?

의 견

아래 이유를 참고하시기 바랍니다.

이 유

「지방재정법」 제9조에서는 지방자치단체의 회계를 일반회계와 특별회계로 구분하면서(제1항), 「지방공기업법」에 따른 지방직영기업이나 그 밖의 특정사업을 운영할 때 또는 특정자금이나 특정세입· 세출로서 일반세입·세출과 구분하여 회계처리할 필요가 있을 때에만 법률 또는 조례로 특별회계를 설치할 수 있도록 규정(제2항 본문)하고 있는데, 이는 지방자치단체의 특별한 필요에 따라 일반회계와 구분하여 특정한 세입으로 특정한 세출에 충당하는 별도의 회계를 설치할 수 있도록 규정한 것으로서, 지방자치단체의 특별회계는 원칙적으로 일반회계 또는 다른 특별회계와 구분하여 운용되어야 할 것입니다.

또한 「국가재정법」 제15조에서는 특별회계 상호 간에 유사하거나 중복되게 설치된 경우 등 일정한 경우에는 특별회계를 다른 특별회계와 통합할 수 있다고 규정하고 있는 반면, 「지방재정법」에서는 특별회계를 다른 특별회계와 통합할 수 있도록 하는 규정을 두고 있지 않고, 다만 같은 법 제9조의2에서는 회계 및 기금의 목적 수행에 지장을 초래하지 아니하는 범위에서 회계 및 기금의 여유재원 등을 통합적으로 활용할 수 있도록 하는 근거 규정을 두면서 그 여유재원 등의 예탁 및 예수는 「지방자치단체 기금관리기본법」 제16조에 따른 통합재정안정화기금의 통합 계정으로 운용하여야 한다고 규정하고 있는바, 「지

방재정법」이 특별회계 상호 간에 통합하여 운용하는 것을 일반적으로 허용하고 있다고 보기는 어렵습니다.

한편 「지방공기업법」 제13조 본문에서는 하수도사업을 포함하여 제2조에 해당하는 사업마다 특별회계를 설치하여야 한다고 규정하면서, 같은 조 단서에서 성질이 같거나 유사한 둘 이상의 사업에 대하여 관리자를 1명만 두는 경우에는 둘 이상의 사업에 대하여 하나의 특별회계를 둘 수 있다고 규정하고 있는바, 이는 하수도사업을 포함한 「지방공기업법」 제2조제1항 각 호의 사업마다 특별회계를 설치하도록 하되, 예외적으로 성질이 같거나 유사한 같은 항 각 호의 사업 간에만 해당 둘 이상의 사업에 대하여 하나의 특별회계를 설치할 수 있도록 한정적으로 허용하고 있는 것으로 보입니다.

그렇다면 「지하수법」 제30조의2제1항에 따라 지하수의 적정한 개발·이용과 보전·관리에 필요한 사업비 등을 조달하기 위하여 설치하는 지하수관리특별회계는 「지방공기업법」 제2조제1항 각 호의 사업에 설치하는 특별회계에 포함되지 않으므로 지하수관리특별회계를 하수도사업특별회계에 통합하여 운영하는 것은 지방공기업법의 취지에 부합하지 않는 것으로 보입니다.

이상과 같은 점을 종합해보면 「지방재정법」, 「지방공기업법」 등 상위법령에 특별회계 상호 간에 통합하여 운영할 수 있도록 하는 별도의 규정이 없는 상태에서, 순천시 지하수관리특별회계를 순천시 하수도사업특별회계와 통합하여 운영하도록 조례로 규정하는 것은 상위법령의 취지에 반할 소지가 있어 바람직하지 않으므로 자치법규 입안에 신중을 기하시기 바랍니다.

사례 15 특별회계 간 통합·운용을 규정할 수 없다고 본 사례

2020. 4. 14. 의견제시 20-0077

질의요지

「지방세기본법」 제7조제3항제1호 및 「지방세법」(2019. 12. 31. 법률 제16854호로 일부개정되어 2021. 1. 1. 시행 예정인 「지방세법」을 말하며, 이하 같음) 제141조에 따른 대전광역시의 지역자원시설세 중 특정자원분 지역자원시설세 및 특정시설분 지역자원시설세에 따른 세입·세출에 대하여 별도의 특별회계를 설치·운용하지 않고, 해당 세입·세출을 「지방공기업법」 제13조 및 「대전광역시 하수도사업 조례」 제7조에 따라 설치된 대전광역시 하수도사업특별회계의 세입·세출에 포함시켜 운용하도록 하는 내용을 대전광역시 조례(2021. 1. 1. 시행 예정인 「지방세법」(법률 제16854호)의 시행에 맞추어 대전광역시 조례 역시 2021. 1. 1. 시행되도록 입안하는 것을 전제로 함)에 규정할 수 있는지?

의 견

이 사안의 경우 질의요지와 같은 내용을 조례에 규정할 수 없을 것으로 보입니다.

이 유

「지방자치법」 제22조 본문에서는 지방자치단체는 법령의 범위 안에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있다고 규정하고 있으므로, 지방자치단체가 제정한 조례가 법령에 위반되는 경우에는 효력이 없습니다(대법원 2003. 9. 23. 선고 2003추13 판결 등 참조).

「지방재정법」 제9조에서는 지방자치단체의 회계를 일반회계와 특별회계로 구분하면서(제1항), 특별회계는 「지방공기업법」에 따른 지방직영기업이나 그 밖의 특정사업을 운영할 때 또는 특정자금이나 특정세입·세출로서 일반세입·세출과 구분하여 회계처리할 필요가 있을 때에만 법률 또는 조례로 특별회계를 설치할 수 있도록 하되(제2항 본문) 목적세에 따른 세입·세출은 다른 법률에 특별한 규정이 있는

경우를 제외하고는 특별회계를 설치·운용하도록 의무를 부과하고 있습니다(제2항 단서).

그런데 「지방세기본법」 제7조제3항제1호에서는 지역자원시설세를 목적세로 규정하고 있고 같은 법 및 「지방세법」에서 지역자원시설세에 대한 특별회계와 관련하여 별도의 규정을 두고 있지 않는바, 지역자원시설세에 따른 세입·세출에 대해서는 「지방재정법」에 따라 특별회계를 설치하여 운용하여야 할 것입니다.

그리고 「지방재정법」에서는 「국가재정법」과 같이 재정의 효율적 운용을 위하여 필요한 경우 다른 법률의 규정에 불구하고 회계의 목적 수행에 지장을 초래하지 아니하는 범위 안에서 회계 상호 간에 여유재원을 전입 또는 전출하여 통합적으로 활용할 수 있도록 한다거나(「국가재정법」 제13조제1항 참조) 일정한 경우 특별회계를 다른 특별회계와 통합할 수 있도록 하는 규정(「국가재정법」 제15조 참조)을 두고 있지 않은바, 위와 같은 「지방재정법」의 태도 및 목적세에 따른 세입·세출에 대하여 특별회계를 "설치"하여 "운용"하도록 한 같은 법 제9조제2항 단서의 문언에 비추어 보면, 지역자원시설세에 따른 세입·세출을 해당 지역자원시설세에 대한 특별회계가 아니라 다른 특별회계에 포함시켜 운용할 수 없다고 할 것입니다.

나아가 하수도사업특별회계는 지방공기업에 특별회계에 의한 독립채산제를 채택하기 위하여 도입된 규정인 「지방공기업법」 제13조(1969. 1. 29. 법률 제2101호로 제정되어 1969. 7. 30. 시행된 「지방공기업법」 제정이유 제3항 참조)에 따라 지방자치단체의 하수도사업(「지방공기업법」 제2조제1항제6호 참조)에 충당할 목적으로 설치된 특별회계인데, 특정자원분 지역자원시설세 및 특정시설분 지역자원시설세(이하 "특정자원분 지역자원시설세등"라 함)는 「지방세법」에 근거하여 주민생활환경 개선사업 및 지역개발사업에 필요한 재원을 확보하기 위하여 부과하는 조세(「지방세법」 제142조제1항 참조)이어서 하수도사업특별회계와 근거법령이 다르고, 사업을 수행하는 지방직영기업의 경비를 원칙적으로 해당 직영기업의 수입으로 충당하도록 한 지방직영기업의 특별회계(「지방공기업법」 제14조제1항 참조)와 자금의 조성방법이 다르며, 조성된 재원의 지출목적 등도 같지 아니한바, 특정자원분 지역자원시설세등에 따른 세입·세출을 하수도사업특별회계에 포함시켜 운용하는 것은 「지방공기업법」 제13조의 입법취지에도 부합하지 않습니다.

이상과 같은 점을 종합해보면 대전광역시의 특정자원분 지역자원시설세등에 따른 세입·세출에 대하여 별도의 특별회계를 설치·운용하지 않고 해당 세입·세출을 같은 시 하수도사업특별회계의 세입·세출에 포함시켜 운용하도록 조례에 규정할 수 없다고 할 것인바 자치법규 입안에 신중을 기하시기 바랍니다.

사례 16 서로 다른 특별회계를 하나의 통합조례에 규정할 수 있다고 본 사례

2012. 9. 14. 의견제시 12-0277

질의요지

서로 다른 법률에 따라 설치하는 특별회계를 하나의 조례로 통합하여 제정할 수 있는지?

의 견

「발전소주변지역 지원에 관한 법률」에 따른 발전소주변지역지원사업 특별회계와 「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률」에 따른 댐주변지역지원사업 특별회계의 설치 및 운용에 관한 규정을 통합하여 하나의 조례로 규정하는 것이 입법기술상 불가능한 것은 아니나, 조례안에서 단일조례로 규율하는 두 특별회계가 각각 별도의 회계라는 점을 명확히 할 필요는 있을 것으로 보입니다.

이 유

「지방재정법」 제9조제2항에 따르면, 지방자치단체는 특정자금이나 특정세입·세출로서 일반세입·세출과 구분하여 회계처리할 필요가 있을 경우 등에만 특별회계를 법률이나 조례로 설치할 수 있는데, 「발전소주변지역 지원에 관한 법률」 제11조, 제16조의2 등에 따르면, 발전소주변지역을 관할하는 특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장은 발전소주변지역지원사업을 실시하기 위한 지원금을 다른 예산과 구분하여 관리하여야 하고, 「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 제44조에서도 댐관리청이나 댐수탁관리자는 댐주변지역지원사업의 재원을 별도의 회계로 구분하여 관리하도록 하고 있는바, 밀양시에서는 법령에 따라 수행하는 발전소주변지역지원사업 및 댐주변지역지원사업의 세입·세출을 별도로 관리하기 위하여 조례로 특별회계를 설치·운용할 수 있을 것입니다.

그런데, 법령체계상 반드시 하나의 상위 개별 법령이나 규정 대상에 대하여 그에 상응하는 하나의

개별 조례를 갖도록 규정하여야만 하는 것은 아니므로, 서로 다른 근거 법령에 따라 설치하는 두 특별회계를 각각의 조례로 규정하는 대신 하나의 조례에서 함께 규율하는 것이 금지되는 것은 아닙니다. 즉, 법령에서 위임한 형식이나 내용에 위배되지 않는 한, 발전소주변지역지원사업 특별회계와 댐주변지역지원사업 특별회계의 설치근거를 하나의 조례에 병렬적으로 규정하는 형식을 택하는 것이 입법기술상 불가능한 것은 아닙니다.

다만, 각각의 지원사업 특별회계를 단일조례로 규정할지 복수조례로 둘 것인지 여부 등 조례 제정의 형식을 어떻게 하는 것이 더 '바람직'한 것인지에 관해서는 조례 이용의 편의성, 법령과의 체계, 대상 제도의 상호연계성, 입법경제성 등 여러 가지 사정을 고려하여 판단하여야 할 것입니다(법제처 2011. 7. 7. 의견제시 11-0124 참조).

참고로, 귀 청에서 제출한 「밀양시 댐·발전소 주변지역지원사업 특별회계 설치 및 운용 조례안」의 제명이나 내용을 살펴보면, 질의요지와 같이 단순히 두 특별회계를 하나의 조례에 통합하여 각각 규정하는 것이 아니라, '댐·발전소주변지역지원사업 특별회계'라는 하나의 회계로 두 특별회계를 실질적으로 통합하는 것으로 오인할 소지가 있는바, 조례안의 내용을 일부 수정하여, 각 개별 법률에서 '별도의 회계로 구분하여 관리하도록' 규정하는 등 서로 다른 목적과 근거, 재원으로 설치되는 두 특별회계가 실제로 통합되는 것은 아님을 명확히하는 것이 바람직할 것입니다.

결론적으로, 「발전소주변지역 지원에 관한 법률」에 따른 발전소주변지역지원사업 특별회계와 「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률」에 따른 댐주변지역지원사업 특별회계의 설치 및 운용에 관한 규정을 통합하여 하나의 조례로 규정하는 것이 입법기술상 불가능한 것은 아니나, 조례안에서 단일조례로 규율하는 두 특별회계가 각각 별도의 회계라는 점을 명확히 할 필요는 있을 것으로 보입니다.

2. 특별회계의 존속기한을 조례에 규정해야 하는지

「지방재정법」 제9조제3항에서는 지방자치단체가 특별회계를 설치하려면 5년 이내의 범위에서 특별회계의 존속기한을 해당 조례에 명시하도록 하되, 법률에 따라 의무적으로 설치·운영되는 특별회계는 예외로 하고 있다. 따라서 특별회계를 설치하는 경우 존속기한을 두어야 하는지를 검토해야 하며, 존속기한을 두는 경우에는 존속기한 만료로 해당 규정이 실효되는 경우를 대비하여 해당 특별회계 소속 재산 및 채권·채무의 승계 등 그 처리에 관한 경과규정을 두는 것이 법률관계의 안정과 명확화를 위해 필요하다[7].

「지방재정법」

제9조(회계의 구분) ① 지방자치단체의 회계는 일반회계와 특별회계로 구분한다.

② 특별회계는 「지방공기업법」에 따른 지방직영기업이나 그 밖의 특정사업을 운영할 때 또는 특정자금이나 특정세입·세출로서 일반세입·세출과 구분하여 회계처리할 필요가 있을 때에만 법률이나 조례로 설치할 수 있다. 다만, 목적세에 따른 세입·세출은 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 특별회계를 설치·운용하여야 한다.

③ 지방자치단체가 특별회계를 설치하려면 5년 이내의 범위에서 특별회계의 존속기한을 해당 조례에 명시하여야 한다. 다만, 법률에 따라 의무적으로 설치·운용되는 특별회계는 그러하지 아니하다.

④ (생 략)

7) 『자치법규 입안 길라잡이(2022)』 177쪽 참조

사례 17

존속기한을 규정해야 한다고 본 사례

2018. 5. 25. 의견제시 18-0104

질의요지

남양주시 의료급여사업 특별회계를 「지방재정법」 제9조제3항의 "법률에 따라 의무적으로 설치· 운용되는 특별회계"로 보아 「남양주시 의료급여사업 특별회계 설치 및 운영 조례」에 존속기한을 명시하지 않아도 되는지?

의 견

남양주시 의료급여사업 특별회계는 「지방재정법」 제9조제3항의 "법률에 따라 의무적으로 설치· 운용되는 특별회계"에 해당하지 않는 것으로 보이므로 「남양주시 의료급여사업 특별회계 설치 및 운영 조례」에 남양주시 의료급여사업 특별회계의 존속기한을 명시하여야 할 것입니다.

이 유

「남양주시 의료급여사업 특별회계 설치 및 운용 조례」(이하 "남양주시조례"라고 함) 제1조에서는 「의료급여법」 제3조에 의한 수급권자에 대한 의료급여 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 남양주시 의료급여사업 특별회계(이하 "남양주시특별회계"라 함)를 설치하고 그 운용에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다고 규정하고 있고, 「지방재정법」 제9조제3항 본문에서는 지방자치단체가 특별회계를 설치하려면 5년 이내의 범위에서 특별회계의 존속기한을 해당 조례에 명시하여야 한다고 규정하는 한편, 같은 항 단서에서는 "법률에 따라 의무적으로 설치·운용되는 특별회계는 그러하지 아니하다"고 규정하고 있습니다.

한편 「의료급여법」 제25조제1항에서는 같은 법에 따른 급여비용의 재원에 충당하기 위하여 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도(이하 "시·도"라 함)에 의료급여기금을 설치한다고 규정하고 있고,

같은 법 제26조제1항부터 제3항까지에서는 기금의 관리와 운용에 관한 사항을 규정하면서, 같은 조 제4항에서는 「의료급여법」에서 정한 사항 외에 기금의 관리·운용에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 해당 지방자치단체의 조례로 정하도록 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 같은 법 시행규칙 제28조제1항에서는 시장·군수·구청장은 의료급여사업에 충당하기 위하여 기금의 교부를 신청하고자 하는 때에는 시·도지사에게 신청하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항에서는 "시장·군수·구청장은 시·도지사로부터 교부받은 기금에 대하여는 일반회계와 구분하여 별도의 계정(이하 "기금계정"이라 한다)을 설정·운용하여야 한다"고 규정하고 있으며, 같은 조 제9항에서는 의료급여기금의 관리·운용에 관하여 「의료급여법」과 같은 법 시행령 및 시행규칙에서 정한 것 외에 필요한 사항은 지방자치단체의 조례로 정한다고 규정하고 있습니다.

이 사안은 남양주시특별회계를 「지방재정법」 제9조제3항 단서의 "법률에 따라 의무적으로 설치·운용되는 특별회계"에 해당하는 것으로 보아 남양주시조례에 남양주시특별회계의 존속기한을 명시하지 않아도 되는지에 대한 질의로 보입니다.

살피건대, 「의료급여법」 제25조제1항에서는 「의료급여법」에 따른 급여비용의 재원에 충당하기 위하여 시·도에 의료급여기금을 설치한다고 규정함으로써, 특별회계가 아닌 의료급여기금의 설치근거만을 두고 있을 뿐만 아니라 기금을 의무적으로 설치하여야 하는 주체 역시 시·도에 한정하고 있습니다. 또한 같은 법 제26조제3항에서는 특별회계가 아닌 기금의 관리·운용 주체를 특별시장· 광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라고 함)로만 한정하여 규정하고 있고, 같은 조 제4항에서는 「의료급여법」에서 정한 사항 외에 기금의 관리·운용에 관하여 필요한 사항을 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 해당 지방자치단체의 조례로 정한다고 규정하고 있을 뿐, 그 외 「의료급여법」에서 의료급여비용 혹은 의료급여사업과 관련하여 특별회계를 의무적으로 두도록 하고 있는 별도의 규정은 없습니다.

그리고 「의료급여법 시행규칙」 제28조제3항에서는 "시장·군수·구청장은 시·도지사로부터 교부받은 기금에 대하여는 일반회계와 구분하여 별도의 계정(이하 "기금계정"이라 한다)을 설정· 운용하여야 한다"고 규정하고 있을 뿐 특별회계를 의무적으로 두도록 규정하고 있지 않습니다. 그 외 「의료급여법 시행규칙」 에도 의료급여비용 혹은 의료급여사업과 관련하여 특별회계를 의무적으로 두도록 하고 있는 별도의 규정은 없습니다.

아울러 「의료급여법 시행규칙」 제28조제3항에서는 시장·군수·구청장은 "시·도지사로부터 교부받은

기금"에 대하여 일반회계와 구분하여 별도의 계정(기금계정)을 설정·운용하여야 한다고 규정하고 있는데, 남양주시조례 제2조에서는 남양주시특별회계의 세입은 "국·도비 보조금·일반회계 전입금 및 기타 수입"으로 한다고 규정하고 있으므로, 남양주시특별회계의 세입은 시·도지사로부터 받는 기금 교부금 외에도 국고 보조금 및 일반회계 전입금 등이 포함되는 것으로 보이는바, 남양주시특별회계는 의료급여법령에 따라 의무적으로 설치된 특별회계라고 보기 어렵습니다. 또한 시·도의 기금으로부터 교부받은 금액을 일반회계와 구별되는 별도의 계정으로 설정·운영함이 요구되더라도 반드시 특별회계 형식으로 하여야 하는 것은 아닐 것이므로, 입법취지상 판단을 하더라도 존속기한의 예외를 두어야 하는 경우에 해당하지 않는다고 할 것입니다.

따라서 남양주시특별회계는「지방재정법」제9조제3항의 "법률에 따라 의무적으로 설치·운용되는 특별회계"에 해당하지 않는 것으로 보이므로 남양주시조례에 남양주시특별회계의 존속기한을 명시하여야 할 것입니다.

사례 18

존속기한을 규정하지 않아도 된다고 본 사례
(질의 다)

2018. 9. 10. 의견제시 18-0184

질의요지

가. 「기반시설부담금에 관한 법률」이 2008. 3. 28. 법률 제9051호로 폐지된 경우, 「기반시설부담금에 관한 법률」에 따라 제정된 「진주시 기반시설특별회계 설치 및 운영 조례」의 효력이 상실하는지?

나. 폐기되기 전의 「기반시설부담금에 관한 법률」과 「진주시 기반시설특별회계 설치 및 운영 조례」에 따라 설치된 진주시 특별회계에 따른 결산상 잉여금을 진주시 일반회계로 전출시킬 수 있는지?

다. 진주시특별회계를 「지방재정법」 제9조제3항 단서의 "법률에 따라 의무적으로 설치·운용되는 특별회계"에 해당하는 것으로 보아 「진주시 기반시설특별회계 설치 및 운영 조례」에 존속기한을 명시하지 않아도 되는지?

의 견

가. 질의 가에 대하여

「기반시설부담금에 관한 법률」이 2008. 3. 28. 법률 제9051호로 폐지된 경우, 「기반시설부담금에 관한 법률」에 따라 제정된 「진주시 기반시설특별회계 설치 및 운영 조례」의 효력이 당연히 상실하는 것은 아니라고 할 것입니다.

나. 질의 나에 대하여

폐기되기 전의 「기반시설부담금에 관한 법률」과 「진주시 기반시설특별회계 설치 및 운영 조례」에 따라 설치된 진주시 특별회계에 따른 결산상 잉여금을 진주시 일반회계로 전출시키는 것은 바람직하지 않은 것으로 보입니다.

다. 질의 다에 대하여

진주시특별회계를 「지방재정법」 제9조제3항 단서의 "법률에 따라 의무적으로 설치·운용되는 특별회계"에 해당하는 것으로 보아 「진주시 기반시설특별회계 설치 및 운영 조례」에 존속기한을 명시하지 않아도 된다고 할 것입니다.

이 유

가. 공통사항

「기반시설부담금에 관한 법률」(2008. 3. 28. 법률 제9051호로 폐지되기 전의 것, 이하 "기반시설부담금법"이라 함) 제4조제1항에서는 같은 법 제3조의 규정에 의하여 징수된 기반시설부담금은 국가에 100분의 30이, 지방자치단체에 100분의 70이 각각 귀속된다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항에서는 지방자치단체의 장은 같은 조 제1항의 규정에 의한 기반시설부담금의 지방자치단체 귀속분을 관리하기 위하여 기반시설특별회계를 설치·운영하여야 한다고 규정하고 있으며, 같은 조 제4항에서는 기반시설특별회계의 설치 및 운용·관리에 관하여 필요한 사항은 당해 지방자치단체의 조례로 정한다고 규정하고 있습니다.

한편, 「진주시 기반시설특별회계 설치 및 운영 조례」(이하 "진주시특별회계조례"라 함) 제3조에서는 진주시장은 기반시설부담금법 제4조제3항의 규정에 따라 기반시설의 설치 또는 그에 필요한 용지의 확보 등에 소요되는 재원인 기반시설부담금의 효율적인 운영 및 관리를 위하여 특별회계(이하 "진주시특별회계"라 함)를 설치한다고 규정하고 있고, 같은 조례 제5조에서는 진주시특별회계의 세출은 기반시설부담금법 제5조의 규정에 의한 기반시설의 설치 또는 그에 필요한 용지의 확보비용 등으로 한다고 규정하고 있습니다.

나. 질의 가에 대하여

이 사안에서는 기반시설부담금법이 2008. 3. 28. 법률 제9051호로 폐지된 경우, 기반시설부담금법에 따라 제정된 진주시특별회계조례의 효력이 상실하는지를 질의하는 것으로 보입니다.

일반적으로 상위법령에서 조례로 정하도록 위임한 경우에는 그 위임취지를 존중하여 위임 사항을 조례로 정하여야 하고, 상위법령의 위임에 따라 제정된 조례가 상위법령의 폐지 또는 제·개정으로 인해 그 근거가 없어지게 되면 그 때부터 조례의 효력이 상실되는 것이 원칙이라 할 것이나, 예외적으로 상위법령 부칙에서 해당 조례와 관련한 사항에 대하여 경과조치를 두는 경우라면 그 취지를 고려하여 해당 조례의 효력 유무를 판단하여야 할 것입니다(법제처 2015. 9. 30. 회신 15-0484 해석례 참조).

살피건대, 2008. 3. 28. 법률 제9051호로 폐지된 「기반시설부담금에 관한 법률」 부칙 제2조에서는 "이 법 시행 당시 종전의 「기반시설부담금에 관한 법률」에 따라 부과하였거나, 부과 또는 환급하여야

할 기반시설부담금에 관하여는 종전의 규정에 따른다"고 규정하고 있는 점에 비추어 볼 때, 2008. 3. 28. 기반시설부담금법이 폐지되었다고 하더라도 기반시설부담금법이 폐지되기 전에 부과되었거나 부과하여야 할 기반시설부담금에 관하여는 폐지된 기반시설부담금법이 여전히 적용되는 것으로 보아야 할 것이므로(2017. 5. 18. 의견제시 17-0071 참조), 기반시설부담금법 제3조 및 제4조제1항·제3항에 따라 징수된 기반시설부담금 중 100분의 70은 지방자치단체가 설치·운영하고 있는 기반시설특별회계에 귀속된다고 할 것입니다.

그렇다면 기반시설부담금법에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 정하고 진주시 기반시설특별회계의 설치 및 운영·관리에 필요한 사항을 규정함을 목적(진주시특별회계조례 제1조)으로 제정된 진주시특별회계조례는 기반시설부담금법이 폐지되기 전에 부과한 기반시설부담금과 부과해야 할 기반시설부담금 및 환급해야 할 기반시설부담금의 운용·관리를 위하여 계속 적용된다고 할 것이므로, 그 효력을 상실하지 아니한다고 할 것입니다.

따라서, 기반시설부담금법이 2008. 3. 28. 법률 제9051호로 폐지된 경우에도 기반시설부담금법에 따라 제정된 진주시특별회계조례의 효력이 당연히 상실하는 것은 아니라고 할 것입니다.

다. 질의 나에 대하여

폐지되기 전의 기반시설부담금법과 진주시특별회계조례에 따라 설치된 진주시 특별회계에 따른 결산상 잉여금을 진주시 일반회계로 전출시킬 수 있는지를 질의하는 것으로 보입니다.

살피건대, 2008. 3. 28. 법률 제9051호로 폐지된 「기반시설부담금에 관한 법률」 부칙 제2조에서는 "이 법 시행 당시 종전의 「기반시설부담금에 관한 법률」에 따라 부과하였거나, 부과 또는 환급하여야 할 기반시설부담금에 관하여는 종전의 규정에 따른다"고 규정하고 있는바, 2008. 3. 28. 기반시설부담금법이 폐지되었다고 하더라도 기반시설부담금법이 폐지되기 전에 부과되었거나 부과하여야 할 기반시설부담금에 관하여는 폐지된 기반시설부담금법이 여전히 적용되는 것으로 보아야 할 것입니다(2017. 5. 18. 의견제시 17-0072 참조).

그렇다면, 기반시설부담금법 제5조 및 같은 법 시행령 제4조제2호에 따르면 기반시설부담금법 제3조의 규정에 의하여 징수된 기반시설부담금 중 지방자치단체 귀속분은 기반시설의 설치 또는 그에 필요한 용지의 확보 그 밖에 기반시설의 설치에 관한 계획의 수립 및 집행, 기존 기반시설의 대체 및 개량,

기반시설부담금의 지방자치단체 귀속분에 대한 관리 및 운영에 필요한 비용 등을 위하여 사용하여야 한다고 규정하고 있고, 진주시특별회계조례 제6조에서는 진주시장은 징수된 기반시설부담금의 자체 귀속분에 대하여 기반시설부담금법 제5조의 규정에 의한 용도에 한하여 사용하여야 한다고 규정하고 있는바, 기반시설부담금법이 폐지되었다고 하더라도 기반시설부담금법에 따라 징수된 기반시설부담금 중 같은 법 제4조제1항에 따라 진주시에 배분되어 같은 조 제3항에 따라 설치된 진주시특별회계로 관리되고 있는 진주시특별회계의 세입금은 같은 법 제5조에 따라 기반시설의 설치 또는 그에 필요한 용지의 확보 등 진주시특별회계의 세출로만 사용되어야 하는 것이고, 이와 달리 진주시기금조례에 따른 진주시기금 등으로 전출시키는 것은 바람직하지 않은 것으로 보입니다.

나아가, 「지방자치단체 기금관리기본법」이나 「지방재정법」에서는 「국가재정법」 제13조제1항과 같이 재정의 효율적 운용을 위하여 필요한 경우에는 다른 법률의 규정에 불구하고 회계 및 기금의 목적 수행에 지장을 초래하지 아니하는 범위 안에서 회계와 기금 간 또는 회계 및 기금 상호 간에 여유재원을 전입 또는 전출하여 통합적으로 활용할 수 있다는 규정을 두고 있지 않고 있는바, 지방자치단체가 기반시설부담금법 제4조제3항 및 제4항에 따라 조례로 설치한 진주시특별회계의 결산상 잉여금을 진주시 일반회계로 전출시키는 것은 예산총계주의의 예외로서 특별회계의 설치목적 및 성격에 부합하지 않은 것으로 보입니다(법제처 2011. 12. 8. 회신 11-0661 해석례 참조).

따라서, 질의 가에서 진주시특별회계조례의 효력이 상실된 경우 폐지되기 전의 기반시설부담금법과 진주시특별회계조례에 따라 설치된 진주시 특별회계에 따른 결산상 잉여금을 진주시 일반회계로 전출시키는 것은 바람직하지 않은 것으로 보입니다.

라. 질의 다에 대하여

「지방재정법」 제9조제3항에서는 지방자치단체가 특별회계를 설치하려면 5년 이내의 범위에서 특별회계의 존속기한을 해당 조례에 명시하여야 하나, 법률에 따라 의무적으로 설치·운용되는 특별회계는 그러하지 아니한다고 규정하고 있는바, 이 사안은 진주시특별회계를 「지방재정법」 제9조제3항 단서의 "법률에 따라 의무적으로 설치·운용되는 특별회계"에 해당하는 것으로 보아 진주시특별회계조례에 진주시특별회계의 존속기한을 명시하지 않아도 되는지를 질의하는 것으로 보입니다.

법의 해석에 있어서는 법령에 사용된 문언의 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하고, 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 다른 해석방법은 제한될 수밖에 없다고 할 것인데

(대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결 참고), 이러한 해석 원리는 조례를 해석하는 경우에도 마찬가지라 할 수 있습니다.

살피건대, 2008. 3. 28. 법률 제9051호로 폐지된 「기반시설부담금에 관한 법률」 부칙 제2조에서는 "이 법 시행 당시 종전의 「기반시설부담금에 관한 법률」에 따라 부과하였거나, 부과 또는 환급하여야 할 기반시설부담금에 관하여는 종전의 규정에 따른다"고 규정하고 있는바, 법문언상 지방자치단체의 장은 기반시설부담금법 제4조에 따라 징수한 기반시설부담금을 관리·운용하기 위하여는 기반시설 특별회계를 의무적으로 설치·운용하여야 한다고 할 것이므로, 지방자치단체장이 설치·운용하는 기반시설특별회계는 「지방재정법」 제9조제3항 단서에 따른 법률에 따라 의무적으로 설치·운용되는 특별회계에 해당하므로 그 존속기한을 관련 조례에 명시할 필요가 없다고 할 것입니다.

따라서, 진주시특별회계를 「지방재정법」 제9조제3항 단서의 "법률에 따라 의무적으로 설치· 운용되는 특별회계"에 해당하는 것으로 보아 진주시특별회계조례에 진주시특별회계의 존속기한을 명시하지 않아도 된다고 할 것입니다.

3. 금고지정 기준 등에 관한 사항을 조례에 규정할 수 있는지

「지방회계법」 제38조제1항에서는 지방자치단체의 장에게 금고지정 사무에 관한 집행권을 부여하고 있고, 같은 조 제4항에서는 금고의 지정기준 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다고 규정하고 있다. 이에 따라 「지방회계법 시행령」 제48조제1항부터 제5항까지에서는 금고지정 기준 등에 관한 사항을 규정하고 있고, 같은 조 제6항에서는 그 외에 금고 지정의 세부기준 및 지정 절차 등에 관하여 필요한 사항은 행정안전부장관이 정한다고 규정하고 있으며, 이에 따른 「지방자치단체 금고지정기준」(2024. 10. 4. 행정안전부예규 제300호로 일부개정된 것을 말함) 6.[1]에서는 같은 기준의 범위에서 금고 지정을 위한 세부적인 사항은 자치단체의 조례 또는 규칙으로 정한다고 규정하고 있다. 이상의 지방회계법령을 종합해보면, 지방자치단체의 장은 「지방자치단체 금고지정기준」의 범위 내에서 금고지정에 관한 사항을 조례 또는 규칙으로 정할 수 있을 것이다[8].

「지방회계법」

제38조(금고의 설치) ① 지방자치단체의 장은 소관 현금과 그가 소유하거나 보관하는 유가증권의 출납, 보관 및 그 밖의 금고 업무를 취급하게 하기 위하여 「은행법」에 따른 은행을 금고로 지정하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금융기관이 대통령령으로 정하는 안정성 기준을 충족할 경우에는 특별회계 및 기금 업무만을 취급하는 금고로 지정할 수 있다.

1. 「농업협동조합법」 제2조제1호에 따른 조합 중 신용사업을 하는 조합
2. 「수산업협동조합법」 제2조제4호에 따른 조합 중 신용사업을 하는 조합
3. 「산림조합법」 제2조제1호에 따른 조합 중 신용사업을 하는 조합
4. 「새마을금고법」 제2조제1항에 따른 새마을금고
5. 「신용협동조합법」 제2조제1호에 따른 신용협동조합

②·③ (생 략)

④ 금고의 지정기준 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

8) 법제처 2020. 1. 14. 의견제시 20-0003 참조

「지방회계법 시행령」

제48조(금고 업무의 약정) ① 법 제38조제1항에 따라 금고를 지정하려는 지방자치단체의 장은 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 금고 업무의 취급능력
2. 주민의 이용 편의
3. 금융기관의 재무구조

② (생 략)

③ 지방자치단체의 장은 법 제38조제1항에 따라 금고를 지정하려는 경우 해당 금융기관과 금고 업무에 관한 약정을 체결하여야 한다.

④·⑤ (생 략)

⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 금고 지정의 세부기준 및 지정 절차 등에 관하여 필요한 사항은 행정안전부장관이 정한다.

사례 19 별도의 평가항목을 추가하고 감점 배점하는 형식으로 규정할 수 없다고 본 사례

2021. 10. 26. 의견제시 21-0303

질의요지

지방자치단체 금고 지정의 평가항목을 지방자치단체 규칙으로 정하면서 「지방자치단체 금고지정 기준」에 포함되지 않은 별도의 항목을 추가로 정하고, 해당 항목에 대해 감점 배점하는 형식으로 규정하는 것이 가능한지?

의 견

아래 이유를 참고하시기 바랍니다.

이 유

「지방자치법」 제22조에서는 지방자치단체는 법령의 범위 안 즉, '법령에 위반되지 않는 범위 내'에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제23조에서는 지방자치단체의 장은 법령이나 조례가 위임한 범위에서 그 권한에 속하는 사무에 관하여 규칙을 제정할 수 있다고 규정하고 있는데, 법령의 직접적인 위임에 따라 위임행정기관이 그 법령을 시행하는데 필요한 구체적 사항을 정한 것이면 그 제정형식이 비록 훈령, 예규 등과 같은 행정규칙이더라도 그것이 상위법령의 위임한계를 벗어나지 않는 한 상위법령과 결합하여 대외적인 구속력을 갖는 법규명령으로서 가능하게 되므로 지방자치단체의 장이 규칙으로 정하고자 하는 사항은 법령과 그 법령의 위임에 따라 위임한계 내에서 제정된 행정규칙에 위반되지 않아야 할 것입니다.

「지방회계법」 제38조에서는 지방자치단체의 장에게 금고지정 사무에 관한 집행권을 부여(제1항)하면서 금고의 지정기준 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정하도록 위임(제4항)하고 있고, 해당 규정의 위임에 따른 같은 법 시행령 제48조에서는 지방자치단체의 장이 금고를 지정하는 경우 고려해야 할

사항을 규정하면서 금고 지정의 세부기준 및 지정 절차 등에 관하여 필요한 사항은 행정안전부장관이 정한다고 규정(제6항)하고 있습니다.

그리고「지방회계법 시행령」제48조제6항의 위임에 따른 행정안전부예규 제71호「지방자치단체 금고지정 기준」(이하 "금고지정기준"이라 한다) 3. [1] 및 별표에서는 경쟁방법에 의하여 금고를 지정할 경우 평가항목을 제1호부터 제6호까지로 구분하여 규정하면서 제6호 기타사항(지역의 특수성을 고려하여 자치단체 조례 또는 규칙으로 정하는 사항, 이하 "자율항목"이라 한다)에 자치단체 실정에 맞도록 세부항목을 정하도록 규정하고 있으므로 지방자치단체에서는 규칙으로 자율항목의 세부항목을 정할 수 있다고 할 것입니다.

살피건대 금고지정기준에서는 100점을 총점으로 하여 평가항목별 배점 기준을 정하면서 자율항목에 11점을 배정하고 있고, 자율항목 세부 평가기준을 조례나 규칙으로 정할 때 준수하여야 할 원칙에 대해 규정하면서 필요시 평가항목을 등급별·순위별로 나누어 배점을 부여하여 평가할 수 있으며, 세부항목별 배점하한은 배점한도의 60퍼센트 이상으로 하도록 규정하면서 달리 '감점'에 대해서는 규정하고 있지 않은바, 금고지정기준에 따른 항목별 배점 기준은 각 평가항목이 지방자치단체 금고지정 평가에서 차지하는 비중을 규정한 것으로 보아야 할 것입니다.

그런데 자율항목 중 어느 하나의 평가항목에 대해 감점 배점한다는 것은 해당 평가항목에 대해 기본적으로 0점을 부여한다는 것으로 이러한 방식은 해당 평가항목이 전체 평가에서 차지하는 비중을 규정한 것으로 볼 수 없고, 0점을 기준으로 '배점한도의 60퍼센트 이상'이라는 배점하한을 설정하기도 곤란하다는 점을 고려하면 자율항목에 특정 평가항목을 규정하면서 해당 항목에 대해 감점 배점하는 형식으로 지방자치단체 규칙에 규정하는 것은 금고지정기준의 취지에 반할 소지가 있는 것으로 보입니다.

사례 20

금고로 지정할 수 있는 금융기관의 범위를 규정할 수 있다고 본 사례

2020. 1. 14. 의견제시 20-0003

질의요지

의성군수가 「지방회계법」 제38조제1항에 따라 금고를 지정하려는 경우, 관할구역에 본점 또는 지점을 둔 금융기관 외에 출장소 등의 영업소를 둔 금융기관도 금고로 지정할 수 있도록 하는 내용을 「의성군 금고지정 및 운영에 관한 규칙」에 규정할 수 있는지?

의 견

이 사안의 경우 질의요지의 내용을 「의성군 금고지정 및 운영에 관한 규칙」에 규정할 수 있을 것으로 보입니다.

이 유

「의성군 금고지정 및 운영에 관한 규칙」(이하 "의성군규칙"이라 함) 제4조제1항에서는 관할구역에 본점 또는 지점을 둔, 「지방회계법」 제38조제1항에 따른 금융기관을 금고로 지정하도록 규정하고 있는데, 이 사안은 해당 규정을 개정하여, 의성군수가 「지방회계법」 제38조제1항에 따라 금고를 지정하려는 경우, 관할구역에 본점 또는 지점을 둔 금융기관 외에 출장소 등의 영업소를 둔 금융기관도 금고로 지정할 수 있도록 하는 내용을 의성군규칙에 규정할 수 있는지를 질의하는 것으로 보입니다.

「지방자치법」 제23조에 따르면 지방자치단체의 장은 법령이나 조례가 위임한 범위에서 그 권한에 속하는 사무에 관하여 규칙을 제정할 수 있는바, 「지방회계법」 제38조제1항에서는 지방자치단체의 장에게 금고지정 사무에 관한 집행권을 부여하고 있고(대법원 2000. 6. 13. 선고 99추92 판결 등 참조), 같은 조 제4항에서는 금고의 지정기준 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다고 규정하고 있습니다. 이에 따라 「지방회계법 시행령」 제48조제1항부터 제5항까지에서는 금고지정 기준 등에 관한

사항을 규정하고 있고, 같은 조 제6항에서는 그 외에 금고 지정의 세부기준 및 지정 절차 등에 관하여 필요한 사항은 행정안전부장관이 정한다고 규정하고 있으며, 이에 따른 「지방자치단체 금고지정기준」(행정안전부예규 제71호, 이하 "금고지정기준"이라 함) 6.[2]에서는 같은 기준의 범위에서 금고 지정을 위한 세부적인 사항은 자치단체의 조례 또는 규칙으로 정한다고 규정하고 있습니다. 이상의 「지방자치법」 및 지방회계법령을 종합해보면, 의성군수는 금고지정기준의 범위 내에서 금고지정에 관한 사항을 규칙으로 정할 수 있다고 할 것입니다.

그리고, 「지방회계법」 제38조제1항 각 호 외의 부분 본문에서는 지방자치단체장은 소관 현금과 그가 소유하거나 보관하는 유가증권의 출납, 보관 및 그 밖의 금고 업무를 취급하게 하기 위하여 「은행법」에 따른 은행을 금고로 지정하여야 한다고 규정하고, 같은 항 각 호 외의 부분 단서에서는 같은 항 각 호의 금융기관이 대통령령으로 정하는 안정성 기준을 충족할 경우 특별회계 및 기금 업무만을 취급하는 금고로 지정할 수 있다고 규정하고 있을 뿐, 금고로 지정될 수 있는 금융기관의 영업소 형태에 관해서는 별도로 규정하고 있는 바가 없습니다. 또한, 「지방회계법 시행령」 제48조제1항에서는 금고를 지정하려는 지방자치단체의 장은 금고 업무의 취급능력, 주민의 이용 편의, 금융기관의 재무구조를 고려하여야 한다고 규정하고 있습니다. 따라서 「지방회계법」 제38조제1항에서 금고 지정 대상으로 규정하고 있는 금융기관에 해당하고, 지방자치단체의 금고 업무 수행에 어려움이 없고 주민들이 이용하기에 불편함이 없다면, 관할구역에 본점 또는 지점을 둔 금융기관 외에 출장소 등의 영업소를 둔 금융기관도 금고로 지정할 수 있도록 하는 것이 법령이 위임한 범위를 벗어난다거나 법령이 규정하고 있는 금고 지정 금융기관의 요건에 위반되는 것으로 보기는 어려울 것이므로, 이러한 내용을 의성군규칙에 규정할 수 있을 것으로 보입니다.

사례 21 금고지정 기준의 입법형식 선택에 관한 기준을 제시한 사례

2020. 6. 12. 의견제시 20-0127

질의요지

「지방회계법」 제38조에 따른 금고의 지정과 관련하여 지방자치단체가 정할 수 있는 사항을 반드시 조례로 규정해야 하는지, 아니면 조례와 규칙 중 어떤 입법형식을 선택해도 무방한지?

의 견

아래 이유를 참고하시기 바랍니다.

이 유

「지방자치법」 제22조 본문에 따르면 지방자치단체는 법령의 범위 안에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있고, 같은 법 제23조 본문에 따르면 지방자치단체의 장은 법령이나 조례가 위임한 범위에서 그 권한에 속하는 사무에 관하여 규칙을 제정할 수 있는 바, 특정 사항에 대하여 조례로 정할지 규칙으로 정할지는 해당 사무의 성격이나 법령의 규정 형식에 따라 결정되게 됩니다.

그리고 여기서 "법령"에는 법률 이외에 대통령령, 총리령 및 부령과 같은 법규명령이 포함되는 것은 물론이지만, 법령의 직접적인 위임에 따라 위임행정기관이 그 법령을 시행하는데 필요한 구체적 사항을 정한 것이면 그 제정형식이 비록 법규명령이 아닌 훈령, 예규 등과 같은 행정규칙이더라도 그것이 상위법령의 위임한계를 벗어나지 않는 한 상위법령과 결합하여 대외적인 구속력을 갖는 법규명령으로서 기능하게 되므로 이러한 행정규칙도 포함된다고 보아야 할 것입니다.

그리고 「지방회계법」 제38조제1항에서는 지방자치단체의 장에게 금고지정 사무에 관한 집행권을 부여하면서, 같은 조 제4항에서는 금고의 지정기준 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다고 규정하고

있고, 같은 법 시행령 제48조제1항부터 제5항까지 에서는 금고지정 기준 등에 관한 사항을 규정하면서, 「지방회계법 시행령」 제48조제6항에서는 같은 조 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 금고지정의 세부기준 및 지정 절차 등에 관하여 필요한 사항은 행정안전부장관이 정하도록 위임하고 있습니다.

이에 따라 지방자치단체의 금고지정 기준에 대해 정하고 있는 「지방자치단체 금고지정기준」(행정안전부예규 제71호, 이하 "금고지정기준"이라 함) 1.[5]에서는 금고의 약정기간은 4년 이내에서 자치단체 조례 또는 규칙으로 정하도록 하고 있고, 3.에서는 금고지정 평가기준과 관련된 사항을, 4.[1]에서는 금고지정심의위원회 심의 사항 중 평가와 관련된 사항과 위원장 및 위원 선정, 위촉 기간, 위원 수, 의사정족수 및 의결정족수 등 기타 심의위원회의 운영에 필요한 사항을, 6.[2]에서는 금고지정을 위한 세부적인 사항을 각 금고지정기준의 범위 내에서 지방자치단체의 조례 또는 규칙으로 정하도록 명시하고 있습니다.

이처럼 「지방회계법」 제38조 및 같은 법 시행령 제48조 등의 상위법령과 결합하여 법규명령으로서 기능하는 금고지정 기준에서 금고지정기준과 관련한 각 사항을 그 내용을 특정하지 않고 조례 또는 규칙으로 정하도록 명시하고 있는데 이는 상위법령의 규정 취지에 반하는 것으로 볼 수 없으므로 지방자치단체의 금고를 지정하기 위한 규정은 법령에 의하여 조례 또는 규칙으로 모두 규정될 수 있을 것입니다.

4. 기금의 존속기한이 경과하면 기금 설치·운영을 위한 조례가 실효되는지

「지방자치법」 제159조제2항에서는 재산의 보유, 기금의 설치·운용에 필요한 사항은 조례로 정하도록 하고 있으므로 법률에 따라 설치된 기금이 아니라면, 지방자치단체의 기금은 조례로 설치한다. 기금 조례에서는 「지방자치단체 기금관리기본법」에서 규정한 사항에 모순되거나 저촉되는 규정을 둘 수 없고, 법률에 따라 설치된 기금의 경우 그 법률에서 기금에 대해 규정한 사항에 모순되거나 저촉되는 규정을 두어서도 안 될 것이다[9].

「지방자치단체 기금관리기본법」 제4조제1항에서는 지방자치단체가 기금을 신설하여 운용하려는 경우 그 존속기한을 해당 조례에 명시하도록 규정하고 있는데, 기금의 존속기한을 정하는 것은 그 기금을 설치하고 운용하기 위하여 마련된 조례 전체의 존속기한을 정한 것과 같다고 볼 것인바, 기금의 존속기한을 두도록 한 취지는 기한이 다다를 때까지 기금의 존속기한이 연장되지 않으면 그 기금 근거의 효력을 잃도록 하려는 것으로서, 원칙적으로 법령의 유효기간이 종료된 후에는 이미 해당 규정이 효력을 잃은 것이므로, 비록 형식적으로 규정의 형태가 남아 있다고 하더라도 실질적으로 적용되지 않는다고 할 것이며, 이 경우 폐지 등 별도의 조치도 필요없다고 할 것이다[10].

한편, 기금의 존속기한이 경과한 경우 기금을 존속시키기 위해 존속기한 규정만 개정하면 존속기한 경과 이후 개정될 때까지 소급하여 기금이 존속했다고 오해할 소지가 있으므로, 존속기한이 경과한 후 해당 기금의 설치 근거를 새로 만드는 경우에는 기금을 설치한 종전의 조례 또는 규정을 폐지하거나 삭제하고 기금에 관한 조례나 규정을 새로 만들어야 한다[11].

9) 『자치법규 입안 길라잡이(2022)』 180쪽 참조
10) 법제처 2014. 10. 27. 의견제시 14-0213 참조
11) 『자치법규 입안 길라잡이(2022)』 185쪽 참조

「지방자치법」

제159조(재산과 기금의 설치) ① 지방자치단체는 행정목적을 달성하기 위한 경우나 공익상 필요한 경우에는 재산(현금 외의 모든 재산적 가치가 있는 물건과 권리를 말한다)을 보유하거나 특정한 자금을 운용하기 위한 기금을 설치할 수 있다.

② 제1항의 재산의 보유, 기금의 설치·운용에 필요한 사항은 조례로 정한다.

「지방자치단체 기금관리기본법」

제4조(기금의 존속기한) ① 지방자치단체가 기금을 신설하여 운용하려는 경우에는 기금의 존속기한을 해당 조례에 명시하여야 한다. 다만, 법률에 따라 의무적으로 설치·운용되는 기금과 「지방공기업법」 제19조제2항에 따른 지역개발을 위한 기금은 존속기한을 명시하지 아니할 수 있다.

② 기금의 존속기한은 기금의 설치목적을 달성하기 위하여 필요한 최소한의 기간으로 설정하여야 하며, 그 기간은 5년을 초과할 수 없다.

③ 존속기한을 넘어서까지 기금을 존치할 필요가 있을 때에는 조례를 개정하여 5년의 범위에서 기금의 존속기한을 연장할 수 있다. 이 경우 「지방재정법」 제33조제9항에 따른 지방재정계획심의위원회의 심의를 거쳐야 한다.

④ 지방자치단체의 장은 기금의 존속기한 및 통합·폐지에 관한 사항 등을 포함한 5년 단위의 기금 정비계획을 매년 작성하여 이를 「지방재정법」 제33조제1항에 따른 중기지방재정계획에 반영하여야 한다.

사례 22

기금과 관련된 규정만 실효된다고 본 사례

2023. 11. 10. 의견제시 23-0422

질의요지

가. 「강원특별자치도교육청 남북교육교류협력에 관한 조례」에 따른 남북교육교류협력기금의 존속기한이 경과한 경우 같은 조례는 전체가 실효되었다고 보아야 하는지, 아니면 남북교육교류협력기금과 관련된 규정만 실효되었다고 보아야 하는지?

나. 질의 가.와 관련하여 남북교육교류협력기금과 관련된 규정만 실효되었다고 보는 경우, 남북교육교류협력기금과 관련된 규정을 제외한 규정의 효력을 유지하는 방식으로 「강원특별자치도교육청 남북교육교류협력에 관한 조례」를 정비하려면 같은 조례를 폐지하고 남북교육교류협력기금과 관련된 내용을 제외한 내용으로 다시 조례를 제정해야만 하는지, 아니면 같은 조례의 남북교육교류협력기금과 관련된 규정만 삭제해도 되는지?

의 견

가. 질의 가에 대하여
아래 이유를 참고하시기 바랍니다.

나. 질의 나에 대하여
아래 이유를 참고하시기 바랍니다.

이 유

가. 질의 가에 대하여

「지방자치단체 기금관리기본법」(이하 "지방기금법"이라 한다) 제4조제1항에서는 지방자치단체가 기금을 신설하여 운용하려는 경우에는 기금의 존속기한을 해당 조례에 명시하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 기금의 존속기한은 기금의 설치목적을 달성하기 위하여 필요한 최소한의 기간으로

설정하여야 하며, 그 기간은 5년을 초과할 수 없다고 규정하고 있으며, 같은 조 제3항에서는 존속기한을 넘어서까지 기금을 존치할 필요가 있을 때에는 조례를 개정하여 5년의 범위에서 기금의 존속기한을 연장할 수 있도록 하고 있습니다.

한편 「강원특별자치도교육청 남북교육교류협력에 관한 조례」(이하 "교류협력조례"라 한다) 제6조제1항에서는 강원특별자치도교육청(이하 "교육청"이라 한다)은 교육청 남북교육교류협력사업(이하 "협력사업"이라 한다)을 원활히 추진하기 위해서 남북교육교류협력기금(이하 "협력기금"이라 한다)을 설치·운용할 수 있도록 하고 있고, 같은 조 제3항에서는 협력기금의 존속기한은 5년으로 한다고 규정하고 있습니다.

이 사안은 교류협력조례에 따른 협력기금의 존속기한이 경과한 경우 교류협력조례 전체가 실효되었다고 보아야 하는지, 아니면 협력기금과 관련된 규정만 실효되었다고 보아야 하는지가 문제됩니다.

살피건대 지방기금법에서는 "기금"의 존속기한을 명시하여야 한다고 규정하고 있고, 이에 따라 교류협력조례에서는 "협력기금"의 존속기한을 정하고 있는바, 그 존속기한이 경과한 경우에는 협력기금과 관련된 규정만 실효되었다고 보아야 할 것입니다.

그런데 교류협력조례는 강원특별자치도교육청과 군사분계선 이북지역 교육관련 기관·단체 간의 교육·학예 분야의 교류와 협력을 활성화하기 위해 필요한 사항을 규정함으로써 한반도 평화 정착에 기여함을 목적(제1조)으로 하는 조례로서, 협력기금의 조성 및 관리에 관한 사항(제6조, 제7조) 등 협력기금에 관한 사항 외에도 협력사업 추진과 관련된 지방보조금 지원에 관한 사항(제4조제2항), 협력사업의 원활한 진행을 위한 협력사업 기본계획의 수립·시행에 관한 사항(제5조), 남북교육교류협력에 관한 사항 등을 심의·조정하기 위한 교육청 남북교육교류협력위원회에 관한 사항(제8조부터 제11조까지) 등에 대해서도 규정하고 있는 것으로 보입니다.

따라서, 교류협력조례에 따른 협력기금의 존속기한이 경과한 경우에도 교류협력조례 전체가 실효되었다고 보기는 어렵고, 협력기금과 관련된 규정만 실효되었다고 보는 것이 타당할 것으로 보입니다.

나. 질의 나에 대하여

질의 가에서 살펴본 바와 같이 교류협력조례에 따른 협력기금의 존속기한이 경과한 경우 협력기금과 관련된 규정은 실효된 것으로 보아야 하는바, 사실상 효력을 상실하였음에도 불구하고 형식적인 조례로 남아 있어 주민에게 혼란을 줄 여지가 있으므로 조례를 정비하는 것이 바람직한 것으로 보입니다.

이와 관련하여 협력기금과 관련된 규정을 제외한 규정의 효력을 유지하는 방식으로 교류협력조례를 정비하려는 경우, 같은 조례를 폐지하고 협력기금과 관련된 내용을 제외한 내용으로 다시 조례를 제정할 수도 있고, 같은 조례의 협력기금과 관련된 규정만 삭제하여 개정할 수도 있을 것입니다.

사례 23

조례 전체가 실효된다고 본 사례

2017. 5. 18. 의견제시 17-0101

질의요지

「서울특별시 영등포구 통합관리기금 설치 조례」에 따른 서울특별시영등포구통합관리기금의 존속기한이 경과한 경우, 같은 조례를 폐지하여야 하는지?

의 견

「서울특별시 영등포구 통합관리기금 설치 조례」에 따른 서울특별시영등포구통합관리기금의 존속기한이 경과한 경우, 같은 조례는 폐지 등 별도의 조치를 취하지 아니하는 경우에도 그 조례는 실효된 것으로 보입니다. 다만, 같은 조례가 사실상 효력을 상실하였음에도 불구하고 형식적인 조례로 남아 있어 주민에게 혼란을 줄 여지가 있으므로 조례정비 차원에서 해당 조례의 폐지 절차를 거치는 것이 바람직한 것으로 보입니다.

이 유

「서울특별시 영등포구 통합관리기금 설치 조례」(이하 "영등포구조례"라 함)는 「지방자치법」 제142조와 「지방자치단체 기금관리기본법」 제16조에 따라 영등포구에서 관리하는 각종 기금의 여유자금을 통합 관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위하여 서울특별시영등포구통합관리기금(이하 "통합관리기금"이라 함)을 설치하고, 그 운용·관리에 필요한 사항을 규정함을 목적(제1조)으로 제정하여 2007년 1월 1일 시행되었으며, 20011년 5월 26일 영등포구 조례 제841호로 같은 조례를 개정하여 기금의 존속기한에 관한 규정을 신설하여 "통합관리기금의 존속기한은 10년으로 한다"라는 규정(제4조)을 두었는바, 이 사안은 통합관리기금의 존속기한 경과 후 영등포구조례를 폐지하는 절차를 거쳐야 하는지 여부에 관한 질의로 보입니다.

「지방자치단체 기금관리기본법」 제4조제1항에서는 지방자치단체가 기금을 신설하여 운용하려는 경우에는 기금의 존속기한을 해당 지방자치단체의 조례에 명시하도록 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 기금의 존속기한은 기금의 설치목적을 달성하기 위하여 필요한 최소한의 기간에서 설정하여야 하며, 그 기간은 5년을 초과할 수 없다고 규정하고 있으며, 같은 조 제3항에서는 존속기한을 넘어서까지 기금을 존치할 필요가 있을 때에는 조례를 개정하여 5년의 범위에서 기금의 존속기한을 연장할 수 있다고 규정하고 있습니다.

이와 같이 기금의 존속기한을 정하는 것은 그 기금을 설치하고 운용하기 위하여 마련된 조례 전체의 존속기한을 정한 것과 같다고 볼 것인바, 기금의 존속기한을 두도록 한 취지는 기한이 다다를 때까지 기금의 존속기한이 연장되지 않으면 그 기금 근거의 효력을 잃도록 하려는 것으로서, 원칙적으로 법령의 유효기간이 종료된 후에는 이미 해당 규정이 효력을 잃은 것이므로, 비록 형식적으로 규정의 형태가 남아 있다고 하더라도 실질적으로 적용되지 않는다고 할 것이며, 이 경우 폐지 등 별도의 조치도 필요없다고 할 것입니다(법제처 2014. 10. 27. 의견제시 14-0213 참조).

살피건대, 영등포구조례 제4조에 기금의 존속기한에 대하여 규정하고 있는 것은 그 기금을 설치하고 운용하기 위하여 마련된 영등포구조례 전체에 대한 존속기한을 정한 것과 같다고 볼 것이고, 통합관리기금의 존속기한은 원칙적으로 영등포구조례가 시행된 날인 2007년 1월 1일부터 기산하여 2017년 1월 1일에 존속기한이 도래하였으므로, 통합관리기금을 설치하고 운용하기 위하여 마련된 영등포구조례 또한 2017년 1월 1일 이후에는 기금의 근거로서 효력을 잃었다고 할 것이므로, 형식적으로 같은 조례의 형태는 남아 있다고 하더라도 실질적으로 적용되지 않는다고 할 것이며, 같은 조례를 실효시키기 위한 목적으로 폐지 등 별도의 조치가 필요하지 않은 것으로 보입니다.

다만, 기금을 설치하는 조례에서 존속기한을 두어 그 존속기한이 경과한 후에 해당 조례의 실효를 위한 목적으로는 반드시 형식적인 폐지 절차를 거쳐야 할 필요는 없지만, 같은 조례가 사실상 효력을 상실하였음에도 불구하고 형식적인 조례로 남아있어 주민에게 혼란을 줄 여지가 있으므로 조례정비 차원에서 영등포구조례의 폐지 절차를 거치는 것이 바람직할 것으로 보입니다.

따라서, 영등포구조례에 따른 통합관리기금의 존속기한이 경과한 경우, 같은 조례는 폐지 등 별도의 조치를 취하지 아니하는 경우에도 그 조례는 실효된 것으로 보입니다. 다만, 같은 조례가 사실상 효력을 상실하였음에도 불구하고 형식적인 조례로 남아 있어 주민에게 혼란을 줄 여지가 있으므로 조례정비 차원에서 해당 조례의 폐지 절차를 거치는 것이 바람직한 것으로 보입니다.

5. 기금으로 융자를 지원받은 자에 대한 융자금 감면 등을 조례에 규정할 수 있는지

「지방자치단체 기금관리기본법」 제6조제1항, 「지방재정법」 제87조제4항, 같은 법 시행령 제130조 및 제131조 등의 규정을 종합하여 볼 때, 「지방재정법」 제86조가 "지방자치단체는 법령이나 조례에 따르지 아니하고는 채권의 전부 또는 일부를 면제하거나 그 지방자치단체에 불리하게 효력을 변경할 수 없다"고 함으로써 조례로 채권면제에 관한 사항을 정할 수 있는 것으로 규정하고 있다고 하더라도 같은 법 제87조 및 같은 법 시행령 제130조, 제131조의 규정이 적용배제되는 것은 아니므로, 조례로 채권 등의 면제에 관해 규정할 때에도 조례의 내용은 「지방재정법」 제87조 및 같은 법 시행령 제130조, 제131조에 위배되지 않아야 할 것이다[12].

「지방자치단체 기금관리기본법」

제6조(기금의 관리 및 운용) ① 기금은 세계현금(歲計現金)의 수입·지출·보관의 절차, 공유재산 및 물품의 관리·처분의 예 또는 채권 관리의 예에 따라 관리하여야 한다.
② ~ ⑥ (생 략)

「지방재정법」

제86조(채권의 보전) 지방자치단체는 법령이나 조례에 따르지 아니하고는 채권의 전부 또는 일부를 면제하거나 그 지방자치단체에 불리하게 효력을 변경할 수 없다.

제87조(관리의 방법 등) ① 채권 관리에 관한 사무는 채권의 발생 원인이나 채권의 내용에 따라 지방자치단체의 이익에 가장 부합하도록 처리하여야 한다.
②·③ (생 략)
④ 관리 대상이 되는 채권의 범위, 채권의 보전 및 그 밖에 채권 관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

12) 법제처 2019. 2. 21. 의견제시 19-0032 참조

「지방재정법 시행령」

제130조(면제) ① 지방자치단체의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이행연기의 특약을 한 채권과 이에 관한 연체금 및 이자를 면제할 수 있다.

1. 채무자가 무자력하거나 이에 가까운 상태에 있다는 이유로 이행연기의 특약을 한 채권으로서 당초의 이행기(당초의 이행기 후에 이행연기의 특약을 한 경우에는 최초로 이행연기의 특약을 한 날)부터 10년을 경과한 후에도 채무자가 무자력하거나 이에 가까운 상태에 있고 이행할 수 있는 가망이 없다고 인정되는 경우
2. 제1호에 준하는 경우로서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 경우

② 지방자치단체의 장은 이행연기의 특약을 한 채권에 대하여 연납이자(제126조의 규정에 의한 이자를 말한다. 이하 같다)를 붙인 경우에 채무자가 당해 채권의 금액(연납이자를 제외한다)의 전부에 상당하는 금액을 그 연장된 이행기 내에 납부하는 때에는 연납이자에 대하여는 채권자의 자력상태에 비추어 부득이하다고 인정되는 경우에 한하여 그 전부 또는 일부에 상당하는 금액을 면제할 수 있다.

③·④ (생 략)

제131조(연체금에 관한 특례) ① 지방자치단체의 장은 이행기한 내에 변제되지 아니한 채권(이자를 붙인 채권이나 다른 법령에 연체금에 관한 규정이 있는 채권은 제외한다)의 금액이 1만원 미만일 때에는 연체금을 붙이지 아니할 수 있다.

② 다음 각 호의 채권에 대하여는 원금의 전부에 상당하는 금액이 변제된 때에는 그때까지 붙은 연체금의 전부 또는 일부를 면제할 수 있다.

1. 지방자치단체가 설치한 교육시설에서 징수하는 수업료 또는 기숙사 사용료
2. 지방자치단체가 설치한 의료시설에서 환자로부터 징수하는 모든 비용
3. 채무자의 고의 또는 중대한 과실에 의하지 아니한 부당이득반환금

사례 24

융자금이나 그 연체금 채권에 대한 감면 등을 규정할 수 없다고 본 사례

2018. 11. 6. 의견제시 18-0214

질의요지

충주시로부터 융자금을 지원받은 농어민이 사망하거나 행방불명된 경우에 그 융자금이나 융자금의 연체금 채권에 대하여 결손처분을 하거나 감면할 수 있도록 하는 내용의 조례를 제정할 수 있는지?

의 견

충주시로부터 융자금을 지원받은 농어민이 사망하거나 행방불명된 경우에 그 융자금이나 융자금의 연체금 채권에 대하여 결손처분을 하거나 감면할 수 있도록 하는 내용의 조례를 제정하는 것은 「지방재정법 시행령」 제130조제1항·제2항 및 제131조제2항에 위배될 소지가 있으므로 조례 제정에 신중을 기하시기 바랍니다.

이 유

「지방자치단체 기금관리기본법」 제6조제1항에서는 기금은 세계현금(歲計現金)의 수입·지출·보관의 절차, 공유재산 및 물품의 관리·처분의 예 또는 채권관리의 예에 따라 관리하여야 한다고 규정하고 있고, 「지방재정법」 제86조에서는 "지방자치단체는 법령이나 조례에 따르지 아니하고는 채권의 전부 또는 일부를 면제하거나 그 지방자치단체에게 불리하게 효력을 변경할 수 없다"고 규정하고 있으며, 같은 법 제87조제4항에서는 관리 대상이 되는 채권·채무의 범위, 채권의 보전 및 그 밖에 채권 관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정하도록 하고 있습니다. 이에 따라 「지방재정법 시행령」 제130조에서는 "채무자가 무자력하거나 이에 가까운 상태에 있다는 이유로 이행연기의 특약을 한 채권으로서 당초의 이행기부터 10년을 경과한 후에도 채무자가 무자력하거나 이에 가까운 상태에 있고 이행할 수 있는 가망이 없다고 인정되는 경우에는 당해 채권과 이에 관한 연체금 및 이자를 면제할 수 있다(제1항)"고

규정하고, “이행연기의 특약을 한 채권에 대하여 연납이자를 붙인 경우에 채무자가 당해 채권의 금액(연납이자를 제외한다)의 전부에 상당하는 금액을 그 연장된 이행기 내에 납부하는 때에는 연납이자에 대하여는 채권자의 자력상태에 비추어 부득이하다고 인정되는 경우에 한하여 그 전부 또는 일부에 상당하는 금액을 면제할 수 있다(제2항)”고 규정하고 있습니다. 또한 같은 법 시행령 제131조제2항에서는 채권 원금의 전부에 상당하는 금액이 변제된 때에 그때까지 붙은 연체금의 전부 또는 일부를 면제할 수 있는 채권의 종류로 지방자치단체가 설치한 교육시설에서 징수하는 수업료 또는 기숙사 사용료(제1호), 지방자치단체가 설치한 의료시설에서 환자로부터 징수하는 모든 비용(제2호), 채무자의 고의 또는 중대한 과실에 의하지 아니한 부당이득반환금(제3호)을 규정하고 있습니다.

「충주시 농업안정기금 조례안」에서는 이 조례 시행 전 「충주시주민소득사업운영관리조례」 및 「충주시농어민소득기금운영관리조례」에서 지원된 융자금이 연체되어 상환이 어려운 농업인에 대하여는 지방세 징수법령을 준용하고, 심의회 의결에 따라 소득자금을 융자받은 농업인이 천재지변, 사망, 행방불명, 파산, 무재산 등의 사유로 인하여 상환능력이 없다고 인정되는 경우에는 결손처분(제1호), 소득자금을 융자받은 농업인이 제1호에 해당하여 대위변제 또는 보증인이 융자금 및 이자를 상환한 경우 연체이자 감면(제2호), 소득자금을 융자받은 농업인이 상환능력을 상실하여 연체이자의 누적으로 상환이 어려울 경우 시장이 지정하는 기한내 융자금과 이자를 상환하는 경우 연체이자 감면(제3호)할 수 있다고 규정하고 있습니다.

지방자치단체는 법령에 위반되지 않는 범위 내에서 자치조례를 제정할 수 있으므로(대법원 2003. 9. 23. 선고 2003추13 판결 참조), 「충주시 농업안정기금 조례」를 개정하면서 기금을 지원받은 사람이 사망·행방불명·파산·무재산 또는 천재지변 등의 사유로 회복할 수 없을 정도로 상환능력을 상실하였다고 인정될 때에는 그 융자금과 이자에 대하여 결손처분을 할 수 있다고 정하거나, 소득자금을 융자받은 농업인이 사망이나 행불 등으로 상환능력이 없어 대위변제 또는 보증인이 융자금 및 이자를 상환한 경우에 연체이자를 감면할 수 있다고 정하고자 하는 경우에는, 이와 같은 규정이 상위법령에 위배됨이 없어야 할 것입니다.

그러므로, 「지방재정법」 제86조가 “지방자치단체는 법령이나 조례에 따르지 아니하고는 채권의 전부 또는 일부를 면제하거나 그 지방자치단체에 불리하게 효력을 변경할 수 없다”고 규정함으로써 조례로 채권면제에 관한 사항을 정할 수 있는 것으로 규정하고 있다고 하더라도 같은 법 제87조 및 같은 법 시행령 제130조, 제131조의 규정이 적용배제 되는 것은 아니므로, 조례로 채권 등의 결손처분이나 감면에 관해 규정할 때에도 조례의 내용은 「지방재정법」 제87조 및 같은 법 시행령 제130조, 제131조에

위배되지 않아야 할 것입니다.

살피건대, 「지방재정법 시행령」 제130조제1항·제2항에서 지방자치단체의 장은 일정한 경우에 한하여 채권과 연체금 및 이자의 전부 또는 일부를 면제할 수 있도록 엄격한 절차와 기준을 규정하고 있는 것은, 지방자치단체에서 농어민에게 금전을 대여하는 융자금 채권은 그 상환기한까지 상환하는 것을 예정하고 있는 금전채권이므로, 자의적으로 결손처분을 하거나 채권을 감면하는 것으로 제한하려는 취지에서 그 요건과 절차를 법령에서 직접 규정한 것으로 보입니다. 또한, 지방자치단체의 채권에 붙이는 연체금의 감면과 관련하여 「지방재정법 시행령」 제131조제2항에서 일정한 채권의 경우에 "원금의 전부에 상당하는 금액이 변제된 때에는 그때까지 붙은 연체금의 전부 또는 일부"를 면제할 수 있도록 한정적으로 규정하고 있는 것도 같은 취지로 보입니다. 이와 같은 융자금이나 연체금 면제의 요건과 기준에 관한 법령규정에도 불구하고 채무자가 사망하거나 행방불명이 되었다는 등의 이유만으로 융자금이나 연체금 채권을 결손처분하거나 감면하는 것은 이와 같은 「지방재정법 시행령」의 규정에 맞지 않는 결과를 초래할 수도 있을 것으로 보입니다(법제처 2016. 12. 13. 의견제시 16-0298 및 2016. 8. 17. 의견제시 16-0160 참조).

결론적으로, 「지방재정법 시행령」 제130조제1항·제2항 및 제131조제2항에 따른 요건과 다른 표현을 사용하여 조례에서 결손·감면 처분 규정을 두게 되면 설사 비슷한 내용이라고 하더라도 특정한 경우 다른 결론에 이를 수 있는바, 법령에서 요건을 완결적으로 정한 경우로서 조례로 요건의 보충이나 해석 등을 위임하지 아니하였다면 그러한 내용을 조례로 규정하는 것은 법령에 위배될 수 있으니 조례 제정에 신중을 기하시기 바랍니다.

사례 25

융자금의 이자 및 연체이자의 감면은 상위법령의 범위에서 가능하다고 본 사례

2016. 6. 14. 의견제시 16-0113

질의요지

융자금을 지원받고 10년이 경과한 채무자가 미상환한 원금 전액을 상환하는 경우, 「장흥군 장흥댐 관련 지역발전기금 특별회계 운영 조례 시행규칙」에 따라 이자와 연체이자를 감면해 줄 수 있는지?

의 견

융자금을 지원받고 10년이 경과한 채무자가 미상환한 원금 전액을 상환하는 경우, 해당 채무자가 「지방재정법 시행령」 제130조제1항·제2항 및 제131조제2항에 규정된 요건을 갖추지 못한 경우에도 「장흥군 장흥댐 관련 지역발전기금 특별회계 운영 조례 시행규칙」에 따라 이자와 연체이자를 감면해 주는 것은 「지방자치법」 제22조와 「지방재정법 시행령」 제130조제1항·제2항 및 제131조제2항을 위반하는 것으로 보입니다.

이 유

「장흥군 장흥댐 관련 지역발전기금 특별회계 운영 조례 시행규칙 일부개정안」(이하 "장흥군규칙안"이라 한다) 제13조의2에서는 융자금 지원일부터 10년이 경과된 채무자가 장흥군 규칙안 시행일부터 2년 이내에 미상환한 원금 전액을 상환하는 경우 이자와 연체이자를 감면할 수 있도록 규정하고 있는바, 이 사안에서는 장흥군규칙안에 따라 융자금의 이자와 연체이자를 감면해 줄 수 있는지가 문제되고 있습니다.

먼저, 지방자치단체는 「지방자치법」 제22조에 따라 법령의 범위 안에서 조례를 정해야 하는데, 「지방재정법」 제86조에서는 지방자치단체는 법령이나 조례에 따르지 않고는 채권의 전부 또는 일부를 면제하거나 그 지방자치단체에 불리하게 효력을 변경할 수 없다고 규정하고 있으며, 같은 법 제87조제4항에서는 관리 대상이 되는 채권·채무의 범위, 채권의 보전 및 그 밖에 채권 관리에 필요한 사항은 대통령령으로

정하도록 하고 있습니다. 따라서 자치법규로 채권의 전부 또는 일부를 면제할 때에는 「지방재정법」 제87조와 같은 조에 따라 위임된 「지방재정법 시행령」의 관련 규정을 위반하지 않는 범위에서 조례로 정해야 할 것입니다.

그런데 「지방재정법 시행령」 제130조에 따르면, 채무자가 무자력하거나 이에 가까운 상태에 있다는 이유로 이행연기의 특약을 한 채권으로서 당초의 이행기부터 10년을 경과한 후에도 채무자가 무자력하거나 이에 가까운 상태에 있고 이행할 수 있는 가망이 없다고 인정되는 경우에는 당해 채권과 이에 관한 연체금 및 이자를 면제할 수 있고(제1항), 이행연기의 특약을 한 채권에 대하여 연납이자를 붙인 경우에 채무자가 당해 채권의 금액(연납이자를 제외한다)의 전부에 상당하는 금액을 그 연장된 이행기내에 납부하는 때에는 연납이자에 대하여는 채권자의 자력상태에 비추어 부득이하다고 인정되는 경우에 한하여 그 전부 또는 일부에 상당하는 금액을 면제할 수 있습니다(제2항). 또한 같은 법 시행령 제131조 제2항에서는 채권 원금의 전부에 상당하는 금액이 변제된 때에 그때까지 붙은 연체금의 전부 또는 일부를 면제할 수 있는 채권의 종류로 지방자치단체가 설치한 교육시설에서 징수하는 수업료 또는 기숙사 사용료(제1호), 지방자치단체가 설치한 의료시설에서 환자로부터 징수하는 모든 비용(제2호), 채무자의 고의 또는 중대한 과실에 의하지 아니한 부당이득반환금(제3호)을 규정하고 있습니다.

이러한 관련 법령의 규정을 보면, 「지방재정법 시행령」 제130조제1항·제2항 및 제131조제2항에서는 "…한 경우에는…면제할 수 있다"고 함으로써 일정한 요건을 갖춘 경우에 해당 행정작용을 할 수 있다는 형식으로 규정하고 있습니다. 그런데 만약, 이를 일정 요건을 갖추지 못한 경우에 대해서는 해당 법령에서 직접 규정하지 않고 있는 것으로 해석한다면, 법령이 정한 요건에의 해당 여부와 무관하게 해당 행정작용을 할 수 있다는 결과가 되어 '일정한 요건'을 정하여 '일정한 행정작용'을 할 수 있도록 한 해당 규정이 무의미하게 될 것입니다. 그렇다면 이는 일정한 요건에 해당하는 경우에 '한하여' 해당 행정작용을 할 수 있는 권한(재량)을 부여한 것으로 보아야 할 것인바, 위에서 살펴본 「지방재정법 시행령」 제130조제1항·제2항 및 제131조제2항의 면제요건을 갖춘 경우에만 채권, 이자 또는 연납이자를 면제할 수 있는 것으로 보아야 할 것입니다(법제처 2015. 1. 22. 의견제시 15-0005 및 2013. 3. 8. 의견제시 13-0049 참조).

따라서, 융자금을 지원받고 10년이 경과한 채무자가 미상환한 원금 전액을 상환하는 경우, 해당 채무자가 「지방재정법 시행령」 제130조제1항·제2항 및 제131조제2항에 규정된 요건을 갖추지 못한 경우에도 장흥군규칙안에 따라 이자와 연체이자를 감면해 주는 것은 「지방자치법」 제22조와 「지방재정법 시행령」 제130조제1항·제2항 및 제131조제2항을 위반하는 것으로 보입니다.











제 4 편

지방의회

1. 지방의회의원의 발의로 조례에 규정할 수 있는 내용인지 (지방자치단체의 장의 고유권한 침해 여부)

「지방자치법」은 지방자치단체의 의사를 내부적으로 결정하는 최고의결기관으로 지방의회를, 외부에 대하여 지방자치단체의 대표로서 지방자치단체의 의사를 표명하고 그 사무를 통할하는 집행기관으로 단체장을 독립한 기관으로 두고, 의회와 단체장에게 독자적인 권한을 부여하여 상호 견제와 균형을 이루도록 하고 있으므로, 법률에 특별한 규정이 없는 한 조례로써 견제의 범위를 넘어서 상대방의 고유권한을 침해하는 규정을 제정할 수 없다. 지방의회는 조례의 제정 및 개폐, 예산의 심의·확정, 결산의 승인, 기타 「지방자치법」 제47조제1항에 규정된 사항에 대한 의결권을 가지는 외에 같은 법 제49조 등의 규정에 의하여 지방자치단체사무에 관한 행정사무 감사권 및 조사권 등을 가지므로, 이처럼 법령에 의하여 주어진 권한의 범위 내에서 집행기관을 견제할 수 있는 것이지 법령에 규정이 없는 새로운 견제장치를 만드는 것은 집행기관의 고유권한을 침해하는 것이 되어 허용할 수 없다[13].

● 예산편성·집행권

「지방자치법」 제47조제1항제2호 및 제142조제1항에서는 예산편성권을 지방자치단체의 장에게, 예산의 심의·확정권을 지방의회에 각각 부여하여 예산에 관한 권한을 지방자치단체의 장과 지방의회에 배분하고 있다. 지방의회는 지방자치단체의 장의 동의 없이는 지출예산 각 항의 금액을 증가하거나 새로운 비용항목을 설치할 수 없다(「지방자치법」 제142조제3항).

따라서 예산편성을 강제하는 것과 같이 예산편성권을 실체적으로 제약하는 자치법규의 경우에는 지방자치단체의 장의 전속적인 권한을 침해하는 것으로 볼 수 있을 것이다. 다만, 판례는 예산낭비 사례 등을 공개하도록 하고 예산성과금의 지급한도를 제한하는 자치법규의 경우에는 지방자치단체의 장의 예산집행 등에 관한 권한을 본질적으로 침해한다고 볼 수 없다고 판시했다[14].

13) 대법원 2012. 11. 29. 선고 2011추87 판결 참조
14) 『자치법규 입안 길라잡이(2022)』 62쪽 참조

● 인사에 관한 권한

집행기관의 인사권은 판례가 대표적으로 집행기관의 고유권한에 속한다고 보는 권한으로 이러한 인사권은 매우 포괄적인 개념이다. 기본적으로 임면이나 위촉·해촉처럼 공무원이나 위원 신분의 발생·소멸에 관한 권한은 당연히 여기에 포함된다. 뿐만 아니라 신분·직위의 변경에 관한 권한, 예컨대 파견이나 징계에 관한 권한도 인사권의 범위에 포함된다고 볼 수 있다.

고유권한 침해인지를 판단함에 있어서 대법원이 고려하는 요소로는 ① 지방의회의원의 개인 자격에서 관여하는지, ② 상위법령에서 부여한 권한을 제약하는지, ③ 사전적·적극적으로 개입하는지 등이 있다[15].

15) 『자치법규 입안 길라잡이(2022)』 54·55쪽 참조

사례 26

지방자치단체의 장의 예산편성권을 침해하지 않는다고 본 사례

(질의 가)

2024. 10. 16. 의견제시 24-0321

질의요지

가. 지방의회의원이 발의하여 도지사로 하여금 100세가 된 주민에게 100만원 이내의 장수축하금을 1회 지급할 수 있도록 하는 내용을 조례에 규정할 수 있는지?

나. 질의 가와 같은 내용을 조례에 규정하면서 부칙에 조례 시행 당시 100세가 넘은 주민에게도 장수축하금을 지급한다는 특례를 규정할 수 있는지?

의 견

가. 질의 가에 대하여

아래 이유를 참고하시기 바랍니다.

나. 질의 나에 대하여

아래 이유를 참고하시기 바랍니다.

이 유

가. 질의 가에 대하여

「지방자치법」 제47조제1항제2호 및 제142조제1항에서는 예산의 심의·확정권을 지방의회에, 예산안의 편성권을 지방자치단체의 장에게 각각 부여하고 있는바, 「지방자치법」상 예산 편성 및 확정과 관련하여 의결기관과 집행기관 간에 권한을 분리·배분하고, 지방의회에서 예산안에 대한 심의 및 결산 승인을 통해 지방자치단체의 장의 예산 집행에 대해 사후에 감시·통제할 수 있도록 함으로써 상호 견제와

균형을 유지하도록 하고 있는 취지를 고려하면, 지방자치단체는 자치사무에 관하여 법률에 규정이 없는 한 지방자치단체의 장의 예산편성권을 침해하지 않는 범위에서 조례를 제정할 수 있을 것입니다(대법원 2012. 11. 29. 선고 2011추87 판결 참조).

이 사안에서는 지방의회의원이 발의하여 도지사로 하여금 100세가 된 주민에게 100만원 이내의 장수축하금을 1회 지급할 수 있도록 하는 내용을 조례에 규정하는 것이 「지방자치법」에 따른 지방자치단체의 장의 고유권한인 예산편성권을 침해하는지가 문제됩니다.

살피건대, 지방보조금 지급과 관련한 조례의 내용이 지방자치단체의 장의 예산편성권을 침해하는지 여부는 상위법령의 규정 내용, 조례 규정 간 체계 및 문언의 의미, 보조금 지급 근거규정의 형식 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 할 것인데(법제처 2022. 9. 22. 의견제시 22-0239 참조), 일반적으로 지방보조금의 지급 근거에 관한 규정은 "지원하여야 한다"와 같이 의무부과 형식으로 하지 않고 "지원할 수 있다"와 같이 권한부여 형식을 취하게 되는바, 이는 의무부과 형식으로 규정하면 보조금 지급에 관한 재량의 여지가 없어져 재정의 탄력적 운영이 어려워지고, 소요예산의 편성 및 집행권은 지방자치단체의 장의 고유한 권한임에도 불구하고 조례에서 강행규정 방식으로 규정하게 되면 지방자치단체의 장의 권한을 침해할 우려가 있기 때문입니다(법제처, 『2022 자치법규 입안 길라잡이』 116쪽 참조).

이 사안의 경우, '강원특별자치도 장수어르신 축하금 지급 조례안'(이하 "강원특별자치도조례안"이라 한다) 제2조제1호에서는 "장수어르신"이란 주민등록상의 나이가 100세가 된 사람을 말한다고 규정하고 있고, 제4조제1항에서는 도지사는 장수어르신에게 예산의 범위에서 100만원 이내의 장수축하금을 "지급할 수 있다"고 규정하고 있으며, 같은 조 제2항에서는 장수축하금 신청과 지급 절차 및 방법 등에 관한 세부적인 사항은 도지사가 따로 정하도록 규정하고 있는바, 이러한 규정은 도지사에게 장수축하금의 예산 편성 및 집행에 관하여 재량권을 부여하고 있는 것으로 보여지고, 도지사에게 반드시 해당 예산을 편성하여 집행할 의무를 부과하는 등 「지방자치법」에 따른 도지사의 권한을 침해할 정도의 견제장치를 두고 있는 것으로 보이지 않으므로, 질의요지와 같은 내용을 조례에 규정하는 것이 도지사의 예산편성권을 침해하는 것으로 보기 어려워 보입니다(법제처 2024. 6. 5. 의견제시 24-0117, 2021. 5. 18. 의견제시 21-0163, 2017. 9. 22. 의견제시 17-0233 참조).

다만, 강원특별자치도조례안 제4조제1항에서는 장수축하금을 "한 차례만" 지급할 수 있다고 규정하고 있어 도지사로 하여금 지급 횟수에 관한 재량의 여지 없이 대상자별로 1회만 지급할 수 있도록 강제하는 규정으로 해석될 소지가 있어 보이는바, 해당 규정에서 지급 횟수에 관한 사항을 삭제하고 "예산의

범위에서 지원할 수 있다"와 같이 장수축하금의 예산 편성 및 집행에 관하여 도지사에게 재량을 부여하는 취지가 명확하게 반영되도록 수정하는 것이 바람직할 것으로 보입니다(법제처 2024. 2. 29. 의견제시 24-0049 참조).

나. 질의 나에 대하여

질의 가에서 살펴본 것처럼, 강원특별자치도조례안에 따른 장수축하금 지급이 도지사의 예산편성권을 침해하는지는 지급 근거규정의 형식 등을 고려하여 판단해야 할 것인데, 강원특별자치도조례안 부칙 제2조에서는 이 조례 시행 당시 강원특별자치도에 주민등록을 1년 이상 계속하여 두고 거주하는 100세 이상인 사람에게 장수축하금을 "지급한다"고 규정하고 있는바, 문언상 이는 도지사에게 장수축하금의 예산 편성 및 집행에 관하여 재량권을 부여하지 않고, 조례 시행 당시 100세 이상인 사람에게 장수축하금을 지급하도록 하는 것으로서, 도지사의 고유권한인 예산편성권을 침해할 소지가 있는 것으로 보입니다.

다만, 강원특별자치도조례안 부칙 제2조가 조례 시행 당시 100세 이상인 사람에게는 반드시 장수축하금을 지급하도록 강제하려는 취지의 규정이 아니라, 해당 조례안의 시행으로 주민등록상 나이가 100세가 된 장수어르신에게 장수축하금을 지급하게 되는 경우에는 조례 시행 당시 이미 100세가 넘은 사람에게도 장수축하금을 지급할 수 있도록 소급적용하는 취지의 규정이라면, 그러한 취지가 명확히 드러나도록 "예산의 범위에서 장수축하금을 지급할 수 있다"는 형식으로 변경하여 규정하는 것이 바람직해 보이는바, 이러한 점을 자치법규 입안 시 참고하시기 바랍니다(법제처 2021. 5. 18. 의견제시 21-0163 참조).

사례 27

지방자치단체의 장의 예산편성권을 침해할 소지가 있다고 본 사례

2022. 9. 22. 의견제시 22-0239

질의요지

지방의회의원 발의로 양양군의 청소년에게 희망키움 바우처를 지원하는 조례를 제정하면서 지급대상, 지급액, 지급절차 등을 구체적으로 조례안에 규정하는 것이 지방자치단체장의 예산편성권을 침해하는지?

의 견

이 사안의 경우 질의요지와 같은 내용을 조례에 규정하는 것은 지방자치단체장의 예산편성권을 침해하는 것으로 보이므로 조례 입안에 신중하시기 바랍니다.

이 유

「지방자치법」 제47조제1항제2호 및 제142조제1항에서는 예산의 심의·확정권을 지방의회, 예산안의 편성권을 지방자치단체의 장에게 각각 부여하고 있는바, 「지방자치법」상 예산 편성 및 확정과 관련하여 의결기관과 집행기관 간에 권한을 분리·배분한 취지 및 지방의회에서 예산안에 대한 심의 및 결산 승인을 통해 지방자치단체장의 예산 집행에 대해 사후에 시·통제할 수 있다는 점 등을 고려하면 지방자치단체의 조례에서 지방자치단체장의 예산편성권을 침해하는 내용을 규정하는 것은 「지방자치법」의 취지에 반한다고 할 것입니다.

이때 지방보조금 지급과 관련한 조례의 내용이 지방자치단체장의 예산편성권을 침해하는지 여부는 상위 법령의 규정 내용, 조례 규정 간 체계 및 문언의 의미, 보조금 지급 근거규정의 형식 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 할 것입니다.

먼저, 지방보조금의 지급 근거에 관한 규정은 “지원하여야 한다”와 같이 의무부과 형식으로 하지 않고 “지원할 수 있다”와 같이 권한부여 형식을 취하게 되는바, 이는 의무부과 형식으로 규정하면 보조금 지급에 관한 재량의 여지가 없어져 재정의 탄력적 운영이 어려워지고, 소요예산의 편성 및 집행권은 지방자치단체의 장의 고유한 권한임에도 불구하고 조례에서 강행규정 방식으로 규정하게 되면 지방자치단체의 장의 권한을 침해할 우려가 있기 때문입니다.

이와 관련하여 「양양군 청소년 희망키움 바우처 지원 조례안」(이하 “양양군조례안”이라 한다) 제3조제1항에서는 군수는 청소년 희망키움 바우처 지원을 위하여 필요한 예산을 마련하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조례안 제7조에서는 군수는 양양군에 주민등록을 둔 13세부터 18세까지의 청소년에게 청소년 희망키움 바우처를 지급한다고 규정하여 보조금 지급에 관하여 확정적으로 규정하고 있습니다.

또한, 양양군조례안 제8조에서는 지급액을 13세부터 15세까지 월 5만원(제1호), 16세부터 18세까지 월 7만원(제2호)으로 규정하고 있고, 같은 조례안 제9조에서는 신청방법을, 제11조에서는 지급시기 및 지급방법을, 제12조에서는 지급 정지 및 환수 등에 대해 구체적으로 규정하고 있습니다.

그렇다면 양양군조례안의 내용들을 종합적으로 고려해 볼 때, 같은 조례안은 청소년 희망키움 바우처 지급과 관련하여 군수가 재량권을 전혀 행사할 수 없도록 규정된 것으로 보입니다.

따라서 질의요지와 같은 내용을 조례에 규정하는 것은 지방자치단체장의 예산편성권을 침해하는 것으로 보이므로 조례 입안에 신중하시기 바랍니다.

사례 28

지방자치단체의 장의 집행권한을 침해하지 않는다고 본 사례

(질의 나)

2024. 8. 28. 의견제시 24-0269

질의요지

가. 민원 처리 담당자를 보호하기 위한 조치로서 민원인이 폭언·폭행 등을 하는 경우 녹음·녹화 등의 절차를 거쳐 민원 응대를 종료할 수 있도록 하는 등 민원 처리 담당자의 민원 응대방법에 관한 구체적인 내용을 조례에 규정할 수 있는지?

나. (질의 가가 가능하다면) 지방의회의원이 발의하여 민원 처리 담당자의 민원 응대방법에 관한 구체적인 내용을 조례에 규정할 수 있는지?

다. (질의 가가 가능하다면) 행정안전부에서 마련·배포한 「공직자 민원응대 매뉴얼」의 내용과 다르게 민원 처리 담당자의 민원 응대방법에 관한 구체적인 내용을 조례에 규정할 수 있는지?

의 견

가. 질의 가에 대하여

아래 이유를 참고하시기 바랍니다.

나. 질의 나에 대하여

아래 이유를 참고하시기 바랍니다.

다. 질의 다에 대하여

아래 이유를 참고하시기 바랍니다.

이 유

가. 질의의 공통사항

「민원 처리에 관한 법률」(이하 "민원처리법"이라 한다) 제4조제1항에서는 민원을 처리하는 담당자는 담당 민원을 신속·공정·친절·적법하게 처리하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 행정기관의 장은 민원인 등의 폭언·폭행, 목적이 정당하지 아니한 반복 민원 등으로부터 민원 처리 담당자를 보호하기 위하여 민원 처리 담당자의 신체적·정신적 피해의 예방 및 치료 등 대통령령으로 정하는 필요한 조치를 하여야 한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 「민원 처리에 관한 법률 시행령」(이하 "민원처리법시행령"이라 한다) 제4조제1항에서는 법 제4조제2항에서 "민원 처리 담당자의 신체적·정신적 피해의 예방 및 치료 등 대통령령으로 정하는 필요한 조치"란 민원인의 폭언·폭행 등이 발생한 경우 민원인으로부터 민원 처리 담당자를 보호하기 위한 조치로서 민원 처리 담당자의 분리 또는 업무의 일시적 중단(제3호) 등의 조치(이하 "보호조치"라 한다)를 말한다고 규정하고 있고, 같은 조 제4항에서는 국가, 지방자치단체 및 법 제2조제3호나목·다목에 따른 행정기관의 장은 제1항의 조치를 위하여 필요한 사항을 관계 법령이나 자치법규 등으로 정할 수 있다고 규정하고 있습니다.

한편, 민원처리법시행령 제4조제4항에 따라 마련하려는 '고흥군 공무원 민원응대에 관한 조례안'(이하 "고흥군조례안"이라 한다)은 고흥군 공무원의 민원응대에 관한 사항을 규정함으로써 민원인의 권익을 보호하고 특이민원으로 인한 공무원의 신체적·정신적 피해를 사전에 예방함을 목적으로 하는 조례로서, 제2조제1호에서는 "특이민원"이란 신체에 폭행을 가하거나 상해를 입히는 행위(가목) 등의 행위를 말한다고 하고 있고, 제4조 및 제5조에서는 민원 처리 담당자에 대한 보호조치로서 특이민원에 대한 전화 및 대면 응대방법을 각각 정하고 있는데, 특이민원을 전화로 응대하는 경우에는 민원인에 대한 폭언·성희롱 발언의 중지 요청, 녹음 실시, 관련 법령에 따른 처벌 경고 등의 일정한 절차를 거쳐 통화를 종료할 수 있도록 하고 있고(제4조제1항), 특이민원을 대면으로 응대하는 경우에는 비상대응팀을 구성하여 녹화·녹음 실시, 민원인 격리 등의 업무분장에 따라 대응하도록 하고 있으며(제5조제1항), 동일한 민원인의 특이민원이 반복되는 경우에는 팀장 또는 부서장이 특이민원을 응대하도록 규정하려 하고 있습니다(제4조제3항 및 제5조제3항).

나. 질의 가에 대하여

일반적으로 상위법령의 위임에 따라 자치법규를 정립하게 되는 경우에는 상위법령에서 정해 놓고 있는 자치법규의 입법형식을 따르면 되지만, 상위법령에서 별도로 자치법규의 입법형식을 정하고 있지 않은 경우에는 우선적으로 사무의 성격과 「지방자치법」 등 관계 법령을 검토하여 그에 맞는 입법형식을 선택해야 할 것입니다(법제처, 『2022 자치법규 입안 길라잡이』, 2022, 11쪽 및 12쪽 참조).

먼저, 민원처리법시행령 제4조제4항에서는 국가, 지방자치단체 등은 민원 처리 담당자에 대한 보호조치를 위하여 필요한 사항을 '관계 법령이나 자치법규 등'으로 정할 수 있도록 규정하고 있어 입법형식에 대해 제한을 두고 있지 않은바, 지방자치단체는 실시하려는 보호조치의 구체적인 내용에 따라 그에 적합한 형식의 '자치법규 등'을 선택하여 관련 내용을 정할 수 있을 것으로 보입니다.

한편, 「지방자치법」에서는 민원을 응대하는 방법 및 절차에 관한 내용을 별도로 정하고 있거나 조례로 정하도록 위임하는 규정을 두고 있지 않고 있고, 고흥군조례안에서 민원 응대방법을 규정하려는 취지는 민원인의 권익을 보호하고 특이민원으로부터 민원 처리 담당자를 보호하기 위한 것으로서, 민원인 응대에 관한 사무는 행정기관이 행정 목표를 설정하고 그것을 효과적으로 달성하기 위해 기획·조직하고 지도·조정·통제하는 관리 업무의 일환으로서 「지방자치법」 제13조제2항제1호에서 자치사무의 하나로 예시하고 있는 행정관리사무에 해당하는 것으로 보이는바(법제처 2013. 6. 4. 의견제시 13-0162 참조), 이러한 사무의 집행 방법·절차에 관한 사항을 조례로 정하는 것은 가능할 것으로 보입니다.

따라서, 민원 처리 담당자를 보호하기 위한 조치로서 민원인이 폭언·폭행 등을 하는 경우 녹음·녹화 등의 절차를 거쳐 민원 응대를 종료할 수 있도록 하는 등 민원 처리 담당자의 민원 응대방법에 관한 구체적인 내용을 조례에 규정할 수 있을 것으로 보입니다.

다. 질의 나에 대하여

「지방자치법」은 의결기관으로서의 지방의회와 집행기관으로서의 지방자치단체의 장에게 독자적 권한을 부여하는 한편, 지방의회는 행정사무감사와 조사권 등에 의하여 지방자치단체의 장의 사무집행을 감시·통제할 수 있게 하고 지방자치단체의 장은 지방의회의 의결에 대한 재의 요구권 등으로 의회의 의결권 행사에 제동을 가할 수 있게 함으로써 상호 견제와 균형을 유지하도록 하고 있으므로, 지방의회는 자치사무에 관하여 법률에 특별한 규정이 없는 한 지방자치단체의 장의 고유권한에 관하여는 조례로 이를 침해할 수 없고, 고유권한이 아닌 사항에 대해서도 그 사무집행에 관한 집행권을 본질적으로 침해하

는 것은 허용되지 않습니다(대법원 2001. 11. 27. 선고 2001추57 판결, 법제처 2024. 6. 25. 의견제시 24-0138 참조).

살피건대, 고흥군조례안 제4조 및 제5조에서는 특이민원에 대한 전화 및 대면 응대방법으로 폭언·성희롱 발언의 중지 요청, 비상대응팀의 구성·운영, 녹음·녹화 실시, 관련 법령에 따른 처벌 경고 등의 구체적인 민원 응대방법에 관한 사항을 규정하고 있는데, 이러한 민원 응대방법은 집행기관 내부의 업무처리 방법 및 절차에 관한 사항이기는 하나, 제4조제1항에서는 '민원처리 담당자는 … 종료할 수 있다'와 같이 집행기관에 재량을 부여하는 형식을 취하고 있고, 제4조제3항 및 제5조제1항·제3항에서는 '응대한다' 또는 '대응한다'와 같이 의무를 나타내는 서술어를 사용하고 있으나 이 규정의 취지가 민원처리 담당자를 특이민원으로부터 보호하기 위한 것으로서, 해당 규정에서 정하고 있는 방법과 절차를 거치지 않고 특이민원을 처리한다 하더라도 민원 처리 담당자에 대한 어떠한 불이익도 없는 점 등을 고려할 때, 이 사안에서의 민원 응대방법에 관한 규정은 민원 처리 담당자에게 의무를 부과하려는 취지가 아니라 일반적인 업무 처리 원칙과 기준을 제시하는 규정으로 보는 것이 타당한바, 이 사안에서의 민원 응대방법에 관한 내용이 지방자치단체의 장의 민원사무에 관한 집행권한을 본질적으로 침해한다고 보기는 어려워 보입니다.

따라서, 이 사안의 경우 지방의회의원이 발의하여 민원 처리 담당자의 민원 응대방법에 관한 구체적인 내용을 조례에 규정할 수 있을 것으로 보입니다.

다만, 앞서 살펴본 것처럼 이 사안에서의 민원 응대방법에 관한 규정이 특이민원 응대에 대한 원칙과 기준을 제시하는 규정에 해당한다 하더라도, 고흥군조례안 제4조제3항 및 제5조제1항·제3항은 제4조제1항과 다른 방식으로 서술됨으로써, 특이민원이 반복하여 발생한 경우와 전화가 아닌 대면으로 특이민원을 응대하는 방법에 대해서는 민원 처리 담당자가 각 민원의 개별성·특수성과 민원 처리 상황, 조직 구성원 등을 고려하지 않고 일률적으로 조례에서 정하고 있는 방법과 절차에 따라 특이민원을 처리해야 하는 것으로 오해될 수 있는 것으로 보이는바, 서술어를 집행기관의 재량이 인정되는 형식의 용어로 수정하거나, 민원 처리 담당자에 대한 보호조치의 실시 근거만 조례에 규정하고, 보호조치의 구체적인 내용으로서 특이민원에 대한 응대방법에 대해서는 규칙 또는 행정규칙(행정조직 내부의 사무 처리 절차 등을 규율하는 훈령·예규 등을 말함)으로 정하도록 위임하는 방안도 고려할 수 있을 것이므로, 이러한 점을 자치법규 입안 시 참고하시기 바랍니다.

라. 질의 다에 대하여

행정안전부에서 마련하여 배포한 「공직자 민원응대 매뉴얼」(이하 “민원매뉴얼”이라 한다)은 민원처리 담당자가 민원 업무를 수행하면서 참고할 수 있도록 구체적인 민원 응대방법을 제시한 가이드라인으로서, 그 내용으로는 민원응대 관련 기본원칙, 일반적인 민원 응대요령 및 폭언·성희롱 등 유형별 특이민원에 대한 응대방법에 관하여 규정하고 있으며, 민원 현장에서 발생하는 다양한 응대 상황에 맞게 민원매뉴얼의 내용을 적절히 활용하도록 하고 있습니다.

이와 같이, 민원매뉴얼은 현행 민원처리법의 위임에 의하지 않고 마련된 민원 응대 가이드라인으로, 민원 업무를 수행하는 지방자치단체에 대하여 구속력이 있는 법규명령으로서의 효력을 가지는 것은 아니라 할 것인바, 고흥군에서 민원매뉴얼의 내용과 다르게 민원 처리 담당자의 구체적인 민원 응대방법에 관한 내용을 조례에 규정하는 것이 불가능한 것으로 보이지 않습니다.

다만, 민원처리법 제4조제2항에서는 민원 처리 담당자에 대한 보호조치에 관한 사항을 규정하면서, 제5조제1항에서는 민원인은 행정기관에 민원을 신청하고 신속·공정·친절·적법한 응답을 받을 권리가 있다고 규정하고 있으므로, 귀 군에서는 민원매뉴얼과 다르게 규정하려는 구체적인 민원 응대방법이 민원 처리 담당자와 민원인의 권익 간의 균형 등에 비추어 타당한지에 대해서는 신중히 검토할 필요가 있는 것으로 보이는바, 이러한 점을 자치법규 입안 시 참고하시기 바랍니다.

사례 29 지방자치단체의 장의 집행권한을 침해할 소지가 있다고 본 사례

2024. 12. 24. 의견제시 24-0456

질의요지

가. 지방의회의원이 발의하여 주유소·축사·공장 등의 설치·운영에 관한 인·허가 등 신청이 있는 경우 청주시장이 신청인의 동의 없이 해당 인·허가 등의 신청 접수일부터 7일 이내에 해당 시설에 관한 내용 등을 대상 지역 주민에게 고지하도록 하는 내용을 조례에 규정할 수 있는지?

나. 지방의회의원이 발의하여 주유소·축사·공장 등의 설치·운영에 관한 인·허가 등 신청이 있는 경우 청주시장이 신청인의 동의를 얻어 해당 인·허가 등의 신청 접수일부터 7일 이내에 해당 시설에 관한 내용 등을 대상 지역 주민에게 고지하도록 하는 내용을 조례에 규정할 수 있는지?

의 견

가. 질의 가에 대하여

아래 이유를 참고하시기 바랍니다.

나. 질의 나에 대하여

아래 이유를 참고하시기 바랍니다.

이 유

가. 질의 가 및 질의 나의 공통사항

「지방자치법」 제28조제1항 본문에 따르면 지방자치단체는 법령의 범위에서 그 사무에 관하여 조례를 제정·개정할 수 있는데, 여기서 "법령의 범위"란 "법령에 위반되지 않는 범위"를 의미하므로, 지방자치단체가 조례를 제정·개정하기 위해서는 조례로 정하려는 사항이 법령에 위반되지 않아야 할 것이고, 「지방자치법」에서는 지방의회와 지방자치단체의 장에게 각각 독자적 권한을 부여하고 상호 견제와 균형을

이루도록 하고 있으므로, 법률에 특별한 규정이 없는 한 조례로써 견제의 범위를 넘어서 고유권한을 침해하는 규정을 둘 수 없을 것입니다(대법원 2002. 4. 26. 선고 2002추23 판결 참조).

그리고, 「민원 처리에 관한 법률」(이하 "민원처리법"이라 한다) 제2조제1호가목1)에서는 법령 등에서 정한 일정 요건에 따라 인가·허가 등을 신청하는 등의 민원을 법정민원으로 규정하고 있고, 같은 조 제3호가목에서는 민원처리법에서의 "행정기관"으로 지방자치단체와 그 소속 기관을 포함하여 규정하고 있으며, 제7조에서는 행정기관의 장은 민원 처리와 관련하여 알게 된 민원의 내용과 민원인 및 민원의 내용에 포함되어 있는 특정인의 개인정보 등이 누설되지 아니하도록 필요한 조치를 강구하여야 하며, 수집된 정보가 민원 처리의 목적 외의 용도로 사용되지 아니하도록 하여야 한다고 규정하고 있는 한편, '청주시 갈등유발 예상시설 사전고지 및 주민 요청 간담회에 관한 조례안'(이하 "청주시조례안"이라 한다) 제2조제4호에서는 "사전고지"란 주민 건강이나 생활에 직접적인 피해를 끼칠 우려가 있는 시설에 대하여 시에서 접수한 행정행위에 대하여 인근 주민에게 미리 알리는 행위를 말한다고 하고 있고, 안 제5조 및 별표에서는 사전고지 대상시설로 주유소·축사 등을 정하고 있으며, 안 제7조에서는 대상 시설의 용도(제1호) 및 대지 위치(제2호) 등을 사전고지 내용으로 하고 있고, 안 제8조제1항에서는 시장은 사전고지 대상시설에 대한 인·허가 신청 등의 접수일부터 7일 이내에 시청 홈페이지(제1호) 등에 사전고지를 해야 한다고 하고 있습니다.

나. 질의 가에 대하여

살피건대, 민원처리법 제7조에서는 민원인 및 민원의 내용에 포함되어 있는 특정인의 개인정보 외에도 "민원의 내용" 자체가 누설되지 않도록 필요한 조치를 강구할 의무를 행정기관의 장에게 부여하고 있는 것이 문언상 명백해 보이고(법제처 2021. 2. 24. 의견제시 21-0024, 2023. 7. 25. 의견제시 23-0219, 2021. 4. 28. 의견제시 21-0105 참조), 해당 규정은 민원의 내용과 민원인 및 민원 내용에 포함된 특정인의 신상정보 등이 누설되는 것을 방지함으로써 민원인 등의 권익이 침해되지 않도록 하는 것 등에 그 입법취지가 있는 것으로 보이는바(2015. 4. 29. 의안번호 제1914930호로 발의된 민원사무 처리에 관한 법률 일부개정법률안(대안반영폐기) 의안원문의 제안이유 및 주요내용 참조), 주유소·축사·공장 등의 설치·운영에 관한 인·허가 등 신청이 있는 경우 신청인의 동의 없이 해당 시설에 관한 내용 등을 대상 지역 주민에게 고지하도록 하는 내용을 조례에 규정하는 것은 민원처리법 제7조에 위반될 소지가 있어 보입니다.

아울러, 청주시조례안에 따른 사전고지 절차는 지역사회에서 갈등 발생이 예상되는 시설의 설치에 관하여 인·허가 등의 접수 단계에서 주민에게 해당 시설에 관한 정보를 제공하려는 제도로서, 인·허가

등 처분을 하기 전에 의견제출 및 간담회(안 제9조 및 제10조) 등을 통해 주민의 의견을 수렴하기 위한 사전 절차로 보이는데, 안 제8조제1항에 따르면 안 별표에 따른 사전고지 대상시설에 대한 인·허가 신청 등이 접수되는 경우 재량의 여지 없이 청주시장은 대상지역 주민에게 사전고지를 해야 할 의무가 발생하는 것처럼 보이는바, 사전고지 대상시설의 설치에 관한 인·허가 등의 근거가 되는 법령에서 해당 신청 내용 등을 사전고지하도록 명시적으로 규정하고 있는 경우가 아닌 한, 지방의회의원이 발의하여 조례에서 인·허가 등의 처분권자인 지방자치단체의 장에게 사전고지 의무를 부과하는 것은 인·허가 처리 등의 업무와 관련한 지방자치단체의 장의 집행권한을 침해할 소지가 있어 보이는바, 자치법규 입안 시 신중하시기 바랍니다.

다. 질의 나에 대하여

살피건대, 민원처리법 제7조에서는 행정기관의 장으로 하여금 민원 처리와 관련하여 알게 된 민원의 내용과 민원인 및 민원의 내용에 포함되어 있는 특정인의 개인정보 등이 누설되지 아니하도록 필요한 조치를 강구하도록 규정하고 있는데, 질의 가에서 살펴본 것처럼 민원처리법 제7조의 입법취지는 민원 내용과 민원인 및 특정인[16]의 신상정보 등이 누설되는 것을 방지함으로써 민원인 등의 권익이 침해되지 않도록 하는 것에 있는 점을 고려하면, 해당 규정에서의 "누설"이란 민원 내용 등을 아직 알지 못하는 제3자에게 '임의'로 알려주는 행위를 의미하는 것으로 보이는바(법제처 2021. 2. 24. 의견제시 21-0024 참조), 민원인이 인·허가 등을 신청한 시설에 관한 정보 등 민원 내용의 공개에 동의하는 경우라면 민원처리법 제7조에 따른 "누설"에 해당한다고 보기는 어려울 것입니다.

그러나, 질의 가에서 살펴본 것처럼, 사전고지 대상시설의 설치 등에 관한 인·허가 등의 근거가 되는 법령에서 해당 신청 내용 등을 사전고지하도록 명시적으로 규정하고 있는 경우가 아닌 한, 민원인이 민원 내용의 공개에 동의하는지 여부와는 별개로, 지방의회의원이 발의하여 조례에서 인·허가 등의 처분권자인 지방자치단체의 장에게 사전고지 의무를 부과하는 것은 인·허가 처리 등의 업무와 관련한 지방자치단체의 장의 집행권한을 침해할 소지가 있어 보이는바, 자치법규 입안 시 신중하시기 바랍니다.

16) 「개인정보보호법」 제2조제3호에서는 "정보주체"란 처리되는 정보에 의하여 알아볼 수 있는 사람으로서 그 정보의 주체가 되는 사람을 말한다고 규정하고 있고, 제17조제1항에서는 개인정보처리자는 "정보주체의 동의를 받은 경우"(제1호) 등에 '정보주체의 개인정보'를 제3자에게 제공할 수 있다고 규정하고 있어, 청주시조례안에 따라 공개하려는 민원 내용에 특정인의 개인정보가 포함되어 있는 경우 민원 내용을 지역 주민에게 공개하려면 특정인의 동의까지 받아야 할 것으로 보임

사례 30 지방자치단체의 장의 인사권을 침해할 소지가 있다고 본 사례

2024. 10. 23. 의견제시 24-0327

질의요지

가. 지방의회의원이 발의하여 세종특별자치시 소속 모든 공직자에게 적용되는 '세종특별자치시 공직자 이해충돌 방지 제도 운영지침'을 조례로 제정할 수 있는지?

나. 지방의회의원이 발의하여 세종특별자치시 소속 모든 공무원에게 적용되는 '세종특별자치시 공무원 행동강령'을 조례로 제정할 수 있는지?

의 견

가. 질의 가에 대하여

질의요지와 같은 내용의 조례를 제정할 수 없을 것으로 보입니다.

나. 질의 나에 대하여

질의요지와 같은 내용의 조례를 제정할 수 없을 것으로 보입니다.

이 유

가. 질의 가 및 질의 나의 공통사항

「지방자치법」 제28조제1항 본문에 따르면 지방자치단체는 법령의 범위에서 그 사무에 관하여 조례를 제정·개정할 수 있는데, 여기서 "법령의 범위"란 "법령에 위반되지 않는 범위"를 의미하므로, 지방자치단체가 조례를 제정·개정하기 위해서는 조례로 정하려는 사항이 법령에 위반되지 않아야 할 것이고, 또한 「지방자치법」은 지방의회와 지방자치단체의 장에게 각각 독자적 권한을 부여하고 상호 견제와 균형을 이루도록 하고 있으므로, 법률에 특별한 규정이 없는 한 조례로써 견제의 범위를 넘어서 고유권한을

침해하는 규정을 둘 수 없을 것입니다(대법원 2002. 4. 26. 선고 2002추23 판결 참조).

한편, 「지방자치법」 제103조제2항에서는 지방의회의 의장은 지방의회 사무직원을 지휘·감독하고 법령과 조례·의회규칙으로 정하는 바에 따라 그 임면·교육·훈련·복무·징계 등에 관한 사항을 처리한다고 규정하고 있고, 제118조에서는 지방자치단체의 장은 지방의회의 사무직원을 제외한 소속 직원을 지휘·감독하고 법령과 조례·규칙으로 정하는 바에 따라 그 임면·교육훈련·복무·징계 등에 관한 사항을 처리한다고 규정하고 있는바, 지방의회 사무직원과 지방자치단체의 집행기관 소속 직원의 복무 사항 처리 등 인사에 관한 권한을 각각 지방의회의 의장과 지방자치단체의 장에게 부여하고 있습니다.

나. 질의 가에 대하여

살피건대, 「공직자의 이해충돌 방지법」 제2조제1호나목에서는 「지방자치법」에 따른 지방자치단체의 집행기관 및 지방의회를 공공기관 중 하나로 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제33조제1항에서는 공공기관의 장은 법과 이 영의 시행에 필요한 범위에서 해당 기관의 특성에 적합한 기관별 이해충돌 방지 제도 운영지침을 제정해야 한다고 규정하고 있어, 문언상 지방의회의 의장은 지방의회 소속 공직자에게 적용되는 지침을, 지방자치단체의 장은 집행기관 소속 공직자에게 적용되는 지침을 제정하도록 각 소관을 구분하고 있는 것으로 보이는바, 이러한 규율 범위를 넘어서 지방자치단체의 장이 아닌 지방의회의원이 발의하여 집행기관 소속 공직자에게도 적용되는 이해충돌 방지 제도 운영지침을 조례로 제정하는 것은 상위법령에 위배될 소지가 있는 것으로 보입니다.

아울러, 「공직자의 이해충돌 방지법」에서는 직무관련자와의 거래 신고(제9조), 직무 관련 외부활동의 제한(제10조), 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지(제13조), 직무상 비밀 등 이용 금지(제14조) 등을 공직자의 이해충돌 방지에 관한 사항으로 규정하면서 그 위반행위에 대한 징계규정(제26조)을 두고 있는데, 이러한 내용은 공직자의 직무수행·복무 등과 관련 있는 사항으로서 그에 관한 권한은 인사권자의 고유권한으로 보이는바, 지방의회의원이 발의하여 집행기관 소속 공직자에게 적용되는 이해충돌 방지 제도 운영지침을 조례로 제정하는 것은 지방자치단체의 장의 고유권한인 인사권을 침해할 소지도 있어 보입니다.

따라서, 지방자치단체의 집행기관 소속 공직자에게 적용되는 공직자 이해충돌 방지 제도 운영지침을 지방의회의원이 발의하여 조례로 제정할 수는 없을 것으로 보입니다.

다. 질의 나에 대하여

살피건대, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제7조에서는 공직자는 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 집무하여야 하며 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다고 규정하고 있고, 제8조제1항에서는 제7조에 따라 공직자가 준수하여야 할 행동강령은 대통령령·국회규칙·대법원규칙·헌법재판소규칙·중앙선거관리위원회규칙 또는 공직유관단체의 내부 규정으로 정한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 「공무원 행동강령」 제2조제1호아목에서는 중앙행정기관의 장(대통령 소속 기관 및 국무총리 소속 기관의 장을 포함한다), 지방자치단체의 장, 지방의회의 장 및 교육감을 "중앙행정기관의 장등"으로 약칭하고 있고, 제24조제1항에서는 중앙행정 기관의 장등은 이 영의 시행에 필요한 범위에서 해당 기관의 특성에 적합한 세부적인 기관별 공무원 행동강령을 제정하여야 한다고 규정하고 있어, 문언상 지방의회의 의장은 지방의회 소속 공무원에게 적용되는 행동강령을, 지방자치단체의 장은 집행기관 소속 공무원에게 적용되는 행동강령을 제정하도록 각 소관을 구분하고 있는 것으로 보이는바, 이러한 규율 범위를 넘어서 지방자치단체의 장이 아닌 지방의회의원이 발의하여 집행기관 소속 공무원에게도 적용되는 행동강령을 조례로 제정하는 것은 상위법령에 위배될 소지가 있는 것으로 보입니다.

아울러, 「공무원 행동강령」에서는 공정한 직무수행에 관한 사항(제2장) 및 부당이득의 수수 금지(제3장) 등을 공무원이 준수해야 할 행동기준으로 규정하면서 그 위반행위에 대한 징계규정(제20조)을 두고 있는데, 이러한 내용은 공직자의 직무수행·복무 등과 관련 있는 사항으로서 그에 관한 권한은 인사권자의 고유권한으로 보이는바, 지방의회의원이 발의하여 집행기관 소속 공무원에게 적용되는 행동강령을 조례로 제정하는 것은 지방자치단체의 장의 고유권한인 인사권을 침해할 소지가 있어 보이며, 공직자 행동강령의 제정·시행 및 원활한 운영에 필요한 사항을 규정하는 것을 목적으로 하는 「공직자 행동강령 운영지침」(2024. 9. 10. 국민권익위원회예규 제322호로 일부개정되어 같은 날 시행된 것을 말함) 제4조제1항에서는 기관별 행동강령을 제정할 때 그 입법형식을 규정하고 있는데, 지방자치단체의 장이 행동강령을 제정할 때에는 "규칙으로" 정한다고 명시하고 있는 점을 고려할 때, 집행기관 소속 공무원에게 적용되는 행동강령에 관한 사항을 조례의 형식으로 정하는 것은 타당하지 않은 것으로 보입니다.

따라서, 지방자치단체의 집행기관 소속 공무원에게 적용되는 공무원 행동강령을 지방의회의원이 발의하여 조례로 제정할 수는 없을 것으로 보입니다.

사례 31 지방자치단체의 장의 조직편성권을 침해할 소지가 있다고 본 사례

2019. 10. 29. 의견제시 19-0304

질의요지

경기도교육청에서 자문기관으로 운영 중인 자문위원회를 의결기관으로 변경하여 운영하도록 하는 내용의 조례를 경기도의회 의원이 발의할 수 있는지(「경기도교육청 신설학교 개방 설계자문위원회 구성 및 운영 조례」 제7조제2항 등 관련)

의 견

이 사안의 경우 경기도의회 의원은 질의 내용의 조례를 발의할 수 없을 것으로 보입니다.

이 유

경기도의회 의원이 발의하는 「경기도교육청 학교 개방 설계심의위원회 구성 및 운영 조례안」(이하 "경기도교육청조례안"이라 함) 제2조제1항에서는 기존 「경기도교육청 신설학교 개방 설계자문위원회 구성 및 운영 조례」 제2조제1항에 따라 설치하여 운영하고 있는 "신설학교 개방 설계자문위원회(이하 "자문위원회"라 함)를 "학교 개방 설계심의위원회(이하 "심의위원회"라 함)"로 그 명칭을 변경하면서 심의를 강조하고 있고, 경기도교육청조례안 제7조제2항에서는 "사업시행자는 위원회의 심의결과를 반영하여야 한다"로 변경하면서, "심의위원회"의 심의결과에 행정관청인 경기도교육청이 따르도록 규정하고 있습니다.

이 사안에서는 자문기관으로 운영 중인 자문위원회를 심의위원회로 변경하여, 심의위원회의 심의·의결 결과에 행정관청인 경기도교육청이 따르도록 하는 의무를 지우도록 하는 내용의 조례안을 경기도의회 의원이 발의할 수 있는지에 대하여 질의한 것으로 보입니다.

먼저, 경기도교육청조례안에서 설치, 운영하고자 하는 심의위원회가 의결기관인지에 대해 살펴보면, 자문기관인 위원회와 의결기관인 위원회의 구분은 그 위원회의 결정에 구속력이 있는지를 기준으로 하는바, 자문기관인 위원회는 행정관청에 대하여 구속력이 없는 의사를 결정하는 위원회를 말하고, 의결기관인 위원회는 법령상 구속력이 있는 의사를 결정하는 위원회를 말하는 것입니다(법제처 2014. 2. 14 의견제시 14-0032 참조). 그런데 경기도교육청조례안 제6조제2항 본문에서 "위원회의 회의는 재적의원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석의원 과반수의 찬성으로 의결한다"로 변경하면서 위원회의 심의·의결기능을 신설하고 있고, 같은 조례안 제7조제2항에서는 "사업시행자는 위원회의 심의결과를 반영하여야 한다"로 변경하여 규정하면서 심의위원회의 심의·의결 결과를 행정관청인 경기도교육청이 반드시 반영하도록 하는 의무를 지우고 있어 그 의사와 판단이 행정관청을 법적으로 기속하는 의결기관인 위원회라 할 수 있을 것입니다.

아울러, 합의제행정기관의 설치와 관련하여, 합의제행정기관에는 그 의사와 판단을 결정하여 외부에 표시하는 권한을 가지는 합의제 행정관청뿐만 아니라 행정주체 내부에서 행정에 관한 의사 또는 판단을 결정할 수 있는 권한만을 가지는 의결기관도 포함되고(대법원 2000. 11. 10. 선고, 2000추36 판결 참조), 「지방자치법」 제116조(법률 제8423호로 개정되기 전의 같은 법 제107조)에 그 설치의 근거가 마련된 합의제행정기관은 지방자치단체의 장이 통할하여 관리·집행하는 지방자치단체의 사무를 일부 분담하여 수행하는 기관으로서, 그 사무를 독립하여 수행한다 할지라도 이는 어디까지나 집행기관에 속하는 것입니다. 이와 같은 합의제행정기관에 대한 「지방교육행정기관의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」 제3조, 제5조 및 제25조에 비추어보면, 특별지방행정기관인 집행기관으로서의 교육감은 집행기관에 속하는 행정기관 전반에 대하여 조직편성권을 가진다고 해석되는바, 교육감은 합의제행정기관을 설치할 고유의 권한을 가지며, 이러한 고유권한에는 그 설치를 위한 조례안의 제안권이 포함된다고 봄이 상당하므로, 지방의회가 합의제행정기관의 설치에 관한 조례안을 발의하여 이를 그대로 의결, 재의결하는 것은 교육감의 고유권한에 속하는 사항의 행사에 관하여 지방의회가 사전에 적극적으로 개입하는 것으로서 관련 법령에 위반되어 허용되지 않는다고 할 것입니다(대법원 2009. 9. 24. 선고 2009추53 판결 참조).

따라서, 위원회의 설치, 구성 및 운영에 관한 사항을 정할 때에도 지방자치단체의 집행기관과 지방의회의 견제와 균형의 법리를 고려하여야 할 것이므로, 경기도의회 의원이 합의제행정기관의 설치에 관한 조례안을 발의하는 것은 교육감의 고유권한에 속하는 사항의 행사에 관하여 지방의회가 사전에 적극적으로 개입하는 것으로서 관련 법령에 위반되어 허용되지 않는 것으로 보입니다.

2. 지방의회의 동의 또는 지방의회에 대한 보고에 관한 사항을 조례에 규정할 수 있는지

「지방자치법」 제28조제1항에 따르면 지방자치단체는 법령의 범위 안에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있고, 같은 법에서는 의결기관으로서 지방의회와 집행기관으로서 지방자치단체의 장에게 독자적 권한을 부여하는 한편, 지방의회는 행정사무감사와 조사권 등을 통해 지방자치단체의 장의 사무 집행을 통제할 수 있고, 지방자치단체의 장은 지방의회의 의결에 대한 재의요구 등으로 의회의 의결권 행사에 제동을 가할 수 있게 함으로써 상호 견제와 균형을 유지하도록 하고 있는바, 지방의회는 자치사무에 관하여 법률에 특별한 규정이 없는 한 지방자치단체의 장의 고유권한을 침해하지 않는 범위에서 조례를 제정할 수 있을 것이다[17].

지방의회에 대한 보고의 경우 집행행위에 대한 사전적 통제수단에 해당하는 것이나, 반드시 의회의 의결이나 의견에 따라야 하는 법적 구속이 없다면 지방자치단체의 장의 고유한 집행권을 본질적으로 침해한 것이라고 할 수 없을 것이다[18].

17) 대법원 2011. 4. 28. 선고 2011추18 판결 참조
18) 대법원 2001. 11. 27. 선고 2001추57 판결 참조

사례 32 업무협약 등의 체결에 관한 사전 또는 사후 보고를 규정할 수 있다고 본 사례

2024. 12. 27. 의견제시 24-0444

질의요지

가. 상호 노력의무만을 포함하는 업무제휴나 협약(안산시의회 의결사항에 해당하는 내용을 포함하는 업무제휴나 협약에 해당하지 않는 것을 전제함)의 체결에 대해 지방자치단체의 장이 의회에 보고하도록 하는 내용을 조례에 규정할 수 있는지?

나. 안산시의회 의결사항에 해당하는 내용을 포함하는 업무제휴나 협약에 대하여, 그 체결을 긴급하게 추진할 필요가 있는 경우 의회의 사전의결에 관한 예외를 규정하고 있던 단서를 삭제하여, 앞으로는 지방의회 의결사항을 포함하고 있는 업무제휴나 협약에 대해 긴급성에 대한 명시적인 예외를 두지 않고 지방자치단체의 장이 의회의 사전의결을 받도록 하는 내용으로 조례를 개정할 수 있는지?

의 견

가. 질의 가에 대하여

질의요지와 같은 내용으로 조례를 개정할 수 있을 것으로 보입니다.

나. 질의 나에 대하여

아래 이유를 참고하시기 바랍니다.

이 유

가. 질의 가 및 질의 나의 공통사항

「지방자치법」 제28조제1항에 따르면 지방자치단체는 법령의 범위 안에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있고, 같은 법에서는 의결기관으로서 지방의회와 집행기관으로서 지방자치단체의 장에게 독자적 권한을 부여하는 한편, 지방의회는 행정사무감사와 조사권 등을 통해 지방자치단체의 장의 사무

집행을 통제할 수 있고, 지방자치단체의 장은 지방의회의 의결에 대한 재의요구 등으로 의회의 의결권 행사에 제동을 가할 수 있게 함으로써 상호 견제와 균형을 유지하도록 하고 있는바, 지방의회는 자치사무에 관하여 법률에 특별한 규정이 없는 한 지방자치단체의 장의 고유권한을 침해하지 않는 범위에서 조례를 제정할 수 있을 것입니다(대법원 2011. 4. 28. 선고 2011추18 판결 참조).

나. 질의 가에 대하여

「안산시 업무제휴 및 협약에 관한 조례」(이하 "안산시조례"라고 한다) 제3조에서는 상호 노력의무만 포함하는 순수한 업무제휴나 협약(이하 "업무제휴등"이라 한다)으로 상호 의무부담이나 권리의 포기가 포함되지 않은 경우(제3호) 등에 대해 안산시조례의 적용을 배제하는 것으로 규정하고 있는 한편, '안산시 업무제휴 및 협약에 관한 조례 일부개정조례안'(이하 "안산시조례안"이라 한다)에서는 안산시조례 제3조제3호를 삭제하고, 안 제6조제2항에서 안산시의회의 의결사항에 해당하는 내용을 포함하는 업무제휴등을 제외한 업무제휴등의 체결에 관하여 사전 또는 사후에 의회에 보고하도록 규정하려는바, 이 사안에서는 상호 노력의무만 포함하는 순수한 업무제휴등에 대해 사전 또는 사후에 의회에 보고하도록 하는 것이 지방자치단체의 장과 지방의회의 권한배분 원리에 위배되는지가 문제됩니다.

살피건대, 안산시조례 제2조제1호에서는 "업무제휴"란 안산시가 국내외 공공기관, 기업체 등과 공동의 업무를 추진하기 위한 협조적 업무관계를 말한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2호에서는 "협약"이란 시가 국내외 제휴기관과 교섭하고 서로 합의된 내용을 확인하고 기록하기 위하여 작성한 양해각서(MOU) 등의 문서를 말한다고 규정하고 있는바, 업무제휴등은 "지방자치단체"인 안산시가 국내외 기관 등과 체결하는 것으로서 이러한 업무제휴등을 체결하는 권한이 지방자치단체의 장에게 전속되는 고유한 권한으로 보기는 어려워 보입니다(법제처 2022. 1. 12. 의견제시 22-0011, 2016. 12. 2. 의견제시 16-0328 참조).

그리고, 안산시조례안 제6조제2항에서는 의회 의결사항에 해당하는 내용을 포함하는 업무제휴등을 제외한 업무제휴등을 체결하기 전에 소관 상임위원회에 보고하도록 하면서(본문), 부득이한 사유로 사전 보고가 곤란한 경우에는 그 사유와 함께 사후 보고할 수 있도록 규정하려는데(단서), 이 사안에서 의회에 대한 보고의 경우 자료 제출 등의 방법으로 보고 행위가 종료되면 보고 의무의 이행이 완료되는 것이지, 보고 후 의회의 의결이나 의견을 기다려 이에 따라야 하는 등 법적 구속이 있는 것으로 보이지는 않는 점(대법원 2011. 11. 27. 선고 2001추57 판결 참조), 내용상 의무부담이나 권리의 포기가 포함되지 않은 업무제휴등에 해당하더라도 향후 업무제휴등을 구체화하는 단계에서 집행기관의 책임성을 담보하

기 위한 절차적 사항을 규율할 필요가 있을 수 있는 점 등을 고려할 때, 질의요지와 같은 업무제휴등의 체결에 대해서 의회에 사전 또는 사후 보고하도록 규정하는 것이 지방자치단체의 장의 집행권을 본질적으로 침해한다고 보기 어렵습니다(법제처 2022. 1. 12. 의견제시 22-0011, 2016. 12. 2. 의견제시 16-0328 참조).

따라서, 질의요지와 같은 내용을 조례에 규정할 수 있을 것으로 보입니다.

다. 질의 나에 대하여

안산시조례 제6조제2항에서는 안산시장은 법령 또는 조례에 따른 의회의 의결사항(제1호) 또는 「지방자치법」 제47조제1항제8호에 따른 법령과 조례에 규정된 것을 제외한 예산 외의 의무부담이나 권리의 포기(제2호)에 해당하는 내용을 포함하는 업무제휴등을 체결하는 경우 사전에 의회의 의결을 받도록 규정하면서(본문), 긴급한 추진이 필요한 경우에는 간담회 등을 통해 소관 상임위원회에 보고한 후 의회의 의결을 받은 때부터 효력을 발생한다는 조건을 붙여 업무제휴등을 체결할 수 있다고 규정(단서)하고 있는 한편, 안산시조례안 제6조제1항에서는 안산시장은 법령 또는 조례에 따른 의회의 의결사항에 해당하는 내용을 포함하는 업무제휴나 협약을 체결할 경우에는 사전에 의회의 의결을 받아야 한다고 규정하려 하면서, 현행 안산시조례 제6조제2항 각 호 외의 부분 단서에 해당하는 내용을 삭제하려는바, 이러한 개정안이 해당 업무제휴등의 체결을 긴급하게 추진할 필요가 있는 경우에도 예외 없이 의회의 사전의결을 받아야 하는 것으로 보아 상위법령에 위배되는지가 문제됩니다.

살피건대, 「지방자치법」 제122조제1항에서는 지방자치단체의 장은 '주민의 생명과 재산 보호'를 위하여 긴급하게 필요한 사항으로서 지방의회를 소집할 시간적 여유가 없거나 지방의회에서 의결이 지체되어 의결되지 아니할 때 선결처분을 할 수 있다고 규정하고 있는바, 이 사안에서 업무제휴등의 긴급한 체결이 필요한 경우 의회의 사전의결을 받지 않고 소관 상임위원회에 보고한 후 의회의 의결을 받은 때부터 효력이 발생한다는 조건을 붙여 업무제휴등을 체결할 수 있도록 하는 현행 규정을 삭제하여 긴급한 업무제휴등의 체결에 대해 사전의결을 받지 않아도 되는 예외사유를 명시하고 있지 않더라도, 「지방자치법」 제122조제1항에 해당하는 경우에는 선결처분으로 업무제휴등을 체결할 수 있을 것으로 보입니다.

한편, 안산시조례안 제6조제1항에 따르면, 안산시의회의 의결사항을 포함하는 업무제휴등의 체결이 「지방자치법」 제122조제1항에 따른 선결처분의 요건에 해당하지 않지만 안산시장이 긴급하게 체결할 필요가 있다고 판단하는 경우 종전과는 달리 의회의 사전의결을 받아 체결해야 할 것으로 보이는데,

질의 가에서 살펴본 것처럼 업무제휴등은 “지방자치단체”인 안산시가 국내외 기관 등과 체결하는 것으로서 이러한 업무제휴등을 체결하는 권한이 지방자치단체의 장에게 전속되는 고유한 권한으로 보기는 어려워 보이는 점(법제처 2022. 1. 12. 의견제시 22-0011, 2016. 12. 2. 의견제시 16-0328 참조), 「지방자치법」 제47조제1항 각 호에서 지방의회의 의결사항을 명시하고 있고, 같은 조 제2항에서는 제1항 각 호의 사항 외에 지방의회에서 의결되어야 할 사항을 조례로 정할 수 있도록 위임하고 있어 법령 또는 조례에 따른 의회의 의결사항에 해당하는 내용이 업무제휴등에 포함되어 있는 경우에는 의회의 사전의결을 거치도록 하는 것이 상위법령에 위배된다고 보기 어려운 점 등을 고려할 때, 질의요지와 같은 내용을 조례에 규정할 수 있을 것으로 보입니다.

사례 33 예산 전용 사유에 관한 사전 보고 및 동의를 규정할 수 없다고 본 사례

2024. 10. 23. 의견제시 24-0370

질의요지

가. 영동군수가 예산을 전용하려는 경우 사전에 군의회의 동의를 받도록 하는 내용을 조례에 규정할 수 있는지?

나. 영동군수가 예산을 전용하려는 경우 사전에 그 사유를 군의회에 보고하도록 하는 내용을 조례에 규정할 수 있는지?

의 견

가. 질의 가에 대하여

아래 이유를 참고하시기 바랍니다.

나. 질의 나에 대하여

아래 이유를 참고하시기 바랍니다.

이 유

가. 질의 가 및 질의 나의 공통사항

「지방자치법」은 지방자치단체의 의사를 내부적으로 결정하는 최고의결기관으로 지방의회를, 외부에 대하여 지방자치단체의 대표로서 지방자치단체의 의사를 표명하고 그 사무를 통할하는 집행기관으로 지방자치단체의 장을 독립한 기관으로 두고, 지방의회와 지방자치단체의 장에게 독자적인 권한을 부여하여 상호 견제와 균형을 이루도록 하고 있으므로, 법률에 특별한 규정이 없는 한 조례로써 견제의 범위를 넘어서 상대방의 고유권한을 침해하는 규정을 제정할 수 없을 것인바, 지방의회는 조례의 제정 및 개폐, 예산의 심의·확정, 결산의 승인, 그 밖에 같은 법 제47조에 규정된 사항에 대한 의결권을 가지는 외에

제49조 등의 규정에 따라 지방자치단체사무에 관한 행정사무감사 및 조사권 등을 가지므로, 이처럼 법령에 의하여 주어진 권한의 범위 내에서 집행기관을 견제할 수 있는 것이지 법령에 규정이 없는 새로운 견제장치를 만드는 것은 집행기관의 고유권한을 침해하는 것이 되어 허용할 수 없을 것입니다(대법원 2012. 11. 29. 선고 2011추87 판결 참조).

한편, '영동군 재정건전화 및 효율화 조례안'은 영동군의 건전한 재정 운용 및 공공자금의 효율적인 운용·관리를 위하여 필요한 사항을 규정함으로써 영동군 공공자금 운용의 공공성, 안정성 및 수익성을 제고하고 영동군 재정의 중장기적인 지속가능성 확보에 기여하는 것을 목적으로 마련된 조례로서(제1조), 안 제13조에서는 예산의 전용 시 일정한 경우에는 사전에 그 사유를 의회에 보고하고 동의를 구해야 한다고 규정하려 하고 있습니다.

나. 질의 가에 대하여

「지방재정법」 제49조제1항에서는 지방자치단체의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 각 정책사업 내의 예산액 범위에서 각 단위사업 또는 목의 금액을 전용(轉用)할 수 있다고 규정하고 있고, 제2항에서는 제1항에도 불구하고 지방의회가 의결한 취지와 다르게 사업 예산을 집행하는 경우(제2호) 등에 해당하는 경우에는 전용할 수 없다고 규정하고 있으며, 제3항에서는 지방자치단체의 장이 제1항에 따라 전용을 한 경우에는 분기별로 분기만료일이 속하는 달의 다음 달 말일까지 그 전용 내역을 지방의회에 제출하여야 한다고 규정하고 있습니다.

이러한 규정에 따르면, 예산 전용에 관한 권한은 지방자치단체의 장의 권한에 해당하는 것으로 보이는데, 「지방재정법」 제49조제2항제2호에서는 지방자치단체의 장이 지방의회가 의결한 취지와 다르게 사업을 집행하려는 경우 등에 대해서는 예산을 전용할 수 없도록 제한하고 있으나, 이는 예산 집행에 관한 지방자치단체의 장의 준수사항에 관한 것이지 이를 근거로 예산을 전용하려는 경우 사전에 지방의회의 동의를 받도록 하는 근거라고 보기는 어렵고, 부적법한 예산 전용에 대해서는 「지방자치법」 제49조에 따라 지방의회가 행정사무감사와 조사권 등에 근거하여 감시·통제할 수 있는 점을 고려할 때, 지방자치단체의 장이 예산을 전용하기 전에 미리 지방의회의 동의를 받도록 하는 것은 지방의회가 사전에 적극적으로 개입하여 사실상 예산 전용 여부를 결정하는 것으로 법령에 근거 없는 새로운 견제장치를 만드는 것이 되어 지방자치단체의 장의 권한을 침해할 소지가 있는 것으로 보입니다(대법원 2009. 12. 24. 선고 2007추189 판결 참조).

또한, 「지방재정법」에서는 세출예산에서 정한 정책사업 외의 정책사업에 관해 예산을 집행하는 것을 예산의 '이용(移用)'이라고 하고, 정책사업 내의 다른 단위사업 또는 목에 관해 예산을 집행하는 것을

예산의 '전용'이라고 하여 양자의 집행 절차를 구분해서 규정하고 있는데, 예산의 '이용'에 대해서만 미리 지방의회의 의결을 거치도록 하고 있고(제47조의2제1항), 예산의 '전용'에 대해서는 사후에 그 전용 내역을 지방의회에 제출하도록 규정(제49조제3항)하고 있는 것에 비추어 볼 때, 예산 전용의 경우 지방의회의 사전적 견제를 허용하지 않는 취지로 해석하는 것이 관련 규정의 체계에 부합할 것이라는 점도 이 사안을 판단할 때 고려해야 할 것입니다.

따라서, 질의요지와 같은 내용을 조례에 규정할 수 없을 것으로 보입니다.

다. 질의 나에 대하여

「지방재정법」 제49조제3항에서는 지방자치단체의 장이 제1항에 따라 전용을 한 경우에는 분기별로 분기만료일이 속하는 달의 다음 달 말일까지 그 전용 내역을 지방의회에 제출하여야 한다고 규정하고 있고, 「지방재정법」 제38조제2항·제41조, 같은 법 시행령 제47조 및 「지방자치단체 예산편성운용에 관한 규칙」 제8조에 따라 행정안전부장관이 정한 「지방자치단체 예산편성 운영기준」(2024. 7. 30. 행정안전부훈령 제358호로 발령·시행된 것을 말하며, 이하 "예산편성운영기준"이라 한다) 제8조제1항 및 별표 13에서는 예산의 전용절차에 대하여 '전용요구(사업부서) ⇒ 심사(예산부서) ⇒ 결정(자치단체장) ⇒ 관계부서에 통지(예산부서) ⇒ 지방의회에 제출(예산부서)'로 규정하고 있습니다.

앞서 살펴본 것처럼, 「지방재정법」 제49조에 따라 예산 전용에 관한 사항은 지방자치단체의 장의 권한에 해당하는 것으로 보이고, 같은 조 제3항에서는 지방자치단체의 장에게 예산 전용에 대한 자료 제출 의무를 부여하고 있으나, 이는 예산 전용을 하고 난 후 사후적으로 지방의회에 보고하도록 하는 규정일 뿐, 예산 전용을 하기 전에 전용 사유를 지방의회에 보고하도록 하거나 그러한 내용을 조례로 정하도록 위임하는 규정을 두고 있지 않으므로, 질의요지와 같은 내용을 조례에 규정하는 것은 상위법령에 위배될 소지가 있어 보입니다.

또한, 지방자치단체의 장이 예산을 전용하기 전에 그 사유를 지방의회에 보고하도록 의무를 부과하는 것은 집행기관에 압박으로 작용하여 견제수단으로서 실질적으로 기능할 수 있다는 점에서 법령에 근거 없는 새로운 견제장치를 만들어 지방자치단체의 장의 예산집행권에 개입하는 것으로 볼 수 있는 것이어서, 「지방자치법」에서 규정한 지방자치단체의 장과 지방의회간의 견제균형 및 권한배분의 법리에 위배될 소지가 있는 것으로 보입니다(대법원 2011. 4. 28. 선고 2011추18 판결 및 법제처 2014. 9. 25. 의견제시 14-0163 참조).

따라서, 질의요지와 같은 내용을 조례에 규정할 수 없을 것으로 보입니다.

사례 34 민간위탁 시 지방의회의 동의를 받아야 한다고 본 사례

2024. 2. 2. 의견제시 24-0010

질의요지

나주시장이 농산물산지유통센터의 운영을 「나주시 농산물산지유통센터 관리 운영 조례」 제5조 각 호에 따른 생산자단체 등에 위탁하려는 경우, 「나주시 사무의 민간위탁촉진 및 관리 조례」 제7조제1항에 따라 나주시의회의 동의를 받아야 하는지?

의 견

이 사안의 경우, 나주시장이 농산물산지유통센터의 운영을 「나주시 농산물산지유통센터 관리 운영 조례」 제5조 각 호에 따른 생산자단체 등에 위탁하려면 「나주시 사무의 민간위탁촉진 및 관리 조례」 제7조제1항에 따라 나주시의회의 동의를 받아야 하는 것으로 보는 것이 바람직할 것으로 보입니다.

이 유

「나주시 사무의 민간위탁촉진 및 관리 조례」(이하 "민간위탁조례"라 한다) 제3조에서는 민간위탁 사무에 관하여 다른 법령 또는 조례에서 "특별한 규정"이 있는 경우를 제외하고는 이 조례에서 정하는 바에 따른다고 규정하고 있고, 같은 조례 제4조제1항에서는 시장은 「지방자치법」 제117조제3항에 따라 소관 자치사무 중 조사·검사·검정·관리업무 등 시민의 권리·의무와 직접 관계되지 아니하는 단순 사실행위인 행정작용(제1호), 공익성보다 능률성이 현저히 요청되는 사무(제2호) 등 같은 항 각 호의 사무를 민간위탁할 수 있다고 규정하고 있으며, 같은 조례 제7조제1항에서는 시장은 제4조제1항 각 호 사무에 대해 민간위탁을 하고자 하는 경우에는 나주시의회(이하 "의회"라 한다)의 사전 동의를 받아야 한다고 규정하고 있습니다.

한편, 「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」(이하 "농수산물유통법"이라 한다) 제51조제1항에서

는 국가나 지방자치단체는 농수산물의 선별·포장·규격출하·가공·판매 등을 촉진하기 위하여 농수산물산지유통센터(이하 "유통센터"라 한다)를 설치하여 운영할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 국가나 지방자치단체는 유통센터의 운영을 생산자단체 또는 전문유통업체에 위탁할 수 있다고 규정하고 있으며, 「나주시 농산물산지유통센터 관리 운영 조례」(이하 "유통센터조례"라 한다) 제3조제2항에서는 시장은 유통센터를 설치하여 직접 운영하거나, 농수산물유통법 제51조제2항에 따라 생산자단체 등에 위탁 운영할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조례 제5조에서는 시장은 유통센터의 효율적인 운영을 위하여 제3조제2항의 규정에 의하여 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제3조제4호의 규정에 의한 생산자단체(제1호) 등 같은 조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 중에서 관리·운영을 위탁할 수 있다고 규정하고 있으며, 그 밖에도 위탁신청 및 지정(제6조), 위탁기간(제7조), 수탁자의 의무(제8조), 위탁의 취소(제9조), 사용료(제13조) 등에 관한 사항을 규정하고 있습니다.

이에 귀 시에서는 유통센터의 운영을 민간에 위탁할 수 있도록 규정하고 있는 농수산물유통법 제51조제2항 및 유통센터조례 제3조제2항 등 농수산물유통법과 유통센터조례에서 민간위탁 관련 규정을 두고 있으므로 의회의 동의와 관련하여 민간위탁조례 제3조의 "특별한 규정"이 있는 경우에 해당한다고 보아 같은 조례 제7조제1항에 따른 의회의 동의를 받지 않아도 되는지 질의하신 것으로 보입니다.

일반적으로 지방자치단체의 민간위탁에 관한 사항을 규정하는 조례에서 지방자치단체의 사무의 민간위탁에 관하여 의회의 동의를 받도록 하는 것은 지방자치단체장의 민간위탁에 대한 일방적인 독주를 제어하여 민간위탁의 남용을 방지하고 그 효율성과 공정성을 담보하기 위한 것이라는 점(대법원 2009. 12. 24. 선고 2009추121 판결 참조)을 고려하면, 민간위탁 시 의회 동의와 관련하여 민간위탁조례 제3조의 "특별한 규정"에 해당하기 위해서는 민간위탁에 관한 사항을 규정하는 법령 또는 개별 조례에서 해당 사무를 의무적으로 위탁하도록 하는 등 민간위탁조례에 따른 의회 동의 절차를 거쳐야 할 필요가 없다고 인정될 수 있는 경우여야 할 것으로 보입니다(법제처 2019. 6. 12. 의견제시 19-0187 참조).

살피건대, 농수산물유통법 제51조제2항 및 유통센터조례 제3조제2항 에서 유통센터의 운영을 생산자단체 등에 위탁할 수 있다고 규정한 것은 해당 사무를 법률 및 조례에서 정한 수탁자에게 위탁하여 수행할 수 있다는 가능성을 열어두고 있는 것에 불과하다는 점, 유통센터조례의 위탁신청 및 지정(제6조), 위탁기간(제7조) 등 민간위탁 관련 규정은 농수산물유통법 제51조제1항, 유통센터조례 제3조제2항에 따라 시장이 유통센터를 설치하여 직접 운영할 수 있음에도 불구하고 민간에 위탁하여 운영하기로 결정한 이후의 절차 등에 관한 사항이라는 점 등을 고려하면, 시장의 민간위탁 남용을 방지하고 그 효율성과 공정성을 담보하기 위하여 유통센터 운영의 위탁에 대해 의회의 동의를 얻을 필요성은 여전히

남아 있는 것으로 보이고, 유통센터조례 제21조에서 유통센터의 관리 및 운영에 관하여 이 조례에서 정한 사항 이외에는 「나주시 사무의 민간위탁촉진 및 관리 조례」를 준용한다고 규정하고 있는데, 유통센터조례에 의회의 동의를 배제하는 규정은 없는 것으로 보이는바, 농수산물유통법이나 유통센터조례의 민간위탁 관련 규정을 민간위탁조례 제3조의 "특별한 규정"으로 보아 같은 조례 제7조제1항에 따른 의회의 동의가 배제될 수 있다고 보기는 어려울 것으로 보입니다.

따라서 이 사안의 경우, 나주시장이 유통센터의 운영을 유통센터조례 제5조에 따른 생산자단체 등에 위탁하려면 「나주시 사무의 민간위탁촉진 및 관리 조례」 제7조제1항에 따라 나주시의회의 동의를 받아야 하는 것으로 보는 것이 바람직할 것으로 보입니다.

사례 35 지방공사의 정관 변경 시 지방의회의 동의를 받도록 규정할 수 없다고 본 사례

2023. 9. 27. 의견제시 23-0345

질의요지

지방공사의 정관을 변경하려는 경우 지방의회의 동의를 받도록 하는 내용을 조례로 규정할 수 있는지?

의 견

아래 이유를 참고하시기 바랍니다.

이 유

「지방자치법」 제28조제1항 본문에 따르면 지방자치단체는 법령의 범위 즉 법령에 위반되지 않는 범위에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있는바, 조례가 법령에 위반되는지 여부는 법령과 조례의 각각의 규정 취지, 규정의 목적과 내용 및 효과 등을 비교하여 양자 사이에 모순·저촉이 있는지 여부에 따라서 개별적·구체적으로 결정하여야 할 것입니다(대법원 2004. 4. 23. 선고 2002추16 판결 참조).

이 사안은 지방공사의 정관을 변경하려는 경우 지방의회의 동의를 받도록 하는 내용을 조례로 규정할 수 있는지에 대한 질의로 보입니다.

「지방공기업법」 제49조제2항에서는 지방자치단체는 지방공사를 설립하는 경우 그 설립, 업무 및 운영에 관한 기본적인 사항을 조례로 정하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제56조제3항에서는 지방공사는 정관을 변경하려는 경우 지방자치단체의 장의 인가를 받아야 한다고 규정하고 있습니다.

살피건대 「지방공기업법」 제49조제2항에 따라 지방자치단체가 지방공사의 설립·업무 및 운영에 관한 사항을 조례로 정하는 경우에도 상위 법령에 위반되는 내용을 규정할 수는 없다고 할 것인데, 같은 법 제56조제3항에서는 지방공사는 정관을 변경하려는 경우 지방자치단체의 장의 인가를 받아야 한다고

규정하고 있을 뿐 지방의회가 직접 지방공사에 대하여 관여할 수 있도록 규정하거나 조례로 위임한 사항은 없는 것으로 보이므로, 지방공사의 정관을 변경하려는 경우에 지방의회의 동의를 받아야만 정관 변경을 할 수 있도록 조례에 규정하는 것은 법령에서 인정하고 있는 범위를 넘어 새로운 정관 변경 절차를 추가하게 되는 것으로 결국 조례가 상위법령의 효력을 좌우하게 되는 결과를 가져오게 되어 상위법령에 위반될 소지가 있습니다(법제처 2021. 7. 8. 의견제시 21-0179 참조).

한편 「지방자치법」 제28조제1항 단서에서는 주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한 사항이나 벌칙을 정할 때에는 법률의 위임이 있어야 한다고 규정하고 있으므로, 조례를 제정함에 있어 그 내용이 주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한 사항이나 벌칙인 경우에는 법률의 위임이 있어야 하고, 법률의 위임 없이 주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한 사항을 정한 조례는 그 효력이 없다고 할 것입니다(대법원 2012. 11. 22. 선고 2010두19270 판결 참조). 그런데 지방공사의 정관을 변경하려는 경우 지방의회의 동의를 받도록 조례에 규정하는 것은 법률의 위임 없이 지방공사에 대해 의무를 부과하는 것이므로 「지방자치법」 제28조제1항 단서에 위반될 소지가 있는 것으로 보입니다(법제처 2021. 7. 8. 의견제시 21-0179 참조).

나아가 법령의 명시적인 근거나 위임 규정 없이 지방공사의 정관을 변경하려는 경우 지방의회의 동의를 받도록 조례에 규정하는 것은 「지방공기업법」 제51조에 따라 독립된 법인격을 가진 법인으로 설립된 지방공사의 운영상 독립성이나 자율성을 훼손시킬 우려가 있으므로 이러한 법인제도의 취지를 고려하여 신중하게 접근할 필요가 있는 점 역시 고려되어야 할 것입니다(법제처 2023. 4. 28. 의견제시 23-0083 참조).

따라서 지방공사의 정관을 변경하려는 경우 지방의회의 동의를 받도록 하는 내용을 조례로 규정하는 것은 상위법령에 위배될 소지가 있으므로, 자치법규 입안에 신중을 기하시기 바랍니다.











제 5 편

위원회

1. 조례로 설치·운영할 수 있는 위원회인지

위원회는 의사결정 과정에 여러 사람이 참여하여 표결의 방법에 따라 하나의 의사를 결정하는 합의제 기관을 말한다. 위원회는 행정의 민주성·공정성의 확보, 전문지식의 활용, 이해의 조정이나 관계 행정기관 간의 의사의 종합·협의·조정 등을 위해 설치된다.

위원회는 위원회의 법적 권한을 기준으로 ① 그 의사와 판단을 결정하여 외부에 표시하는 권한을 가지는 합의제행정기관인 위원회와 ② 행정에 관한 의사와 판단을 결정하여 외부에 표시하는 권한은 없지만, 그 의사와 판단이 행정관청을 법적으로 구속하는 의결기관인 위원회와 ③ 법적 구속력을 가지지 않는 자문기관인 위원회로 구분된다.

또한, 위원회는 설치 근거에 따라 법령에 따라 설치되는 위원회와 조례에 따라 설치되는 위원회로 구분할 수 있다.

「지방자치법」 제130조에서는 지방자치단체는 그 "소관 사무의 범위에서" 법령이나 그 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 심의회·위원회 등의 자문기관을 설치·운영할 수 있고, 지방자치단체는 자문기관 운영의 효율성 향상을 위하여 해당 지방자치단체에 설치된 다른 자문기관과 성격·기능이 중복되는 자문기관을 설치·운영해서는 아니 되며, 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 성격과 기능이 유사한 다른 자문기관의 기능을 포함하여 운영할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제78조부터 제80조까지에서는 자문기관의 설치요건, 구성 및 존속기한을 규정하고 있다[19].

19) 『자치법규 입안 길라잡이(2022)』 204·206쪽 참조

「지방자치법」

제130조(자문기관의 설치 등) ① 지방자치단체는 소관 사무의 범위에서 법령이나 그 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 자문기관(소관 사무에 대한 자문에 응하거나 협의, 심의 등을 목적으로 하는 심의회, 위원회 등을 말한다. 이하 같다)을 설치·운영할 수 있다.

② 자문기관은 법령이나 조례에 규정된 기능과 권한을 넘어서 주민의 권리를 제한하거나 의무를 부과하는 내용으로 자문 또는 심의 등을 하여서는 아니 된다.

③ 자문기관의 설치 요건·절차, 구성 및 운영 등에 관한 사항은 대통령령으로 정한다. 다만, 다른 법령에서 지방자치단체에 둘 수 있는 자문기관의 설치 요건·절차, 구성 및 운영 등을 따로 정한 경우에는 그 법령에서 정하는 바에 따른다.

④ 지방자치단체는 자문기관 운영의 효율성 향상을 위하여 해당 지방자치단체에 설치된 다른 자문기관과 성격·기능이 중복되는 자문기관을 설치·운영해서는 아니 되며, 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 성격과 기능이 유사한 다른 자문기관의 기능을 포함하여 운영할 수 있다.

⑤ (생 략)

사례 36

기관위임사무에 관한 심의위원회 설치·운영 조례를 제정할 수 없다고 본 사례

(질의 가)

2022. 11. 30. 의견제시 22-0268

질의요지

가. 다목적댐의 주변지역에 대한 「댐건설·관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 제43조에 따른 댐주변지역지원사업 중 같은 법 시행령 제40조제2항 및 별표 6 제1호에 따른 지역지원사업에 관한 사항을 심의하기 위한 자문위원회를 설치하는 내용을 조례로 규정할 수 있는지?

나. 수력발전소의 주변지역에 대한 「발전소주변지역 지원에 관한 법률」 제10조제1호에 따른 기본지원사업 중 같은 법 시행령 제19조 및 별표 1에 따른 소득증대사업, 공공·사회복지사업, 주민복지지원사업, 기업유치지원사업의 시행에 관한 사항을 심의하기 위한 자문위원회를 설치하는 내용을 조례로 규정할 수 있는지?

다. 댐 및 발전소로 인해 불편을 겪는 지역주민 중 「댐건설·관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 및 「발전소주변지역 지원에 관한 법률」에 따라 지원을 받지 않는 주민에 대하여 지원할 수 있도록 하는 내용을 조례로 규정할 수 있는지?

의 견

가. 질의 가에 대하여

아래 이유를 참고하시기 바랍니다.

나. 질의 나에 대하여

질의요지와 같은 내용을 조례로 규정할 수 있을 것으로 보입니다.

다. 질의 다에 대하여

아래 이유를 참고하시기 바랍니다.

이 유

가. 질의 가·나의 공통사항

「지방자치법」 제130조제1항에서는 지방자치단체는 소관 사무의 범위에서 조례로 정하는 바에 따라 심의회·위원회 등의 자문기관을 설치·운영할 수 있다고 규정하고 있습니다. 여기에서 지방자치단체의 소관사무라 함은 고유사무인 자치사무와 개별 법령에 의하여 지방자치단체에 위임된 단체위임사무를 말하고, 국가사무로서 지방자치단체의 장에게 위임되거나 상위 지방자치단체의 사무로서 하위 지방자치단체의 장에게 위임된 기관위임사무는 여기에 포함되지 않습니다. 다만 기관위임사무에 있어서도 그에 관한 개별 법령에서 일정한 사항을 조례로 정하도록 위임하고 있는 경우에는 위임받은 사항에 관하여 개별 법령의 취지에 부합하는 범위 내에서 이른바 위임조례를 정할 수 있다고 할 것입니다.

이와 관련하여 법령 상 지방자치단체의 장이 처리하도록 규정하고 있는 사무가 자치사무인지 기관위임사무에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 그에 관한 법령의 규정 형식과 취지를 우선 고려해야 할 것이지만, 그 외에도 그 사무의 성질이 전국적으로 통일적인 처리가 요구되는 사무인지 여부나 그에 관한 경비부담과 최종적인 책임귀속의 주체 등도 아울러 고려하여 판단해야 할 것입니다.

나. 질의 가에 대하여

「댐건설·관리 및 주변지역지원등에 관한 법률」(이하 "댐건설관리법"이라 한다) 제2조제2호에서는 다목적댐은 환경부장관이 건설하는 댐으로서 특정용도 중 둘 이상의 용도로 이용하는 것을 말한다고 규정하고 있고, 같은 법 제5조제1항에서는 댐은 환경부장관이 관리하고, 다만 시·도지사 또는 시장·군수가 건설한 댐은 해당 시·도지사 또는 시장·군수가 관리한다고 규정하고 있으며, 같은 조 제2항에서는 댐을 관리하는 환경부장관, 시·도지사 또는 시장·군수(이하 "댐관리청"이라 한다)는 댐의 관리를 위하여 필요한 때에는 댐의 설치·운영에 관한 업무를 수행하는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관(이하 "댐수탁관리자"라 한다)에 댐의 관리를 위탁할 수 있다고 규정하고 있습니다.

그리고 댐건설관리법 제43조제1항에서는 댐관리청이나 댐수탁관리자는 댐건설이 완료된 후 대통령령으로 정하는 댐 주변지역의 주민소득 증대와 복지 증진을 도모하기 위하여 매년 대통령령으로 정하는 바에 따라 댐 주변지역의 지원사업(이하 "댐주변지역지원사업"이라 한다)에 관한 계획을 수립하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 댐주변지역지원사업에 관한 계획을 수립하려는 경우에는 미리 댐 주변지역을 관할하는 시장·군수 또는 구청장과 협의하도록 규정하고 있으며, 같은 조 제4항에서는 댐주변지역지원사업은 대통령령으로 정하는 바에 따라 댐관리청 또는 댐수탁관리자(제1호), 댐 주변

지역을 관할하는 시장·군수 또는 구청장(제2호)이 시행한다고 규정하고 있고, 이에 따른 같은 법 시행령 제40조제4항에서는 댐주변지역지원사업 중 지역지원사업(이하 "댐지역지원사업"이라 한다)의 시행자로 관할 시장·군수·구청장을 규정하고 있습니다.

살피건대 댐건설관리법에 따르면 다목적댐의 댐관리청은 환경부장관으로 규정하고 있는 점(제2조제2호 및 제5조제1항), 댐주변지역지원사업에 관한 계획을 수립하는 주체는 댐관리청이나 댐수탁관리자로 규정하고 있는 점(제43조제1항), 댐주변지역지원사업에 관한 계획을 수립할 때 댐 주변지역을 관할하는 군수는 협의의 상대방에 불과한 것으로 보이는 점(제43조제2항), 군수는 댐관리청이나 댐수탁관리자가 수립한 댐주변지역지원사업에 관한 계획에 따른 댐지역지원사업을 시행하는 자에 불과한 것으로 보이는 점(제43조제4항 및 같은 법 시행령 제40조제4항) 등에 비추어 보면, 댐지역지원사업에 관한 사무는 기관위임사무에 해당하는 것으로 보입니다.

그런데 댐건설관리법에서는 댐지역지원사업에 관한 사무의 시행과 관련한 사항이나 댐지역지원 사업에 관한 사무의 시행을 위해 위원회를 설치·운영하는 사항을 조례로 정하도록 위임하고 있지 않고, 기관위임사무에 관한 사항을 심의하기 위한 자문위원회를 설치·운영하는 경우에는 「지방자치법」 제130조제1항이 적용되지 않는다고 보아야 할 것이므로 질의요지와 같은 내용을 조례로 규정할 수는 없을 것으로 보입니다.

다만 양구군에서 양구군수에게 위임된 댐지역지원사업의 시행에 관한 사항을 심의하기 위하여 규칙으로 위원회를 설치·운영하는 것은 가능할 것으로 보이므로 이러한 점을 자치법규 입안 시 참고하시기 바랍니다.

다. 질의 나에 대하여

「발전소주변지역 지원에 관한 법률」(이하 "발전소주변지역법"이라 한다)제9조에서는 산업통상자원부장관은 매년 지원사업에 관한 계획을 수립하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제10조에서는 주변지역의 개발과 주민의 복리를 증진하기 위하여 시행하는 지원사업을 기본지원사업으로 분류하면서(제1항제1호) 지원사업의 종류별 지원내용, 대상 지역, 시행 기간, 지원방법 등에 관한 구체적인 사항은 대통령령으로 정하도록 규정(제2항)하고 있습니다.

그리고 이에 따른 발전소주변지역법 시행령 제19조에서는 기본지원사업의 종류와 세부 내용을 규정하면서(제1항 및 별표 1), 기본지원사업의 대상 지역은 주변지역으로 하고(제2항) 기본지원사업 중 소득증대사업, 공공·사회복지사업, 주민복지지원사업, 기업유치지원사업(이하 "발전소지역지원사업")은 지방

자치단체의 장이 시행한다(제4항)고 규정하고 있습니다.

살피건대 발전소주변지역법에 따르면 발전소 주변지역에 대한 지원사업 계획은 산업통상자원부 장관이 수립하도록 규정하고 있고(제9조), 지방자치단체장은 이에 따른 지원사업 중 일부를 시행하는 자에 불과한 것으로 보이는 점(제10조제2항 및 같은 법 시행령 제19조제4항), 지원사업에 드는 비용은 「전기사업법」 제48조에 따른 전력산업기반기금에서 부담하도록 규정하고 있다는 점(제13조), 일정한 사유가 발생하면 산업통상자원부장관이 해당 지원사업을 중단하게 할 수 있다는 점(제16조의3) 등을 고려할 때, 발전소지역지원사업은 기관위임사무에 해당하는 것으로 보여집니다.

다만 발전소주변지역법 시행령 제19조제4항 각 호에서는 주민복지지원사업의 지원대상, 지원절차 및 대출한도액·대출이자율·상환기간 등 지원조건에 관한 기준(제1호)과 기업유치지원사업의 지원대상, 지원절차 및 지원한도·지원기간 등 지원조건에 관한 기준(제2호)을 해당 지방자치단체의 조례로 정하도록 규정하고 있고, 같은 영 제36조에서는 지방자치단체의 장이 시행하는 지원사업에 관하여 이 영에서 정한 사항 외에 예산지원 등 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정할 수 있도록 규정하고 있습니다.

따라서 발전소주변지역법 시행령 제19조제4항에 따라 발전소지역지원사업 중 주민복지지원사업, 기업유치지원사업에 관한 사항을, 같은 영 제36조에 따라 발전소지역지원사업 중 소득증대사업, 공공·사회복지사업에 관한 사항을 조례로 정할 수 있다고 할 것이므로, 발전소지역지원사업에 관한 사항을 심의하기 위한 자문위원회를 설치·운영하는 사항은 조례로 정할 수 있을 것으로 보입니다.

라. 질의 다에 대하여

「지방자치법」 제28조제1항에 따르면 지방자치단체는 법령의 범위 안에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있는데, 여기서 법령의 범위란 법령에 위반되지 않는 범위를 의미하고 그 사무란 지방자치단체의 고유사무인 자치사무와 개별 법령에 따라 지방자치단체에 위임된 단체위임사무를 의미합니다.

살피건대 「지방자치법」 제13조제2항에서는 주민의 복지증진에 관한 사무(제2호)를 지방자치단체의 사무로 예시하고 있는 점 등을 고려하면 지역 내 댐 및 발전소로 인해 불편을 겪는 지역주민 중 댐건설관리법 및 발전소주변지역법에 따라 지원을 받지 않는 주민에 대하여 지원하는 사무는 지방자치단체의 소관 사무에 해당하는 것으로 보여집니다.

한편 조례가 규율하는 특정사항에 관하여 그것을 규율하는 국가의 법령이 이미 존재하는 경우에도 조례가 법령과 별도의 목적에 기하여 규율함을 의도하는 것으로서 그 적용에 의하여 법령의 규정이

의도하는 목적과 효과를 전혀 저해하는 바가 없는 때 또는 양자가 동일한 목적에서 출발한 것이라고 할지라도 국가의 법령이 반드시 그 규정에 의하여 전국에 걸쳐 일률적으로 동일한 내용을 규율하려는 취지가 아니고 각 지방자치단체가 그 지방의 실정에 맞게 별도로 규율하는 것을 용인하는 취지라고 해석되는 때에는 그 조례가 국가의 법령에 위배되는 것은 아니라고 할 것입니다.

댐건설관리법 제43조제4항에서는 댐주변지역지원사업은 대통령령으로 정하는 바에 따라 댐관리청 또는 댐수탁관리자(제1호), 댐 주변지역을 관할하는 시장·군수 또는 구청장이 시행하도록 규정하고 있고, 발전소주변지역법 제10조 및 같은 법 시행령 제19 및 별표 1에서는 발전소주변지역에 거주하는 주민에 대해서는 지원사업을 하도록 규정하고 있으나 두 법 모두 해당 규정의 취지가 주변지역이 아니라 하더라도 댐 및 발전소로 인해 불편을 감수해야 하는 지역이 있다면 각 지방자치단체가 지역 실정에 맞게 지원하려는 것을 금지하려는 취지로 보이지는 않습니다.

따라서 지방자치단체에서 댐 및 발전소 주변지역 외의 지역에 거주하는 주민에 대해 지원을 하는 내용의 조례를 제정하는 것이 댐건설관리법 및 발전소주변지역법에 위배된다고 하기는 어렵다고 할 것입니다.

다음으로 지방자치단체의 재정에 관한 기본원칙을 정하고 있는 「지방재정법」 제17조제1항에서는 지방자치단체가 그 소관에 속하는 사무와 관련하여 법률에 규정이 있는 경우(제1호), 보조금을 지출하지 아니하면 사업을 수행할 수 없는 경우로서 지방자치단체가 권장하는 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우(제4호) 등에 한하여 기부·보조, 그 밖의 공금 지출을 할 수 있다고 규정하고 있으므로 질의요지와 같은 내용을 조례로 규정할 수 있는지 판단하기 위해서는 댐건설관리법 및 발전소주변 지역법에 따라 지원을 받지 않는 주민에 대한 지원이 「지방재정법」 제17조제1항에 해당하는지 여부를 살펴볼 필요가 있습니다.

먼저 같은 조 제1호의 “법률의 규정이 있는 경우”에 해당하기 위해서는 개별적인 법률상 근거가 필요한데 질의요지에 따르면 댐건설관리법과 발전소주변지역법 상 지원 대상이 아닌 주민에게 지원을 하려는 것이므로 이 사안의 경우 「지방재정법」 제17조제1항제1호에 해당하지 않는다고 할 것입니다.

또한 질의요지와 같은 비용지원을 하는 것이 「지방재정법」 제17조제1항제4호에 해당하는지 살펴보면 “지방자치단체가 권장하는 사업”인지 여부는 보조금 지출 대상의 성격, 실제 보조금이 지출될 사업의 내용, 해당 사업이 지방 재정에 미치는 영향, 해당 사업에 대해 지방자치단체 주민이 갖는 일반적 인식 등 객관적 요소를 종합적으로 고려하여 판단해야 할 사항이므로 지방자치단체에서는 위와 같은 판단에 따라 조례 제정 여부를 결정하여야 할 것으로 보입니다.

사례 37

자치사무에 관한 자문위원회의 설치 조례를 제정할 수 있다고 본 사례

(질의 가)

2024. 8. 8. 의견제시 24-0260

질의요지

가. 상수원보호구역 주변의 공장설립이 제한되는 지역 주민에 대한 소득증대사업 등의 지원사업에 관한 군수의 자문에 응하게 하기 위하여 자문위원회를 두도록 하는 내용을 조례에 규정할 수 있는지?

나. (질의 가가 가능하다면) 자문위원회에 참석하는 민간위원에게 수당과 여비를 지급할 수 있도록 하는 내용을 조례에 규정할 수 있는지?

의 견

가. 질의 가에 대하여

아래 이유를 참고하시기 바랍니다.

나. 질의 나에 대하여

아래 이유를 참고하시기 바랍니다.

이 유

가. 질의 가에 대하여

「지방자치법」 제130조 및 같은 법 시행령 제78조에 따르면, 지방자치단체는 업무의 특성상 전문적인 지식이나 경험이 있는 사람의 의견을 들어 결정할 필요가 있거나, 업무의 성질상 다양한 이해관계의 조정 등 특히 신중한 절차를 거쳐 처리할 필요가 있는 경우에 '소관 사무'의 범위에서 법령이나 그

지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 자문기관(소관 사무에 대한 자문에 응하거나 협의, 심의 등을 목적으로 하는 심의회, 위원회 등을 말하며, 이하 같다)을 설치·운영할 수 있다고 규정하고 있는데, 여기서 '소관 사무'란 지방자치단체의 자치사무와 단체위임사무를 의미하는바(법제처 2022. 3. 25. 의견제시 22-0088 참조), 이 사안에서는 군수가 「수도법」 제7조의2에 따라 상수원보호구역 주변의 공장설립이 제한되는 지역 주민에 대한 소득증대사업 등의 지원사업을 수립·시행하는 것이 지방자치단체의 소관 사무에 해당하는지 살펴보아야 할 것입니다.

먼저, 「수도법」 제7조의2제1항에서는 상수원보호구역의 상류지역이나 취수시설의 상류·하류 일정지역으로서 대통령령으로 정하는 지역을 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 공장을 설립할 수 없는 지역(이하 "공장설립제한지역"이라 한다)으로 규정하고 있고, 「수도법」 제9조에서는 제8조제1항 또는 제2항에 따라 상수원보호구역을 관리하는 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 상수원보호구역에 거주하는 주민 또는 상수원보호구역에서 농림·수산업 등에 종사하는 자에 대한 지원사업 계획을 수립·시행할 수 있다고 규정하고 있는데, 「수도법」에서는 상수원보호구역이 아닌 공장설립제한지역의 주민에 대한 지원에 관한 사항을 별도로 규정하거나 조례로 정하도록 위임하는 규정을 두고 있지 않습니다.

살피건대, 수익적 행정행위에 대해서는 조례제정권자에게 광범위한 입법형성의 자유가 인정되는 점을 고려할 때, 「수도법」의 규정이 공장설립제한지역의 주민에 대해 각 지방자치단체가 자체적으로 재원을 마련하여 지원사업을 시행하는 것을 금지하려는 취지인 것으로 보기는 어렵고(법제처 2016. 12. 15. 의견제시 16-0323 참조), 이 사안의 지원은 상수원보호구역 주변지역에서의 공장설립 제한 등의 규제로 인해 불이익을 받게 되는 주민에 대하여 생활 편익과 복지 증진, 소득 보조 등을 통해 해당 주민의 삶의 질을 향상시키려는 것으로, 「지방자치법」 제13조제2항제2호가목에서 자치사무의 하나로 예시하고 있는 '주민복지에 관한 사업'에 해당하는 것으로 보이는바, 공장설립제한지역의 주민에 대해 소득증대사업 등의 지원사업을 수립·시행하는 사무는 자치사무에 해당하는 것으로 보입니다.

따라서, 횡성군의 소관 사무인 공장설립제한지역의 주민에 대한 지원에 관하여 횡성군수가 여러 사람의 의견을 들어 결정할 필요가 있거나 신중한 절차를 거쳐 처리할 필요가 있는 것으로 인정하는 경우에는 「지방자치법」 제130조에 따라 조례의 형식으로 자문위원회를 설치·운영할 수 있는 것으로 보입니다(법제처 2024. 6. 25. 의견제시 24-0195 참조).

나. 질의 나에 대하여

「지방자치법」 제130조에서는 지방자치단체는 그 소관 사무의 범위에서 법령이나 그 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 자문기관을 설치·운영할 수 있다고 규정하고 있으므로, 개별 법령에 의하여 설치되는 자문기관인 경우에는 그 법령에서 자문기관의 구성방법 등에 관해 규정하고 있다면 그에 따라야 할 것이지만, 지방자치단체의 조례에 의하여 설치되는 자문기관인 경우에는 그 구성과 운영에 관한 사항은 조례제정권자에게 광범위한 입법형성권이 부여되어 있다 할 것입니다(법제처 2018. 10. 18. 의견제시 18-0204 참조).

따라서, 조례에 의하여 설치되는 자문기관인 이 사안의 자문위원회의 경우, 그 운영기준·방법에 관한 사항인 참석위원에 대한 수당과 여비의 지급에 관한 내용을 조례에 규정할 수 있을 것으로 보입니다(법제처 2019. 2. 27. 의견제시 19-0071 참조).

다만, 횡성군에는 이 사안의 자문위원회의 수당과 여비에 관하여 적용할 수 있는 「횡성군 각종 위원회 구성 및 운영에 관한 조례」(이하 "횡성군위원회조례"라 한다)가 있으므로, 이 사안의 자문위원회의 설치·운영에 관한 사항을 규율함을 목적으로 하는 개별조례에서 횡성군위원회조례와 달리 규정하여 지급하려는 것이 아니라면, 동일한 목적과 내용의 수당 및 여비에 관한 사항을 중복하여 규정하는 것은 입법체계적으로 바람직하지 않은 것으로 보이는바, 이러한 점을 자치법규 입안 시 참고하시기 바랍니다.

2. 위원회의 심의·의결사항의 범위 및 효력

자문기관인 위원회와 의결기관인 위원회의 구분은 그 위원회의 결정에 구속력이 있는지를 기준으로 하는바, 자문기관인 위원회는 행정관청에 대하여 구속력이 없는 의사를 결정하는 위원회를 말하고, 의결기관인 위원회는 법령상 구속력이 있는 의사를 결정하는 위원회를 말하는 것이다. 따라서 자문기관인 위원회의 의결내용은 조언의 성격을 가질 뿐이므로 행정관청은 실제 그 의결내용에 따를 의무가 없으며, 그 의사를 채택할 것인지의 여부는 행정관청이 결정하게 되는 반면에, 의결기관인 위원회의 의결내용은 구속력을 가지므로 행정관청은 그 의결내용에 따르도록 하고 있다[20].

20) 법제처 2014. 4. 24. 의견제시 14-0032 참조

사례 38

법령에 따라 설치된 자문위원회에서 법령에서 정하지 않은 사항을 심의할 수 있다고 본 사례

(질의 가)

2022. 7. 20. 의견제시 22-0201

질의요지

「재난 및 안전관리 기본법」 제11조제1항에서는 지역별 재난 및 안전관리에 관한 사항을 심의· 조정하기 위하여 시장·군수·구청장 소속으로 시·군·구 안전관리위원회를 둔다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항에서는 시·군·구 안전관리위원회의 회의에 부칠 의안을 검토하고, 재난 및 안전관리에 관한 관계 기관 간의 협의·조정 등을 위하여 지역위원회에 안전정책실무조정위원회를 둘 수 있다고 규정하고 있는바,

가. 안전정책실무조정위원회에서 시에서 주관하는 지역축제·행사의 안전관리계획을 심의하도록 「통영시 안전관리위원회 운영조례」에 규정할 수 있는지?

나. "안전정책실무조정위원회의 심의를 거친 사항은 시·군·구 안전관리위원회의 심의를 거친 것으로 본다"고 「통영시 안전관리위원회 운영조례」에 규정할 수 있는지?

의 견

가. 질의 가에 대하여

이 사안의 경우 안전정책실무조정위원회에서 시에서 주관하는 지역축제·행사의 안전관리계획을 심의하도록 「통영시 안전관리위원회 운영조례」에 규정할 수 있을 것으로 보입니다.

나. 질의 나에 대하여

이 사안의 경우 "안전정책실무조정위원회의 심의를 거친 사항은 시·군·구 안전관리위원회의 심의를 거친 것으로 본다"고 「통영시 안전관리위원회 운영조례」에 규정하는 것은 바람직하지 않은 것으로 보입니다.

이 유

가. 질의 가에 대하여

「지방자치법」 제28조제1항 본문에 따르면 지방자치단체는 법령의 범위에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있는데, 여기서 "그 사무"란 지방자치단체의 자치사무와 법령에 따라 지방자치단체에 속하게 된 단체위임사무를 의미합니다. 그리고 "법령의 범위"란 "법령에 위반되지 않는 범위"를 의미하는데, 특정 사항에 관하여 국가 법령이 이미 존재할 경우에도 그 규정의 취지가 반드시 전국에 걸쳐 일률적인 규율을 하려는 것이 아니라 각 지방자치단체가 그 지방의 실정에 맞게 별도로 규율하는 것을 용인하고 있다고 인정되는 경우라면 조례가 법령에서 정하지 않은 사항을 규정하고 있더라도 이를 들어 법령에 위반되는 것이라고 할 수는 없을 것입니다.

질의요지와 같은 내용을 조례에 규정할 수 있으려면 지역축제·행사의 안전관리에 관한 사무가 통영시의 소관 사무에 해당하고, 상위법인 「재난 및 안전관리 기본법」(이하 "재난안전법"이라 한다)에 위반되지 않아야 할 것입니다.

먼저 지역축제·행사의 안전관리에 관한 사무가 통영시의 소관 사무에 해당하는지 살펴보면, 재난안전법에서는 이 법은 국가·지방자치단체가 국민의 생명 및 신체의 안전과 재산보호에 관련된 행위를 할 때에는 안전을 우선적으로 고려함을 기본이념으로 하고(제2조), 국가와 지방자치단체는 재난이나 그 밖의 각종 사고를 예방하고 피해를 줄이기 위하여 노력하여야 한다(제4조제1항)고 규정하고 있습니다. 그리고 「지방자치법」 제13조제2항에서는 "재해대책의 수립 및 집행"(제4호너목)과 "지역의 화재예방·경계·진압·조사"(제6호나목)를 지방자치단체의 사무로 예시하고 있습니다. 따라서 지역축제·행사의 안전관리에 관한 사무는 사고를 예방하여 통영시민의 안전을 보장하기 위한 것이므로 통영시의 소관 사무에 해당한다고 볼 수 있습니다.

다음으로 지역축제·행사의 안전관리계획을 안전정책실무조정위원회(이하 "실무위원회"라 한다)에서 심의하도록 「통영시 안전관리위원회 운영조례」(이하 "통영시조례"라 한다)에 규정하는 것이 재난안전법 제11조에 위반되는지를 살펴보면, 재난안전법 제11조에서는 지역별 재난 및 안전관리에 관한 다음 각 호의 사항을 심의·조정하기 위하여 시장·군수·구청장 소속으로 시·군·구 안전관리위원회(이하 "지역위원회"라 한다)를 두고(제1항), 지역위원회의 회의에 부칠 의안을 검토하고, 재난 및 안전관리에 관한 관계 기관 간의 협의·조정 등을 위하여 지역위원회에 실무위원회를 둘 수 있으며(제3항), 지역위원회 및 실무위원회의 구성과 운영에 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다(제5항)고 규정하고 있습니다.

살피건대, 각 지역별 안전관리 정책과 구체적인 위원회의 운영방식은 해당 지자체의 실정에 따라 다를 수 있다는 점, 재난안전법 제11조제5항에서 실무위원회의 구성과 운영에 필요한 사항을 조례로 정하도록 포괄적으로 위임하고 있다는 점 등에 비추어 볼 때, 위 규정의 취지는 해당 지자체가 지역별 특색에 맞게 그 위원회를 구성하여 탄력적으로 운영할 수 있도록 하려는 것으로 볼 수 있으므로, 법령에서 정하지 않은 사항인 "실무위원회에서 시에서 주관하는 지역축제·행사의 안전관리계획을 심의"하는 내용을 통영시조례에 규정하더라도 법령에 위반된다고 보기는 어려울 것입니다.

따라서 실무위원회에서 시에서 주관하는 지역축제·행사의 안전관리계획을 심의하도록 통영시조례에 규정할 수 있을 것으로 보입니다.

나. 질의 나에 대하여

통영시조례 제7조에서는 시에서 주관하는 지역축제·행사의 안전관리계획을 심의하는 등 위원회의 효율적인 운영을 도모하기 위하여 지역위원회에 실무위원회를 두고(제1항), 실무위원회의 심의를 거친 사항은 지역위원회의 심의를 거친 것으로 본다(제4항)고 규정하고 있는바, 이 사안은 이러한 간주 규정을 조례에 둘 수 있는지를 질의하신 것으로 보입니다.

이와 관련하여 일반적으로 실무위원회는 본 위원회가 아닌 사람으로 구성되고, 그 기능 및 역할도 본 위원회에서 심의되는 안건에 대한 사전 조사·연구·검토·조정 등으로 제한되는 경우가 대부분입니다. 따라서 실무위원회는 본 위원회의 의사를 대표할 수 있는 요건을 갖추었다고 볼 수 없으며, 본 위원회와 구성원이 다른 실무위원회의 심의·의결을 본 위원회의 심의·의결로 간주하는 경우 본 위원회의 기능을 형해화시킬 우려가 있으므로, 실무위원회의 심의·의결을 본 위원회의 심의·의결로 간주하는 규정은 두지 않는 것이 바람직합니다.

이 사안의 경우 통영시조례에 따르면, 지역위원회의 구성원은 "부시장, 통영소방서장, 통영경찰서장, 통영해양경찰서장, 육군 제8358부대 1대대장, 통영교육지원청 교육장 등"(제3조제2항)인 반면, 실무위원회의 구성원은 "부시장 및 지역위원회의 위원이 소속하는 기관·단체의 직원 중에서 해당 기관·단체의 장이 지명하는 자"(제7조제2항)로서 서로 상이하므로, 실무위원회가 지역위원회의 의사를 대표할 수 있는 요건을 갖추었다고 볼 수 없습니다.

따라서 실무위원회의 심의를 거친 사항을 지역위원회의 심의를 거친 것으로 보도록 통영시조례에 규정하는 것은 바람직하지 않은 것으로 보입니다.

사례 39 자문위원회의 심의·의결에 법적 구속력이 없다고 본 사례

2021. 10. 1. 의견제시 21-0286

질의요지

인천광역시 캠프마켓(부평미군기지) 반환공여구역주변지역 등 시민참여위원회(이하 "시민참여위원회"라 한다)가 심의·의결하는 사항에 인천광역시가 반드시 따라야 하는 법적 구속력이 있는지?

의 견

이 사안의 경우 시민참여위원회가 심의·의결하는 사항에 인천광역시가 반드시 따라야 하는 법적 구속력이 있다고 보기는 어렵다고 할 것입니다.

이 유

「지방자치법」 제116조제1항과 제116조의2제1항에서는 각각 지방자치단체는 그 소관 사무의 일부를 독립하여 수행할 필요가 있으면 법령이나 조례로 정하는 바에 따라 '합의제행정기관'을 설치할 수 있다고 규정하고 있고, 그 소관 사무의 범위에서 법령이나 조례로 정하는 바에 따라 심의회·위원회 등의 '자문기관'을 설치·운영할 수 있다고 규정하고 있는바, 조례로 설치된 위원회가 「지방자치법」 제116조에 따라 그 의결에 구속력이 인정되는 합의제행정기관[합의제 행정기관에는 그 의사와 판단을 결정하여 외부에 표시하는 권한을 가지는 합의제 행정관청뿐만 아니라 행정주체 내부에서 행정에 관한 의사 또는 판단을 결정할 수 있는 권한만을 가지는 의결기관도 포함함(대법원 2000. 11. 10. 선고 2000추36 판결 참조)]에 해당하는지 또는 제116조의2에 따라 그 의결에 구속력이 인정되지 않는 자문기관에 해당하는지는 해당 위원회의 심의 사항이나 조례의 규정 형식 등을 종합적으로 고려해서 판단해야 할 것입니다.

그리고 「지방자치법 시행령」 제80조에서는 「지방자치법」 제116조의2에 따라 설치하는 자문기관의 설치요건에 대해 규정하고 있고, 같은 영 제80조의2에서는 자문기관의 위원은 비상임으로 하도록 규정하

고 있으며, 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」 제5조제3항에서는 「지방자치법 시행령」 제80조에 따라 설치되는 자문기관에는 상설의 사무처나 사무국·과·담당관을 둘 수 없다고 규정하고 있으므로, 조례로 규정하고 있는 위원회가 이러한 관련 법령의 요건을 충족하고 있다면 이는 「지방자치법」 제116조의2에 따른 자문기관에 해당하는 것으로 보는 것이 합리적이라고 할 것입니다.

이와 관련하여 「인천광역시 캠프마켓(부평미군기지) 반환공여구역주변지역 등 시민참여위원회 운영 조례」(이하 "인천시조례"라 한다) 제3조에서 시민참여위원회는 종합계획[인천시조례 제2조제2호의 반환공여구역과 같은 조 제3호의 반환공여구역주변지역에 해당하는 지역의 발전 및 주민복지 향상을 위한 사업과 각종 지원에 대한 발전 종합계획을 의미함(인천시조례 제2조제4호)]과 연도별 사업계획의 수립에 관한 사항(제1호), 확정된 종합계획의 변경에 관한 사항(제2호), 종합계획과 연도별 사업계획에 의해 추진되고 있는 사업에 관한 사항(제3호), 지역특색을 반영한 반환공여구역의 부지활용에 관한 사항(제4호), 그 밖에 인천광역시장이 필요하다고 인정하는 사항(제5호) 등을 심의·의결한다고 규정하고 있습니다.

살피건대 인천시조례 제3조에서 시민참여위원회의 기능에 대해 규정하면서 "심의·의결"이라는 용어를 사용하고 있는데 "심의"는 심사하고 토의하는 검토의 한 방법에 해당하고, "의결"은 일반적으로 의사결정 주체가 다수인 위원회 내부의 의견을 모으는 행위 형식을 의미하는 것이므로(법제처 2017. 2. 6. 의견제시 17-0033, 2014. 2. 24. 의견제시 14-0032 참조) 조례에서 "심의·의결"이라는 용어를 사용하고 있다는 것만으로 그 위원회의 심의·의결에 법적 구속력이 있는지 판단할 수는 없습니다.

한편 인천시조례에서는 시민참여위원회의 결정에 인천광역시장이 반드시 따라야 하는 구속력을 별도로 규정하고 있지 않고 상임위원이나 사무국 등 상설 조직을 규정하고 있지 않으며, 「인천광역시 행정기구 설치 조례 시행규칙」 제16조제9항제2호에서는 시민참여위원회의 운영을 캠프마켓과장의 분장사항으로 규정하고 있는 점을 고려하면, 인천시조례에 따른 시민참여위원회는 인천광역시장이 반환공여구역주변지역에 대한 종합계획 등을 수립·시행하는 과정에서 주민 대표, 시민단체, 관련 전문가들의 의견을 종합적으로 듣기 위해 설치한 자문위원회로 보는 것이 합리적이라 할 것입니다.

따라서 시민참여위원회가 심의·의결하는 사항에 인천광역시장이 반드시 따라야 하는 법적 구속력이 있다고 보기는 어려울 것입니다.

3. 위원의 자격·구성 등에 관한 사항을 조례에 규정할 수 있는지

법령에서 지방자치단체에 두는 자문기관의 설치를 규정하고 있는 경우에 이러한 법령의 규정은 그 자문기관의 명칭·심의사항·구성방법 등에 대하여 지방자치단체의 권한에 일정한 제한을 부과하고 있다고 볼 것이고, 해당 지방자치단체는 그 자문기관을 법령에서 정한 명칭과 형태로 조직·운영할 의무가 있다고 할 것이다[21].

21) 2019. 1. 31. 의견제시 19-0034

사례 40

법령에서 정한 내용 외에 주민지원협의체의 구성원 등의 자격을 제한하는 내용을 규정할 수 없다고 본 사례

2021. 2. 9. 의견제시 20-0311

질의요지

가. 「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 제17조의2 및 같은 법 시행령 제18조제1항·별표 2에서 정한 내용 외에 주민지원협의체를 구성하는 주민대표가 될 수 있는 자격을 제한하는 내용을 조례로 규정할 수 있는지?

나. 「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 시행령」 별표 2 제2호나목에 따라 화성시의회가 주민지원협의체의 위원이 되는 주민대표를 추천함에 있어서 '화성시 그린환경센터 주민지원협의체위원 추천대상자 선정위원회'에서 선정한 사람들 중에서만 추천하도록 하는 내용을 조례에 규정할 수 있는지?

의 견

가. 질의 가에 대하여

이 사안의 경우 질의요지와 같은 내용을 조례에 규정할 수 없을 것으로 보입니다.

나. 질의 나에 대하여

이 사안의 경우 질의요지와 같은 내용을 조례에 규정할 수 없을 것으로 보입니다.

이 유

가. 질의의 공통사항

「지방자치법」 제22조 본문에 따르면 지방자치단체는 "법령의 범위 안", 즉 "법령에 위반되지 않는 범위 내"에서 조례를 제정할 수 있고, 주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한 사항이나 벌칙을 정할

때에는 법률의 위임이 있어야 합니다.

「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률」(이하 "폐기물시설촉진법"이라 한다) 제17조의2제1항에서는 환경상 영향조사를 위한 전문연구기관의 선정, 주변영향지역의 주민지원사업에 대한 협의 등의 기능을 수행(폐기물시설촉진법 제17조의2제2항 참조)하는 주민지원협의체(이하 "지원협의체"라 한다)는 해당 폐기물처리시설 소재지의 특별자치시·특별자치도·시·군·구 의회(이하 "지방의회"라 한다) 의원, 주민대표 및 주민대표가 추천한 전문가 가운데 폐기물처리시설 설치기관이 관할 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 및 특별자치시·특별자치도·시·군·구의회와 협의하여 구성하도록 하면서, 같은 항 단서 및 각 호에서 지방협의체의 구성원이 될 수 없는 자를 피성년후견인 또는 파산선고를 받고 복권(復權)되지 아니한 자(제1호), 법률 또는 법원의 판결에 따라 자격이 정지되거나 상실된 자(제4호) 등으로 규정하고 있고, 같은 조 제3항에서는 지원협의체의 세부적인 구성방법을 대통령령으로 정하도록 위임하고 있습니다.

그리고 폐기물시설촉진법 제17조의2제3항의 위임에 따라 지원협의체의 구성방법에 대해 규정하고 있는 「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 시행령」(이하 "폐기물시설촉진법 시행령"이라 한다) 제18조제1항 및 별표 2제2호에서는 지원협의체 위원에 대해 규정하면서 주민대표의 경우에는 주변영향지역(주변영향지역이 결정·고시되지 아니한 경우에는 폐기물매립시설의 경우 부지 경계선으로부터 2킬로미터 이내, 그 밖의 폐기물처리시설의 경우 부지 경계선으로부터 300미터 이내를 말하며, 이하 같음)에 거주하는 지역주민으로서 해당 지방의회에서 추천한 읍·면·동별 주민대표일 것(나목)을 규정하고 있을 뿐이고, 달리 지원협의체 구성원의 자격요건에 대해 조례로 달리 정할 수 있도록 위임하고 있지 않습니다.

나. 질의 가에 대하여

이처럼 폐기물시설촉진법령에서 주변영향지역에 거주하는 지역주민인 읍·면·동별 주민대표가 지원협의체 위원이 되도록 규정한 취지는 주변영향지역의 경우 폐기물처리시설의 설치·운영으로 환경상 영향을 받을 가능성이 있으므로, 그 범위 안에서 거주하는 주민들 중에서 선정한 주민대표로 하여금 지원협의체의 구성원이 되어 환경상 영향조사, 주민지원사업의 결정에 참여하고 지역주민의 이해관계를 반영할 수 있도록 함으로써, 그 주민들이 폐기물처리시설 설치·운영으로 인한 환경상 불이익을 보상받을 수 있도록 하려는 데 있다고 할 것으로서(대법원 2018. 8. 1. 선고 2014두42520 판결 및 법제처 2009.

10. 12. 회신 09-0310 해석례 참조), 특히 폐기물시설촉진법 제17조의2에서 지원협의체 구성원의 결격사유를 규정하고 있는 것은 범죄자 등 부적격자가 지원협의체 구성원이 되는 것을 방지하기 위한 것입니다[구 폐기물설치촉진법(2004. 2. 9. 법률 제7169호로 일부개정된 것) 검토의견서].

그런데 「화성시 그린환경 센터 주민지원협의체위원 추천대상자 선정위원회 구성 및 운영 등에 관한 조례안」(이하 "화성시조례안"이라 한다)에서는 화성시 그린환경센터(폐기물시설촉진법에 따라 설치된 폐기물처리시설로서 폐기물을 태워 생긴 열을 인근 택지지구로 공급하는 곳을 말함) 지원협의체 위원 중 지방의회에서 추천하는 대상자 선정에 대해 규정하면서(제1조) 화성시로부터 폐기물 관련 업무를 위탁받아 영리활동을 하는 사람 등을 대상자에서 제외하도록 규정하고 있는 바, 이는 조례로 지원협의체의 주민대표가 될 수 있는 자격을 법률에서 규정한 사유보다 확대하여 규정하는 것으로 폐기물시설촉진법 제17조의2제1항 및 「지방자치법」 제22조 단서에 반할 소지가 있어 보입니다.

다. 질의 나에 대하여

폐기물시설촉진법 제17조의2 및 같은 법 시행령 제18조제1항 및 별표 2 제2호나목에서는 "해당 지방의회에서 추천한" 읍·면·동별 주민대표를 지원협의체의 주민대표 위원으로 구성하도록 규정하면서 지방의회가 추천하는 읍·면·동별 주민대표의 자격요건으로 주변영향지역에 거주하는 지역주민일 것을 규정하고 있을 뿐, 지방의회가 별도 위원회에서 선정한 사람 중에서 주민대표를 추천하도록 하는 등 주민대표의 구성에 있어 지방의회의 추천권한을 제한하는 아무런 규정을 두고 있지 않습니다.

또한 지원협의체의 주민대표에 관한 내용은 폐기물시설촉진법 시행령 제정 당시 시·군·구의회에서 주민대표를 "선정"하도록 규정하였던 것을 시·군·구의회에서 "추천"하도록 개정되었는데, 그 취지는 지원협의체 주민대표 위원의 선정은 폐기물처리시설 설치기관이 관할 시·군·구청장 및 시·군·구의회의 협의한 후 이루어지게 되므로 시·군·구의회에서는 "선정"하도록 하는 것이 적정하지 않아 같은 영을 2007년 7월 4일 대통령령 제20164호로 일부개정하면서 지방의회에서 주민대표로 추천하도록 규정하였습니다[구 폐기물설치촉진법 시행령(2007. 7. 4. 대통령령 제20164호로 일부개정되어 같은 날 시행된 것) 조문별 개정이유서].

이상과 같은 폐기물시설촉진법 및 같은 법 시행령의 관련 규정과 입법연혁 등에 비추어 볼 때, 같은 법 시행령 별표 2 제2호나목에서 지방의회가 추천한 읍·면·동별 주민대표가 지원협의체 위원이 되도록 규정한 것은, 지방의회에 지원협의체의 위원 중 주민대표에 해당하는 위원을 자율적으로 추천할 권한을

부여한 것이라고 할 것입니다(법제처 2019. 10. 7. 회신 19-0372 해석례 및 법제처 2020. 2. 3. 의견제시 20-0023 참조).

그런데 화성시조례안과 같이 지방의회가 선정위원회에서 선정한 사람들 중에서만 지원협의체 지역대표로 추천할 수 있도록 규정하는 것은 폐기물시설촉진법 시행령 별표 2 제2호나목에 따라 지방의회에 부여된 지원협의체 주민대표에 관한 자율적인 추천권을 하위법규인 조례에서 제한하는 것으로써 지방의회에서 주민대표를 추천하도록 한 폐기물시설촉진법 시행령 별표 2 제2호나목에 위반될 소지가 있다고 할 것입니다.

사례 41

법령에 따라 설치된 심의회의 구성원 등에 관한 사항을 법령과 달리 정할 수 없다고 본 사례

2019. 1. 31. 의견제시 19-0034

질의요지

인제군이 「수산업·어촌 발전 기본법」 제8조 및 같은 법 시행령 제13조에 따른 시·군·구 수산업·어촌정책심의회 운영과 관련하여,

가. 시·군·구 수산업·어촌정책심의회의 구성원 수 상한(上限)을 법령보다 줄여 조례에 규정할 수 있는지?

나. 같은 심의회의 명칭을 "인제군 수산업·어촌정책심의회"로 하지 않고 "인제군 내수면 어업관련 산업 심의위원회"로 조례에 규정할 수 있는지?

다. 같은 심의회의 구성에 있어 부위원장 중 1인을 부군수가 되도록 하지 않고 농업기술센터장이 되도록 조례에 규정할 수 있는지?

의 견

가. 질의 가에 대하여

이 사안의 경우 인제군이 「수산업·어촌 발전 기본법」 제8조 및 같은 법 시행령 제13조에 따른 시·군·구 수산업·어촌정책심의회의 구성원 수 상한(上限)을 줄여 조례에 규정하는 것은 상위법령에 위배될 소지가 있으므로 바람직하지 않는 것으로 보입니다.

나. 질의 나에 대하여

이 사안의 경우 인제군이 「수산업·어촌 발전 기본법」 제8조 및 같은 법 시행령 제13조에 따른 명칭을 "인제군 수산업·어촌정책심의회"로 하지 않고 "인제군 내수면 어업관련 산업 심의위원회"로 조례에 규정하는 것은 상위법령에 위배될 소지가 있으므로 바람직하지 않는 것으로 보입니다.

다. 질의 다에 대하여

이 사안의 경우 인제군이 "인제군 수산업·어촌정책심의회"의 구성에 있어 농업기술센터장을 부위원장으로 조례에 규정하는 것은 상위법령에 위배되는 것으로 보입니다.

이 유

가. 질의의 공통사항

「수산업·어촌 발전 기본법」(이하 "수산업기본법"이라 함) 제8조제1항에서는 시·군 및 자치구에 시·군·구 수산업·어촌정책심의회(이하 "시·군·구심의회"라 함)를 둔다고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제13조제1항에서는 위원장 1명과 부위원장 2명을 포함하여 35명 이내의 위원으로 구성한다고 규정하고 있으며, 같은 조 제2항에서는 위원장은 시장·군수·구청장이 되고 부위원장 중 1명은 해당 시·군·자치구의 부시장·부군수 또는 부구청장이 되며, 다른 1명은 같은 조 제3항제2호부터 제4호까지의 규정에 따른 위원 중에서 호선한다고 규정하고 있는 등 시·군·구심의회의 구성 등에 관한 사항에 대해 규정하고 있습니다.

한편, 「인제군 내수면어업 관련 산업 육성 조례안」(이하 "인제군조례안"이라 함) 제6조에서는 내수면어업관련 산업 심의위원회를 설치 운영할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조례안 제7조제1항에서는 위원회는 위원장 1명, 부위원장 2명을 포함한 13명 이내로 구성한다고 규정하고 있으며, 같은 조 제2항에서는 위원장은 군수가 되고 부위원장은 농업기술센터장과 다른 1명은 같은 조 제3항제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 위원 중에서 호선하며, 당연직 위원은 내수면어업관련 부서장으로 한다고 규정하고 있습니다.

나. 질의 가에 대하여

이 사안은 시·군·구심의회 구성 시 위원 수의 상한을 13명 이내로 규정하는 것이 수산업기본법 시행령 제13조제1항에 위배되는 지에 대한 질의로 보입니다.

먼저, 「지방자치법」 제22조 본문에서는 지방자치단체는 법령의 범위 안에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있다고 규정하고 있으므로 지방자치단체가 제정한 조례가 법령에 위반되는 경우에는 효력이 없다 할 것이고(대법원 2003. 9. 23. 선고 2003추13 판결 참조), 조례가 법령에 위반되는지 여부는

법령과 조례의 각각의 규정 취지, 규정의 목적과 내용 및 효과 등을 비교하여 양자 사이에 모순·저촉이 있는 지의 여부에 따라서 개별적·구체적으로 결정하여야 할 것입니다(대법원 2004. 4. 23. 선고 2002추16 판결 참조).

아울러, 법령에서 지방자치단체에 두는 자문기관의 설치를 규정하고 있는 경우에 이러한 법령의 규정은 그 자문기관의 명칭·심의사항·구성방법 등에 대하여 지방자치단체의 권한에 일정한 제한을 부과하고 있다고 볼 것이고, 해당 지방자치단체는 그 자문기관을 법령에서 정한 명칭과 형태로 조직·운영할 의무가 있다고 할 것입니다. 즉, 지방자치단체의 장은 명시적인 규정이 없는 한 법령에서 설치하도록 한 자문기관을 반드시 해당 법령의 규정에 따라 설치해야 합니다(법제처 2010. 2. 1. 회신 09-0395 해석례 참조).

살피건대, 수산업기본법 제8조제1항에서 시·군 및 자치구에 시·군·구심의회를 둔다고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제13조제1항에서는 에서는 시·군·구심의회는 위원장 1명과 부위원장 2명을 포함하여 35명 이내의 위원으로 구성한다고 규정하고 있으며, 같은 조 제3항에서 시·군·구심의회 위원의 임명 또는 위촉권을 시장·군수·구청장에게 부여하고 있고, 시·군·구심의회의 구성·운영에 관해서 조례로 정하도록 위임한 규정이 없는 점을 보면, 해당 법령에서 직접 그 자문기관의 구성·운영에 관한 사항을 확정적·완결적으로 규정하고 있다고 보이므로, 시·군·구심의회는 "35명 이내의 위원으로 구성한다"는 같은 법 시행령 제13조의 범위에서 군수가 재량판단으로 같은 심의회의 구성을 줄여 운영하는 것은 별론으로 하고, 인제군조례안에서 위원 수의 상한(上限)을 13명 이내로 제한하여 법령과 다르게 규정하는 것은, 법령에 따른 인제군수의 위원 임명·위촉 권한을 제약하는 결과가 되어 상위법령에 위반될 소지가 있으므로 바람직하지 않는 것으로 보입니다.

다. 질의 나에 대하여

이 사안은 시·군·구심의회의 명칭을 "인제군 수산업·어촌정책심의회"로 하지 않고 "인제군 내수면어업관련 산업 심의위원회"로 법령과 다르게 조례에 규정하는 것이 수산업기본법 제8조제1항에 위배되는 지에 대한 질의로 보입니다.

수산업기본법 제8조제1항에서는 시·군 및 자치구에 시·군·구심의회를 둔다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 시·군·구심의회는 시·군·구 계획의 수립 및 변경에 관한 사항(제1호), 같은 법 제10조에 따른 수산업·어촌에 관한 연차보고서(제2호), 수산 분야의 중요 정책 등에 관한 사항(제3호)에 대해 심의한다고 규정되어 있으며, 같은 법 시행령 제7조에서는 시·군 및 자치구의 수산업·어촌 발전계획의

수립 및 변경 시에는 시장·군수·구청장은 시·군·구심의회의 심의를 거치도록 규정하고 있습니다.

앞서 살펴본 바와 같이, 법령에서 지방자치단체에 두는 자문기관의 설치를 규정하고 있는 경우에 이러한 법령의 규정은 그 자문기관의 명칭·심의사항·구성방법 등에 대하여 지방자치단체의 권한에 일정한 제한을 부과하고 있다고 볼 것이고, 해당 지방자치단체는 그 자문기관을 법령에서 정한 명칭과 형태로 조직·운영할 의무가 있다고 할 것입니다.

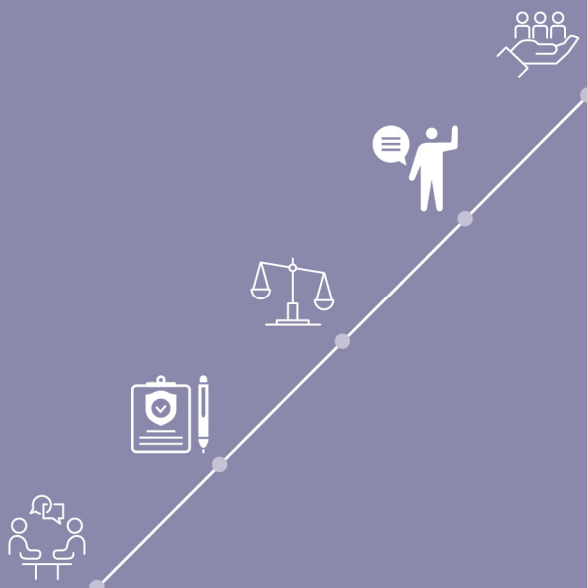
법령 규정의 해석에 있어서는 법률에 규정된 문구의 문리적 의미가 해석의 출발점이고, 법률의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다 할 것인데, 수산업기본법 제8조제1항에서 시·군 및 자치구에 시·군·구심의회를 둔다고 규정한 것은 어느 지방자치단체에서나 수산업·어촌정책과 관련하여 같은 조 제2항에 관한 사항을 심의하도록 법률에 따라 일률적으로 두도록 하는 의미라고 볼 수 있고, 같은 규정에 따라 두는 위원회의 명칭을 법령에서 "시·군·구 수산업·어촌정책심의회"라고 규정하고 있다면, 같은 위원회의 구성·운영에 관한 세부적인 사항에 관해서 규정하기 위한 조례에서도 같은 명칭을 사용하는 것이 바람직합니다(법제처 2012. 10. 17. 회신 12-0420 해석례 참조).

따라서, 인제군이 위원회의 명칭을 "인제군 수산업·어촌정책심의회"로 하지 않고 "인제군 내수면 어업관련 산업 심의위원회"로 법령과 다르게 조례에 규정하는 것은 상위법령에 위배될 소지가 있으므로 바람직하지 않는 것으로 보입니다.

라. 질의 다에 대하여

이 사안은 같은 시·군·구심의회를 구성함에 있어서 부위원장 중 1인을 부군수가 되도록 하지 않고 농업기술센터장이 되도록 조례에 규정할 수 있는지에 대한 질의로 보입니다.

앞서 살펴본 바와 같이, 수산업기본법 시행령 제13조제2항에서 시·군·구심의회의 부위원장 중 1명은 해당 시·군·자치구의 부시장·부군수 또는 부구청장이 된다고 규정하고 있으므로, 인제군에서 시·군·구심의회를 두면서 부위원장을 인제군 부군수가 아닌 농업기술센터장이 되도록 조례에 규정하는 것은 상위법령에 위배되는 것으로 보입니다.



제 6 편

지방자치단체 출자·출연기관 등

1. 지방자치단체 출자·출연기관 등의 정관 기재사항 및 정관 제정·개정과 관련한 보고·동의를 조례에 규정할 수 있는지

지방자치단체 출자·출연 기관은 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에 따라 출자·출연 기관으로 지정된 후 3개월 이내에 목적, 명칭, 주된 사무소가 있는 곳 등이 기재된 정관을 작성하여 미리 지방자치단체의 장과 협의해야 하고, 이를 변경하는 경우에도 동일하다(제8조). 정관 변경 시 지방자치단체의 장과 협의 후 지방의회의 승인을 받도록 하는 경우가 있는데, 상위법령인 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」 제8조제2항, 「민법」 제45조제3항 및 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률 시행령」 제10조를 종합하여 보면 출자·출연 기관의 정관을 변경하려는 경우 미리 지방자치단체의 장과 협의하여 주무관청의 허가를 받도록 규정하고 있을 뿐, 지방의회가 직접 출자·출연 기관에 대하여 견제할 수 있도록 법령에 근거를 두거나 조례로 정하도록 위임한 사항이 없으므로 정관 변경 시 지방자치단체의 장과 협의 후 지방의회의 승인을 받도록 하는 것은 상위법령에 위반될 소지가 있어 허용되지 않는다고 보아야 할 것이다[22].

「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」

제8조(정관) ① 출자·출연 기관의 정관에는 다음 각 호의 사항을 기재하여야 한다. 다만, 출자·출연 기관의 형태와 특성이나 업무 내용상 해당하지 아니하는 사항은 기재하지 아니할 수 있다.

1. 목적
2. 명칭
3. 주된 사무소가 있는 곳
4. 자본금 또는 출연금
5. 주식 발행에 관한 사항
6. 주주총회에 관한 사항
7. 임직원에 관한 사항
8. 이사회의 운영
9. 사업 범위 및 내용과 그 집행
10. 예산과 회계
11. 정관의 변경

22) 『자치법규 입안 길라잡이(2022)』 247·248쪽 참조

12. 해산에 관한 사항
13. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

② 출자·출연 기관은 제5조에 따라 출자·출연 기관으로 지정된 후 3개월 이내에 제1항에 따른 정관을 작성하여 미리 지방자치단체의 장과 협의하여야 한다. 정관의 기재사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

사례 42 지방연구원의 정관 기재사항을 규정하는 것은 바람직하지 않다고 본 사례

2023. 10. 11. 의견제시 23-0387

질의요지

가. 「지방자치단체출연 연구원의 설립 및 운영에 관한 법률」 제5조에서 정관에 포함하도록 한 사항을 조례로 구체화하여 규정할 수 있는지?

나. 지방자치단체출연 연구원이 정관을 변경하려는 경우 지방의회의 동의를 받도록 하는 내용을 조례로 규정할 수 있는지?

의 견

가. 질의 가에 대하여

아래 이유를 참고하시기 바랍니다.

나. 질의 나에 대하여

아래 이유를 참고하시기 바랍니다.

이 유

가. 질의의 공통사항

지방자치단체출연 연구원의 설립·지원 및 육성과 체계적인 관리 및 책임경영에 관한 기본적인 사항을 규정하고 있는 「지방자치단체출연 연구원의 설립 및 운영에 관한 법률」(이하 "지방연구원법"이라 한다)에서는 지방자치단체출연 연구원(이하 "지방연구원"이라 한다)을 지방자치단체 등이 출연·보조하고, 연구를 주된 목적으로 수행하는 연구원을 말한다고 규정(제2조)하면서, 특별시·광역시·특별자치시·도 및 특별자치도와 인구 50만 이상의 시(이하 "대도시"라 한다)에는 지방연구원을 둘 수 있다고 규정하고 있습니다(제4조제1항 및 제2항).

그리고 지방연구원법 제5조에서는 지방연구원의 정관에는 목적, 명칭, 이사회에 관한 사항 등이 포함되어야 하고(제1항), 지방연구원의 정관변경은 이사회의 의결을 거쳐 특별시장·광역시장· 특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다) 또는 대도시 시장의 승인을 받아야 한다(제2항)고 규정하고 있습니다.

나. 질의 가에 대하여

그런데 지방연구원법 제5조제1항에서는 지방연구원의 정관에 포함되어야 할 사항으로 재산 및 회계에 관한 사항(제5호), 임원·연구원 및 직원에 관한 사항(제6호), 이사회에 관한 사항(제7호) 등을 규정하고 있는바, 이 사안의 경우 지방연구원법 제5조에서 정관에 포함하도록 한 사항을 조례로 구체화하여 규정할 수 있는지에 관한 것으로 보입니다.

살피건대 지방연구원법에서는 임원의 구성·직무·선임·임기 등에 관한 사항(제6조부터 제9조까지), 이사회의 구성과 기능에 관한 사항(제10조), 이사회의 운영에 관한 사항(제11조), 운영재원 및 수익사업에 관한 사항(제13조 및 제14조) 등을 규정하면서 일정한 사항을 조례로 정하도록 하거나(제8조제4항 및 제13조제3항 등), 정관으로 정하도록 규정(제8조제1항·제3항 및 제11조제4항 등)하고 있을 뿐 정관에 포함하도록 한 사항을 조례로 구체화하도록 하는 규정을 두고 있지는 않는 것으로 보입니다.

그리고 지방연구원은 지방연구원법 제3조에 따른 법인으로서 독립된 법인격을 가지고 있고, 같은 법 제12조제1항에서도 지방연구원은 연구 및 경영에서 독립성과 자율성이 보장된다고 규정하여 지방연구원의 독립성 및 자율성을 명시적으로 보장하고 있다는 점에 비추어볼 때, 지방연구원법이 정관에 포함하도록 규정하고 있는 사항을 조례로 구체화하는 규정을 두는 것은 독립된 법인격을 가진 지방연구원의 독립성이나 자주성을 훼손시킬 우려가 있는 것으로 보입니다.

따라서 질의요지와 같이 지방연구원법 제5조에서 정관에 포함하도록 한 사항을 조례로 구체화하여 규정하는 것은 지방연구원의 독립성이나 자주성을 훼손시킬 우려가 있어 바람직하지 않을 것으로 보이므로 조례 입안에 신중을 기하시기 바랍니다.

다. 질의 나에 대하여

지방연구원법 제5조에서는 지방연구원의 정관에는 목적, 명칭, 이사회에 관한 사항 등이 포함되어야 하고(제1항), 지방연구원의 정관변경은 이사회의 의결을 거쳐 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인을 받아야 한다(제2항)고 규정하고 있습니다.

살피건대 지방연구원법 제5조제2항에서는 지방연구원의 정관변경은 이사회의 의결을 거쳐 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인을 받아야 한다고 규정하고 있을 뿐 지방의회가 직접 지방연구원에 대하여 관여할 수 있도록 규정하거나 지방의회가 관여할 수 있도록 조례로 위임한 사항은 없는 것으로 보이는바, 지방의회의 동의를 정관변경의 필수적 절차로 두고 지방연구원에서 정관을 변경할 때에 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인 외에 지방의회의 동의를 반드시 받아야 한다는 취지라면 이는 법령에서 인정하고 있는 범위를 넘어 새로운 정관변경 절차를 추가하게 되는 것으로 상위법령의 취지에 위배될 소지가 있습니다.

또한 「지방자치법」 제28조제1항 단서에서는 주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한 사항이나 벌칙을 정할 때에는 법률의 위임이 있어야 한다고 규정하고 있으므로, 조례를 제정함에 있어 그 내용이 주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한 사항이나 벌칙인 경우에는 법률의 위임이 있어야 하고, 법률의 위임 없이 주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한 사항을 정한 조례는 그 효력이 없다고 할 것입니다(대법원 2012. 11. 22. 선고 2010두19270 판결 참조).

그런데 지방연구원의 정관을 변경하려는 경우 지방연구원으로 하여금 지방의회의 동의를 받도록 하는 내용을 조례로 규정하는 것은 법률의 위임 없이 지방연구원에 지방의회의 동의를 받아야 하는 의무를 부과하는 것이므로 「지방자치법」 제28조제1항 단서에 위반될 소지가 있는 것으로 보입니다(법제처 2021. 2. 23. 의견제시 21-0061 참조).

나아가 법령의 명시적인 근거나 위임 규정 없이 지방연구원의 정관을 변경하려는 경우 지방연구원으로 하여금 지방의회의 동의를 받도록 하는 의무를 부과하는 것은 지방연구원법 제3조 및 제12조에 따라 독립된 법인격을 가진 법인으로 설립된 지방연구원의 경영상 독립성이나 자율성을 훼손시킬 우려가 있으므로 이러한 법인제도의 취지를 고려하여 신중하게 접근할 필요가 있는 점 역시 고려되어야 할 것입니다(법제처 2023. 8. 4. 의견제시 23-0288 참조).

따라서 지방연구원이 정관을 변경하려는 경우 지방의회의 동의를 받도록 하는 내용을 조례로 규정하는 것은 상위법령에 위배될 소지가 있으므로, 자치법규 입안에 신중을 기하시기 바랍니다.

사례 43

지방자치단체 출자·출연기관의 정관을 제정·개정하려는 경우 지방의회의 사전동의를 받도록 규정할 수 없다고 본 사례 (질의 가)

2021. 2. 23. 의견제시 21-0061

질의요지

가. 김천복지재단의 정관을 제정·변경하려는 경우 사전에 시의회의 동의를 받도록 하는 내용을 조례에 규정할 수 있는지?

나. 김천시장이 김천복지재단의 사업과 관련된 자치사무를 김천복지재단에 위탁하려는 경우 사전에 시의회의 동의를 받도록 하는 내용을 조례에 규정할 수 있는지?

다. 김천시장이 김천복지재단의 사업계획서, 예산서, 결산서를 시의회에 제출하도록 하는 내용을 조례에 규정할 수 있는지?

의 견

가. 질의 가에 대하여

이 사안의 경우 질의요지와 같은 내용을 조례에 규정할 수 없을 것으로 보입니다.

나. 질의 나에 대하여

이 사안의 경우 질의요지와 같은 내용을 조례에 규정할 수 있을 것으로 보입니다.

다. 질의 다에 대하여

이 사안의 경우 질의요지와 같은 내용을 조례에 규정할 수 있을 것으로 보입니다.

이 유

가. 질의의 공통사항

「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」(이하 "지방출자출연법"이라 한다) 제4조제1항에서는 지방자치단체는 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 자본금 또는 재산의 전액을 출자 또는 출연하거나 지방자치단체 외의 자와 공동으로 출자하거나 출연하여 「상법」에 따른 주식회사나 「민법」 또는 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」에 따른 재단법인을 설립할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항에서는 출자·출연 기관과 관련한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다고 규정하고 있습니다.

그리고 「김천시 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례안」(이하 "김천시조례안"이라 한다)에 따르면 김천복지재단(이하 "복지재단"이라 한다)은 김천시장(이하 "시장"이라 한다)이 「민법」 제32조에 따라 복지사각지대의 취약계층 보호 지원 등을 위하여 설립하는 재단법인(제2조 및 제3조)으로서 지방출자출연법의 적용을 받는 출자·출연기관에 해당[지방출자출연법은 지방자치단체가 설립하고 같은 법 제5조에 따라 지정·고시된 출자·출연기관에 대하여 적용되나(제2조제1항), 복지재단은 현재 설립 중으로 김천시 출자·출연기관으로 지정·고시되지 않았음. 그러나 김천시는 현재 출연기관의 설립 및 지정·고시와 김천시의 출연을 위한 절차가 진행 중이라고 설명하고 있으므로 복지재단이 김천시 출자·출연기관으로 지정·고시되어 지방출자출연법이 적용됨을 전제로 검토함]하므로 지방출자출연법 제4조제3항에 따라 복지재단의 운영 등에 관한 기본적인 사항은 조례로 정할 수 있다고 할 것입니다.

나. 질의 가에 대하여

그러나 「지방자치법」 제22조에 따르면 지방자치단체는 "법령의 범위 안" 즉, "법령에 위반되지 않는 범위 내"에서 조례를 제정할 수 있으므로 조례로 정하는 내용이 출자·출연 기관과 관련된 상위 법령에 위반되지 않아야 할 것인바, 지방출자출연법 제8조제2항에서는 출자·출연 기관은 제5조에 따라 출자·출연 기관으로 지정된 후 3개월 이내에 제1항에 따른 정관을 작성하여 미리 지방자치단체의 장과 협의하여야 하고 정관의 기재사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다고 규정하고 있으며, 「민법」 제45조제3항(제42조제2항 준용)에서는 재단법인의 정관 변경 시 주무관청의 허가를 받지 않으면 효력이 없다고 규정하고 있습니다.

이처럼 지방출자출연법과 「민법」에서는 정관을 제정·변경하려는 경우에는 미리 지방자치단체의 장과 협의하고 주무관청의 허가를 받도록 규정하고 있을 뿐, 지방의회가 직접 출자·출연기관에 대하여 견제할 수 있도록 법령에 근거를 두거나 조례로 정하도록 위임한 사항은 없는 것으로 보입니다.

그런데 김천시조례안 제5조제2항에서는 복지재단은 정관을 제정하거나 변경하는 경우 주무관청에 정관 제정·변경 허가 신청을 하기 전에 시장과 협의하도록 하면서, 사전에 김천시의회의 동의를 받도록 규정하고 있는바, 해당 내용이 시의회의 승인을 정관 제정·변경의 필수적 절차로 두고 재단이 시장과 협의가 되었다 하더라도 시의회의 사전 승인 없이는 주무관청에 정관 제정·변경 허가 신청을 할 수 없도록 하는 취지라면, 이는 법령에서 인정하고 있는 범위를 넘어 새로운 정관 제정·변경 허가 절차를 추가하게 되는 것으로 결국 조례가 상위법령의 효력을 좌우하게 되는 결과를 가져오게 되어 상위법령에 위반될 소지가 있습니다(법제처 2016. 4. 27. 의견제시 16-0100 참조).

또한 「지방자치법」 제22조 단서에 따르면 지방자치단체가 조례를 제정함에 있어 그 내용이 주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한 사항이나 벌칙인 경우에는 법률의 위임이 있어야 하고, 법률의 위임 없이 주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한 사항을 정한 조례는 그 효력이 없다고 할 것인데(대법원 2012. 11. 22. 선고 2010두19270 판결 등 참조), 김천시조례안 제5조제2항의 내용이 복지재단으로 하여금 정관을 제정·변경하려는 경우 주무관청에 허가 신청을 하기 이전에 시의회의 동의를 받도록 하는 것이라면 이는 법률의 위임 없이 복지재단에 대해 추가적인 의무를 부과하는 것이므로, 「지방자치법」 제22조 단서에도 위반되는 것으로 판단됩니다.

아울러 법령의 명시적인 근거나 위임 규정 없이 김천시조례안에서 정관 제정·변경에 대한 주무관청의 허가 이전에 시의회의 동의를 받도록 한다면 독립된 법인격을 가진 법인인 복지재단의 운영에 대한 독립성이나 자주성을 훼손시킬 우려가 있으므로, 「민법」 등에 따른 법인제도의 취지를 고려하여 신중하게 접근할 필요가 있습니다.

이러한 점을 종합적으로 고려하면 질의요지와 같은 내용을 조례로 규정하는 것은 「지방자치법」 제22조 단서 등 상위법령에 위반될 소지가 있다고 할 것입니다.

다. 질의 나에 대하여

먼저 「지방자치법」 제104조제2항에서는 지방자치단체의 장은 조례나 규칙으로 정하는 바에 따라 그 권한에 속하는 사무의 일부를 관할 지방자치단체나 공공단체 또는 그 기관에 위임하거나 위탁할

수 있다고 규정하고 있는바, 여기서 “공공단체”란 법령이나 조례에 따라 설치된 단체, 지방자치단체가 출연·보조를 통하여 재정적으로 그 시설의 설치·운영에 대하여 관리·감독을 할 수 있는 단체 또는 그 밖에 지방자치단체가 그 조직이나 활동 등에 대하여 법률상 또는 사실상의 영향력을 행사할 수 있는 단체 등을 말한다고 할 것이고(법제처 2010. 4. 16. 의견제시 10-0037 및 2018. 5. 4. 의견제시 18-0081 참조), 질의 가에서 살펴본 바와 같이 복지재단은 지방출자출연법 제4조 및 김천시조례안에 따라 김천시의 출연금 등을 기본재산으로 설립된 출연기관으로서, 「지방자치법」 제104조제2항의 공공단체에 해당한다고 볼 수 있을 것입니다(법제처 2018. 6. 28. 의견제시 18-0134 참조).

그리고 김천시조례안 제9조에 따르면 시장은 재단의 사업과 관련된 사무를 시의회의 동의를 거쳐 복지재단에 위탁할 수 있다고 규정하고 있는바, 지방자치단체장이 일정한 사무에 대해 위탁을 하는 경우 지방의회의 사전 동의를 받도록 하는 것은 사무 위탁 시 제도의 취지에 반하여 보조금의 교부 등으로 비용이 더 드는 경우가 있고, 공평성의 저해 등에 의한 행정서비스의 질적 저하를 불러올 수 있으며, 위탁기관과 수탁자 간에 책임 한계가 불명확하게 될 우려도 있고, 행정의 민주화와 종합성이 손상될 가능성도 있으므로 위와 같은 단점을 보완할 수 있는 장치를 두려는 것으로 위탁 권한을 지방자치단체장으로부터 박탈하려는 것은 아니라는 점을 고려하면, 그러한 통제 장치를 둘 필요성은 수탁기관이 공공단체라 하여 달리 볼 것은 아니라고 할 것입니다(법제처 2020. 11. 12. 의견제시 20-0228 참조).

따라서 질의요지와 같이 시장이 복지재단의 사업과 관련된 자치사무를 복지재단에 위탁하려는 경우 시의회의 사전 동의를 받도록 하는 내용을 조례로 규정하는 것은 가능하다고 할 것입니다.

라. 질의 다에 대하여

지방출자출연법 제18조에서는 출자·출연 기관은 매 회계연도의 사업계획 등을 작성하고 그에 따른 예산을 회계연도 개시 전까지 편성하여야 하며(제1항), 예산이 성립되거나 변경되었을 때에는 지체 없이 지방자치단체의 장에게 보고하여야 한다고 규정(제2항)하고 있고, 같은 법 제19조에서는 출자·출연 기관은 매 회계연도가 끝난 후 2개월 이내에 결산서를 작성하여 지방자치단체의 장에게 제출하여야 한다고 규정하고 있습니다.

한편 김천시조례안 제10조에서는 재단은 연간 사업계획서 및 예산서를 작성하여 사업연도 개시 2개월 전까지 시장에게 제출하고 시장은 시의회에 제출하여야 하며(제1항), 시장은 재단으로부터 보고받은 결산서를 시 결산서 제출 시 함께 시의회에 제출하여야 한다고 규정하고 있는데(제3항), 시의회가 시장의

업무나 권한행사에 개입하는 별도의 규정은 없으며 시의회에 사업계획서 및 예산서, 결산서를 제출한 이후 시의회의 의결이나 의견에 일률적으로 따라야 하는 등 법적 구속이 있는 것은 아니라는 점을 고려하면, 김천시조례안의 해당 규정이 지방자치단체장의 집행권한을 본질적으로 침해한다고 보기는 곤란한 점, 지방출자출연법에서 사업계획서 등을 지방자치단체장에게 보고하도록 하는 규정이 지방의회의 보고나 제출 등의 절차를 배제하려는 취지로 보기 어려운 점 등을 종합적으로 고려해 볼 때, 시장이 복지재단의 사업계획서 및 예산서, 결산서를 시의회에 제출하도록 규정하는 것이 시장의 권한을 침해한다거나 상위법령에 직접적으로 위배된다고 할 수는 없을 것으로 보입니다(대법원 2001. 11. 27. 선고 2001추57 판결 참조).

또한 「지방자치법」 제39조제1항에 따라 지방자치단체 예산의 심의·확정 및 결산의 승인 권한은 지방의회에 있고, 「지방재정법」 제33조제1항에서는 지방자치단체의 장은 출연금을 포함한 예산안을 지방의회에 제출하도록 규정하고 있으며, 같은 법 제18조에서는 지방자치단체가 출자 또는 출연을 하려면 미리 해당 지방의회의 의결을 얻어야 한다고 규정하고 있는 점 등을 미루어 볼 때 출자· 출연기관에 대한 출연 및 지방자치단체의 재정운용에 대한 최종적인 확정권한은 지방의회에 유보되어 있으며, 출자·출연기관에 대한 출연금의 운용 현황이나 실태에 대한 사전 자료 제출이 지방의회의 적절하고 효율적인 심의를 보조하기 위해 필요하다고 보입니다(법제처 2016. 4. 27. 의견제시 16-0100 참조).

따라서 질의요지와 같이 시장이 복지재단의 사업계획서 및 예산서, 결산서를 시의회에 제출하도록 하는 내용을 조례로 규정하는 것은 가능할 것으로 보입니다.

사례 44

지방자치단체 출자·출연기관의 정관의 제정·개정과 관련한 협의사항을 지방의회에 보고하도록 할 수 있다고 본 사례 (질의 가)

2018. 10. 1. 의견제시 18-0218

질의요지

제천시 출자·출연기관으로 설립하려고 하는 제천문화재단 관련 사항을 규정한 「제천문화재단 설립 및 운영에 관한 조례안」에 대하여,

가. 제천시장이 제천문화재단의 정관 제정·개정과 관련하여 제천문화재단과 협의한 사항을 시의회에 보고하여야 한다고 조례로 규정할 수 있는지?

나. 제천시장이 제천문화재단의 사업계획서 및 예산서를 승인한 경우 그 승인사항을 시의회에 보고하여야 한다고 조례로 규정할 수 있는지?

다. 제천문화재단이 사업실적과 감사결과를 첨부한 결산 보고서를 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에 시의회 의장에게 제출하여야 한다고 조례로 규정할 수 있는지?

의 견

가. 질의 가에 대하여

제천시장이 제천문화재단의 정관 제정·개정과 관련하여 제천문화재단과 협의한 사항을 시의회에 보고하여야 한다고 조례로 규정하는 것은 가능할 것으로 보입니다.

나. 질의 나에 대하여

제천시장이 제천문화재단의 사업계획서 및 예산서에 대한 승인사항을 시의회에 보고하여야 한다는 내용의 제천시조례안 제13조제2항은, 그 전제가 되는 제천시조례안 제13조제1항이 상위법령에 위배될 소지가 있으므로 그 역시 상위법령에 위배될 소지가 있다고 할 것인바, 자치법규 입안에 신중을 기하시기 바랍니다.

다. 질의 다에 대하여

제천문화재단이 사업실적과 감사결과를 첨부한 결산 보고서를 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에 시의회 의장에게 제출하여야 한다고 조례로 규정하는 것은 상위법령에 위배될 소지가 있다고 할 것이므로, 자치법규 입안에 신중을 기하시기 바랍니다.

이 유

가. 질의의 공통사항

「제천문화재단 설립 및 운영에 관한 조례안」(이하 "제천시조례안"이라 함) 제1조에서는 제천문화재단의 설립 및 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다고 규정하고 있고, 같은 조례안 제2조에서는 재단의 설립과 운영은 「민법」 및 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」(이하 "지방출자출연법"이라 함) 등 관계 법령에서 달리 정하는 경우를 제외하고는 이 조례에서 정하는 바에 따른다고 규정하고 있습니다.

한편, 지방출자출연법 제2조제1항 전단은 "이 법은 지방자치단체가 설립하고 제5조에 따라 지정·고시된 출자기관 또는 출연기관(이하 '출자·출연기관'이라 한다)에 대하여 적용한다"고 규정하고 있고, 같은 법 제4조제1항에서는 지방자치단체는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 자본금 또는 재산의 전액을 출자 또는 출연하거나 지방자치단체 외의 자와 공동으로 출자하거나 출연하여 「상법」에 따른 주식회사나 「민법」 또는 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」에 따른 재단법인을 설립할 수 있다고 규정하는 한편, 같은 항 제1호에서 문화, 예술, 장학, 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지할 수 있는 사업을 규정하고 있습니다. 또한 같은 조 제3항에서는 출자·출연기관의 설립 목적(제1호), 주요 업무와 사업(제2호), 출자 또는 출연의 근거와 방법(제3호), 그 밖에 기관의 운영 등에 관한 기본적인 사항(제4호)을 조례로 정할 수 있도록 규정하고 있습니다.

그리고, 「지역문화진흥법」 제19조제1항에서는 지방자치단체의 장은 지역문화진흥에 관한 중요 시책을 심의·지원하고 지역문화진흥 사업을 수행하기 위하여 지역문화재단 및 지역문화예술위원회를 설립·운영할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 "지역문화재단 및 지역문화예술위원회는 법인으로 하되, 이 법에서 규정한 것을 제외하고는 「민법」 중 재단법인에 관한 규정을 준용한다"고 규정하고 있으며, 같은 조 제3항에서는 "그 밖에 지역문화재단 및 지역문화예술위원회의 설립 및 운영에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 지방자치단체의 조례로 정한다"고 규정하고 있습니다.

나. 질의 가에 대하여

제천시조례안 제6조제2항에서는 제천문화재단은 정관을 제정 또는 변경하고자 할 때에는 주무관청에 정관변경 허가 신청을 하기 전에 이사회의 의결을 거쳐 시장과 협의하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항에서는 시장은 같은 조 제2항의 협의사항을 지체 없이 제천시의회(이하 "시의회"라 함)에 보고하여야 한다고 규정하고 있으며, 지방출자출연법 제8조제2항은 "출자·출연기관은 제5조에 따라 출자·출연기관으로 지정된 후 3개월 이내에 제1항에 따른 정관을 작성하여 미리 지방자치단체의 장과 협의하여야 한다. 정관의 기재사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다"고 규정하고 있는바, 이 사안은 제천시장이 제천문화재단의 정관 제정·개정에 대하여 제천문화재단과 협의한 사항을 시의회에 보고하여야 한다고 조례로 규정할 수 있는지에 대한 질의로 보입니다.

먼저, 「지방자치법」은 의결기관으로서의 지방의회와 집행기관으로서의 지방자치단체장에게 독자적 권한을 부여하는 한편, 지방의회는 행정사무감사와 조사권 등에 의하여 지방자치단체장의 사무집행을 감시 통제할 수 있게 하고 지방자치단체장은 지방의회의 의결에 대한 재의요구권 등으로 의회의 의결권행사에 제동을 가할 수 있게 함으로써 상호 견제와 균형을 유지하도록 하고 있으므로, 지방의회는 자치사무에 관하여 법률에 특별한 규정이 없는 한 조례로써 지방자치단체장의 고유권한을 침해하지 않는 범위 내에서 조례를 제정할 수 있다고 할 것이고(대법원 2013. 4. 11. 선고 2012추22 판결 참조), 또한 지방의회가 지방자치단체장의 고유권한이 아닌 사항에 대하여도 그 사무집행에 관한 집행권을 본질적으로 침해하는 것은 허용될 수 없다고 할 것입니다(대법원 2001. 11. 27. 선고 2001추57 판결 참조).

그런데, 「지방자치법」 제9조제2항제5호라목에서는 "지방문화·예술의 진흥"을 지방자치단체의 사무로 규정하고 있고, 앞서 살펴본 바와 같이 지방출자출연법 제4조제3항에서는 설립 목적(제1호), 주요 업무와 사업(제2호), 출자 또는 출연의 근거와 방법(제3호), 그 밖에 기관의 운영 등에 관한 기본적인 사항(제4호)을 조례로 정할 수 있도록 규정하고 있으며, 「지방문화진흥법」 제19조제3항에서는 같은 조 제1항 및 제2항에서 규정한 것 외의 지역문화재단 및 지역문화예술위원회의 설립 및 운영에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 지방자치단체의 조례로 정한다고 규정하고 있습니다. 이와 같이 출자·출연기관인 지역문화재단의 설립 및 운영에 관한 사항을 "조례"로 정하도록 한 지방출자출연법 및 「지방문화진흥법」의 관련 규정 등에 의할 때, 제천문화재단의 운영 권한이 제천시장에게 전속적으로 부여된 것으로 볼 수는 없다 할 것이고, 따라서 제천문화기관의 운영에 대한 지방의회의 관여가 배제되는 것은 아닌 것으로 보입니다(법제처 2017. 1. 10. 의견제시 17-0008 참조).

또한, 지방출자출연법 제8조제2항에서는 "출자·출연기관은 제5조에 따라 출자·출연기관으로 지정된 후 3개월 이내에 제1항에 따른 정관을 작성하여 미리 지방자치단체의 장과 협의하여야 한다. 정관의 기재사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다"고 규정함으로써 출자·출연기관의 정관의 제정 및 개정에 있어 지방자치단체장과 출자·출연기관 사이의 협의 절차를 규정하고 있으나 지방자치단체 의회에 관한 사항에 대해서는 따로 규율하고 있지 아니하므로, 위 규정이 지방자치단체장이 출자·출연기관과 협의를 마친 사항에 대하여 시의회에 보고하도록 조례로 규정하는 것을 반드시 배제하려는 취지로 보이지는 않습니다.

이상의 사정들에 더하여, 제천시조례안 제3항에서는 제천시장이 출자·출연기관의 정관 제정 및 개정과 관련하여 출자출연기관과 협의를 하기 이전에 사전에 보고하도록 하는 것이 아니라 협의를 마친 후 사후적으로 보고하도록 규정하고 있고, 시의회에 보고를 한 후 반드시 시의회의 의결이나 의견에 일률적으로 따라야 하는 등 법적 구속을 규정하고 있지도 않는 점, 출자·출연기관의 정관 제정 및 개정과 관련한 협의사항을 시의회에 보고하도록 함으로써 제천시 출자·출연기관 운영의 책임성과 실효성을 담보할 필요성도 있는 점 등까지 고려하면, 제천시장으로 하여금 제천문화재단과 정관 제정 및 개정과 관련하여 협의한 사항에 대하여 시의회의 동의 또는 승인을 받도록 하는 정도가 아니라 시의회에 보고하도록 하는 것이 제천시장의 집행권을 본질적으로 침해하는 것이라고 보기는 어렵습니다(대법원 2001. 11. 27. 선고 2001추57 판결, 법제처 2016. 12. 2. 의견제시 16-0328, 법제처 2017. 1. 10. 의견제시 17-0008 등 참조).

그렇다면, 제천시장이 제천문화재단의 정관 제정·개정과 관련하여 제천문화재단과 협의한 사항을 시의회에 보고하여야 한다고 조례로 규정하는 것은 가능할 것으로 보입니다.

다. 질의 나에 대하여

제천시조례안 제13조제1항에서는 제천문화재단은 매 사업연도의 사업계획서 및 예산서를 회계연도 개시 2개월 전까지 시장에게 제출하고 승인을 받아야 하며 이를 변경할 때에는 사전에 시장의 승인을 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 시장은 같은 조 제1항의 승인사항을 지체 없이 시의회에 보고하여야 한다고 규정하고 있습니다. 한편 지방출자출연법 제18조제1항에서는 출자·출연기관은 매 회계연도의 사업계획 등을 작성하고 그에 따른 예산을 회계연도 개시 전까지 편성하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항은 출자·출연기관은 예산이 성립되거나 변경되었을 때에는 지체 없이

지방자치단체의 장에게 보고하여야 한다고 규정하고 있는바, 이 사안은 제천시장이 제천문화재단의 사업계획서 및 예산서를 승인한 경우 그 승인사항을 시의회에 보고하여야 한다고 조례로 규정할 수 있는지에 대한 질의로 보입니다.

그런데, 제천시장이 제천문화재단의 사업계획서 및 예산서에 대한 승인사항을 시의회에 보고하여야 한다고 조례로 규정하기 위해서는, 그 전제로서 제천시조례안 제13조제1항과 같이 제천문화재단으로 하여금 매 사업연도의 사업계획서 및 예산서를 회계연도 개시 2개월 전까지 시장에게 승인받도록 하고, 사업계획서 및 예산서를 변경할 때에도 사전에 시장의 승인을 받도록 조례로 규정하는 것이 가능하여야만 할 것입니다.

그러므로, 제천시조례안 제13조제1항과 같은 내용을 조례로 규정하는 것이 가능한지 여부에 대하여 살피건대, 먼저 예산의 "성립"이란 편성된 예산안이 적법한 절차에 따라 심의·의결을 거친 후의 상태를 의미한다고 할 것입니다(지방자치법 제131조, 지방재정법 제46조). 그런데 지방출자출연법 제18조제1항에서는 사업계획의 작성과 예산안의 편성 단계에서는 출자·출연기관이 지방자치단체장에게 보고하거나 승인받을 것을 규정하지 않고 있습니다. 또한 지방출자출연법 제18조제2항부터 제4항까지에서는 예산이 성립되거나 변경되었을 때 출자·출연기관으로 하여금 지방자치단체장에게 보고하도록 하고, 지방자치단체장은 보고된 예산이 법령에 위반되거나 해당 지방자치단체의 회계 관계 규정 등을 고려하여 필요하다고 인정되는 경우에는 그 시정을 명하여야 하며, 지방자치단체장이 시정을 명한 경우 출자·출연기관은 특별한 사정이 없으면 이에 따라야 한다고 규정함으로써 지방자치단체장에게 시정명령 권한을 부여하고 있으나, 위 시정명령권 역시 출자·출연기관의 예산이 성립한 이후에 적용되는 사후적 권한에 해당합니다.

또한, 지방출자출연법 제18조제5항에서는 같은 조 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 예산의 편성 등과 그 보고와 관련하여 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 같은 법 시행령 제14조제2항에서는 행정안전부장관은 법 제27조제2호에 따라 다음 연도의 예산의 편성·집행과 자금 운영에 관한 사항을 정하는 운영지침(이하 '예산편성지침'이라 함)을 매년 6월 30일까지 지방자치단체의 장 또는 출자·출연기관의 장에게 통보하여야 한다고 규정하고 있으며, 같은 조 제3항에서는 지방자치단체의 장은 같은 조 제2항에 따라 통보받은 예산편성지침에 관한 세부사항을 작성하여 출자·출연기관의 장에게 통보할 수 있다고 규정하고 있을 뿐, 그 외 예산으로 성립하기 전의 편성된 예산안이나 사업계획에 대하여 지방자치단체장이 "승인"의 방법으로 관여할 수 있는 규정은 두지 않고 있습니다.

이상과 같이, 지방출자출연법령의 규정들에서는 출자·출연기관의 사업계획의 작성 및 예산안의 편성에 관한 지방자치단체장의 승인 권한을 부여하지 않고 있습니다. 아울러 지방출자출연법 제3조제2항에서는 지방자치단체는 출자·출연기관의 자율적인 운영을 보장하며, 공정하고 자유로운 경제질서를 해치지 아니하도록 노력하여야 한다고 규정하고 있습니다. 그리고 지방출자출연법 제4조제1항에서는 지방자치단체는 특정 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 재산의 전액을 출연하거나 지방자치단체 외의 자와 공동으로 출연하여 「민법」 또는 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」에 따른 재단법인을 설립할 수 있도록 규정하고 있고, 이에 따라 제천시조례안 제4조는 제천문화재단을 「민법」에 따른 재단법인으로 설립한다고 규정하고 있으므로, 제천문화재단에 관한 조례의 입안에 있어서는 일정한 목적에 바쳐진 재산에 관하여도 독립된 법인격을 부여하여 재단법인을 설립할 수 있도록 한 「민법」의 법인제도의 취지를 고려하여 신중하게 접근하여야 할 것입니다.

이상의 사정을 고려하면, 법령의 명시적인 근거 규정이나 위임 규정이 없이 제천시조례안 제13조제1항에서 제천문화재단의 사업계획서와 예산서에 대하여 회계연도 개시 2개월 전까지 시장의 승인을 받도록 하고 이를 변경할 때에도 사전에 시장의 승인을 받아야 한다고 규정하는 것은 독립된 법인격을 가진 제천문화재단 운영의 독립성이나 자율성을 훼손시킬 우려가 있고, 나아가 상위법령인 지방출자출연법과 그 하위법령 및 「민법」 등에 위반될 소지가 있다고 할 것이어서 바람직하지 않다고 할 것입니다(법제처 2018. 6. 7. 의견제시 18-0102 참조).

그렇다면, 제천시장이 제천문화재단의 사업계획서 및 예산서에 대한 승인사항을 시의회에 보고하여야 한다는 내용의 제천시조례안 제13조제2항은, 그 전제가 되는 제천시조례안 제13조제1항이 상위법령에 위배될 소지가 있으므로 그 역시 상위법령에 위배될 소지가 있다고 할 것인바, 자치법규 입안에 신중을 기하시기 바랍니다.

라. 질의 다에 대하여

지방출자출연법 제19조는 출자·출연기관은 매 회계연도가 끝난 후 3개월 이내에 결산서를 작성하여 지체 없이 지방자치단체의 장에게 제출하여야 한다고 규정하고 있는바, 이 사안은 제천문화재단이 사업실적과 감사결과를 첨부한 결산 보고서를 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에 시의회 의장에게 제출하여야 한다고 조례로 규정할 수 있는지에 대한 질의로 보입니다.

살피건대, 「지방자치법」 제22조 단서에서는 주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한 사항이나 벌칙을

정할 때에는 법률의 위임이 있어야 한다고 규정하고 있으므로, 조례를 제정함에 있어 그 내용이 주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한 사항이나 벌칙인 경우에는 법률의 위임이 있어야 하고, 법률의 위임 없이 주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한 사항을 정한 조례는 그 효력이 없습니다(대법원 2012. 11. 22. 선고 2010두19270 판결 참조). 그런데, 제천시조례안 제14조제1항에서는 제천문화재단으로 하여금 매년도의 결산 보고서를 시장뿐만 아니라 시의회 의장에게까지 제출하여야 할 의무를 부과하고 있는데, 지방출자출연법 제19조는 출자·출연기관이 결산서를 제출하여야 하는 대상으로 "지방자치단체의 장"만을 규정하고 있으며 그 외에 결산서의 제출과 관련한 사항을 조례로 정할 수 있도록 위임하고 있지도 않습니다. 따라서 제천시조례안 제14조제1항은 법률의 위임이 없이 제천문화재단에 추가적인 의무를 부과하는 것이므로 「지방자치법」 제22조 단서에 위배될 소지가 있습니다.

나아가, 질의 나에서 살펴본 바와 같이 지방출자출연법 제3조제2항에서는 지방자치단체는 출자·출연 기관의 자율적인 운영을 보장하며, 공정하고 자유로운 경제질서를 해치지 아니하도록 노력하여야 한다고 규정하고 있는 점, 법령의 명시적인 근거나 위임 규정 없이 조례로 제천문화재단에 추가적인 의무를 부과하도록 한다면 독립된 법인격을 가진 법인인 제천문화재단 운영의 독립성이나 자주성을 훼손시킬 우려가 있으므로 「민법」에 따른 법인제도의 취지를 고려하여 신중하게 접근하여야 할 필요성이 있는 점(법제처 2013. 8. 8. 의견제시 13-0225 등 참조) 역시 고려되어야 할 것입니다.

그렇다면, 제천문화재단이 사업실적과 감사결과를 첨부한 결산 보고서를 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에 시의회 의장에게 제출하여야 한다고 조례로 규정하는 것은 상위법령에 위배될 소지가 있다고 할 것이므로, 자치법규 입안에 신중을 기하시기 바랍니다.

2. 지방자치단체 출자·출연기관의 지도·감독에 관한 사항을 조례에 규정할 수 있는지

「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」 제3조제2항에서 지방자치단체로 하여금 출자·출연 기관의 자율적인 운영을 보장하도록 하고, 공정하고 자유로운 경제질서를 해치지 않도록 책무를 부여하고 있는 점에 비추어 볼 때, 법률의 명시적인 근거나 위임 규정 없이 조례로 출자·출연 기관에 새로운 의무를 부과하도록 한다면, 「상법」에 따른 주식회사나 「민법」 또는 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」에 따른 재단법인으로 설립되어 독립된 법인격을 가진 출자·출연 기관의 독립성과 자율성을 훼손시킬 수 있는 것으로 보인다[23].

「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에 따르면 출자·출연 기관은 매 회계연도의 사업계획 등을 작성하고, 그에 따른 예산을 회계연도 개시 전까지 편성해야 하고, 예산이 성립되거나 변경되었을 때에는 지체 없이 지방자치단체의 장에게 보고해야 한다(제18조제1항 및 제2항). 그리고 매 회계연도가 끝난 후 2개월 이내에 결산을 완료하고 지체 없이 결산서를 작성하여 지방자치단체의 장에게 제출해야 한다(제19조).

한편, 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」이 지방자치단체의 장에게는 출자·출연 기관에 대한 인사감사(제15조의3), 출자·출연 기관의 예산 성립·변경에 대한 시정명령(제18조제4항), 출자기관의 사채발행 등에 대한 승인(제22조), 출자·출연 기관에 대한 일반적인 지도·감독(제25조) 및 검사(제26조) 등의 권한을 부여하는 규정을 두고 있는 반면, 지방의회에 대해서는 출자·출연 기관의 운영에 직접적으로 관여할 수 있도록 하는 규정을 두고 있지 않은 점 또한 출자·출연기관에 대한 지도·감독사항을 조례에 규정할 때 함께 고려할 필요가 있을 것이다.

23) 법제처 2018. 10. 1. 의견제시 18-0218 참조

「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」

제3조(경영의 기본원칙) ① (생 략)

② 지방자치단체는 출자·출연 기관의 자율적인 운영을 보장하며, 공정하고 자유로운 경제질서를 해치지 아니하도록 노력하여야 한다.

제15조의3(인사감사 등) ① 지방자치단체의 장은 비위행위 중 채용비위의 근절 등을 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 출자·출연 기관의 인사운영의 적정 여부를 감사(이하 이 조에서 "인사감사"라 한다)할 수 있으며, 필요한 경우 관계 서류를 제출하도록 요구할 수 있다.

② 지방자치단체의 장은 인사감사 결과 위법 또는 부당한 사실이 발견되면 지체 없이 해당 출자·출연 기관의 장에게 그 시정(是正)과 관련자에 대한 인사상의 조치 등을 요구하여야 한다.

③ 출자·출연 기관의 장은 제2항에 따른 요구가 있을 경우 정당한 사유가 없으면 이를 즉시 이행하고 그 이행결과를 해당 지방자치단체의 장에게 통보하여야 한다.

제18조(예산의 편성 등) ① 출자·출연 기관은 매 회계연도의 사업계획 등을 작성하고, 그에 따른 예산을 회계연도 개시 전까지 편성하여야 한다.

② 출자·출연 기관은 예산이 성립되거나 변경되었을 때에는 지체 없이 지방자치단체의 장에게 보고하여야 한다.

③ 지방자치단체의 장은 제2항에 따라 보고된 예산이 법령에 위반되거나 해당 지방자치단체의 회계관계 규정 등을 고려하여 필요하다고 인정되는 경우에는 그 시정을 명하여야 한다.

④ 제3항에 따라 지방자치단체의 장이 시정을 명한 경우 출자·출연 기관은 특별한 사정이 없으면 이에 따라야 한다.

⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 예산의 편성 등과 그 보고와 관련하여 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제19조(결산) 출자·출연 기관은 매 회계연도가 끝난 후 2개월 이내에 결산을 완료하고 지체 없이 결산서를 작성하여 지방자치단체의 장에게 제출하여야 한다. 이 경우 자산총액, 부채규모, 종업원 수, 수익 등이 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 출자·출연 기관은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 감사인에 해당하는 자 중에서 선임한 회계감사인의 회계감사 보고서를 첨부하여 결산서와 함께 제출하여야 한다.

제22조(출자기관의 사채발행 등) ① 출자기관은 사채(社債)를 발행하거나 금융회사 등으로부터 자금(외국으로부터의 차관을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 차입할 경우 지방자치단체의 장의 승인을 받아야 한다. 이 경우 사채 발행의 한도는 대통령령으로 정한다.

② (생 략)

제25조(지도·감독 등) ① 지방자치단체의 장은 다음 각 호의 사업에 대하여 해당 출자·출연 기관을 지도하거나 감독할 수 있다.

1. 법령이나 조례에 따라 지방자치단체가 출자·출연 기관에 위탁한 사업
2. 지방자치단체의 소관 업무와 직접 관련되는 사항으로서 대통령령으로 정하는 사업

② 출자·출연 기관의 장은 다음 각 호의 사항에 대해서는 지방자치단체의 장과 협의하여야 한다.

1. 기구 및 정원의 변동에 관한 사항
2. 임직원의 채용과 면직, 보수체계 등 대통령령으로 정하는 중요한 사항에 관한 규정의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항

제26조(검사·보고 등) ① 지방자치단체의 장은 출자·출연 기관의 업무, 회계 및 재산에 관한 사항을 검사할 수 있으며, 해당 기관에 필요한 보고를 하게 할 수 있다.

② 지방자치단체의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 출자·출연 기관에 대해서는 적어도 3년마다 업무, 회계 및 재산에 관한 사항을 검사하여야 한다.

1. 지방자치단체의 지분이 100분의 50 이상인 기관
2. 지방자치단체의 지분이 100분의 50 미만인 기관 중 제2조제3항 각 호의 요건에 해당하는 기관

사례 45

출자·출연기관의 사업계획과 예산안에 대한 군수의 사전 승인에 관한 사항을 규정할 수 없다고 본 사례

2019. 10. 29. 의견제시 19-031

질의요지

곡성군에서 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에 따라 설립하려고 하는 곡성군 미래교육재단과 관련하여, 곡성군 미래교육재단이 사업계획과 예산안에 대해 회계연도 개시 1개월 전까지 군수의 승인을 받아야 한다는 내용을 조례에 규정할 수 있는지?

의 견

이 사안의 경우 귀 군에서는 질의요지와 같은 내용을 조례에 규정할 수 없을 것으로 보입니다.

이 유

「곡성군 미래교육재단 설립 및 운영지원 조례안」(이하 "곡성군조례안"이라 함) 제8조제3항에서는 곡성군 미래교육재단(이하 "미래교육재단"이라 함)은 사업계획과 예산안에 대하여 회계연도 개시 1개월 전까지 군수의 승인을 얻어야 한다고 규정하고 있습니다. 위와 같은 내용을 조례로 규정하는 것이 가능한지에 대하여 살피건대, 먼저 예산의 "성립"이란 편성된 예산안이 적법한 절차에 따라 심의·의결을 거친 후의 상태를 의미한다고 할 것입니다(「지방자치법」 제131조, 「지방재정법」 제46조). 그런데 이와 관련하여 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」(이하 "지방출자출연법"이라 함) 제18조제1항에서는 예산이 성립되기 전의 사업계획 작성 및 예산안 편성 단계에서는 출자·출연기관이 지방자치단체장에게 보고하거나 승인받을 것을 규정하지 않고 있습니다. 또한 같은 조 제2항부터 제4항까지에서는 예산이 성립되거나 변경되었을 때 출자·출연기관으로 하여금 지방자치단체장에게 보고하도록 하고, 지방자치단체장은 보고된 예산이 법령에 위반되거나 해당 지방자치단체의 회계 관계 규정 등을 고려하여

필요하다고 인정되는 경우에는 그 시정을 명하여야 하며, 지방자치단체장이 시정을 명한 경우 출자·출연기관은 특별한 사정이 없으면 이에 따라야 한다고 규정함으로써 지방자치단체장에게 시정명령 권한을 부여하고 있으나, 위 시정명령권 역시 출자· 출연기관의 예산이 성립한 이후에 적용되는 사후적 권한에 해당합니다.

또한, 같은 법 제18조제5항에서는 같은 조 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 예산의 편성 등과 그 보고와 관련하여 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 같은 법 시행령 제14조제2항에서는 행정안전부장관은 같은 법 제27조제2호에 따라 다음 연도의 예산의 편성·집행과 자금 운영에 관한 사항을 정하는 운영지침(이하 "예산편성지침"이라 함)을 매년 6월 30일까지 지방자치단체장 또는 출자·출연기관의 장에게 통보하여야 한다고 규정하고 있으며, 같은 조 제3항에서는 지방자치단체장은 같은 조 제2항에 따라 통보받은 예산편성지침에 관한 세부 사항을 작성하여 출자·출연기관의 장에게 통보할 수 있다고 규정하고 있을 뿐, 그 외 예산으로 성립하기 전의 편성된 예산안이나 사업계획에 대하여 지방자치단체장이 "승인"의 방법으로 관여할 수 있는 규정은 두지 않고 있습니다. 나아가 지방출자출연법 시행령 제14조제2항에 따른 「행정안전부 2020년도 지방출자·출연기관 예산편성지침」에서도 지방출자출연기관이 설립 지방자치단체에 당해연도 예산편성(안)에 의견을 확인하도록 규정하거나(같은 지침 Ⅰ), 이사회의 심의·의결 또는 관계법령에 따라 예산이 확정되거나 변경된 때에는 그 내용을 지방자치단체장에게 보고하도록 규정하고 있을 뿐(같은 지침 Ⅳ), 역시 성립되기 전의 예산안이나 사업계획에 대하여 지방자치단체장의 승인을 받도록 하는 규정은 두지 않고 있습니다.

이상과 같이, 지방출자출연법 및 그 하위법령의 각 규정에서는 출자·출연기관의 사업계획의 작성 및 예산안의 편성에 관한 지방자치단체장의 승인 권한을 부여하지 않고 있습니다. 아울러 지방출자출연법 제3조제2항에서는 지방자치단체는 출자·출연기관의 자율적인 운영을 보장하며, 공정하고 자유로운 경제질서를 해치지 아니하도록 노력하여야 한다고 규정하고 있습니다. 그리고 지방출자출연법 제4조제1항에서는 지방자치단체는 특정 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 재산의 전액을 출연하거나 지방자치단체 외의 자와 공동으로 출연하여 「민법」 또는 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」에 따른 재단법인을 설립할 수 있도록 규정하고 있고, 이에 따라 곡성군조례안 제3조에서는 미래교육재단을 「민법」에 따른 재단법인으로 한다고 규정하고 있으므로, 미래교육재단에 관한 조례의 입안에 있어서는 일정한 목적에 바쳐진 재산에 관하여도 독립된 법인격을 부여하여 재단법인을 설립할 수 있도록 한 「민법」의 법인제도의 취지를 고려하여 신중하게 접근하여야 할 것입니다.

이상의 사정을 고려하면, 법령의 명시적인 근거 규정이나 위임 규정이 없이 곡성군조례에서 미래교육재단의 사업계획과 예산안을 회계연도 개시 1개월 전까지 군수의 승인을 받아야 한다고 규정하는 것은 독립된 법인격을 가지는 미래교육재단의 운영의 독립성이나 자율성을 훼손시킬 우려가 있고, 나아가 상위법령인 지방출자출연법과 그 하위법령 및 「민법」 등에 위반될 소지가 있다고 할 것이므로, 자치법규 입안에 신중을 기하시기 바랍니다(법제처 2018. 6. 7. 의견제시 18-0102, 2018. 10. 1. 의견제시 18-0217 참조).

사례 46

출자·출연기관의 결산서를 소관 상임위 등에 제출하도록 규정할 수 없다고 본 사례

(질의 가)

2024. 6. 25. 의견제시 24-0197

질의요지

가. 지방자치단체 출자·출연 기관으로 하여금 결산서를 작성하여 지방의회 소관 상임위원회 및 예산결산특별위원회에 제출하도록 하는 내용을 조례에 규정할 수 있는지?

나. 지방자치단체 출자·출연 기관으로 하여금 매 회계연도가 끝난 후 2개월 이내에 출연금에 대한 정산보고서를 작성하여 지방자치단체의 장에게 제출하고, 정산 결과 발생한 집행잔액 및 이자를 지방자치단체에 반납하도록 하는 내용을 조례에 규정할 수 있는지?

다. 지방의회의원이 발의하여 지방자치단체의 장으로 하여금 지방자치단체 출자·출연 기관의 업무, 회계 및 재산에 관한 사항을 검사하도록 하는 내용을 조례에 규정할 수 있는지?

의 견

가. 질의 가에 대하여

아래 이유를 참고하시기 바랍니다.

나. 질의 나에 대하여

아래 이유를 참고하시기 바랍니다.

다. 질의 다에 대하여

아래 이유를 참고하시기 바랍니다.

이 유

가. 질의의 공통사항

「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」(이하 "지방출자출연법"이라 한다)은 지방자치단체가 출자(出資)하거나 출연(出捐)하여 설립한 기관의 운영에 필요한 사항을 정하여 그 기관의 경영을 합리화하고 운영의 투명성을 높임으로써 지역주민에 대한 서비스 증진에 이바지함을 목적으로 하는 법률로서(제1조), 같은 법 제2조제1항에서는 이 법은 지방자치단체가 설립하고 제5조에 따라 지정·고시된 출자기관 또는 출연기관(이하 "출자·출연 기관"이라 한다)에 대하여 적용한다고 규정하고 있고, 같은 법 제3조제1항에서는 출자·출연 기관은 해당 기관의 경영의 효율성을 높이고 지역주민에 대한 공공복리가 증진될 수 있도록 노력하여야 한다고 규정하고 있으며, 같은 조 제2항에서는 지방자치단체는 출자·출연 기관의 자율적인 운영을 보장하며, 공정하고 자유로운 경제질서를 해치지 아니하도록 노력하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제4조제1항에서는 지방자치단체는 문화, 예술, 장학, 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지할 수 있는 사업(제1호) 등의 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 자본금 또는 재산의 전액을 출자 또는 출연하거나 지방자치단체 외의 자와 공동으로 출자하거나 출연하여 「상법」에 따른 주식회사나 「민법」 또는 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」에 따른 재단법인을 설립할 수 있다고 규정하고 있으며, 같은 조 제3항에서는 출자·출연 기관과 관련한 설립 목적(제1호), 주요 업무와 사업(제2호), 출자 또는 출연의 근거와 방법(제3호), 그 밖에 기관의 운영 등에 관한 기본적인 사항(제4호)은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다고 규정하고 있습니다.

나. 질의 가에 대하여

「지방자치법」 제28조제1항 단서에서는 주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한 사항이나 벌칙을 정할 때에는 법률의 위임이 있어야 한다고 규정하고 있으므로, 조례를 제정할 때 그 내용이 주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한 사항이나 벌칙인 경우에는 법률의 위임이 있어야 하고, 법률의 위임 없이 주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한 사항을 정한 조례는 그 효력이 없다고 할 것인데(대법원 2012. 11. 22. 선고 2010두19270 판결 참조), 여기서 주민이란 지방자치단체 관할구역에 주된 사무소나 본점이 있는 법인을 포함하는 개념이라고 할 것입니다.

살피건대, 지방출자출연법 제19조에서는 출자·출연 기관은 매 회계연도가 끝난 후 2개월 이내에 결산을 완료하고 지체 없이 결산서를 작성하여 지방자치단체의 장에게 제출하여야 한다고 규정하고

있어, 출자·출연 기관이 작성한 결산서를 제출하는 대상은 지방자치단체의 장뿐이고, 그 외의 기관·단체에 제출하도록 조례로 위임하고 있지 않은바, 출자·출연 기관으로 하여금 결산서를 작성하여 지방의회 소관 상임위원회 및 예산결산특별위원회에 제출하도록 하는 내용을 조례에 규정하는 것은 법률의 명시적 위임 없이 출자·출연 기관에 새로운 의무를 부과하는 것이어서 「지방자치법」에 위배될 소지가 있어 보입니다.

나아가, 지방출자출연법 제3조제2항에서 지방자치단체로 하여금 출자·출연 기관의 자율적인 운영을 보장하도록 하고, 공정하고 자유로운 경제질서를 해치지 않도록 책무를 부여하고 있는 점에 비추어 볼 때, 법률의 명시적인 근거나 위임 규정 없이 조례로 출자·출연 기관에 새로운 의무를 부과하도록 한다면, 「상법」에 따른 주식회사나 「민법」 또는 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」에 따른 재단법인으로 설립되어 독립된 법인격을 가진 출자·출연 기관의 독립성과 자율성을 훼손시킬 수 있는 것으로 보이고(법제처 2018. 10. 1. 의견제시 18-0218 참조), 지방출자출연법이 지방자치단체의 장에게는 출자·출연 기관에 대한 인사감사(제15조의3), 출자·출연 기관의 예산 성립·변경에 대한 시정명령(제18조제4항), 출자기관의 사채발행 등에 대한 승인(제22조), 출자·출연 기관에 대한 일반적인 지도·감독(제25조) 및 검사(제26조) 등의 권한을 부여하는 규정을 두고 있는 반면, 지방의회에 대해서는 출자·출연 기관의 운영에 직접적으로 관여할 수 있도록 하는 규정을 두고 있지 않은 점 등을 고려할 때, 출자·출연 기관으로 하여금 결산서를 작성하여 지방의회 소관 상임위원회 및 예산결산특별위원회에 제출하도록 하는 것은 지방출자출연법의 입법취지 및 규정체계에도 부합하지 않는 것으로 보입니다.

따라서, 질의요지와 같은 내용을 조례에 규정하는 것은 상위법령에 위배될 소지가 있는 것으로 보이므로, 조례 입안에 신중하시기 바랍니다.

다. 질의 나에 대하여

질의 가에서 살펴본 것과 같이, 지방출자출연법 제19조에서는 출자·출연 기관은 매 회계연도가 끝난 후 2개월 이내에 결산서를 작성하여 지체 없이 지방자치단체의 장에게 제출하여야 한다고 규정하고 있을 뿐 출연금의 정산에 관하여는 별도로 규정하고 있지 않은바, 출자·출연 기관으로 하여금 매 회계연도가 끝난 후 2개월 이내에 출연금에 대한 정산보고서를 작성하여 지방자치단체의 장에게 제출하고, 정산 결과 발생한 집행잔액 및 이자를 지방자치단체에 반납하도록 하는 것은 법률의 명시적 위임 없이 출자·출연 기관에 새로운 의무를 부과하는 것이어서 「지방자치법」 제28조제1항 단서에 위배될 소지가

있어 보입니다.

또한, 지방출자출연법 제27조에서는 행정안전부장관은 출자·출연 기관에 공통적으로 적용할 예산의 편성·집행과 자금 운영에 관한 사항(제2호), 회계와 결산에 관한 사항(제3호) 등에 관한 운영지침을 정하고, 이를 각 지방자치단체의 장 또는 출자·출연 기관의 장에게 통보할 수 있다고 규정하고 있는데, 그 위임에 따라 마련된 「2024년도 지방출자·출연기관 예산편성 운영지침」[해당 지침은 법령보충적 행정규칙으로서 대외적 구속력을 가지는 것으로 봄(법제처 2022. 1. 19. 회신 21-0615 해석례 참조)]에서는 매 회계연도 세입세출결과 발생한 잉여금은 다음연도 세입예산에 편성하여 처리함이 기본원칙이라고 규정하고 있고(18쪽), 그중 이자수입의 경우 출연기관에 귀속시켜 처리하는 것으로 규정하고 있는바(19쪽), 출자·출연 기관으로 하여금 정산 결과 발생한 집행잔액 및 이자를 지방자치단체에 반납하도록 하는 것은 이와 같은 지방출자출연법령에도 위배될 소지가 있다고 할 것입니다.

따라서, 질의요지와 같은 내용을 조례에 규정하는 것은 상위법령에 위배될 소지가 있는 것으로 보이므로, 조례 입안에 신중하시기 바랍니다.

라. 질의 다에 대하여

지방출자출연법 제26조제1항에서는 지방자치단체의 장은 출자·출연 기관의 업무, 회계 및 재산에 관한 사항을 검사할 수 있으며, 해당 기관에 필요한 보고를 하게 할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 지방자치단체의 장은 지방자치단체의 지분이 100분의 50 이상인 기관(제1호)이나 지방자치단체의 지분이 100분의 50 미만인 기관 중 같은 법 제2조제3항 각 호의 요건에 해당하는 기관(제2호)에 해당하는 출자·출연 기관에 대해서는 적어도 3년마다 업무, 회계 및 재산에 관한 사항을 검사하여야 한다고 규정하고 있습니다.

그런데, 익산시에서는 지방의회의원이 발의하여 지방자치단체의 장으로 하여금 지방자치단체 출자·출연 기관의 업무, 회계 및 재산에 관한 사항을 검사하도록 하는 내용을 조례에 규정하려는바, 이와 같이 규정하는 것이 지방자치단체의 장과 지방의회의 권한 배분의 원리에 위배되지 않는지 문제될 수 있습니다.

「지방자치법」은 의결기관으로서의 지방의회와 집행기관으로서의 지방자치단체의 장에게 독자적 권한을 부여하는 한편, 지방의회는 행정사무감사와 조사권 등에 의하여 지방자치단체의 장의 사무집행을

감시·통제할 수 있게 하고 지방자치단체의 장은 지방의회의 의결에 대한 재의 요구권 등으로 의회의 의결권 행사에 제동을 가할 수 있게 함으로써 상호 견제와 균형을 유지하도록 하고 있으므로, 지방의회는 자치사무에 관하여 법률에 특별한 규정이 없는 한 지방자치단체의 장의 고유권한에 관하여는 조례로 이를 침해할 수 없고, 고유권한이 아닌 사항에 대해서도 그 사무집행에 관한 집행권을 본질적으로 침해하는 것은 허용되지 않습니다(대법원 2001. 11. 27. 선고 2001추57 판결 참조).

살피건대, 지방출자출연법 제26조제2항 각 호에 해당하는 경우를 제외하면 출자·출연 기관에 대한 업무·회계 및 재산에 관한 검사 권한은 지방자치단체의 장의 권한이라 할 것이고, 그 권한에는 출자·출연 기관에 대한 검사의 실시 여부, 검사 주기, 방법 등에 관한 사항의 결정까지 포함된다고 보아야 할 것이며, 상위법령에서는 출자·출연 기관의 업무, 회계 및 재산에 관한 사항을 검사할 수 있는 근거를 두고 있을 뿐 검사의 시행 여부를 조례로 정할 수 있도록 위임하고 있지 않으므로, 지방자치단체의 장에게 출자·출연 기관의 업무, 회계 및 재산에 관한 사항을 일률적으로 검사하도록 의무를 부과하는 것은 출자·출연 기관에 대한 업무·회계 및 재산 검사에 관한 지방자치단체의 장의 재량권을 침해할 소지가 있는 것으로 보입니다(법제처 2024. 3. 8. 의견제시 24-0047, 2024. 3. 29. 의견제시 24-0098 참조).

따라서, 질의요지와 같은 내용을 조례에 규정하는 것은 상위법령에 위배될 소지가 있는 것으로 보이므로, 조례 입안에 신중하시기 바랍니다.











제 7 편

위탁·대행

1. 지방자치단체의 사무 위탁 대상·범위에 해당하는지

권한의 위임이나 위탁, 재위임 등은 권한의 법적 소재를 대외적으로 변경하는 것이므로 법률에서 위임이나 위탁을 허용하고 있는 경우에 한하여 인정되는데[24], 「지방자치법」, 국가사무의 기관위임과 관련하여 「정부조직법」 및 「행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정」에서 권한의 위임 및 위탁에 관한 일반적 근거규정을 두고 있다.

한편, 「영유아보육법」, 「하수도법」, 「폐기물관리법」 등 개별 법률에서 지방자치단체의 권한의 위임이나 위탁에 관한 규정을 두고 있는 경우도 있다. 이와 같은 규정은 「지방자치법」에 따른 권한의 위임이나 위탁에 관한 규정의 특별규정의 의미가 있으므로 민간위탁에 관한 조례 등을 입안할 때 위 상위법령에 위반되지 않도록 해야 한다[25].

「지방자치법」

제117조(사무의 위임 등) ① 지방자치단체의 장은 조례나 규칙으로 정하는 바에 따라 그 권한에 속하는 사무의 일부를 보조기관, 소속 행정기관 또는 하부행정기관에 위임할 수 있다.
② 지방자치단체의 장은 조례나 규칙으로 정하는 바에 따라 그 권한에 속하는 사무의 일부를 관할 지방자치단체나 공공단체 또는 그 기관(사업소·출장소를 포함한다)에 위임하거나 위탁할 수 있다.
③ 지방자치단체의 장은 조례나 규칙으로 정하는 바에 따라 그 권한에 속하는 사무 중 조사·검사·검정·관리업무 등 주민의 권리·의무와 직접 관련되지 아니하는 사무를 법인·단체 또는 그 기관이나 개인에게 위탁할 수 있다.
④ 지방자치단체의 장이 위임받거나 위탁받은 사무의 일부를 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 다시 위임하거나 위탁하려면 미리 그 사무를 위임하거나 위탁한 기관의 장의 승인을 받아야 한다.

24) 대법원 1992. 4. 24. 선고 91누5792 판결 참조
25) 『자치법규 입안 길라잡이(2022)』 257·258쪽 참조

사례 47 공공단체에 대한 자치사무 위탁으로서 조례에 규정할 수 있다고 본 사례

2023. 9. 15. 의견제시 23-0323

질의요지

제천시장이 수행하는 스포츠마케팅에 관한 사무의 일부를 「국민체육진흥법」 제33조의2제1항에 따라 설립된 제천시 체육회에 위탁할 수 있도록 하는 내용을 조례에 규정할 수 있는지?

의 견

이 사안의 경우, 질의요지와 같은 내용을 조례에 규정할 수 있을 것으로 보입니다.

이 유

「제천시 스포츠마케팅 지원 및 활성화 조례안」(이하 "제천시조례안"이라 한다) 제2조제3호에서는 "스포츠마케팅"이란 스포츠대회나 전지훈련의 유치·지원을 통해 시 체육시설을 홍보하는 등 시의 이미지나 가치를 드높이는 행위 등이 포함된 모든 활동을 말한다고 규정하고 있고, 같은 조례안 제3조에서는 제천시장은 스포츠대회 및 전지훈련 유치 등 스포츠마케팅에 필요한 계획을 수립· 시행하고 이에 필요한 행정·재정적 지원을 할 수 있다고 규정하고 있으며, 같은 조례안 제4조제1항에서는 제천시장은 스포츠마케팅 계획을 매년 수립·시행하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 스포츠마케팅 계획에 포함되어야 하는 사항으로 스포츠대회 유치 및 지역경제 활성화(제1호), 전지훈련 유치 및 지원(제2호), 스포츠마케팅 시책의 지역사회 붐 조성 및 홍보(제3호), 스포츠마케팅 관련 조사·연구 및 컨설팅사업 추진(제4호), 그 밖에 스포츠마케팅에 관한 사항(제5호)을 규정하고 있습니다.

한편, 「국민체육진흥법」 제33조의2제1항에서는 지역사회의 체육 진흥에 관한 다음 각 호의 사업과 활동을 하게 하기 위하여 관할 지방자치단체의 장의 인가를 받아 지방체육회를 설립한다고 규정하면서, 각 호에서는 지방체육회에 가맹된 체육단체와 생활체육종목단체 등의 사업과 활동에 대한 지도와 지원

(제1호), 지역 체육대회의 개최와 국내외 교류(제2호), 체육회가 개최하는 체육대회의 참가(제3호), 선수 양성과 경기력 향상 등 지역 전문체육 진흥을 위한 사업(제4호), 그 밖에 지역 체육 진흥을 위하여 필요한 사업(제12호) 등을 규정하고 있습니다.

그리고, 「스포츠산업 진흥법」 제2조제2호에서 "스포츠산업"이란 스포츠와 관련된 재화와 서비스를 통하여 부가가치를 창출하는 산업을 말한다고 규정하고 있고, 같은 법 제4조제1항에서는 국가 및 지방자치단체는 스포츠산업의 진흥을 위하여 필요한 시책을 수립·시행하여야 한다고 규정하고 있습니다.

이 사안은 제천시장이 수행하는 스포츠마케팅에 관한 사무의 일부를 「국민체육진흥법」 제33조의2 제1항에 따라 설립된 제천시 체육회에 위탁할 수 있도록 하는 내용을 조례에 규정할 수 있는지에 관한 질의로 보이는데, 지방자치단체의 장이 스포츠마케팅에 관한 사무를 위탁하거나 할 수 있도록 하는 「스포츠산업 진흥법」 등 개별 법령상 근거는 없는 것으로 보입니다.

한편, 「지방자치법」 제117조제2항에서는 지방자치단체의 장은 조례나 규칙으로 정하는 바에 따라 그 권한에 속하는 사무의 일부를 관할 지방자치단체나 공공단체 또는 그 기관(사업소·출장소를 포함한다)에 위임하거나 위탁할 수 있다고 규정하고 있으므로, 지방자치단체의 장은 공공단체 또는 그 기관에 위탁하려는 사무가 그 권한에 속하는 사무인 경우 개별 법령에 근거 규정이 없더라도 조례로 해당 사무의 위탁에 관한 사항을 규정할 수 있다고 할 것입니다.

이와 관련하여 「스포츠산업 진흥법」 제4조제1항에서 지방자치단체는 스포츠산업의 진흥을 위하여 필요한 시책을 수립·시행하여야 한다고 규정하고 있는 점, 「지방자치법」 제13조제2항제5호에서는 교육·체육·문화·예술의 진흥에 관한 사무를 지방자치단체의 사무로 예시하고 있는 점, 제천시조례안은 스포츠마케팅을 통하여 제천시의 스포츠산업을 활성화함으로써 지역경제 발전에 기여함을 목적으로 하고 있는 점(제1조) 등을 고려하면 스포츠산업의 진흥을 위한 스포츠마케팅에 관한 사무는 제천시의 자치사무에 해당하는 것으로 보입니다.

또한, 「지방자치법」 제117조제2항의 "공공단체"의 범위에는 법령이나 조례에 따라 설치된 단체, 지방자치단체가 출연·보조를 통하여 재정적으로 그 시설의 설치·운영에 대하여 관리·감독을 할 수 있는 단체 또는 그 밖에 지방자치단체가 그 조직이나 활동 등에 대하여 법률상 또는 사실상의 영향력을 행사할 수 있는 단체 등이 포함된다는 점에 비추어 볼 때(법제처 2018. 5. 4. 의견제시 18-0081, 2010. 4. 16. 회신 10-0037 해석례 참조), 제천시 체육회는 「국민체육진흥법」 제33조의2제1항에 따라 제천시장의 인가를 받아 설립된 지방체육회이고, 같은 법 제43조제2항에서는 지방체육회는 설립을

인가한 지방자치단체의 장이 감독한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제44조제1항에 따라 지방자치단체의 장은 지방체육회에 대하여 그 업무에 관한 보고를 명하거나 소속 공무원에게 그 사업소·사업장 등에 출입하여 장부·서류, 그 밖의 물건을 검사하게 할 수 있는바, 제천시 체육회는 「국민체육진흥법」에 따라 설립되고, 제천시장의 감독을 받는 기관으로서 그 조직이나 활동 등에 대하여 제천시가 영향력을 행사할 수 있으므로 「지방자치법」 제117조제2항의 "공공단체"에 포함되는 것으로 보입니다(법제처 2023. 4. 19. 의견제시 23-0129 참조).

따라서, 제천시장이 수행하는 스포츠마케팅에 관한 사무의 일부를 「국민체육진흥법」 제33조의2제1항에 따라 설립된 제천시 체육회에 위탁할 수 있도록 하는 내용을 조례에 규정할 수 있을 것으로 보입니다.

사례 48 법령상 수탁기관이 아닌 지방공단에 대한 사무 위탁을 규정할 수 없다고 본 사례

2024. 7. 18. 의견제시 24-0165

질의요지

「청소년활동 진흥법」에 따라 지방자치단체가 설치한 청소년수련시설의 운영을 지방공단에 위탁할 수 있도록 하는 내용을 조례에 규정할 수 있는지?

의 견

질의요지와 같은 내용을 조례에 규정할 수 없을 것으로 보입니다.

이 유

「지방자치법」 제28조제1항에서는 지방자치단체는 법령의 범위에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있다고 규정하고 있는데, 여기서 "법령의 범위"란 법령에 위반되지 않는 범위를 의미하고, 조례가 법령에 위반되는지 여부는 법령과 조례의 각 규정 취지, 규정의 목적과 내용 및 효과 등을 비교하여 양자 사이에 모순·저촉이 있는지 여부에 따라서 개별적·구체적으로 판단해야 할 것입니다(대법원 2022. 7. 28. 선고 2021추5050 판결 참조).

먼저, 「청소년활동 진흥법」(이하 "청소년활동법"이라 한다) 제10조제1호 각 목에서는 청소년수련시설의 종류를 청소년수련관, 청소년수련원, 청소년문화의 집 등으로 정하고 있고, 제11조제1항에서는 지방자치단체는 「청소년 기본법」 제18조제1항에 따라 청소년활동법 제10조제1호가목에 따른 청소년수련관(제2호) 등의 청소년수련시설을 설치·운영하여야 한다고 규정하고 있으며, 제16조제1항에서는 지방자치단체는 청소년수련시설의 효율적 운영을 위하여 「청소년 기본법」 제3조제8호에 따른 청소년단체(이하 "청소년단체"라 한다)에 그 운영을 위탁할 수 있다고 규정하고 있습니다.

또한, 「지방자치법」 제117조제2항 및 제3항에서는 지방자치단체의 장은 조례나 규칙으로 정하는 바에 따라 그 권한에 속하는 사무의 일부를 관할 지방자치단체나 공공단체 또는 그 기관(사업소· 출장소를 포함한다)에 위임하거나 위탁할 수 있고, 그 권한에 속하는 사무 중 조사·검사·검정· 관리업무 등 주민의 권리·의무와 직접 관련되지 아니하는 사무를 법인·단체 또는 그 기관이나 개인에게 위탁할 수 있다고 규정하고 있는 한편, 「지방공기업법」 제49조제1항에서는 지방자치단체가 같은 법 제2조에 따른 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 필요한 경우에는 지방공사를 설립할 수 있다고 규정하고 있고, 제71조제1항에서는 지방공사가 국가 또는 지방자치단체의 사업을 대행할 수 있으며, 이 경우에 필요한 비용은 국가 또는 지방자치단체가 부담한다고 규정하고 있고, 제76조제1항에서는 지방자치단체가 같은 법 제2조의 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 필요한 경우에는 지방공단을 설립할 수 있다고 규정하고 있으며, 제76조제2항에서는 지방공단의 설립·운영에 관하여 같은 법 제71조를 준용한다고 규정하고 있는바, 이 사안에서는 청소년활동법에 따라 지방자치단체가 설치한 청소년수련시설의 운영을 청소년단체가 아닌 지방공단에 위탁할 수 있도록 하는 내용을 조례에 규정할 수 있는지 문제됩니다.

살피건대, 행정권한의 위탁은 행정기관의 장이 그 권한 중 일부를 다른 행정기관의 장에게 맡겨 그 수탁기관의 장의 권한과 책임 아래 행사하도록 하는 것이어서 권한의 법적인 귀속을 변경하는 것이므로 법률에서 위탁을 허용하고 있는 경우에 한정하여 인정될 것인데, 지방자치단체의 업무에 관하여 위임·위탁을 규정하고 있는 「지방자치법」 제117조의 규정은 다른 법률에서 해당 업무에 대하여 위임·위탁을 규정하고 있지 않은 경우에 적용되는 일반규정이라 할 것인바, 청소년수련시설의 운영 위탁은 개별 법률인 청소년활동법에서 직접적으로 규정하고 있으므로, 청소년활동법이 우선적으로 적용되는 것으로 보아야 할 것입니다(법제처 2013. 12. 27. 회신 13-0587 해석례 참조).

그런데, 청소년활동법 제16조제1항에서는 지방자치단체가 청소년수련시설의 운영을 '청소년단체'에 위탁할 수 있도록 하고 있고, 이는 청소년수련시설 운영의 수탁기관을 청소년육성을 주된 목적으로 설립된 법인 등 청소년단체로 한정하여 전문성과 책임성을 확보하려는 것으로 보아야 할 것이므로(법제처 2017. 3. 6. 회신 17-0034 해석례 참조), 청소년수련시설의 운영을 청소년육성을 주된 목적으로 설립된 법인이 아닌 지방공단에 위탁할 수 있도록 하는 내용을 조례에 규정하는 것은 이러한 청소년활동법 및 관련 법령의 취지에 위배되는 것으로 볼 수 있습니다.

한편, 「지방공기업법」 제71조제1항 및 제76조제2항에 따르면 지방공단은 지방자치단체가 설립한 청소년수련시설의 운영을 '대행'할 수 있으므로 해당 규정을 근거로 청소년수련시설의 운영을 지방공단에 '위탁'할 수 있는지에 대해 의문이 있을 수 있으나, 일반적으로 '행정업무의 대행'은 행정기관이

법령상의 업무를 대행기관으로 하여금 사실상 행하게 하되, 그 명의와 책임은 원(原)권한자인 행정기관에게 귀속되도록 하는 것으로, 이러한 대행은 행정기관의 권한을 공공단체 또는 사인에게 법적으로 이전하여 행정권한을 수탁받은 자가 그의 이름으로 행정권한을 행사할 수 있고 그 행정권 행사의 법적 효과 또한 수탁자에게 귀속되는 '위탁'과는 차이가 있는바(법제처 2023. 4. 28. 의견제시 23-0110 참조), 해당 규정을 근거로 청소년수련시설의 운영을 지방공단에 위탁할 수 있다고 보기는 어렵습니다.

따라서, 「청소년활동 진흥법」에 따라 지방자치단체가 설치한 청소년수련시설의 운영을 지방공단에 위탁할 수 있도록 하는 내용을 조례에 규정할 수 없을 것으로 보입니다.

2. 지방자치단체 사무 대행의 근거 또는 의회 동의에 관한 사항을 조례에 규정할 수 있는지

일반적으로 행정업무의 대행은 행정기관이 법령상의 업무를 대행기관으로 하여금 사실상 행하게 하되, 그 명의와 책임은 원(原)권한자인 행정기관에게 귀속되도록 하는 것을 말하는 것으로, 이러한 대행은 대행을 받는 자가 대외적으로 행정기관인 피대행관청의 이름과 책임으로 업무를 처리하여 일반국민이나 주민이 대행을 하고 있는 대행기관을 행정기관으로 오인하는 등의 문제가 있을 수 있기 때문에 대행은 피대행관청의 권한 또는 업무를 규정한 법률에 규정해야 하고, 행정기관이 지정한 자에게 행정업무를 대행하게 하는 경우라면 지정기준, 지정취소, 지정절차 등 대행과 관련된 핵심적 사항도 법률에 근거를 두어야 할 것이다[26].

26) 법제처 2015. 6. 9. 의견제시 15-0110 및 2020. 2. 3. 의견제시 20-0009 참조

사례 49 법령의 근거 없이 사무 대행에 관한 사항을 규정할 수 없다고 본 사례

2021. 2. 24. 의견제시 20-0326

질의요지

법령의 근거 없이 교통약자 이동편의시설 검사업무를 비영리법인에게 대행하게 할 수 있도록 하는 내용의 조례를 제정할 수 있는지?

의 견

이 사안의 경우 질의요지와 같은 내용은 조례에 규정할 수 없을 것으로 보입니다.

이 유

「지방자치법」에서는 지방자치단체의 장에게 그 자치단체의 사무와 법령에 따라 그 지방자치단체의 장에게 위임된 사무를 관리하고 집행하도록 하면서(제103조), 지방자치단체의 사무를 분장하기 위하여 필요한 행정기구와 지방공무원을 두도록 하고 있고(제112조), 업무의 효율적 수행을 위해 필요하면 직속기관이나 사업소 등을 둘 수 있도록 규정(제113조 및 제114조)하고 있는 바, 이와 같이 「지방자치법」에서 자치단체 사무의 관리 및 집행권한을 지방자치단체의 장에게 부여하고, 이를 위하여 행정기구와 공무원 등을 갖추도록 하는 것은 지방자치단체의 사무를 지방자치단체 스스로 처리하도록 하기 위한 것입니다.

그리고 일반적으로 행정업무의 대행은 행정기관이 법령상의 업무를 대행기관으로 하여금 사실상 행하게 하되, 그 명의와 책임은 원(原)권한자인 행정기관에게 귀속되도록 하는 것을 말하는 것으로 이러한 대행은 대행을 받는 자가 대외적으로 행정기관인 피대행관청의 이름과 책임으로 업무를 처리하기 때문에 일반국민이나 주민이 대행을 하고 있는 대행기관을 행정기관으로 오인하는 등의 문제가 있을 수 있기(법제처 2013. 10. 25. 회신 13-0417 해석례 참조)때문에 대행은 피대행관청의 권한 또는 업무를 규정한

법률에 규정해야 하고, 행정기관이 지정한 자에게 행정업무를 대행하게 하는 경우라면 지정기준, 지정취소, 지정절차 등 대행과 관련된 핵심적 사항도 법률에 근거를 두어야 할 것입니다(법제처 2015. 6. 9. 의견제시 15-0110, 2020. 2. 3. 의견제시 20-0009, 「법령 입안·심사기준」(2019) p.464 참조).

그런데 「교통약자의 이동편의 증진법」(이하 "교통약자법"이라 한다) 제9조부터 제11조까지에서는 교통수단, 여객시설, 도로를 설치·관리하는 교통사업자 등에게 이동편의시설을 설치기준에 맞게 설치하고 이를 유지·관리하여야 한다는 의무를 부과하고 있고, 같은 법 제28조에서는 교통행정기관[교통수단의 운행·운항 또는 여객시설의 설치·운영에 관하여 교통사업자를 지도·감독하는 중앙행정기관의 장, 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다) 또는 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말하며, 이하 같음)을 말함(교통약자법 제2조제6호)]은 필요하다고 인정할 때에는 소속 공무원으로 하여금 이동편의시설[휠체어 탑승설비, 장애인용 승강기, 장애인을 위한 보도(步道), 임산부가 모유수유를 할 수 있는 휴게시설 등 교통약자가 교통수단,

여객시설 또는 도로를 이용할 때 편리하게 이동할 수 있도록 하기 위한 시설과 설비를 말하며(교통약자법 제2조제7호), 이하 같음]이 설치기준에 맞게 설치되거나 유지·관리되는지에 관하여 검사하게 할 수 있도록 하면서(제3항) 이러한 검사를 하는 공무원은 그 권한을 표시하는 증표를 지니고 이를 관계인에게 보여주어야 한다고 규정(제4항)하고 있습니다.

그리고 교통약자법 제29조에서는 이동편의시설을 설치하지 않거나 설치한 이동편의시설이 설치기준에 맞지 않게 유지·관리하는 경우 교통사업자에게 이동편의시설 설치나 개선을 명할 수 있도록 규정하고 있고, 이러한 시정명령 위반의 경우 이행강제금(제29조의2) 및 벌칙(제31조) 부과 대상으로 규정하고 있습니다.

이처럼 교통약자법령에서는 이동편의시설을 설치기준에 맞게 유지·관리하도록 하기 위하여 이동편의시설의 검사에 대해 규정하면서, 이를 위반한 경우 시정명령이나 이행강제금, 벌칙의 부과대상이 되므로 검사 대상의 신뢰를 확보할 수 있도록 하기 위하여 검사를 하는 공무원에게 그 권한을 표시하는 증표를 지니고 이를 관계인에게 보여주도록 한 것으로 보이고, 달리 교통행정기관이 이동편의시설의 검사업무를 대행할 수 있도록 하는 내용은 규정하고 있지 않습니다.

따라서 이동편의시설의 검사업무를 법령의 근거 없이 비영리법인으로 하여금 대행하게 할 수 있도록 하는 내용의 조례를 제정하는 것은 교통약자법령에 위배될 소지가 있어 보입니다.

사례 50

법령에 따라 사무를 대행하게 하는 경우 민간위탁조례에 따른 지방의회의 동의를 받지 않아도 된다고 본 사례

2023. 2. 13. 의견제시 23-0028

질의요지

삼척시장이 「하수도법」 제19조의2제1항 및 「삼척시 공공하수도시설 관리대행 운영 조례」 제3조에 따라 공공하수도의 운영·관리 업무를 대행하게 할 경우 「삼척시 사무의 민간위탁 조례」 제5조제1항에 따라 지방의회의 동의를 받아야 하는지?

의 견

삼척시장이 「하수도법」 제19조의2제1항 및 「삼척시 공공하수도시설 관리대행 운영 조례」 제3조에 따라 공공하수도의 운영·관리 업무를 대행하게 할 경우 「삼척시 사무의 민간위탁조례」 제5조제1항에 따른 지방의회의 동의는 받지 않아도 될 것으로 보입니다.

이 유

「하수도법」 제19조의2제1항에 따르면 공공하수도관리청은 대통령령으로 정하는 시설·장비 및 기술 인력 등의 요건을 갖추어 환경부장관에게 등록한 자 또는 하수도사업을 수행하는 지방공사 또는 지방공단으로서 환경부령으로 정하는 바에 따라 환경부장관에게 신고한 자(이하 "관리대행업자"라 한다)에게 공공하수도의 운영·관리 업무를 대행하게 할 수 있다고 규정하고 있고, 「삼척시 공공하수도시설 관리대행 운영 조례」(이하 "삼척시조례"라 한다) 제3조에서는 공공하수도시설은 삼척시장(이하 "시장"이라 한다)이 운영·관리하여야 하며, 효율적인 운영과 관리를 위해 필요한 경우에는 관리대행업자에게 업무를 대행하게 할 수 있다고 규정하고 있습니다.

한편, 「지방자치법」 제117조제3항에서는 지방자치단체의 장은 조례나 규칙으로 정하는 바에 따라

그 권한에 속하는 사무 중 조사·검사·검정·관리업무 등 주민의 권리·의무와 직접 관련되지 아니하는 사무를 법인·단체 또는 그 기관이나 개인에게 위탁할 수 있다고 규정하고 있고, 「삼척시 사무의 민간위탁 조례」(이하 "민간위탁조례"라 한다) 제5조제1항에 따르면 시장은 사무를 민간위탁하는 경우에는 삼척시의회의 동의를 받아야 한다고 규정하고 있습니다.

이 사안은 시장이 「하수도법」 제19조의2제1항 및 삼척시조례 제3조에 따라 공공하수도의 운영·관리 업무를 대행하게 할 경우 민간위탁조례를 적용하여 지방의회의 동의를 받아야 하는지를 질의하고 있는 것으로 보입니다.

일반적으로 "행정업무의 대행"이란 행정기관이 법령상의 업무를 대행기관으로 하여금 사실상 행하게 하되, 그 명의는 원(原) 권한자인 행정기관으로 하고 책임도 원 권한자인 행정기관에 귀속되도록 하는 것을 말하며, 대행에 따른 법령상 권한의 이전은 발생하지 않고 대행기관이 원 권한자인 행정기관 명의로 업무를 수행함으로써 그 법률적 효과는 원 권한자인 행정기관이 직접 행사(行使)한 것과 같은 효력이 발생한다는 점에서, 행정기관의 권한을 공공단체 또는 사인에게 법적으로 이전하여 행정권한을 수탁받은 수탁자가 수탁자의 이름으로 행정권한을 행사할 수 있고 그 행정권 행사의 법적 효과 또한 수탁자에게 귀속되는 "민간위탁"과는 차이가 있다고 할 것입니다.

또한, 「하수도법」 제74조제3항에서는 지방자치단체의 장은 공공하수도에 관한 '공사' 업무를 대통령령으로 정하는 관계전문기관에 위탁할 수 있다고 규정하여 대행과 위탁을 구분하고 있는 점, 민간위탁조례는 「지방자치법」 제117조제3항에 따라 시장의 권한에 속하는 사무 중 민간위탁에 필요한 사항을 규정함으로써 민간의 행정참여 기회를 확대하고 행정능률을 향상시키는 것을 목적(제1조)으로 하는 점 등을 종합하여 볼 때, 시장이 공공하수도의 운영·관리 업무를 대행하게 할 경우 그 법적 성격을 달리하는 민간위탁조례 제5조제1항을 유추적용하여 지방의회의 동의를 받도록 하는 것은 올바른 법적용이라고 할 수는 없습니다.

따라서, 삼척시장이 「하수도법」 제19조의2제1항 및 삼척시조례 제3조에 따라 공공하수도의 운영·관리 업무를 대행하게 할 경우 민간위탁조례 제5조제1항에 따른 지방의회의 동의는 받지 않아도 될 것으로 보입니다.

자치법규 의견제시 주제별 주요 사례 50선

발 행 일 2025년 1월

발 행 처 법제처 자치법제지원과

주 소 세종특별자치시 도움5로 20, 정부세종청사 법제처(7-1동)

전 화 (044)200-6900

홈 페 이 지 www.moleg.go.kr

편집·인쇄 한결엠 (02)6952-0551